

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO

DIREITO GLOBAL EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DAS DOENÇAS RARAS:
Um acesso mais equânime ante os desafios de diagnóstico, tratamento e custo dos direitos

MURILO MENEGHETTI NASSIF

SÃO PAULO - SP
2026

MURILO MENEGETTI NASSIF

DIREITO GLOBAL EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DAS DOENÇAS RARAS:

Um acesso mais equânime ante os desafios de diagnóstico, tratamento e custo dos direitos

DOUTORADO EM DIREITO

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie para obtenção do título de Doutor em Direito.

Linha de pesquisa: O Poder Econômico e seus Limites Jurídicos.

Orientadora: Prof(a). Dra. Irene Patrícia Nohara.

SÃO PAULO - SP
2026

N268d Nassif, Murilo Meneghetti.
Direito global em saúde na perspectiva das doenças raras
[recurso eletrônico] : um acesso mais equânime ante os desafios
de diagnóstico, tratamento e custo dos direitos. / Murilo
Meneghetti Nassif.
.1 MB ; (PDF).

Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico)
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.
Orientadora: Profa. Dra. Irene Patrícia Nohara.
Referências bibliográficas: f. 185-205.

1. Direito. 2. Saúde. 3. Acesso. 4. Doenças Raras. 5. Direito
Global. I. Nohara, Irene Patricia, *orient.* II. Título.

CDDir 341.641

MURILO MENEGHETTI NASSIF

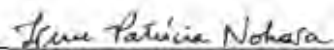
DIREITO GLOBAL EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DAS DOENÇAS RARAS: *Um acesso mais equânime ante os desafios de diagnóstico, tratamento e custo dos direitos*

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie para obtenção do título de Doutor em Direito.

Data: 02 / 02 / 2026

Banca Examinadora

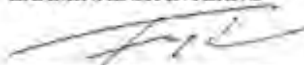
Professora Dra. Irene Patricia Nohara


PRESIDENTE / ORIENTADORA

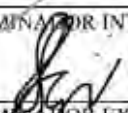
Professor Dr. Giovani Agostini Saavedra

Giovani Saavedra
Assinado de forma digital por Giovani Saavedra
Data: 2026.02.26 22:57:11 -03'00'
EXAMINADOR INTERNO

Professor Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto


EXAMINADOR INTERNO

Professor Dr. Silvio Gabriel Serrano Nunes


EXAMINADOR EXTERNO

Professor Dr. Fernando Reverendo Vidal Akaoui

FERNANDO REVERENDO VIDAL AKAOUI
Assinado de forma digital por FERNANDO REVERENDO VIDAL AKAOUI
Data: 2026.02.26 16:52:41 -03'00'
EXAMINADOR EXTERNO

Corpos invisíveis, vozes silenciadas, enfrentam doenças raras em jornadas marcadas; a sociedade, muitas vezes indiferente, deixa suas vidas apagadas. Mas a justiça exige, e a ética demanda, que se garantam cuidados e acesso à saúde a toda demanda, pois direitos não são apenas palavras lançadas, mas instrumentos de vida e esperanças renovadas.

(o autor)

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa é resultado da colaboração, estímulo e assistência de diversas pessoas. Minha gratidão e apreço para todos que, direta e indiretamente contribuíram para sua realização: aos meus queridos pais que desde cedo me propiciaram e incentivaram estudar e cuidaram da minha saúde. A toda a minha família, em especial aos meus filhos, minha fonte de esperança para um mundo melhor, mais equânime e com saúde para todos.

Aos colegas que tive o privilégio de conhecer na Universidade Presbiteriana Mackenzie e a esta Instituição que acolheu as minhas ideias por meio de seus professores. Todos que, conjuntamente, contribuem para a excelência da Instituição.

À Professora Dra. Irene Patrícia Nohara, uma orientadora mais do que humana e de sabedoria ímpar. Não poderia ter tido melhor sorte nesta jornada de orientação.

Gratidão eterna ao Pai Celestial, pela vida!

RESUMO

Esta tese parte da constatação de que pessoas afetadas por doenças raras enfrentam desigualdades estruturais e injustiças persistentes no acesso à saúde, que podem ser mitigadas por mecanismos de cooperação em escala global, nos quais o direito desempenha papel central. Sustenta-se que, em um contexto de globalização e intensa conectividade tecnológica, o direito humano fundamental à saúde, no recorte específico das doenças raras, deve ser compreendido e aplicado de forma integrada entre os Estados, superando a lógica fragmentada de políticas públicas nacionais. A pesquisa adota metodologia hipotético-dedutiva, articulando análise jurídica qualitativa e diálogo interdisciplinar com a saúde pública, para examinar dilemas concretos na interseção entre direito e políticas de saúde. Como contribuição teórica e normativa, o trabalho propõe um paradigma de direito global em saúde orientado para a redução das desigualdades e pelo fortalecimento da justiça social, tendo o acesso à saúde como princípio jurídico estruturante.

Palavras-chave: Direito. Saúde. Acesso. Doenças Raras. Direito Global.

ABSTRACT

This thesis is grounded in the recognition that people affected by rare diseases face structural inequalities and persistent injustices in access to health care, which may be mitigated through mechanisms of cooperation on a global scale, in which law plays a central role. It argues that, in the context of globalization and intense technological connectivity, the fundamental human right to health, within the specific scope of rare diseases, must be understood and applied in an integrated manner among States, overcoming the fragmented logic of national public policies. The research adopts a hypothetical-deductive methodology, combining qualitative legal analysis with interdisciplinary dialogue with public health, in order to examine concrete dilemmas at the intersection of law and health policies. As a theoretical and normative contribution, the thesis proposes a paradigm of global health law oriented toward the reduction of inequalities and the strengthening of social justice, with access to health care as a structuring legal principle.

Key-words: Law. Health. Access. Rare Diseases. Global Law.

RESUMÉ

Cette thèse repose sur le constat que les personnes atteintes de maladies rares sont confrontées à des inégalités structurelles et à des injustices persistantes dans l'accès à la santé, lesquelles peuvent être atténuées par des mécanismes de coopération à l'échelle globale, dans lesquels le droit joue un rôle central. Elle soutient que, dans un contexte de mondialisation et de forte connectivité technologique, le droit humain fondamental à la santé, dans le cadre spécifique des maladies rares, doit être compris et appliqué de manière intégrée entre les États, en dépassant la logique fragmentée des politiques publiques nationales. La recherche adopte une méthodologie hypothético-déductive, combinant une analyse juridique qualitative et un dialogue interdisciplinaire avec la santé publique, afin d'examiner des dilemmes concrets à l'intersection du droit et des politiques de santé. À titre de contribution théorique et normative, la thèse propose un paradigme de droit global de la santé orienté vers la réduction des inégalités et le renforcement de la justice sociale, faisant de l'accès à la santé un principe juridique structurant.

Mots Clés: Droit. Santé. Accès. Maladies Rares. Droit Mondial.

RESUMEN

Esta tesis parte del reconocimiento de que las personas afectadas por enfermedades raras enfrentan desigualdades estructurales e injusticias persistentes en el acceso a la salud, que pueden ser mitigadas mediante mecanismos de cooperación a escala global, en los cuales el derecho desempeña un papel central. Se sostiene que, en un contexto de globalización e intensa conectividad tecnológica, el derecho humano fundamental a la salud, en el ámbito específico de las enfermedades raras, debe ser comprendido y aplicado de manera integrada entre los Estados, superando la lógica fragmentada de las políticas públicas nacionales. La investigación adopta una metodología hipotético-deductiva, articulando el análisis jurídico cualitativo con un diálogo interdisciplinario con la salud pública, para examinar dilemas concretos en la intersección entre el derecho y las políticas de salud. Como contribución teórica y normativa, el trabajo propone un paradigma de derecho global de la salud orientado a la reducción de las desigualdades y al fortalecimiento de la justicia social, teniendo el acceso a la salud como principio jurídico estructurante.

Palabras clave: Derecho. Salud. Acceso. Enfermedades Raras. Derecho Global.

SOMMARIO

Questa tesi muove dalla constatazione che le persone affette da malattie rare affrontano disuguaglianze strutturali e persistenti ingiustizie nell'accesso alla salute, che possono essere mitigate attraverso meccanismi di cooperazione su scala globale, nei quali il diritto svolge un ruolo centrale. Si sostiene che, in un contesto di globalizzazione e di intensa connettività tecnologica, il diritto umano fondamentale alla salute, con specifico riferimento alle malattie rare, debba essere compreso e applicato in modo integrato tra gli Stati, superando la logica frammentata delle politiche pubbliche nazionali. La ricerca adotta una metodologia ipotetico-deduttiva, articolando l'analisi giuridica qualitativa con un dialogo interdisciplinare con la sanità pubblica, al fine di esaminare dilemmi concreti all'intersezione tra diritto e politiche sanitarie. Come contributo teorico e normativo, il lavoro propone un paradigma di diritto globale della salute orientato alla riduzione delle disuguaglianze e al rafforzamento della giustizia sociale, assumendo l'accesso alla salute come principio giuridico strutturante.

Parole chiave: Diritto. Salute. Accesso. Malattie Rare. Diritto Globale.

LISTA DE TABELAS

Quadro 1 – Quadro comparativo de metodologias de avaliação econômica em saúde

Quadro 2 – Quadro resumo das teorias decisórias

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ACB – Análise de Custo-Benefício

ACE – Análise de Custo-Efetividade

ACM – Análise de Custo-Minimização

ACU – Análise de Custo-Utilidade

AED – Análise Econômica do Direito

ATS – Avaliação de Tecnologias em Saúde

CELAC – Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos

CID – Classificação Internacional de Doenças

CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina

CFM – Conselho Federal de Medicina

CQCT – Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco

DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos

CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS

EMA – European Medicine Agency

EURORDIS – Organização Europeia de Doenças Raras

FDA – Food and Drug Administration

G7 – Grupo dos Sete

G20 – Grupo dos Vinte

HSE – Health Service Executive

ICH – International Council for Harmonisation

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IGF – Internet Governance Fórum

IRDIRC – Consórcio Internacional de Pesquisa de Doenças Raras

LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

GNRD – Rede Global de Vigilância e Pesquisa de Doenças Raras

MHRA – Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

NHS – National Health Service

OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMS – Organização Mundial de Saúde

ONU – Organização das Nações Unidas

ONG – Organização Não Governamental

PAMI – Programa de Assistência Médica Integral

PBS – Pharmaceutical Benefits Scheme

PIB – Produto Interno Bruto

PIDESC – Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

PMDA – Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

SUS – Sistema Único de Saúde

SWISSMEDIC – Swiss Agency for Therapeutic Products

WHO – World Health Organization

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	17
1. DOENÇAS RARAS, SAÚDE E O DIREITO À SAÚDE.....	22
1.1. Doenças raras.....	23
1.2. Conceito do termo saúde nesta pesquisa	32
1.3. Direito à saúde para a perspectiva de um direito global à saúde	34
1.4. Direito à saúde é um direito humano fundamental e temática multidisciplinar	36
1.5. Natureza jurídica-vinculante da temática multidisciplinar que é o direito à saúde	38
1.6. Tensão que reside no binômio saúde e direito.....	41
1.7. Patamar irreduzível da saúde que o direito visa resguardar	44
1.8. Síntese sobre as doenças raras e a conceituação da saúde e do direito à saúde.....	45
1.9. Evolução tecnológica na temática da saúde	47
2. ACESSO À SAÚDE.....	56
2.1. Como ocorre o acesso à saúde no espaço	57
2.2. Acesso à saúde no tempo e a relação e impacto da tecnologia.....	72
2.3. Acesso à saúde através da avaliação de tecnologias em saúde.....	78
2.4. Avaliação de tecnologias em saúde e a análise econômica da saúde	80
2.5. Acesso à saúde e a pluralidade	85
3. PAPEL DO DIREITO NO ACESSO À SAÚDE	92
3.1. Escassez de recursos e o custo dos direitos	93
3.2. Acesso e a saúde global.....	100
3.3. Acesso à saúde como um princípio	102
3.3.1. Os princípios.....	103
3.3.2. Princípio do acesso à saúde ou princípio da acessibilidade.....	105
3.3.2.1. Equidade como direcionador de operacionalização do acesso à saúde	110
3.3.2.2. Racional científico como direcionador da operacionalização do acesso à saúde.....	114
3.3.2.3. Transparência como direcionador de operacionalização do acesso à saúde	116
3.3.3. Síntese do princípio do acesso à saúde ou princípio da acessibilidade	120
3.4. O papel dos Tribunais no acesso à saúde	120
4. ENTENDENDO O PODER E A TOMADA DE DECISÃO PARA CONSTRUIR UM DIREITO GLOBAL EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DAS DOENÇAS RARAS ...	130
4.1. Como se decide: teorias decisórias.....	135
4.1.1. Teoria dos jogos	136
4.1.2. Escolha racional.....	137

4.1.3.	Teoria da racionalidade limitada	138
4.1.4.	Escolha ou preferência social	139
4.1.5.	Teoria da escolha pública	140
4.1.6.	Economia comportamental	141
4.2.	Concluindo as teorias decisórias e o como se decide	143
4.3.	Quem faz as escolhas: quem detêm o poder	145
4.3.1.	Controle do poder e os anseios sociais	148
4.3.2.	Heterogeneidade na tomada da decisão	151
4.4.	Conclusão sobre quem faz as escolhas com o olhar para as raridades	153
4.5.	Considerações finais do poder decisório	155
5.	DIREITO GLOBAL EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DAS DOENÇAS RARAS	157
5.1.	Harmonização como um caminho para o direito global à saúde em doenças raras	158
5.2.	Arquitetura global inclusiva e participativa	164
5.3.	Mecanismos de incentivos econômicos como viabilizador do direito global em saúde nas doenças raras	168
5.4.	Governança de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras	173
5.5.	Síntese propositiva ao direito global em saúde na perspectiva das doenças raras ...	176
	CONCLUSÃO	179
	REFERÊNCIAS	185

INTRODUÇÃO

“Se lhes dão papel pautado / escrevam do outro lado”.

Juan Ramón Jiménez

Este trabalho resulta de uma trajetória de investigação do pesquisador acerca do alcance e da efetividade do direito fundamental do ser humano a uma vida digna e saudável, no recorte de uma minoria¹, que são os pacientes que convivem com doenças raras. A pesquisa é fruto de décadas de convivência, estudo acadêmico e atividade profissional no debate de casos difíceis e complexos, que suscitaram (e ainda seguem suscitando) reflexões críticas, filosóficas, jurídicas e sociais sobre o que e como é compreender a efetividade e os limites da relação entre direito e saúde no âmbito jurídico e social.

Elaborada na linha de pesquisa o *Poder Econômico e seus Limites Jurídicos*, a tese tem por objetivo vislumbrar, a partir do direito, meios capazes de contribuir para a redução da distância que existe entre os pacientes que convivem com alguma doença rara e o adequado diagnóstico e tratamento da doença. Busca-se fazê-lo de maneira mais objetiva, sem desconsiderar o custo dos direitos sociais e o desafio metodológico de integrar um programa de pesquisa em direito a uma pesquisa que envolve saúde e política pública.

A tese tem como ponto de partida a seguinte indagação básica: quais são os fundamentos para se construir um direito global à saúde sob a perspectiva das doenças raras e frente aos desafios de diagnóstico, tratamento e custo dos direitos? É essa pergunta que orienta toda a investigação, e é a ela que os capítulos buscam responder, a partir de análises conceituais, normativas e comparativas.

Juristas e operadores do direito há muito escrevem sobre a temática do direito à saúde ao redor do mundo. Há vasta produção.² Ensaaios, artigos, dissertações, teses e toda uma

¹ Para fins acadêmicos registre-se que o termo minorias será usado tanto no que diz respeito ao limite numérico, quando com a ideia de um grupo vulnerável. É sabido que há muitos debates conceituais ao redor do termo minorias, dado que há entendimentos de que a expressão grupo vulnerável conferia maior precisão que o conceito de minorias. No escopo deste trabalho, contudo, adota-se a terminologia minoria por entender estar mais conectada com a realidade das raridades já que se vincula, também, com a quantidade numérica. Sobre os debates conceituais sobre o tema: RAMACCIOTTI, Barbara Lucchesi; CALGARO, Gerson Amauri. *Construção do conceito de minorias e o debate teórico no campo do Direito*. Sequência: estudos jurídicos e políticos, v.42, n.89, 2021. DA SILVEIRA, Rebeca Costa Gadelha; FREITAS, Raquel Coelho. *Definindo minorias: desafios, tentativas e escolhas para se estabelecer critérios mínimos rumo a conceituação de grupos minoritários*. Revista de Teoria e Filosofia do Estado. Maranhão, v.3, n.2, p.95-116, Jul/Dez. 2017.

² Apenas a título de exemplo, se pesquisarmos a expressão “Direito à saúde”, no Google Acadêmico na rede mundial de computadores, a pesquisa retornará com mais de 90 mil resultados. O mesmo termo nos idiomas Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Alemão também resultará em dezenas de milhares de achados.

doutrina jurídica molda os conceitos do direito à saúde. No entanto, tanto a partir da prática acadêmica quanto profissional, ainda carece um debate acadêmico jurídico e aprofundado sobre o *acesso à saúde*.

A lacuna identificada foi a ausência de um debate jurídico aprofundado sobre o acesso à saúde como o garantidor do direito à saúde em perspectiva global, especialmente no recorte das doenças raras. É a partir desse conceito – acesso à saúde como garantidor do direito à saúde em uma esfera de atuação global – que a tese inova, oferecendo contribuição para o campo do direito. O acesso à saúde é tema multidisciplinar que depende de políticas de saúde e que imprescinde da integração entre o direito e outras áreas de conhecimento como medicina, farmácia, economia, ética e políticas sociais.

Sendo o acesso à saúde assunto multidisciplinar, nada melhor do que tratá-lo em uma pesquisa de um programa de pós-graduação em direito político e econômico, cujo propósito é refletir criticamente sobre o impacto que as principais mudanças de paradigma da sociedade contemporânea têm causado na esfera jurídica, criando relações entre o direito, a economia e a política.

É neste contexto da temática da saúde, no recorte das doenças raras, que se desenvolve esta pesquisa em uma perspectiva global. Diz-se “global” ao invés de “internacional” pois, como será visto neste trabalho, a ideia desenvolvida na pesquisa inclui a participação de instituições informais e arranjos que podem incluir atores não estatais, além de outras práticas e fontes que não estão incluídas nas concepções padrão formal da normatividade do direito internacional.

Sob o aspecto metodológico o trabalho adota, primordialmente, a abordagem hipotético-dedutiva, também conhecida como método dedutivo ou racional-dedutivo. Fundamentado na lógica dedutiva, o trabalho parte de um contexto macro para alcançar resultados específicos. O método dedutivo é muito destacado e presente, a título de exemplo, na análise das premissas gerais sobre o acesso à saúde no *espaço* (compreendido em sentido político-jurídico, equivalente ao território de um determinado Estado-nação) e no *tempo*, interconectando-os com a tecnologia para que se possa chegar à uma conclusão final. A técnica da pesquisa é a indireta, com destaque para a pesquisa bibliográfica. Adotando ~~este método hipotético-dedutivo~~ esta metodologia formula-se a hipótese geral sobre o direito global à saúde e a testa a partir de recortes normativos e comparativos. Assim, busca-se assegurar a proximidade com dilemas concretos como os enfrentados por pacientes e sistemas de saúde. ~~A combinação metodológica amplia a validade dos resultados revelando a adequação da~~

~~pesquisa jurídica quando integrada ao programa de pós-graduação em direito político e econômico.~~

Como se verá ao longo do texto, apesar de permeado por conceitos relacionados à saúde, este trabalho se insere como uma pesquisa aplicada ao campo jurídico. A conexão entre as áreas da saúde e do direito encontra-se na afirmação do direito à saúde como direito humano fundamental e universal. Este é um tema permanentemente atual que segue – e seguirá – desafiando a sociedade e o ordenamento jurídico ao redor do mundo por envolver o maior valor que o ser humano possui, que é a vida.

Estudar um tema multidisciplinar, que demanda diálogo com outras áreas de conhecimento como medicina, farmácia, economia, ética, filosofia, ciências sociais e políticas, constitui um desafio relevante por não se restringir a um chamado “isolamento teórico” que estaria limitado à ciência jurídica. Este desafio se torna ainda maior ao envolver um bem jurídico fundamental e a busca por uma reflexão equilibrada. Ainda mais quando lembramos que assegurar o direito à saúde envolve custos.

Por ter um custo atrelado o direito à saúde traz consigo uma conclusão lógica: o custo da saúde necessário para assegurar uma vida digna está, em certa medida, precificado pela sociedade. Colocar preço ao custo de saúde que está intrinsecamente relacionado com uma vida digna, de uma forma que seja menos subjetiva possível, é uma realidade difícil e complexa³ que vai além da ponderação jurídica e evidencia tensões entre os direitos e as limitações práticas impostas pelos recursos disponíveis.

É neste macro contexto, recorte e metodologia que a pesquisa tomou corpo e tem como objetivo geral propor fundamentos jurídicos que permitam a construção deste direito global em saúde, com foco nas doenças raras. Como objetivos específicos busca-se: (i) analisar conceitualmente as doenças raras e a evolução do direito à saúde; (ii) examinar o acesso à saúde como garantidor desse direito; (iii) pesquisar sobre os custos dos direitos sociais e o papel dos tribunais; (iv) compreender a dinâmica do poder e da tomada de decisão em saúde; e (v) discutir os caminhos para a construção de um direito global em saúde no recorte das doenças raras.

³ Toma-se a liberdade de ser transparente com o leitor e reconhecer que não é fácil fazer uma ponderação de fatores que se relacionam com o bem jurídico de maior valor, que é a vida. Como qualquer ser humano e pesquisador somos influenciados, em certa medida, pelas próprias experiências, valores, crenças e perspectivas. A partir desta perspectiva é que a pesquisa tenta buscar o máximo de esforço para minimizar as influências na busca da melhor prática científica e acadêmica.

Para tanto, o trabalho foi estruturado em cinco capítulos, cada um dialogando com a indagação básica: O primeiro capítulo parte da análise conceitual das doenças raras e da evolução do direito à saúde como direito humano fundamental. Resgata a construção histórica da noção de saúde, a definição da OMS e sua crítica, as conexões com a dignidade humana e a necessidade de enquadrar as doenças raras não como exceção, mas como parte do núcleo essencial desse direito. O capítulo estabelece as bases conceituais que permitem compreender a saúde em chave multidisciplinar e em perspectiva global.

Nesse percurso evidencia-se como modelos distintos de sistemas de saúde – do SUS brasileiro ao NHS britânico, passando por experiências canadenses, alemãs, indianas ou latino-americanas – lidam com os desafios do acesso à saúde.

A comparação entre os sistemas revela que, apesar das diferenças estruturais, há elementos comuns que aproximam os sistemas: a escassez de recursos, a pressão por inovações terapêuticas e a necessidade de escolhas racionais. Ao final desta comparação demonstra-se que o acesso à saúde, em todas essas realidades, é a dimensão que torna o direito à saúde efetivo. Por isso que o acesso à saúde constitui o eixo central para pensar as doenças raras em perspectiva global.

O terceiro capítulo demonstra que o acesso à saúde é estruturado como um princípio jurídico – o princípio do acesso à saúde ou princípio da acessibilidade – que é direcionado pela (i) equidade, como critério de priorização e redução de desigualdades no atendimento do ser humano; (ii) um racional científico que assegure evidências técnicas e argumentações científicas ao tratar da saúde; e (iii) transparência, como forma dar clareza aos atos em saúde para que a sociedade possa participar das decisões sociais.

O capítulo articula como esse desenho principiológico responde às tensões entre custo dos direitos, escassez de recursos e judicialização; além de como os tribunais, ao aplicarem o princípio do acesso à saúde com base nos direcionadores convertidos enunciados normativos em acesso concreto para pessoas com doenças raras.

O quarto capítulo desloca o olhar para o poder e a tomada de decisão. São examinadas teorias decisórias e suas implicações para a saúde, assim como a falta de heterogeneidade de atores envolvidos – países, organismos multilaterais, indústria farmacêutica, ONGs, associações de pacientes – afeta as decisões sobre o acesso à saúde.

O capítulo mostra como esses múltiplos centros de decisão tornam a saúde um campo de governança complexa e fragmentada, e como essa fragmentação impacta diretamente o

acesso às doenças raras. É aqui que se evidencia a necessidade de uma direção mais transparente, participativa e cooperativa na temática de saúde e do direito à saúde.

O quinto e derradeiro capítulo responde de forma direta à indagação básica que orienta esta pesquisa. A partir das análises conceituais, normativas e comparativas desenvolvidas nos capítulos anteriores, o texto propõe um caminho para a construção de um direito global em saúde voltado às raridades.

O capítulo destaca a harmonização normativa como estratégia para aproximar sistemas nacionais sem comprometer a soberania; a arquitetura global inclusiva e participativa, que integra Estados-nação, organismos multilaterais, sociedade civil e empresas; e os mecanismos de incentivos econômicos exemplificativos que poder ser utilizados para tornar viável a proposta desta pesquisa.

Espera-se que as conclusões da pesquisa possam, de alguma forma, contribuir para iniciativas globais em saúde, especialmente no contexto das doenças raras, reforçando a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que busca enfrentar os maiores desafios contemporâneos e promover o desenvolvimento sustentável.

A relevância acadêmica do trabalho está na inovação teórica de propor um direito global em saúde a partir do recorte das doenças raras. A relevância social está na possibilidade de oferecer maior visibilidade e efetividade às demandas de pacientes que historicamente enfrentaram desigualdade, exclusão e silêncio.

1. DOENÇAS RARAS, SAÚDE E O DIREITO À SAÚDE

“Health for All” | Saúde para Todos

Declaração de Alma Ata, 1978

Nos antigos salões do Olimpo, entre as divindades imponentes e os feitos grandiosos dos deuses gregos, uma figura teve destaque pela sua sagacidade e pela sua profunda conexão com a humanidade. Essa figura é Asclépio, chamado deus da medicina e da cura na antiga mitologia grega. Filho da mortal Coronis com Apolo, o deus do sol, Asclépio foi criado pelo sábio centauro Quíron, que era um mestre nas artes da medicina e da cura.

Asclépio era dotado de conhecimento e habilidades únicas. Era uma figura reverenciada em templos de cura por toda a Grécia antiga, local em que as pessoas buscavam tratamento para suas enfermidades. Diz-se na mitologia grega que ele possuía o dom da cura e até mesmo a capacidade de ressuscitar os mortos. Seu sucesso incomum teria atraído a atenção de Zeus – o rei dos deuses do Olimpo – que o matou com o receio de Asclépio tornar os humanos imortais.

Após sua morte Asclépio foi transformado na constelação conhecida como Serpentário, ou Ofiúco. Embora não esteja entre as mais proeminentes nem possua estrelas particularmente brilhantes ou fáceis de identificar como outras constelações mais famosas, o Serpentário tem seu próprio conjunto estelar e pode ser observado no céu noturno, dependendo da época do ano e da localização geográfica do observador.

A jornada de Asclépio transcende os mitos.⁴ Embora enraizada em antigos mitos, sua jornada carrega um simbolismo que permanece vivo até hoje, especialmente no campo da saúde. Como deus da medicina e da cura, representa o conhecimento sobre o corpo, a busca pela recuperação física e, ao mesmo tempo, a esperança e a promessa de alívio aos que sofrem. Idealiza, assim, a aspiração humana por uma vida saudável, digna e livre de sofrimento.

A analogia com a jornada de Asclépio reside na ideia central de que toda pessoa tem o direito de buscar tratamento médico adequado e de qualidade, sem discriminação ou exclusão. Assim como Asclépio era um símbolo de esperança para os necessitados, na Antiguidade, hoje o direito à saúde expressa a aspiração de que cada indivíduo possa acessar os cuidados indispensáveis à preservação da saúde e do bem-estar.

⁴ MARTINS E SILVA, João Alcindo. *Asclepius e o “culto da serpente”*. Boletim da SPHM. Vol. 19 (4). P. 15-18. Portugal: Outubro, Novembro, Dezembro 2004.

Trata-se de uma aspiração que está consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (“DUDH”), como um pilar fundamental da dignidade humana⁵ e que, tal como nas antigas batalhas entre os deuses e semideuses, segue enfrentando adversidades. Nestas batalhas está a dos cidadãos que vivem com doenças raras e que lutam, muitas vezes, de forma solitária e incompreendidas pela sociedade em busca de uma vida digna.

Para estes indivíduos – que convivem com doenças raras – alcançar o diagnóstico e tratamento especializado e adequado pode parecer tão distante quanto o Monte Olimpo, um lugar na montanha escarpada, com pico acima das nuvens e frequentemente coberta de neve no norte da Grécia antiga, acima da superfície da terra e a morada dos deuses. É com um olhar para estes seres humanos que convivem com doenças raras que esta pesquisa foi realizada.

Analisar as barreiras enfrentadas pelas pessoas que vivem com doenças raras revela-se fundamental para compreender os limites e potencialidades do direito à saúde. A evocação do mito de Asclépio, ao mesmo tempo em que ilumina a dimensão simbólica da esperança e da cura, problematiza as tensões entre norma e realidade social, trazendo consigo o desejo pela busca de resposta sobre quais seriam, na perspectiva do direito, os fundamentos para se construir um direito global à saúde na perspectiva das doenças raras.

Para compreender esses fundamentos, inicia-se a pesquisa pela análise conceitual das doenças raras e do próprio termo saúde, partindo de uma reflexão que ainda hoje inspira o campo da medicina e do direito. É nesse contexto que se retoma a figura de Asclépio, o deus da cura na mitologia grega, como metáfora inicial da luta humana pelo direito à saúde.

1.1. Doenças raras

O recorte desta pesquisa é o das doenças raras, dentro da macro temática da saúde. Contudo, antes de delimitar o recorte específico das doenças raras, é necessário estabelecer, ainda que de forma sintética, o que se compreende por doença no contexto desta pesquisa.

No campo da saúde, a noção de doença está associada à presença de uma condição, alteração ou disfunção que afeta o funcionamento físico, mental ou comportamental do indivíduo, podendo comprometer sua funcionalidade, qualidade de vida e expectativa de

⁵ ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. 2.Ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. Malheiros: São Paulo, 2017. p. 31: “Sobre os direitos fundamentais é possível formular teorias das mais variadas espécies. Por exemplo, teorias históricas, que explicam o desenvolvimento dos direitos fundamentais, teorias filosóficas, que se empenham em esclarecer seus fundamentos, e teorias sociológicas, que versam sobre a função dos direitos fundamentais no sistema social. Difícil haver uma disciplina no âmbito das ciências humanas que, a partir de sua perspectiva e com seus métodos, não esteja em condições de contribuir com a discussão acerca dos direitos fundamentais”.

sobrevivência. Trata-se de um conceito construído e operacionalizado predominantemente no âmbito das ciências da saúde, que serve de base para a organização dos sistemas de diagnóstico, vigilância epidemiológica, pesquisa clínica e formulação de políticas públicas.

A OMS – Organização Mundial da Saúde adota uma abordagem funcional e classificatória da doença, materializada na Classificação Internacional de Doenças – CID, instrumento técnico que sistematiza e codifica doenças, transtornos, lesões e outras condições relacionadas à saúde.⁶ A CID fornece uma linguagem comum para o reconhecimento e registro das doenças como, também, constitui referência central para a produção de dados epidemiológicos, a definição de protocolos clínicos, a alocação de recursos e a tomada de decisões no âmbito dos sistemas de saúde ao redor do mundo.

Nesse sentido, para os fins desta pesquisa, a doença é compreendida a partir de seu enquadramento técnico-sanitário, tal como reconhecida e classificada nos sistemas internacionais de saúde, especialmente na CID. Assim, as repercussões sociais, econômicas e jurídicas associadas à doença, embora relevantes, não alteram o conceito técnico-sanitário adotado no recorte desta pesquisa. É a partir dessa compreensão que se torna possível delimitar, em seguida, o recorte específico das doenças raras e analisar as particularidades que essas condições impõem ao direito à saúde.

Doenças raras são raridades. Quando estamos diante de raridades, estamos diante de minorias ou grupos minoritários que, no contexto do direito, referem-se a segmentos sociais detentores de características específicas que estão em uma posição inferior em comparação com um grupo dominante. Esses grupos minoritários, na maioria das vezes, enfrentam desafios e desvantagens sociais, econômicas e/ou políticas devido à condição minoritária.⁷

As minorias que aqui se referenciam são pessoas. O ser humano que, de algum modo, convive com alguma alteração em sua saúde e bem-estar – geralmente de origem genética⁸ –

⁶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-11*. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2019. Disponível em: <https://icd.who.int/>. Acesso em: 07.02.2026.

⁷ Para fins acadêmicos registre-se, novamente, que há outros debates conceituais ao redor do termo minorias, dado que há entendimentos de que a expressão grupo vulnerável conferia maior precisão que o conceito de minorias.

⁸ NAUD, Ludmila Macêdo. *Doenças ultrarraras e o fornecimento do medicamento pós-estudo*. Rev Bras Bioética 2019; 15(e12): 1-16: “Em torno de 80% das doenças raras e ultrarraras têm origem genética. O restante das doenças decorre de infecções bacterianas ou virais, alergias, causas degenerativas, cânceres raros, doenças autoimunes, malformação congênita, doenças infecciosas e tóxicas, ou manifestações raras de doenças comuns, causadas por exposição ambiental durante a gravidez ou ao longo da vida (*European Union Committee of Experts on Rare Diseases*, 2012). A grande maioria das doenças ultrarraras e raras se manifesta na primeira infância.”

que lhe impôs a raridade. Uma pessoa que busca viver uma vida que tenha o mínimo⁹ de respeito e dignidade.

As doenças raras são “graves, crônicas, progressivas, degenerativas, incapacitantes, limitantes e trazem risco à vida”.¹⁰ Poucos são os especialistas no assunto. A título de exemplo, dado de 2020 do CFM apontava que 38,7% dos médicos no Brasil eram generalistas, sendo que quase 40% do total de especialistas estavam concentrados nas especialidades de clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ginecologia.¹¹

Realizar o diagnóstico não é simples pois, a despeito da importância de se identificar as doenças raras no estágio inicial da doença, é comum a falta de conhecimento dos próprios profissionais de saúde sobre essas condições. Tal falta acaba por resultar em diagnósticos tardios. Ademais, sinais e sintomas de doenças raras não necessariamente são específicos, podem ser vagos e dificultam o diagnóstico.

É comum que um paciente que conviva com doença rara leve anos até obter o correto diagnóstico da enfermidade, especialmente quando o sistema de saúde de um Estado-nação não está preparando para tanto. E isto ocorre tanto em países que pela OCDE são considerados economicamente desenvolvidos, como em desenvolvimento e com desigualdades sociais internas. O principal motivo é que os centros de especialidade de doenças raras são poucos e estão concentrados em grandes centros urbanos.

Para muitas destas doenças inexiste a cura, sendo pequeno o percentual de doenças raras que possuem opções de tratamento. Em termos de mortalidade, morbidade e ônus econômico para o sistema de saúde, dados de 2017 já apontavam que um terço das crianças com uma doença rara morria antes de atingir seu quinto aniversário e, um em cada três leitos hospitalares em hospitais pediátricos são ocupados por crianças com doenças raras.¹²

⁹ SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchitine. Reserva do Possível, Mínimo Existencial e Direito à Saúde: Algumas Aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (org.). *Direitos Fundamentais – Orçamento e Reserva do Possível*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2008. p.19: “Na doutrina pós guerra, o primeiro jurista de renome a sustentar a possibilidade de reconhecimento de um direito subjetivo à garantia positiva dos recursos mínimos para uma existência digna foi o publicista Otto Bachof, que, já no início da década de 1950, considerou que o princípio da dignidade da pessoa humana (...) não reclama apenas a garantia da liberdade, mas, também, um mínimo de segurança social, já que, sem os recursos materiais para uma existência digna, a própria dignidade da pessoa humana ficaria sacrificada”.

¹⁰ SOKEI, Mauro; BULGARELI, Jaqueline. *Os desafios do acesso aos medicamentos para o tratamento das doenças raras*. Journal of Management & Primary Health Care, V.12, N. Spec, p.1-2, 2021.

¹¹ SCHEFFER, Mário (coord.). *Demografia Médica no Brasil 2020* São Paulo: Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, Conselho Federal de Medicina, 2020.

¹² WALKER, C.E. et al., 2017. *The Collective Impact of Rare Diseases in Western Australia: An Estimate Using a Population-Based Cohort*. Genetics in Medicine, 19, p. 546–552.

A complexidade das próprias doenças raras e a falta de ferramentas de triagem eficazes contribuem negativamente para atrasos no diagnóstico. O mieloma múltiplo, por exemplo, uma doença rara que atinge quase 230 mil pessoas ao redor do mundo, segundo a Agency for Research on Cancer - IARC,¹³ é um câncer de difícil identificação por ser confundido com outras doenças frequentes. O diagnóstico precoce é chave para o tratamento.

Da mesma forma existem cânceres considerados mais raros que afetam crianças e a informação, nesses casos, também é essencial para salvar vidas. Quanto mais rápido se faz o diagnóstico correto, maior a chance de tratamento e de se propiciar uma vida com qualidade para o paciente. Toda essa lacuna no conhecimento e na compreensão das doenças raras influencia diretamente na escolha de tratamentos adequados, impactando a qualidade de vida dos pacientes.

A escassez de informações, aliada à limitada experiência clínica, gera incerteza diagnóstica e terapêutica, prolongando o sofrimento físico e psicológico. Pacientes enfrentam uma jornada marcada por ansiedade, frustração e vulnerabilidade, que transcende a esfera médica, afetando também suas relações sociais e emocionais.

Ademais, as opções terapêuticas são restritas e, geralmente, o custo do tratamento é (ou tende a ser) mais elevado quando comparado ao de outras enfermidades não raras.¹⁴ Apesar dos valores financeiros investidos em pesquisa e desenvolvimento se assemelharem aos montantes empregados em doenças comuns, o destino destas pesquisas é para um número significativamente menor de pacientes, o que acaba por limitar as pesquisas e o custo agregado da tecnologia levada ao mercado de consumo.

Não bastasse todos os desafios apontados, é fato que as desigualdades econômicas também impactam negativamente a obtenção do diagnóstico e tratamento de doenças raras. Pacientes de camadas sociais mais baixas enfrentam barreiras financeiras, como custos de exames e medicamentos. Isso cria disparidades no cuidado, agravando a situação para aqueles que já lidam com condições médicas desafiadoras.¹⁵

No mesmo contexto dos desafios está a localização geográfica e onde vivem os pacientes. A geografia muitas vezes determina a indisponibilidade de serviços de saúde

¹³ Disponível em: https://www.iarc.who.int/cards_page/world-cancer-report/. Acesso em 20.08.2025.

¹⁴ SOKEI, Michelle. Os desafios do acesso aos medicamentos para o tratamento das doenças raras no Brasil. *Journal of Management & Primary Health Care*, v. 12, p. 1-15, 2020. DOI: 10.14295/jmphc.v12.1071. Disponível em: <https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/1071>. Acesso em: 22.08.2025.

¹⁵ BRISCOE, Simon; MARTIN PINTADO, Clara; SUTCLIFFE, Katy; MELENDEZ-TORRES, G. J. et al. Evidence of inequities experienced by the rare disease community with respect to receipt of a diagnosis and access to health and social care services: a scoping review of UK and international evidence. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, v. 20, art. 303, 12 junho 2025

especializados para pacientes com doenças raras. Regiões remotas podem carecer de centros médicos equipados para diagnosticar e tratar essas condições. O desafio logístico de se deslocar para áreas urbanas para cuidados especializados adiciona uma camada de complexidade ao já complicado cenário, especialmente em regiões de maior desigualdade econômica.¹⁶

O impacto de viver com uma doença rara vai além da saúde. Envolve todos os aspectos da vida do indivíduo e de famílias em todo o mundo. A comunidade ao redor do ser humano raro experimenta múltiplas desigualdades e vulnerabilidades relacionadas à discriminação, inclusão e integração social. Isolamento social, sobrecarga emocional, ansiedade e depressão são comuns. Pais e cuidadores lutam para encontrar escolas dispostas a receber as pessoas com doenças raras. Famílias são empobrecidas pelo aumento dos custos associados ao cuidado de doenças raras.¹⁷

Acessar e se manter em um labor digno é um desafio tanto para os pacientes quanto para os cuidadores. Dar voz ao que é vivido pelos indivíduos afetados por doenças mais incomuns, de forma direta e indireta, é fundamental para permitir que estes indivíduos deixem de ser ignorados e renegados nas sociedades. É fundamental para mostrar as políticas públicas que insistem em negacionismo. Visibilizar minorias é evitar que políticas públicas estacionem em mera retórica ante os desafios vividos por estes indivíduos.

Dentre os desafios relacionados as raridades estão alguns que são visíveis enquanto outros – talvez a maioria – que são invisíveis e que cercam apenas o entorno do paciente, familiares e sua comunidade mais próxima. Entender estes desafios não é fácil para quem não os vivencia.¹⁸ Conhecer estes desafios e dar voz ao paciente raro – e seu entorno – é

¹⁶ Doenças raras demandem centros, profissionais e exames especializados. A telemedicina que – que floresceu um pouco mais na crise pandêmica da Covid-19 – é uma ferramenta importante e que pode contribuir com este desafio logístico permitindo consultas iniciais com médicos altamente especializados sem a necessidade de grandes deslocamentos iniciais. Sem ignorar os desafios do tema, a telemedicina é um avanço para ampliar equidade, reduzir barreiras geográficas e acelerar diagnósticos e tratamentos no sistema de saúde como um todo e, também, para as doenças raras. CHEN, Faye H. *et al.* *Telehealth for rare disease care, research, and education across the globe: a review of the literature by the IRDiRC telehealth task force*. European Journal of Medical Genetics, v. 72, art. 104977, dez. 2024.

¹⁷ ANDERSON, Matilda; ELLIOTT, J. Elizabeth; ZURYNSKI, A Yvonne. *Australian families living with rare disease: experiences of diagnosis, health services use and needs for psychosocial support*. Orphanet J Rare Dis 8, 22 (2013). Disponível em: <https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/1750-1172-8-22#citeas>. Acesso em 09.03.2023.

¹⁸ Muitas pessoas famosas lutam em silêncio contra doenças raras. Outras, dão visibilidade para conscientizar o público e impulsionar pesquisas e melhor acesso a tratamentos. Cite-se, aqui, o lutador de wrestling profissional francês, Maurice Tillet (1903 - 1954), que sofria de uma doença rara conhecida por acromegalia, que leva ao crescimento anormal de tecidos e órgãos ao longo do tempo, resultando em características como mãos e pés aumentados, mudanças no rosto e outros sintomas. Diz-se que após sua morte, uma máscara mortuária de seu

fundamental para impulsionar a pesquisa, promover a conscientização e estabelecer políticas de saúde eficazes.

Ao tratar essas condições como uma preocupação mais ampla e na esfera jurídica global pode-se incentivar a colaboração internacional para superar barreiras diagnósticas, melhorar a disponibilidade de tratamentos inovadores e oferecer apoio abrangente a comunidades afetadas em todo o mundo. Afinal, o debate em torno das doenças raras vai além do diagnóstico e tratamento e, conforme será desdobrado ao longo deste trabalho, este debate envolve – minimamente – multidisciplinariedade, harmonização de conceitos e participação social.

Objetivando definir um parâmetro mais harmônico de política pública e conceitual sobre as pessoas com doenças raras, a Organização Mundial da Saúde - OMS estipulou que as doenças raras são aquelas que afetam até 65 em cada 100.000 indivíduos.¹⁹ Apesar deste conceito não ser igual em todos os Estados-nação, uma vez que há variações na normatividade jurídica entre Estados-nação, trata-se de um parâmetro harmônico.²⁰ Dado estimado harmônico, também, é de que existam entre 6 e 8 mil tipos diferentes de doenças raras²¹ que acometem de 6% a 8% da população mundial.²²

rosto teria sido criada, capturando sua aparência única e marcante. Essa máscara teria se tornado uma inspiração para o personagem Shrek, o ogro verde da animação produzida pela DreamWorks Animation, que tinha características físicas incomuns.

¹⁹ Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/educamunicacao-em-doencas-raras>. Acesso em 09.01.2023.

²⁰ A definição de doenças raras segue a política pública de cada país ou região. No Brasil a doença que é considerada rara é a que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos (*Portaria MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014*). No Japão, o termo “doença órfã”, que inclui doenças raras é uma condição com prevalência de 2,5 casos por 10.000 habitantes (*McCabe, Claxton, Tsuchiya, 2005*). Nos Estados Unidos da América são 7 casos por 10.000 habitantes (*United States of America, 1984 - Orphan Drug Act of 1983*). Na Europa, é definida como uma condição que afeta 5 ou menos por 10.000 habitantes (*European Union Committee of Experts on Rare Diseases, 2012*). O termo de doença ultrarrara também é diferente entre países. No Reino Unido, a condição é descrita com uma prevalência menor que um caso por 50.000 habitantes (*National Institute for Clinical Excellence, 2004*). Nos Estados Unidos é uma doença que afeta menos que 2000 pessoas (*Ledbetter e Faucett, 2008*). No Brasil é uma doença que afeta 1 a cada 50.000 pessoas. (*Resolução CNS nº 563, de 10 de novembro de 2017*). In NAUD, Ludmila Macêdo. *Doenças ultrarraras e o fornecimento do medicamento pós-estudo*. Rev Bras Bioética 2019;15(e12):1-16. Para mais informações sobre a genealogia das doenças raras, vide CARDOSO, João Vitor. O direito a medicamentos órfãos: do orphan drug act às avaliações de tecnologias em saúde no SUS (p.393-405). In *XXV Mostra da pós-graduação UPM e USP: convergências e transbordamentos interdisciplinares*. Org. Glaucia Eneida Davino, Mirian Celeste Martins, Rosângela Patriota Ramos. São Paulo: Liber Ars, 2019.

²¹ SCHIEPPATI A.; HENTER J-I.; DAINA E, Aperia A. *Why rare diseases are an important medical and social issue*. Lancet 2008; 371(9629):2039–41.

²² No âmbito da classificação internacional de doenças - CID, a despeito de algumas doenças raras possuírem uma identificação própria, a maioria das raridades são identificadas pelo CID-11, com cerca de 5.500 doenças. Disponível em: <https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/rare-diseases>. Acesso em 09.01.2023.

A OMS tem reconhecido a importância das doenças raras e chamado os Estados-nação a tomarem ações nesta temática. A própria OMS, por exemplo, criou uma categoria específica na Classificação Internacional de Doenças – CID, um sistema padrão e abrangente de codificação e classificação de doenças e condições de saúde que é desenvolvido e mantido por esta agência, fornecendo uma linguagem comum e uniforme para descrever e registrar diversas condições de saúde que afetam os seres humanos.²³

O órgão também vem reforçando a visibilidade das raridades ao dar suporte institucional à celebração anual do Dia Mundial das Doenças Raras, criado em 2008 pela EURORDIS²⁴. O destaque da OMS se dá em busca da cobertura universal de saúde para este grupo vulnerável e, por consequência, auxilia na redução das subnotificações das doenças, que ocorre quando os casos existentes não são devidamente identificados, diagnosticados ou registrados nos sistemas oficiais de saúde por ausência de diagnóstico, diagnóstico incorreto e falta de protocolos padronizados.

Desde 2019 a OMS também passou a desenvolver uma Rede Global de Vigilância e Pesquisa de Doenças Raras (“GNRD”),²⁵ que tende a facilitar e incrementar a coleta e análise de dados sobre doenças raras em todo o mundo e, como consequência, melhorar a base de estudos e a compreensão dessas condições, a prevalência, o impacto na saúde pública, dentre outros. São elementos que poderão, com o tempo, aperfeiçoar estratégias de prevenção, além de prover um diagnóstico e tratamento mais assertivo para quem convive com doenças raras.²⁶

Em 10 de fevereiro de 2025, durante a 156ª sessão do Conselho Executivo da OMS, foi aprovado o relatório do Diretor-Geral que recomendava à 78ª Assembleia Mundial da Saúde a adoção da resolução intitulada “*Rare diseases: a global health priority for equity and inclusion*”: documento oficial da OMS que eleva as doenças raras à condição de prioridade

²³ Maiores informações disponíveis em: <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases> Acesso em 18.08.2025.

²⁴ O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado anualmente no último dia de fevereiro. Mas, o primeiro Dia Mundial das Doenças Raras foi em 29 de fevereiro de 2008. Uma data simbólica por também ser "rara".

²⁵ Maiores informações disponíveis em: <https://www.rarediseasesinternational.org/pt-br/collaborative-global-network/#:~:text=A%20Rede%20Global%20para%20as%20Doen%C3%A7as%20Raras%20%28GNRD%29,com%20Doen%C3%A7as%20Raras%20%28PLWRD%29%20em%20todo%20o%20mundo.> Acesso em 18.08.2025.

²⁶ Dentre os aperfeiçoamentos sobre o tema menciona-se, por exemplo, a necessidade de se estabelecer subclassificações às chamadas DCBs/DCIs no que diz respeito aos medicamentos biológicos. NASSIF, Murilo Meneghetti. *Compra pública de medicamento biológico e os desafios decorrentes da intercambialidade automática no âmbito do SUS*. Dissertação (mestrado profissional) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, 2020. p. 63-64.

global em saúde, destacando a urgência em promover equidade e inclusão para os pacientes que convivem com doenças raras.²⁷

Trata-se de um marco mundial que foi aprovado por unanimidade e que incumbiu a OMS de elaborar, em colaboração com Estados-Membros e organizações da sociedade civil, um Plano Global de Ação de 10 anos, orientado por metas claras, com vistas a garantir equidade, inclusão e efetiva proteção do direito à saúde para as pessoas com doenças raras.

É neste contexto e conceito das doenças raras que sobrevém este trabalho que, a partir do campo do direito, com um olhar mais equânime e sem desconsiderar o custo dos direitos sociais, visa pesquisar quais seriam os fundamentos para se construir este direito global em saúde voltado às doenças raras.

Busca-se, a partir deste trabalho, promover a efetividade dos textos normativos de normas constitucionais, infraconstitucionais e voluntariamente acordados em organismos multilaterais, com cada Estado-nação atuando na promoção da dignidade das pessoas raras e com a integração destes indivíduos na sociedade. Essa busca e promoção da dignidade das pessoas raras conta, ainda, com a evolução da tecnologia e a inovação científica que, conforme será visto ao final deste capítulo, está impactando o direito à saúde e impondo mais desafios ao tema da saúde.

Assim, investir em pesquisa e desenvolvimento e pensar em como prover tecnologias em saúde para doenças raras é uma das formas de enfrentar os desafios. Até porque a realidade mostra que o desenvolvimento de novos tratamentos para doenças raras é complexo ante a dificuldade em se recrutar uma população suficientemente grande de pacientes para estudos, diante do pequeno número de indivíduos afetados por estas doenças.²⁸ A base de evidências em doenças raras é – e sempre será – limitada.

Adiciona-se a este desafio outros fatores relacionados às doenças raras, que passam pelo debate científico de eficácia de tratamento, custos, aspectos sociais e benefícios econômicos. No mais, como estas doenças afetam minorias e o poder e a tomada de decisão sobre temas afetos a doenças raras não está nas mãos das minorias, existe um desafio aos Estados-nação quando precisam enfrentar e endereçar a demanda em saúde a estes indivíduos. Especialmente de impacto financeiro e orçamentário do Estado-nação.

²⁷ Informação disponível em: [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_\(15\)-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_(15)-en.pdf). Acesso em 18.08.2025.

²⁸ GRIGGS, Robert C. *et. all. Clinical research for rare disease: Opportunities, challenges, and solutions.* Molecular Genetics and Metabolism, V.96, Issue 1, Jan. 2009. p.20-26.

O desafio enfrentado pelas pessoas raras é comum e global. Não se trata de tema de uma região e apenas de um ou outro Estado-nação, mas, de todos. Um Estado-nação pode enfrentar melhor a temática do que outro, em suas políticas públicas. Da mesma forma, um outro Estado-nação pode ter um ordenamento jurídico que garanta maior universalização do tratamento de doenças. E, um terceiro, por circunstâncias diversas, como a desigualdade social, por exemplo, pode não conseguir prover o direito à saúde destas minorias.

O fato é que todos os países ao redor do mundo possuem o desafio relacionado ao tema das doenças raras. Inexiste uma resposta única de como cada Estado-nação deve enfrentar e prover o diagnóstico e tratamento de minorias com doenças raras.²⁹ Essa resposta nunca existirá de modo único, linear e conclusivo, dado que estamos diante de indivíduos que convivem com doenças raras e uma temática que envolve diversas áreas de conhecimento que passam pela medicina, farmácia, direito, economia, etc.

Todavia, a despeito de se tratar de tema complexo, isso não quer dizer que não deva ser enfrentado. Ao contrário. Existem caminhos e formas para enfrentar o tema. Caminhos que, se bem trilhados e conforme será visto no decorrer deste trabalho, poderão levar a um resultado positivo à sociedade como um todo. Neste contexto, o que aqui se começa a dizer é que os Estados-nação deveriam repensar suas atuações em relação à temática desta pesquisa. Um pensar vinculado com a cidadania³⁰, de modo coletivo e que possa ir além das barreiras de suas fronteiras territoriais.

²⁹ A afirmação tanto é verdadeira que o tema integra os objetivos de desenvolvimento sustentável global no âmbito da agenda 2030. Só porque uma doença afeta um pequeno número de pessoas não a torna irrelevante ou menos importante que as doenças que afetam um grande número de pessoas. A visão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contempla um mundo no qual ninguém fica para trás, incluindo pessoas que sofrem de doenças raras. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Acesso em 22.08.2025.

³⁰ Cidadania é um conceito amplo. É uma definição não estanque que varia no tempo e no espaço. Diz respeito a uma determinada ordem jurídico-política de um país, de um Estado, no qual uma Constituição define e garante quem é cidadão, que direitos e deveres ele terá em função de uma série de variáveis tais como a idade, o estado civil, etc. A cidadania é diferente em cada Estado-nação. Nasceu a partir de processos de lutas que ensejaram a Independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa e, na sua acepção mais ampla, é a expressão concreta do exercício da democracia. Sobre o tema, vide PINSKY, Jaime *et all.* *História da Cidadania*. São Paulo: Editora Contexto, 2013. Este conceito amplo também pode ser visto em discursos históricos, como o do presidente da Assembleia Nacional Constituinte da República Federativa do Brasil, Dr. Ulysses Guimarães, e, 5 de outubro de 1998, ao enfatizar que a verdadeira cidadania se concretiza quando todos têm acesso à educação, saúde, moradia, alimentação e dignidade: “A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos Poderes. Mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa.”. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/radio/programas/277285-integra-do-discurso-presidente-da-assembleia-nacional-constituente-dr-ulysses-guimaraes-10-23/>. Acesso em 18.08.2025.

1.2. Conceito do termo saúde nesta pesquisa

Segundo a OMS, a saúde compreende “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de infecções ou enfermidades”.³¹ Tal concepção, de caráter abrangente, desloca a noção de saúde do campo estritamente biomédico para uma perspectiva multidimensional, que incorpora fatores psicológicos, sociais e ambientais.

A definição da OMS é no sentido de que a saúde vai além do combate a doenças infecciosas e epidemias e abrange questões como o combate à má alimentação, promoção da igualdade de gênero, da saúde mental e assim por diante, impondo a necessidade de políticas públicas integradas para a sua promoção. Trata-se de uma compreensão ampla e integral da saúde e de bem-estar como meio de proporcionar ao ser humano uma vida e morte³² dignas.

Esta amplitude conceitual pregada pela OMS – um braço da Organização das Nações Unidas – ONU³³ – é objeto de algumas críticas por estudiosos que alegam se tratar de um ideal utópico, inexecutável e oriundo de movimentos aspiracionais pós Segunda Guerra Mundial.³⁴ Também é objeto de debates e reflexões positivas, oriundas da evolução social, que buscam uma compreensão mais especializada sobre o tema. Um olhar mais centrado na singularidade e no contexto real de cada indivíduo³⁵ e na experiência do paciente.³⁶

³¹ Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Disponível em: <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1>. Acesso em: 20.08.2025.

³² A morte digna também enseja muitos debates éticos, filosófico e jurídicos. Sobre o tema no âmbito do direito vide DIAS, Roberto. A dignidade da pessoa humana e o testamento vital no ordenamento constitucional brasileiro. In: BERTOLDI, Márcia Rodrigues; OLIVEIRA, Kátia Cristine Santos de (Coord.). *Direitos fundamentais em construção: estudos em homenagem ao ministro Carlos Ayres Britto*. Belo Horizonte : Fórum, 2010, p. 99-120; e, também, FRAGKOU, Roxani. *De l'euthanasie aux soins palliatifs: la nécessité d'une réponse au-delà du strict droit positif*, Médecine & Droit, Volume 2012, Issue 114, 2012, ps.76-92.

³³ A OMS (ou no idioma inglês, “WHO” – World Health Organization), é uma agência especializada em saúde que está subordinada a ONU. Maiores informações em <https://www.who.int/>. Acesso em 20.08.2025.

³⁴ SCLIA, Moacyr. *História do conceito de saúde*. PHYSIS - Revista de Saúde Coletiva. Physis 17 (1), Abr. 2007. Disponível em <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-456560>. Acesso em 20.08.2025. SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. *O conceito de saúde*. Ponto de Vista. Rev. Saúde Pública 31 (5), Out. 1997, disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-234432>. Acesso em: 20.08.2025.

³⁵ DALMOLIN, Bárbara Brezolin; BACKES, Dirce Stein; ZAMBERLAN, Cláudia; SCHAURICH, Diego; COLOMÉ, Juliana Silveira. *Significados do conceito de saúde na perspectiva de docentes da área da saúde*. Esc. Anna Nery 15 (2), Jun 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/NJb3hzFmZwKrnqBDGnLv3L/?lang=pt>. Acesso em 20.08.2025.

³⁶ Desde 2010 o *The Beryl Institute* vem trabalhando na temática da experiência do paciente como ponto fulcral da evolução do direito à saúde ao redor do mundo. Uma temática que ganhou ainda mais força nos debates com a crise pandêmica da Covid-19. Segundo este instituto, a experiência do paciente é a soma de todas as interações moldadas pela cultura de uma organização, que influenciam as percepções do paciente em todo o cuidado que envolve o paciente. Disponível em: <https://www.theberylinstitute.org/page/DefiningPX>. Acesso em 20.08.2025. No Brasil, por exemplo, o HumanizaSUS foi instituído em 2003 como uma política pública objetivando dar efetividade aos princípios do sistema único de saúde brasileiro, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Maiores informações disponíveis em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/humanizasus>. Acesso em 20.08.2025.

No contexto desta pesquisa, que trata da saúde vinculada a doenças incomuns e menos prevalentes na população, adota-se o entendimento de saúde como um direito humano fundamental de caráter universal. Parte-se, para tanto, da abrangente concepção estabelecida pela OMS como um conceito aberto e de textura ampla na ciência jurídica,³⁷ apto a abarcar múltiplas dimensões (físicas, psíquicas e sociais) e a orientar a construção de interpretações normativas e políticas públicas entre o direito e a saúde.

Interpretar a saúde em um contexto amplo e abordar esta temática referenciando a DUDH significa adotar, como premissa, que o bem maior a ser tutelado pelo direito sempre será a vida de todo e qualquer indivíduo. A premissa inicial que este trabalho se molda, portanto, está arraigada na dignidade da pessoa humana³⁸ e no ideal de que cada ser humano é um fim em si e não pode ser um mero instrumento de outros homens.

Essa concepção ampla e de textura aberta, pautada na dignidade da pessoa humana, revela que a saúde não pode ser vista apenas como condição biológica, mas como um bem jurídico que exige proteção maior. Se a saúde, entendida dessa forma, constitui um direito humano fundamental, impõe-se analisar em que medida ela se transforma em um direito subjetivo passível de tutela. É essa reflexão que orienta o próximo capítulo.

Até poque, conforme será visto mais adiante neste trabalho, o chamado “direito à saúde” varia conforme o contexto do *lugar* e do *tempo* no qual está inserido. O direito à saúde é mutável de acordo com políticas públicas de cada Estado-nação. Pode evoluir ou retroceder pelo advento de novas tecnologias que venham surgir e pode progredir ou regredir com bases em fatores políticos, sociais, éticos e religiosos.

³⁷ A textura aberta do direito pode ser entendida como uma indeterminação linguística nas normas jurídicas que enseja dúvida sobre a sua aplicação no caso concreto. Sobre o tema, vide HART, Herbert Lionel Adolphus. *O conceito do direito*. 1.Ed. Trad. Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2021. p.161-199. A indeterminação de regra que é constatada em determinados casos concretos (os chamados casos difíceis), é que Hart atribuiu a denominação de textura aberta do direito e defendeu, em sua teoria, que a autoridade competente para avaliar o caso tem o dever de exercer um poder discricionário sobre tais normas para criar o direito, sempre balizado pela proporcionalidade. Dentre os principais críticos da teoria hartiniana está Ronald Dworkin que defende a impossibilidade desta discricionariedade do julgador por, segundo o autor, implicar na criação de novo direito aos fatos pretéritos. Para Dworkin o direito não é incompleto ou indeterminado e o julgador sempre poderá, quando necessário, usufruir da moral e dos princípios para prolatar decisões em casos difíceis. DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. São Paulo: Martins Fontes, 2020.

³⁸ “Todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, sendo incondicionada, não dependendo de qualquer outro critério, senão ser humano. O valor da dignidade humana se projeta, assim, por todo o sistema internacional de proteção. Todos os tratados internacionais, ainda que assumam a roupagem do Positivismo Jurídico, incorporam o valor da dignidade humana.” PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. In LEITE, George Salomão (Org.). *Dos Princípios Constitucionais: Considerações em torno das normas principiológicas da Constituição*. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 188. Mais sobre a dignidade da pessoa humana e sua normatividade, vide DANTAS Jr, João Fabrício. *A dignidade como fundamento jurídico: a força normativa constitucional*. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 23, n. 3, p. 573-590, setembro/dezembro 2023.

1.3. Direito à saúde para a perspectiva de um direito global à saúde

O direito à saúde floresceu em uma época de pós-guerra, na década de 1940, através da DUDH que passou a enriquecer textos constitucionais aspiracionais e outras normas infraconstitucionais em diversos países³⁹ como Portugal (1976), Espanha (1978), Brasil (1988), Colômbia (1991), dentre outros. Na esteira de evolução o direito à saúde se consolidou em pactos e acordos internacionais e passou a ocupar um espaço relevante nos debates democráticos⁴⁰ sobre políticas sociais.

Um marco desta evolução é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 1966, reconhecendo o direito de todas as pessoas ao mais alto padrão possível de saúde física e mental.⁴¹ Outros exemplos incluem a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,⁴² além de outros tratados regionais de direitos humanos como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos⁴³ e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.⁴⁴

Com a globalização o debate sobre o direito à saúde continuou a se expandir ao longo do tempo e do espaço convidando para a esfera de debates, além de juristas, diversos outros profissionais, tais como, filósofos, médicos, farmacêuticos, sociólogos, cientistas sociais,

³⁹ No âmbito deste trabalho também denominaremos “países” como “Estados-nação” ou “Estado-nação”.

⁴⁰ Usa-se o regime democrático relacionado ao direito à saúde por entender que seria uma falácia falarmos de direitos em regimes totalitários. Contudo, de se registrar que o direito à saúde se faz presente em países com regimes totalitários de governo. Não como um direito propriamente dito e na acepção do termo “direitos”, mas, como um sistema que mantém o controle do ser humano que ali se insere. A Alemanha nazista (década de 1930-1940), tem muitos registros de políticas de saúde pública com campanhas de combate ao tabagismo, higiene e saneamento. No Brasil, por exemplo, os principais marcos teóricos sanitários são oriundos da década de 1970, período histórico conhecido como regime militar e ditatorial. É com o objetivo de controle do ser humano que países com regimes não democráticos geralmente possuem um sistema de saúde mais estruturado do que países com regimes democráticos (a título de exemplo, cite-se países da região geográfica do golfo pérsico tais como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar que possuem sistemas de saúde modernos e bem financiados).

⁴¹ De acordo com o PIDESC, os Estados-nação são obrigados a tomar medidas progressivas para garantir o acesso universal a cuidados de saúde, prevenção e tratamento de doenças, e a melhoria contínua das condições de saúde.

⁴² A Convenção sobre os Direitos da Criança (“CDC”), adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1989, reconhece o direito de toda criança desfrutar do mais alto padrão possível de saúde e acesso a serviços de saúde adequados, ao passo que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (“CDPD”), adotada pela Assembleia Geral da ONU em 2006, estabelece que as pessoas com deficiência têm o direito de desfrutar do mais alto padrão possível de saúde, sem discriminação, incluindo serviços de saúde acessíveis e de qualidade.

⁴³ Também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, este tratado internacional busca proteger e promover os direitos humanos nas Américas, desde que foi adotado em 22 de novembro de 1969, na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos realizada na cidade de San José, Costa Rica.

⁴⁴ Popularmente conhecida como a Carta Africana, trata-se de um instrumento regional de proteção dos direitos humanos adotado pela Organização da Unidade Africana (“OUA”) em 27 de junho de 1981. A OUA foi sucedida pela União Africana (“UA”), que manteve a Carta Africana como seu principal tratado de direitos humanos.

dentre outros. Cada qual, por sua vez, aborda o direito à saúde sob suas perspectivas científicas e interesses que podem ser acadêmicos, ideológicos, sociais, econômicos e financeiros.

Assim, enquanto para o jurista o direito à saúde é tratado com um direito humano fundamental⁴⁵, para a medicina o direito à saúde poderia ser traduzido como a garantia de se prover a cura e tratamentos de qualidade.⁴⁶ Já para a bioética este direito poderia ser entendido como um imperativo moral e social, ligado à dignidade humana⁴⁷ e, para a economia, um bem que exige alocação eficiente de recursos escassos.⁴⁸ É justamente em razão da multidisciplinariedade que envolve o tema que se faz necessário conceituarmos o direito à saúde para fins deste trabalho.

No conceito deste trabalho, o direito à saúde é definido como a aplicação de uma norma ou conjunto de normas que resultaram de uma determinada ação política de um Estado-nação, ou seja, o direito à saúde advém da aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais, integrando direitos sociais e cuja efetividade depende da aplicação de políticas públicas estatais, além da interação com outras áreas de conhecimento como, por exemplo, a medicina, farmácia, economia e ciências políticas e sociais.

Cada Estado-nação, com base em suas crenças, valores, sistema político e jurídico, define o que é o direito à saúde circunscrito àquela territorialidade e, ainda, como atuará para efetivar este direito ao indivíduo que está, de alguma forma, inserido na territorialidade estatal. Trata-se de uma deliberação que é mutável pela política pública, por contextos religiosos, por formas de governo e pela própria história dos direitos como se vê pela evolução histórica dos chamados direitos de segunda “geração” ou “dimensão” (a depender do contexto utilizado).⁴⁹

⁴⁵ PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

⁴⁶ Nos termos da Constituição da OMS de 1946.

⁴⁷ BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. *Principles of Biomedical Ethics*. 7. ed. New York: Oxford University Press, 2013.

⁴⁸ MUSGROVE, Philip. *Public and Private Roles in Health: Theory and Financing Patterns*. Washington, DC: World Bank, 1996.

⁴⁹ Em uma abordagem histórica-evolutiva os direitos de primeira “dimensão” ou “geração” são os que buscam garantir a liberdade individual e os direitos políticos dos cidadãos ao passo que os de segunda “dimensão” ou “geração” objetivam promover a igualdade social e a justiça econômica, buscando melhorar as condições de vida das pessoas e garantir o acesso a recursos e serviços básicos, incluindo saúde, educação, moradia, trabalho, dentre outros. Sobre o tema vide: VASAK, Karel. *As dimensões internacionais dos direitos do homem*: manual destinado ao ensino dos direitos do homem nas universidades. Lisboa: Livros Técnicos e Científicos, 1983. Publicado em 1978 pela Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura. Já a terceira “geração” ou “dimensão” de direitos alberga os chamados direitos supraindividuais ao passo que a quarta geração está voltada para os movimentos sociais e a ascensão tecnológica da modernidade. Sobre o tema vide: BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. 8 Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004; BONAVIDES, Paulo. *Curso de Direito Constitucional*. 19. Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2006; NOVELINO, Marcelo. *Direito Constitucional*. 3 Ed. São Paulo: Editora Método, 2009; SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 10 Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

Em síntese, ainda que cada Estado-nação defina os contornos do direito à saúde conforme sua realidade política, histórica e cultural, trata-se de um direito que se insere em uma matriz maior de direitos humanos fundamentais. Essa inserção reforça, além do caráter universal, a interdependência com outros direitos sociais, econômicos, civis e culturais. É a partir dessa perspectiva que se desenvolve o capítulo seguinte.

1.4. Direito à saúde é um direito humano fundamental e temática multidisciplinar

Os direitos humanos, que incluem direitos sociais, econômicos, civis, culturais e políticos, são interdependentes e indivisíveis. Impõem a cada Estado-nação a obrigação de corrigir, progressivamente, as injustiças e condições que impeçam o alcance destes direitos.⁵⁰ Sendo o direito à saúde um direito humano fundamental, impõe-se aos Estados-nação o dever de se definir as condições que garantam a cada indivíduo alcançar este direito, ou seja, aos serviços e bens necessários para tanto.⁵¹

O reconhecimento de que o bem maior a ser tutelado pelo direito sempre será a vida de todo e qualquer indivíduo é um fato que pode ser objeto de diversos debates (religioso, social, ético, jurídico, etc.). Mas, independentemente de onde se origina o debate, o reconhecimento de que a vida é o bem maior a ser tutelado pelo direito é fruto de decisão política.

A decisão política em questão foi tomada em 1948 pelos países membros da ONU através de uma declaração universal estipulando trinta direitos fundamentais, ou seja, anuindo com uma norma – inicialmente de cunho minimamente moral – que integra a base moderna do plano-jurídico internacional sobre direitos humanos e fundamentais.⁵² Neste contexto, o direito à saúde passou a ser um direito humano fundamental.

Trata-se de um direito que vem evoluindo no tempo e no espaço e que é fruto de constantes decisões políticas, como a tomada na Assembleia Geral da ONU, de 16 de

⁵⁰ Os direitos humanos são a mais pura e simples existência do ser humano. Sobre o tema, a tradicional obra de BOBBIO, Norberto. *A Era dos direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 1992. No âmbito do Brasil, vide TRINDADE, José Damião de Lima. *História social dos direitos humanos*. São Paulo: Ed. Peirópolis, 2002

⁵¹ LEARY, Virgínia. *The right to health in international human rights law*. Health and Human Rights, 1994, p. 24-56. O texto debate o conceito do direito à saúde no direito internacional dos direitos humanos. Lembra que a expressão "*direito à saúde*" é tratada pela Constituição da OMS e tratados internacionais de direitos humanos como um direito ao que poderíamos dizer ser o mais elevado padrão alcançável de saúde. A autora argumenta que abordar questões de saúde por meio de uma perspectiva de direitos adiciona uma dimensão importante à consideração do estado de saúde e que a expressão "*direito à saúde*" enfatiza a conexão do estado de saúde com questões de dignidade, não discriminação, justiça e participação.

⁵² UNITED NATIONS. History of the Declaration. Disponível em: <https://www.unpopulation.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html>. Acesso em 24.08.2025.

dezembro de 2021, aprovando⁵³ uma resolução de caráter social para enfrentar os desafios das pessoas que vivem com uma doença rara e suas famílias.⁵⁴ Trata-se do primeiro documento oficial da ONU a, expressamente, reconhecer e tentar endereçar os desafios enfrentados pelos pacientes de doenças raras e seus familiares.

As decisões políticas tomadas sobre o tratamento da saúde como um direito fundamental continuam a ser adotadas ao redor do mundo. Cite-se a Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos – CELAC, órgão regional multilateral composto por 33 países, que através da declaração de Buenos Aires datada de 24 de janeiro de 2023, enfatiza a importância de melhorar o enfrentamento dos desafios atuais e futuros em saúde, colocando o ser humano no centro das políticas de saúde e, ainda, garante que a prestação de serviços em saúde leve em consideração as necessidades específicas de grupos em situação de vulnerabilidade e/ou historicamente discriminados.⁵⁵

Em 10 de fevereiro de 2025, durante a 156ª sessão do Conselho Executivo da OMS foi aprovado o relatório do Diretor-Geral que recomendava à 78ª Assembleia Mundial da Saúde a adoção da resolução intitulada “*Rare diseases: a global health priority for equity and inclusion*”.⁵⁶ Trata-se de documento oficial da OMS que eleva as doenças raras à condição de prioridade global em saúde, destacando a urgência em promover equidade e inclusão para os pacientes que convivem com doenças raras. Um marco mundial que foi aprovado por unanimidade.

Na medida em que uma nova norma estipula a adoção de políticas públicas integradas para a promoção universal de serviços de saúde, inclusão social, equidade de oportunidades, bem como o fortalecimento de mecanismos de coleta de dados e conscientização social, além

⁵³ O texto em questão foi proposto por Espanha, Brasil e Qatar e teve o apoio imediato de 54 países-membros da ONU. Durante os debates prévio sua aprovação se deu pela quase totalidade dos países membros. Exceção foram Israel e Estados Unidos da América. Em Assembleia Geral o texto foi ratificado por unanimidade.

⁵⁴ United Nations. Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2021. 76/132. Addressing the challenges of persons living with a rare disease and their families. Disponível em: <https://www.rarediseasesinternational.org/wp-content/uploads/2022/01/Final-UN-Text-UN-Resolution-on-Persons-Living-with-a-Rare-Disease-and-their-Families.pdf>. Acesso em 20.08.2025.

⁵⁵ “Subrayamos la importancia de perfeccionar la coordinación de las capacidades nacionales y potenciarlas para enfrentar mejor los desafíos actuales y futuros en materia sanitaria, promoviendo un enfoque solidario y de cooperación. Asimismo, nos comprometemos a continuar la implementación de acciones gubernamentales que sitúen a la persona en el centro de las políticas de salud y resiliencia, asegurando que la prestación de servicios tenga en cuenta las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñez, juventudes, personas mayores y personas con discapacidad, incorporando el reconocimiento del rol que cumplen las personas cuidadoras;” in DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES. VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Buenos Aires, 24 de enero de 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/arquivos/declaracion-de-buenos-aires-version-final.pdf>. Acesso em 28.01.2023.

⁵⁶ Disponível em: [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_\(15\)-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_(15)-en.pdf). Acesso em 18.08.2025.

do fortalecimento da atenção primária à saúde, esta norma mobiliza diferentes campos do conhecimento – por exemplo a ciência política, ética, economia, farmácia, medicina e direito – em busca da sua executoriedade prática. Não é diferente em relação a todas as demais normas antes mencionadas.

É, pois, nessa busca pela efetividade da tutela da vida por meio do direito e, conseqüentemente, pela concretização do direito à saúde, consagrado como direito humano fundamental, que se revela a necessidade de compreender o direito à saúde sob uma perspectiva multidisciplinar. Em outras palavras, o direito à saúde deve ser estudado de forma sistêmica, envolvendo de maneira integrada diferentes áreas do conhecimento que, de alguma forma, dialogam com o conceito da saúde.

1.5. Natureza jurídica-vinculante da temática multidisciplinar que é o direito à saúde

Mencionou-se no subcapítulo anterior que a decisão política tomada em 1948 com a estipulação da DHDU era de cunho moral. O que se considera, agora, é que essa decisão política foi consagrada na história e, com o decorrer dos anos, foi integrando a base legislativa e costumeira dos Estados-nação que integram a ONU, fazendo com que os efeitos decisórios da norma se tornasse – ou ao menos deveriam ter se tornado – de caráter ou natureza-jurídica vinculante.⁵⁷

Quando Estados-nação aprovam uma norma na ONU – e em outras comunidades multilaterais –, na qual exortam a cada país, que participou voluntariamente de sua construção e a aprovou, a acelerar os esforços para alcançar a cobertura universal de saúde até 2030 e promover o bem-estar de todas as pessoas, incluindo especificamente as pessoas que vivem

⁵⁷ “A força jurídica vinculante da Declaração Universal de Direitos Humanos advém, ainda, do fato do documento integrar o direito costumeiro internacional ou os princípios gerais do direito internacional, o que pode ser comprovado: pela posterior incorporação de seus princípios e normas por Constituições de diversos Estados, pelas frequentes referências feitas por resoluções posteriores da ONU à obrigação legal de observância à Declaração Universal, e pelas decisões proferidas por Cortes nacionais referindo-se ao documento como fonte formal de direito”, in PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o direito constitucional internacional*. 1. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 216-217. Já em sentido contrário ao caráter vinculante da DUDH, afirma-se que, ao preferir, a maioria dos governos representados na Assembleia Geral a adoção de uma declaração, na forma de resolução, os Estados teriam deixado claro sua opção por um documento não-vinculante, mantendo-a dentro das chamadas *soft law*. Sobre o tema: “The International Bill of Human Rights is a powerful statement of your rights and should persuade all Governments to respect your rights. For the two Covenants to become binding in your country, your Government must ratify them. This means your Government must expressly agree to abide by them.” Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>. Acesso em 10.01.2023. Sobre o tema vide, também, ARNOLD, Rainer. Are Human Rights Universal and Binding? in: Brown, K., Snyder, D. (eds). *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law*. Springer, Dordrecht, 2012. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2354-2_25.

com uma doença rara, é ilógico pensar que um Estado-nação membro da ONU atuará de forma a não promover o cumprimento do quanto deliberado por ele próprio.

Ainda mais quando estes mesmos países membros da ONU, em menos de 3 anos após referida deliberação, desta vez no escopo da OMS, reconhecem oficialmente as doenças raras como uma prioridade global de saúde e declaram, por unanimidade, que atuarão para: reduzir desigualdades, promover a inclusão por meio da integração das doenças raras nas políticas nacionais de saúde, fortalecer diagnósticos precoces, obter tratamentos e apoio a pesquisas, incorporar sistemas de informação padronizados, dentre outros.

Ao constituir direitos e obrigações cada Estado-nação define um modelo social. Estabelece o que importa ao indivíduo e o que a sociedade perseguirá como meio de executoriedade ao direito constituído. Descumprir o direito acordado e concedido resulta, nesse caso, em um sistema de injustiças. Noutras palavras, resulta no reconhecimento de que o direito (como instituto), não possui o valor que lhe fora conferido pelo Estado-nação.⁵⁸

A lógica-dedutiva é pensar que cada Estado-nação sempre atuará para garantir a aplicação dos direitos que são e foram constituídos por eles próprios. É lógico pensar que um Estado-nação atuará, no seu dia a dia, para garantir a execução do direito fundamental universal à saúde, cumprindo a deliberação de uma política internacional na qual o próprio Estado ajudou a construir.

É lógico afirmar que as disposições da ONU e OMS que visam enfrentar os desafios de pessoas que vivem com uma doença rara será perseguida e cumprida por cada Estado-nação, sem óbices para tanto. Concedido o direito, o fato de a sociedade ter de arcar com um custo financeiro para garanti-lo e executá-lo não deveria – portanto – ser usado como argumento para o descumprimento do direito constituído. A única exceção a esta regra seria

⁵⁸ Em levando os direitos à sério, Ronald Dworkin aborda a necessidade de se observar a integralidade dos direitos concedidos. “Caso contrária, a incapacidade do governo em ampliar o direito irá demonstrar que seu reconhecimento no caso original é uma impostura, uma promessa que ele pretende manter apenas até o momento em que este se tornar inconveniente” Fundamentado sua explicação Dworkin afirma que o único modo do governo atuar, sem voltar atrás no reconhecimento do direito, seria lastreado em 3 hipóteses: “Primeiro, o governo poderia mostrar que os valores protegidos pelo direito original não estão realmente em jogo no caso marginal, ou que estão em jogo apenas de forma atenuada. Segundo, poderia mostrar que se o direito for definido de modo a incluir o caso marginal, algum direito concorrente (...). Terceiro, (...) se o direito fosse assim definido, o custo para a sociedade não seria simplesmente adicional, mas de grau muito superior ao custo pago no caso da concessão do direito original; um grau suficientemente alto para justificar qualquer atentado à dignidade ou à igualdade que possa estar aqui envolvido”. DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. São Paulo: Martins Fontes, 2020. p.307. Nesta mesma obra Dworkin apresenta uma teoria de justiça fincada em direitos e políticas públicas que, no entender do autor devem ser baseadas no conceito em que os participantes de um grupo são igualitários como seres humanos, independentemente de sua realidade socioeconômica, crença ou qualidade de vida. Uma teoria que prioriza mais a neutralidade estatal na promoção dos direitos fundamentais.

a integral, completa e comprovada escassez de recursos, um tema que será tratado em momento posterior neste trabalho.

Entretanto, não necessariamente a prática de atuação condiz com o pensamento lógico e com a realidade.⁵⁹ Quando tratamos do direito à saúde não estamos debatendo um tema de natureza puramente jurídica, mas, um tema multidisciplinar e que envolve o direito, a política, a ética, a medicina e diversas outras áreas de conhecimento. Um direito que tem sua base na DUDH, que é de caráter vinculante – ou ao menos deveria ser – para todos os países que seguem membros da ONU.

Neste ponto, vale a pena trazer e distinguir os instrumentos da chamada *hardlaw* e *softlaw*, no âmbito do direito internacional da saúde. Tratados e convenções ratificados pelos Estados-nação, como por exemplo o PIDESC, configuram *hardlaw*, isto é, norma juridicamente vinculante que impõe obrigações claras aos signatários. Já resoluções, declarações e planos de ação, com por exemplo da OMS, muitas vezes possuem natureza de *softlaw*, em que não estabelecem obrigações jurídicas formais, mas, criam parâmetros normativos, expectativas legítimas e padrões de conduta que influenciam práticas, a sociedade, o poder político e jurídico.

Esta distinção é importante pois a efetividade real dessas resoluções depende, em grande medida, da internalização pelos Estados-nação e da atuação de atores transnacionais – sociedade civil, organizações de pacientes – que pressionam pela sua concretização. Nesse sentido, mesmo que de natureza não vinculante, os instrumentos de *softlaw* exercem função normativa relevante, sobretudo em áreas nas quais os tratados multilaterais são escassos como é o caso das doenças raras.

Assim, este diálogo entre *softlaw* e *hardlaw* torna-se necessário para se compreender a natureza vinculante e a executoriedade prática do direito à saúde e de um direito global à saúde. Em paralelo, reconhecer o caráter vinculante do direito à saúde no contexto da DUDH não elimina, todavia, as tensões que se colocam diante de sua efetividade. A distância entre a norma e a realidade concreta do que se provêm em saúde evidencia que a executoriedade desse

⁵⁹ Quando nos deparamos no Brasil, por exemplo, com o Relatório Luz uma iniciativa do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 da ONU, observamos que a realidade prática vivenciada pela ODS n.º 3 (relacionadas à saúde) no Brasil está muito aquém do que se pretende com a Agenda 2030 e, com grande risco de não se atingir os anseios e objetivos desta Agenda Global. Essa é a informação do Relatório Luz 2023. Disponível em: <https://gtagenda2030.org.br/relatorio-luz/>. Acesso em 3.3.2024. Não diferente é a análise do Relatório Luz 2024, que mostra que a maioria das metas em saúde estão retrocedendo ou estagnadas. Disponível em: https://gtagenda2030.org.br/wp-content/uploads/2024/10/rl_2024_pt-web-completo_lowres.pdf. Acesso em 18.8.2025.

direito encontra limites políticos, econômicos e estruturais que dificultam diariamente aos indivíduos darem concretude prática ao direito à saúde.

1.6. Tensão que reside no binômio saúde e direito

Há pouco foi dito que a prática cotidiana nem sempre reflete a lógica teórica quando se trata de prover o direito à saúde. Essa discrepância evidencia uma crise persistente, na qual normas e princípios formais não se traduzem em promoção efetiva. Embora o direito à saúde seja reconhecido como fundamental e multidisciplinar, envolvendo direito, política, ética e ciência, na prática observa-se que barreiras estruturais, insuficiência de recursos e desigualdades sociais comprometem sua efetividade.

A lacuna entre o que é estabelecido em norma e o que é concretamente oferecido aos indivíduos expõe a vulnerabilidade de determinados grupos, reforçando que, sem mecanismos robustos de implementação e fiscalização, o direito à saúde corre o risco de permanecer apenas no plano teórico.

Ao aprofundar-se para entender este desafio a partir das regras e codificações dos Estados-nação observa-se que, a depender das regras e codificações que regem a administração de um determinado Estado-nação, a decisão sobre política de saúde que afeta o outrem (que pode ser uma decisão a afetar um indivíduo ou uma coletividade), deriva de uma ação de dois poderes.

Decisões sobre políticas de saúde derivam de um *poder político*, responsável pela definição das políticas deste país e vinculado ao discurso político, quase sempre centrado em favor de maiorias; ou, de um *poder jurídico* (se e quando existente), como responsável por garantir o cumprimento de normas jurídicas dentro dos muros do Estado no qual detém o poder.⁶⁰

Tendo claro de onde deriva a decisão sobre saúde é que se entende que a lógica do pensamento jurídico sobre a saúde e a aplicação do direito à saúde é uma eterna crise. A interação entre os poderes político e jurídico cria uma tensão permanente no direito à saúde, especialmente quando envolve minorias ou grupos vulneráveis.

⁶⁰ Uma ressalva ao Poder Jurídico. As decisões emanadas por este Poder, com frequência, são fundamentadas em conceitos jurídicos abstratos e indeterminados. Quando assim o são estão suscetíveis a interpretações distintas e entendimentos que carregam um certo viés ideológico do intérprete do direito, mesmo que de forma inconsciente. Assim, ao interpretar a norma, o Poder Jurídico acaba por decidir politicamente influenciando (de forma positiva ou negativa), as ações e decisões do Poder Político.

Essa tensão decorre do fato de que, enquanto o poder político é frequentemente orientado em prioridades de maior impacto eleitoral, o poder jurídico tende a ser provocado de maneira reativa e da interpretação do direito posto naquele Estado-nação. Os conflitos surgem quando não se efetivam direitos individuais ou coletivos que foram objeto de algum tipo de promessa social,⁶¹ contribuindo para exclusões, desigualdades e, no caso do direito à saúde, afetando o bem maior do ser humano: a vida.

As “promessas não cumpridas” oriundas do poder político revelam o déficit de implementação estrutural e a prevalência de um discurso normativo, como aquele que está no texto da DUDH, que não encontra equivalência prática. Para as raridades o cenário é ainda mais difícil pois, além da alegação de escassez de recursos, há também uma certa invisibilidade política como visto no subcapítulo inaugural desta pesquisa. Desse embate resulta um campo de instabilidade no qual a efetividade do direito à saúde passa a depender cada vez mais da capacidade institucional de se implementar o direito.

Ocorre que, quando o poder jurídico precisa intervir para garantir prestações específicas o resultado se transforma em um paradoxo: o direito à saúde, um direito humano fundamental e temática multidisciplinar, se torna objeto de disputas que revelam a fragilidade das estruturas estatais e a necessidade de repensar mecanismos globais e cooperativos para sua efetiva proteção.

Para reduzir esta tensão é que se traz a ideia de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras, com o pensamento de que ao se organizar os grupos minoritários em uma perspectiva maior de cooperação eles deixarão de, isoladamente, serem minoritários e, com isso se tornarão um grupo estruturado capaz de ensejar um certo grau de engajamento junto ao poder político que detêm a capacidade institucional de implementar o direito à saúde.

É pelo fato das raridades serem minorias – em conjunto com a complexidade que envolve as doenças raras – que brota a possibilidade de se avaliar o direito à saúde das raridades em uma dimensão de um direito à saúde “global”. Isso, no que diz respeito à

⁶¹ Tendo em mente que a legitimidade do poder político é, em grande medida, conferida pela capacidade de se cumprir as obrigações assumidas para com os cidadãos (ex.: a garantia de direitos fundamentais), poder-se-ia afirmar que, quando o poder político falha em prover o direito à saúde, ele poderia ser visto como não cumprindo seu contrato social ou moral com o povo. Até que ponto a sociedade pode e deve resistir a um governo que negligencie direitos fundamentais? Sobre o tema em uma perspectiva filosófica, vide NUNES, Silvio Gabriel Serrano. *As origens do constitucionalismo calvinista e o direito de resistência: a legalidade bíblica do profeta em John Knox e o contratualismo secular do jurista em Théodore de Bèze*. 2017. Tese (Doutorado em Filosofia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. doi:10.11606/T.8.2017.tde-12062017-105723. Acesso em: 03.07.2024.

administração deste direito, um pouco em linha com as propostas de um direito administrativo global⁶² que têm crescido desde a primeira década do século XXI.

A ideia de pensamento em um direito global nesta perspectiva de administração e gestão interessará nos pontos de convergência desta teoria para auxiliar a instrumentalizar *standards* de gestão do tema já que, conforme será exposto mais adiante, entende-se que a teoria e conceito do pluralismo jurídico (a coexistência de múltiplos sistemas normativos (estatais e não estatais) que regulam a vida social de forma simultânea), melhor se aproxima das bases da pesquisa do que a teoria do direito administrativo global (conjunto de normas e práticas administrativas transnacionais que regulam organizações, atores e regimes além do âmbito exclusivo dos Estados).

Ademais, formular qualquer ideia que possa, de alguma forma, interferir na territorialidade e soberania de um determinado Estado-Nação é irreal e utópica dentro do jogo de poder político e econômico existente no mundo, mesmo em áreas territoriais comunitárias. Nenhum país sujeitar-se-á a um espaço global que possa interferir em sua territorialidade e soberania.

Assim, para viabilizar esse espaço, a defesa por um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras precisa ser alicerçada em elementos e fenômenos distintos da territorialidade e da soberania estatal, ou seja, a territorialidade e soberania estatal precisam ser respeitadas e a busca deste direito deve ser construída através de pontes de cooperação e integração sem violar normas internas de cada Estado-nação.

Talvez isso não seja tão complexo quanto se possa imaginar já que, as normatividades internas de cada Estado-nação, no contexto do direito à saúde, possuem muitas semelhanças de funcionamento e de organização sistêmica, conforme será visto no segundo capítulo. É a partir de uma atuação harmônica em âmbito global que a crise e tensão entre o direito e a saúde, na perspectiva das doenças raras, pode se dissipar.

⁶² VENTURINI, Otávio. *Teorias do direito administrativo global e standards: desafios à estabilidade do direito*. São Paulo: Almedina, 2020. De se registrar, contudo, que parte de estudiosos do direito adotam compreensões clássicas de que o Estado é quem organiza e instrumentaliza internamente toda a sua atividade. Nesta clássica compreensão caberia apenas ao Estado instrumentalizar os procedimentos legais estatais, dentro dos limites de sua territorialidade, não havendo espaço para uma administração de cunho “global”. Esta é uma das razões, inclusive, que esta pesquisa usa o termo “um pouco” ao expor sobre a possibilidade de administrar esse direito à saúde em uma perspectiva global. Outras razões serão expostas na sequência e aprofundadas ao longo do trabalho de pesquisa.

1.7. Patamar irredutível da saúde que o direito visa resguardar

Diante da tensão que marca o binômio direito e saúde, como visto, torna-se relevante refletir sobre a existência de um núcleo essencial que não pode ser relativizado nem subordinado a interesses políticos ou econômicos. Trata-se do chamado “mínimo existencial”,⁶³ expressão da ideia de que há prestações estatais mínimas necessárias à garantia da dignidade humana, núcleo que integra o conteúdo essencial dos direitos fundamentais. A compreensão do mínimo existencial adotada neste trabalho dialoga com a construção teórica desenvolvida por Ingo Wolfgang Sarlet,⁶⁴ especialmente no que se refere à identificação de um núcleo essencial dos direitos fundamentais diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana e juridicamente exigível perante o Estado.

Embora a terminologia “mínimo existencial” seja mais difundida no Brasil, seu fundamento remonta ao constitucionalismo alemão, no qual se firmou a noção de que o Estado tem o dever jurídico-positivo de assegurar condições básicas de subsistência. O mínimo existencial, em diálogo com os direitos humanos, foi progressivamente incorporado em diferentes sistemas jurídicos como forma de limitar a discricionariedade estatal, estabelecendo que certos patamares de proteção social não podem ser negados ou negligenciados.⁶⁵

No campo da saúde o mínimo existencial adquire relevância singular pois, o alcance a cuidados médicos básicos, diagnósticos e tratamentos indispensáveis se conecta diretamente à preservação da vida e da integridade física e psíquica.⁶⁶ Quando o debate é direcionado às doenças raras, a noção de mínimo existencial ganha contornos ainda mais sensíveis, dado os

⁶³ TORRES, Ricardo Lobo. *O mínimo existencial e os direitos fundamentais*. Revista de Direito Administrativo, 177 – pgs. 24-49, 1989.

⁶⁴ SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 14. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.

⁶⁵ Alemanha reconhece que o Estado deve garantir um padrão mínimo de subsistência (Existenzminimum) que assegure dignidade e condições básicas de vida, especialmente para populações vulneráveis (LEISNER, Walter Georg. *Existenzsicherung im Öffentlichen Recht: Minimum – Grundlagen – Förderung*. Mohr Siebeck., 2011). Na França, a proteção aos direitos sociais fundamentais, como saúde e assistência social, tem como base o princípio de dignidade humana (SIMMONS, Dana. *Vital Minimum: Need, Science, and Politics in Modern France*. University of Chicago Press. I. 2015). A Suprema Corte da Índia também reconheceu o conceito do mínimo existencial impondo que o Estado forneça recursos mínimos essenciais, como alimentação, abrigo e saúde, para que a vida seja digna (RAJADURAI, Samuel. *Promised Land and Right to Subsistence: The Disintegration of Peasantry and the Neoliberal Policy on Food Security in India*. 2017). Organismos como a ONU e o PIDESC defendem que todos os Estados devem assegurar condições mínimas de subsistência e acesso à saúde, alimentação, moradia e educação, em linha com o conceito de mínimo existencial.

⁶⁶ NUNES, Silvio Gabriel Serrano; COMPARINI, Julio de Souza. O direito constitucional à saúde: a ponderação entre o mínimo existencial e a reserva do possível. In: NIELSEN JÚNIOR, Diógenes (org.). *Princípios Constitucionais: Diretrizes e Aplicabilidade no Direito*. v. 1. 1. ed. Londrina: Toth, 2022

significativos desafios e barreiras de ordem individual e social que a raridade enfrenta conforme explicado no início deste capítulo na abordagem sobre o que são as doenças raras.⁶⁷

Assim, o mínimo existencial em saúde e, na perspectiva e recorte das doenças raras, revela-se como um instrumento normativo de equalização. Ao se reconhecer a vulnerabilidade intrínseca desses grupos o direito impõe a cada Estado-nação o dever de resguardar o patamar mínimo de dignidade, de modo a que o direito à saúde não se converta em promessa vazia. Ao mesmo tempo, a exigibilidade desse núcleo essencial reforça a necessidade de cooperação transnacional e de arranjos institucionais inovadores, capazes de articular soberania estatal e solidariedade global, conforme delineado no subcapítulo anterior.

1.8. Síntese sobre as doenças raras e a conceituação da saúde e do direito à saúde

Este capítulo permitiu percorrer o caminho conceitual necessário para compreender as doenças raras e a realidade das raridades como campo de reflexão inicial acerca da saúde e do direito à saúde. Partindo do recorte inicial do que se entende por doenças raras, constatou-se que tais enfermidades, embora diversas em manifestações clínicas e origens genéticas, compartilham um elemento estruturante: um certo grau de invisibilidade que acomete seus portadores, colocando-os em posição de vulnerabilidade.

Em seguida, ao conceituar o termo saúde no âmbito desta pesquisa, verificou-se que se trata de um fenômeno que transcende a mera ausência de enfermidade, constituindo um estado de bem-estar integral, físico, mental e social. Sob a ótica do campo do direito, o direito à saúde revela-se como um direito humano fundamental, cuja proteção se insere em uma complexa temática multidisciplinar.

Tal multidisciplinariedade reflete-se na necessidade de diálogo entre direito, medicina, ética, economia e política, exigindo uma abordagem integrada em busca da executoriedade prática do direito à saúde, afinal, enquanto a DHDU proclama uma universalidade do direito à saúde e as ações políticas adotadas pelos Estados-nação ratificam a DHDU, os mecanismos estatais de implementação podem não estar se revelando suficientes.

A premissa é de que não há como compreender o direito à saúde de forma isolada, tanto da realidade social de cada Estado-nação quanto de outras áreas de conhecimento. Muito menos se faz possível garantir a execução deste direito, apenas e tão somente, sob uma

⁶⁷ ALMEIDA, Michelle Aparecida Ganho; DE SÉLLOS-KNOERR, Viviane Coelho; KNOERR, Fernando Gustavo. *O direito fundamental à saúde, o princípio da reserva do possível e o mínimo existencial: uma discussão em relação às doenças raras e o fornecimento de medicamentos*. Revista Internacional Consinter de Direito, v. 9, p. 437, 2023.

perspectiva jurídica. Esta premissa se confirma com o fato de que juristas e operadores do direito escreveram e seguem escrevendo sobre a temática do direito à saúde, ao menos desde 1948 com a DHDU.⁶⁸

Ensaaios, artigos, dissertações, teses e toda uma doutrina jurídica molda os conceitos do direito à saúde e que poderia ser segregada em três grandes marcos. O marco inicial de reconhecimento da existência do direito à saúde, em um caráter mais filosófico, abstrato e principiológico. Um segundo momento com debates sobre as consequências que o reconhecimento do direito à saúde traz para a sociedade. E o momento atual em que o debate aborda o viés econômico da saúde diante das crescentes tecnologias e limitação de recursos.

O que ainda não se aprofundou no campo do direito de forma mais estruturada em todos estes marcos, contudo, é o debate sobre a executoriedade sistêmica do direito à saúde, ou seja, a realidade fática e concreta de que o *direito à saúde* somente será garantido a cada indivíduo, se e quando, o indivíduo que dele necessita obtiver o *acesso à saúde*. Trata-se de um tema que também é multidisciplinar e que imprescinde de políticas de saúde e integração entre o direito e outras áreas de conhecimento, tais como, por exemplo, medicina, farmácia, odontologia, ética, bioética, filosofia, sociologia, economia, ciências políticas e sociais.

Assim, o direito à saúde apenas realizar-se-á concretamente quando o indivíduo conseguir usufruir dos serviços, recursos e tecnologias necessários para alcançar à saúde. É por isso que o *acesso à saúde* é o garantidor do *direito à saúde*. Tal como o direito não fornece receitas prontas, mas, insiste em princípios-chave e fundamentais de um sistema judicial, o acesso à saúde se assemelha ao imprescindir da principiologia e elementos de direcionamento que, uma vez identificados permitirá reconhecer quais são os fundamentos para se construir um direito global à saúde na perspectiva das doenças raras.

Antes de avançarmos para o estudo do acesso à saúde – elemento garantidor do direito à saúde – é necessário integrar à pesquisa a evolução tecnológica na temática da saúde, dado que esta evolução vem transformando radicalmente os parâmetros do diagnóstico, tratamento e custos, influenciando diretamente o debate jurídico sobre o que é o acesso à saúde.

⁶⁸ Apenas a título de exemplo, se pesquisarmos a expressão “*Direito à saúde*”, no Google Acadêmico na rede mundial de computadores, a pesquisa retornará com mais de 90 mil resultados. O mesmo termo nos idiomas Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Alemão também resultará em dezenas de milhares de achados.

1.9. Evolução tecnológica na temática da saúde

O direito à saúde não se restringe à formulação de normas, mas, envolve a capacidade de acompanhar os avanços científicos e tecnológicos. Ocorre que a tecnologia em saúde⁶⁹ não para de evoluir. Dos exames clínicos e equipamentos de diagnósticos aos tratamentos medicamentosos. No diagnóstico, os serviços por imagem crescem de forma significativa com a evolução de pesquisas em áreas ópticas,⁷⁰ criação de novos softwares e tecnologia de informação.

A integração de *big data* na saúde há tempo já permite uma análise abrangente dos históricos clínicos de pacientes, possibilitando diagnósticos personalizados e tratamentos sob medida. E a inteligência artificial, cada vez mais presente no segmento de saúde, têm desempenhado um papel relevante nessa evolução tecnológica, permitindo análises mais precisas e rápidas de dados médicos.

Ferramentas avançadas de inteligência artificial já podem interpretar exames de imagem, como ressonâncias magnéticas e tomografias, com maior eficiência, auxiliando os profissionais de saúde a identificarem doenças em estágios iniciais, o que aumenta as chances de sucesso nos tratamentos.⁷¹

Outro avanço relevante está na telemedicina com o uso de plataformas digitais e dispositivos conectados. Equipamentos portáteis de monitoramento possibilitam a coleta de dados em tempo real sobre a saúde dos pacientes.⁷² Ademais, isto permite que os pacientes sejam acompanhados à distância pelos profissionais de saúde, garantindo uma resposta mais rápida a emergências e a otimização de tratamentos contínuos.

Especificamente no que diz respeito à telemedicina, de se destacar o sistema de saúde dinamarquês que é reconhecido por sua abordagem avançada e integrada à telemedicina, com destaque para o monitoramento remoto de doenças crônicas, como a doença pulmonar

⁶⁹ Desde 2019 a OMS vem tentando dar um encaminhamento para o conceito das tecnologias em saúde que, basicamente, se refere a como uma aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos visa resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida do ser humano. Disponível em: <https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/health-technologies>. Acesso em 07.11.2024.

⁷⁰ SILVEIRA, Rafael Cerqueira de Barros *et. all.* *Cirurgia laparoscópica: evolução, aplicações clínicas e impacto na saúde pública.* Contribuciones a Las Ciencias Sociales, v. 17, n. 4, p. e6151, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/6151>. Acesso em: 22.10. 2024.

⁷¹ FONSECA, Frederico Rosa *et. all.* *O impacto da inteligência artificial na interpretação de exames de imagem em diagnóstico médico.* Brazilian Journal of Health Review, v. 7, n. 3, p. e69808, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/69808>. Acesso em: 22.10.2024.

⁷² OLIVEIRA, Bruna Soraya da Silva Barbosa *et. all.* *Análise e Evolução da Telemedicina no Brasil nos Anos 2019-2023 e sua atual importância.* Revista Contemporânea, v. 4, n. 10, p. e6123, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6123>. Acesso em: 22.10.2024.

obstrutiva crônica - DPOC e insuficiência cardíaca, por meio de kits domiciliares e plataformas digitais.⁷³ Isso somente foi possível pois, em meados da década de 2000, a Dinamarca passou a investir sistematicamente na digitalização de seus serviços de saúde com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e ampliar a disponibilidade de cuidados médicos à população do país.

A cronologia evolutiva dos medicamentos também apresenta saltos exponenciais no contexto evolutivo das tecnologias em saúde. Dos medicamentos sintéticos descobertos no início do século XX aos medicamentos biológicos da década de 1980. Da era das vacinas aos antibióticos. Da biologia molecular à biotecnologia com a atual terapia gênica que utiliza técnicas de DNA recombinante para substituir ou manipular genes visando corrigir uma informação que está errada ou ausente no DNA de um indivíduo, podendo levar a cura de uma doença ou o alívio dos seus sintomas.⁷⁴

Na pesquisa clínica não é diferente. A sua evolução demanda atenção constante da bioética e do biodireito,⁷⁵ bem como de reguladores no mundo todo de modo a assegurar os direitos e a segurança dos participantes, assim como para aprimorar os processos de pesquisa em prol do ser humano.⁷⁶ Os temas tradicionais da ciência avançaram para os aplicativos de

⁷³ Sobre o tema, vide o programa TeleCare Nord. Disponível em: <https://www.interregeurope.eu/good-practices/telecare-north-denmark>. Acesso em: 18.08.2025.

⁷⁴ SILVA JÚNIOR, João Batista da Silva. *Produtos de terapia gênica: panorama atual de riscos e regulação dos medicamentos à base de genes e células*. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade de Brasília, Brasília, 2023, 222 f.

⁷⁵ Na doutrina de Maria Helena Diniz o biodireito “Tem a vida por objeto principal, salientando que a verdade jurídica não poderá salientar-se à ética e ao direito, assim como o progresso científico não poderá acobertar crimes contra a dignidade humana, nem traçar sem limites jurídico, os destinos da humanidade” DINIZ, Maria Helena. *O estado atual do biodireito*. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 44.

⁷⁶ Apenas a título de exemplo, no Brasil, o Projeto de Lei n.º 70822/2017, que dispõe sobre a pesquisa clínica com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos no Brasil, foi sancionado em 28 de maio de 2024, dando vigência à Lei Federal n.º 14.874, dispondo sobre a pesquisa com seres humanos e instituindo o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Referida legislação, que reforça as exigências éticas da pesquisa clínica tem pontos que deixaram a desejar na melhora do ambiente interno brasileiro, como a ausência de limite de prazo para a continuidade do tratamento pós-estudo e que deixava o Brasil atrás de outros Estados-nação nesta temática e na possibilidade de aumento de estudos clínicos no Brasil. Sobre o tema, vide AITH, Fernando. Lei que regula pesquisas com seres humanos no Brasil traz avanços e retrocessos. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-fernando-aith/lei-que-regula-pesquisas-com-seres-humanos-no-brasil-traz-avancos-e-retrocessos-07062024>. Acesso em 18.07.2024. De se registrar, contudo, que este ponto foi alterado. Em 17 de junho de 2025 o Congresso Nacional brasileiro derrubou o veto presidencial (VET 13/2024) retomando a vigência do dispositivo legal vetado. Mas o tema ainda não se findou e seguida em debate, quando da apresentação definitiva desta tese, uma vez que a Sociedade Brasileira de Bioética – SBB ingressou perante o Supremo Tribunal Federal brasileiro com uma ação direta de inconstitucionalidade para debater, além do tema objeto do veto, outras disposições da novel legislação (ADI 7875/ADI7875).

saúde com tecnologias que auxiliam na coleta e armazenamento de dados objetivando a otimização do autocuidado de um indivíduo, bem como a divulgação de informações.⁷⁷

As tecnologias em saúde estão cada vez mais abrangentes. A evolução tecnológica em saúde é notável.⁷⁸ Esta conexão entre saúde e tecnologia que traz evoluções em prol da vida também traz consigo os dilemas éticos e legais envolvidos na implementação de novas soluções tecnológicas. São desafios que vão da guarda e armazenamento de dados ao risco de vazamento de dados pessoais e sensíveis.

Trata-se de uma realidade que não para de crescer e que enseja intensos debates sobre os impactos sistêmicos que estão transformando a sociedade e que, ao mesmo tempo, podem colocar em xeque a sustentabilidade financeira de sistemas de saúde dos Estados-nação.⁷⁹ Todos esses fatos já são vivenciados no dia a dia por diferentes Estados-nação.

As conexões em rede no mundo digital também integram o contexto evolutivo da saúde. Conexões entre diversas pessoas e entidades ao redor do mundo que ultrapassam os limites das fronteiras nacionais e que aumentam a cada dia. Qualquer pessoa de posse de uma tecnologia conectada à rede mundial de computadores pode, teoricamente, realizar uma pesquisa em qualquer navegador de busca e localizar assuntos que lhe sejam de interesse.

A tecnologia já transformou o mundo e a área da saúde não é exceção. Tanto é que, desde 2018, a OMS vem empregando de forma mais destacada o termo “saúde digital” para se referir a todos os aspectos da tecnologia aplicada à saúde, incluindo dispositivos vestíveis, aplicativos de saúde, registros eletrônicos de saúde e sistemas de informação em saúde.⁸⁰

Com a inteligência artificial uma pessoa pode encontrar ainda mais informações em questão de segundos. Ao mesmo tempo, em questão de minutos, quando muito horas, pessoas estão conectadas independentemente de nacionalidade ou de onde fisicamente estão localizadas ao redor do mundo.⁸¹

⁷⁷ World Health Organization, *Health technology assessment of medical devices*. Geneva. WHO, 2011. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241501361>. Acesso em 29.01.2023.

⁷⁸ GARCIA, Lara Rocha. *Inovação tecnológica e direito à saúde: aspectos jurídicos, econômicos, tecnológicos e de políticas públicas*. Curitiba: Juruá, 2017.

⁷⁹ NABUT, Lucas Coelho. *A incorporação das novas tecnologias médicas na saúde suplementar: uma análise jurídica em busca da sustentabilidade e eficiência*. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020. 211f.

⁸⁰ A 71ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio de 2018, aprovou uma resolução sobre “saúde digital”, que incentivou os Estados-membros a priorizar o desenvolvimento e o uso ampliado de tecnologias digitais em saúde. É a partir desta resolução que o termo saúde digital passa a ser utilizado de forma mais enfática ao redor do mundo. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/279505/A71_R7-en.pdf?sequence=1. Acesso em 19.08.2025.

⁸¹ LEAL, Tourinho Saul. *Direito à inovação: a vida nas cidades inteligentes*. 2. Ribeirão Preto/SP: Ed. Migalhas, 2020. p. 109-122.

Em um olhar mais abstrato, a telemedicina que se comentou há pouco poderia ser realizada a partir de qualquer país do mundo. Da mesma forma, os debates de diagnósticos com interpretações de inteligência artificial e a conexão em redes entre acadêmicos, sociedades médicas e associações de pacientes.

O que se vê em toda essa evolução tecnológica é que o mundo, que já é extremamente complexo, tem sua complexidade aumentada a cada dia e de forma exponencial. Transpondo as fronteiras territoriais e geográficas definidas pelo mapa do mundo, o ser humano, com seus computadores e smartphones plugados na rede mundial de computadores podem ter informação irrestrita a muito mais do que se possa imaginar.

Com um desafio a mais que estes computadores e smartphones trazem. O desafio que reside no fato de serem quase que um espelho dos seus usuários, ou seja, refletindo muitas vezes apenas os interesses dos próprios usuários em virtude dos direcionamentos proporcionados pelos algorítmicos. É toda essa realidade de conexões que enseja – a cada dia – mais dificuldade de compreensão da realidade global, das distintas classes sociais, de grupos minoritários e de excluídos.

Na perspectiva do direito, toda essa conexão mundial anteriormente abordada fez surgir, ao final da década de 1990, conceitos sobre um novo tipo de constitucionalismo: o constitucionalismo digital.⁸²

Um conceito ainda em construção, mas que, como a expressão sugere, é constituído por dois espíritos. O primeiro termo – *digital* – refere-se a tecnologias baseadas na rede mundial de computadores e tecnologias para processar dados de modo geral. O segundo termo – *constitucionalismo* – refere-se à ideologia política nascida no século XVIII em que, segundo a ideia lockeana, o poder dos governos deve ser legalmente limitado e sua legitimidade depende do cumprimento dessas limitações.⁸³

O avanço científico-tecnológico da saúde e a complexidade social mundial interage diretamente com o direito, o constitucionalismo digital e a inteligência artificial.⁸⁴ Se relaciona

⁸² DE GREGORIO, Giovanni. *The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union*. Electronic copy. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3506692>. Acesso em 19.7.2024.

⁸³ Ao leitor interessado no constitucionalismo digital no território brasileiro, vide: SAAVEDRA, Giovani Agostini; BORGES, Gabriel Oliveira de Aguiar. *Constitucionalismo Digital Brasileiro*. Revista da AJURIS, v.49, n.152, p.157–180, 2022. Disponível em: <http://revistadaajuris.ajuris.org.br/index.php/REVAJURIS/article/view/1228>. Acesso em 19.7.2024. Vide, também, CELESTE, E., & da Silva Santarém, P. R. *Constitucionalismo Digital: Mapeando a resposta constitucional aos desafios da tecnologia digital*. Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça, 15(45), 63–91. Disponível em: <https://doi.org/10.30899/dfj.v15i45.1219>. Acesso em 19.7.2024.

⁸⁴ PINTO, Felipe.; GARCIA, Lara. *Desafios internacionais da aplicação da inteligência artificial no Direito*. Revista Justiça do Direito, v. 35, n. 2, p. 6-29, 1 set. 2021.

com a inovação, a ética e a bioética. A bioética que “traz consigo a preservação da vida em sua mais ampla dimensão”,⁸⁵ com princípios que já são referenciados em debates sobre a regulamentação da inteligência artificial,⁸⁶ em um contexto que integra o constitucionalismo digital e as preocupações sobre o futuro evolutivo da sociedade global.

Todo esse mundo digital e inovador, cada vez mais veloz e conectado, interage com a saúde e com debates sobre limites éticos da inovação.⁸⁷ Também permite o contato de minorias ao direito à saúde que podem interagir em uma grande rede complexa global mundial. A vida das raridades na sociedade possui forte conexão e relação com comunidades.

As comunidades surgem, inicialmente, pelas associações de pacientes, ou seja, um conjunto de indivíduos (pacientes, familiares, profissionais de saúde, etc.) que vivem em um determinado Estado-nação com algum objetivo em comum. No caso das raridades, os objetivos em comuns são a obtenção do diagnóstico e tratamento do paciente raro e a busca de uma vida inclusiva.

Essa formação comunitária decorre de falhas da atuação estatal que faz com que as minorias busquem se associar a seus semelhantes⁸⁸ em busca de ações afirmativas em relação aos direitos fundamentais dos pacientes e do entorno deles já que, conforme comentamos antes, o impacto de viver com uma doença rara vai além da saúde de um indivíduo.⁸⁹ Uma formação comunitária que inicia, geralmente, de um sofrimento e que está em transformação já que, é a partir do processo de transformação das sociedades que comunidades são mantidas vivas enquanto outras se extinguem ou nascem.

⁸⁵ NASSIF, Murilo M. Bioética e a troca de medicamentos biológicos no SUS: Como a intercambialidade dos biológicos se relaciona com a bioética. In RIBEIRO, Raphael Lima (org.) et all. *Direito, Estado e Sociedade – Interseções*. v. 4, São Paulo: Dialética, 2022.

⁸⁶ MITTELSTADT, Brent. *Principles alone cannot guarantee ethical AI*. Nat Mach Intell 1, 501–507 (2019). Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4>. Acesso em 11.01.2023.

⁸⁷ O filósofo Michael Sandel aborda a ética na era da engenharia genética e argumenta que a revolução genética está mudando a forma como filósofos discutem a ética ao redor do mundo. “O problema da eugenia e da engenharia genética é que elas representam o triunfo unilateral da intenção deliberada sobre o dado inato, do domínio sobre a reverência, do moldar sobre o contemplar. Mas por que, poderíamos nos indagar, se preocupar com tal triunfo? Por que não simplesmente nos livramos do incômodo com o melhoramento, como qualquer superstição? O que se perderia caso a biotecnologia dissolvesse nosso senso de dádiva?” SANDEL, Michael. *Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética*. 1. Ed. Trad. Ana Carolina Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 97.

⁸⁸ OLIVEIRA, Cláudio Roberto Cordovil; Guimarães, Maria Cristina Soares; MACHADO, Rejane. *Doenças raras como categoria de classificação emergente: o caso brasileiro*. Revista DataGramaZero - Revista de Informação: Rio de Janeiro, v.13, n.1, p. 1-10, 2012.

⁸⁹ Ao leitor que desejar explorar um pouco mais o papel das associações de pacientes, vide: NUNES, João Arriscado; MATIAS, Marisa; FILIPE, Ângela Marques. *As organizações de pacientes como atores emergentes no espaço da saúde: o caso de Portugal*. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, [S. l.], v. 1, n. 1, 2007. Disponível em: <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/894>. Acesso em: 05.07.2024.

Fato é que a tecnologia e globalização estão auxiliando há tempos neste processo de transformação, manutenção, nascimento e extinção de comunidades. Dentre as transformações, a mais significativa está na perda da territorialidade geográfica das comunidades ao redor do mundo que, conectadas em rede global, passam a ser constituídas por indivíduos de distintos Estado-nação, diferentes culturas e pensamentos.

São comunidades que vão além das territorialidades geográficas estatais e que constituem uma nova forma de se fazer a sociedade globalizada. Desprendida do espaço territorial e do tempo estas comunidades se fundam na cooperação e trocas objetivas.⁹⁰

Toda essa transformação das comunidades permitiria – em teoria – que as raridades se conectassem ao redor do mundo e compartilhassem os desafios que enfrentam em distintos Estados-nação o que, por sua vez, de forma individual e coletiva, as auxiliaria nos desafios que enfrentam cotidianamente como minorias nos limites territoriais de seu Estado-nação de origem ou moradia.

As associações de pacientes, que inicialmente estavam restritas à determinadas regiões de cada Estado-nação, estão cada vez mais interligadas no plano transnacional em comunidades virtuais, ganhando espaço e voz no mundo.⁹¹ Tal qual a ciência é essencial para a saúde, a tecnologia se torna cada vez mais impregnada em todas as esferas sociais e comunitárias. Quando ciência, saúde, tecnologia e comunidade se cruzam o progresso pode ser incalculável, com resultados qualitativos e quantitativos exponenciais à vida.

Não é por acaso que tecnologias digitais em rede já se tornaram um vetor de mudança em todos os setores da economia global. Ao se redefinir as maneiras pelas quais indústrias, instituições, indivíduos e todos os Estados-nação interagem através de dados, vislumbra-se uma oportunidade de criação de um ambiente cada vez mais inovador e inclusivo.

Desta crescente de dados surgem novos desafios e abordagens como o de proteger dados confidenciais com a necessidade de usá-los de forma inovadora, confiável e segura.⁹² Os dados que todas as tecnologias captam estão armazenados em servidores ao redor do mundo (localizados no espaço de um determinado território soberano) e, por mais que o direito circunscrito a cada Estado-nação imponha suas limitações e restrições, fato é que sempre serão

⁹⁰ LÉVY, Pierre. *Cyberdemocratie*. Paris : Odile Jacob, 2002. Lévy tem defendido que essa rede de pessoas e a participação em comunidades virtuais é um estímulo à formação de inteligências coletivas. A troca de informações e conhecimentos permite a intermediação cultural tradicional, abrindo caminhos às visões alternativas de uma cultura.

⁹¹ Apenas a título de exemplo, o website RareConnect (<https://www.rareconnect.org/en>) permite que pacientes com doenças raras se conectem globalmente.

⁹² DEATON, Angus. *A grande saída: saúde, riqueza e as origens da desigualdade*. Tradução Marcelo Levy. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

imperfeitas e insuficientes pela razão de que a tecnologia avança sempre mais rápido do que o direito, a regulação e o controle.

Os dados e a disponibilidade imediata de conhecimento já transformaram o mundo. Inclusive já há quem defenda que toda essa transformação de dados já ensejou o deslocamento do eixo de poder.⁹³ Não se trata de futurologia, mas, de uma aparente realidade do presente que pode ser encarada como uma realidade ou ignorada por motivos diversos que vão desde a falta de conhecimento até os eventuais interesses existentes por detrás do tema.

O aumento do compartilhamento de dados de saúde digitalizados e centralizados forneceu novas oportunidades para análise de dados e uso de inteligência artificial na prestação de cuidados de saúde de modo geral. Como já mencionado, os provedores de saúde em todo o mundo estão aplicando inteligência artificial para dar suporte a diagnósticos e outras decisões clínicas, automatizar o planejamento do tratamento e gerenciar doenças crônicas⁹⁴.

Empresas privadas e instituições diversas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de novos aplicativos para inteligência artificial,⁹⁵ muitas vezes em colaboração estreita com as partes interessadas em saúde, governo e instituições acadêmicas. Ainda assim, o compartilhamento de dados entre várias agências governamentais, prestadores de serviços de saúde e organizações do setor privado é limitado pela ausência de serviços estruturais. Também é limitado – e assim deve ser – por normas de privacidade.

Embora a coleta e o compartilhamento de informações possa ser benefício para aprimorar o diagnóstico e tratamento das doenças raras é igualmente necessário reconhecer a importância da confidencialidade, especialmente no contexto de informações sensíveis relacionadas à saúde. O tratamento de dados de pacientes exige mecanismos rigorosos de

⁹³ DARON, Acemoglu; ROBINSON, James A. 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. New York: Crown. Publicado em 2012, o livro explora as razões por trás das disparidades econômicas e políticas entre nações, investigando por que algumas sociedades prosperam enquanto outras permanecem em pobreza persistente. Com exemplos históricos e contemporâneos os autores argumentam e demonstram como as instituições influenciam a forma como o poder é distribuído em uma sociedade e como as decisões políticas e econômicas são tomadas; como se ajusta o eixo do poder no mundo.

⁹⁴ Apenas a título de exemplo, desde 2023, está em vigor na Itália uma norma que estabelece programas nacionais de triagem para diabetes tipo 1 que, por sua vez, já aparenta ter resultados promissores reduzindo casos de cetoacidose diabética em crianças diagnosticadas. O programa preventivo italiano também tem contribuído para a coleta de dados sobre a doença, fator essencial para o avanço de tratamentos farmacológicos capazes de retardar ou até mesmo interromper a progressão da doença. Mais sobre o tema em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-futuro-da-diabetes-tipo-1>. Acesso em 18.08.2025.

⁹⁵ Sobre a necessidade de se debater melhor a IA em saúde, vide NASSIF, Murilo Meneghetti. *Inteligência artificial e saúde*. A busca de uma regulação com princípios globais. São Paulo: Jota, 2023. Disponível em <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/inteligencia-artificial-e-saude-27112023>. Acesso em 3.3.2024.

proteção para preservar a privacidade, prevenir discriminações e garantir que a divulgação de informações não comprometa direitos individuais⁹⁶.

A crescente inovação de sistemas de telemedicina (já mencionado antes) e cuidados virtuais ao redor do mundo, forçadas pela pandemia da covid-19, representa uma mudança significativa na forma como os pacientes acessam os cuidados de saúde. A transformação digital com novos recursos avança exponencialmente e de modo cada vez mais imprevisível e a inteligência artificial já é capaz de construir moléculas para novos medicamentos para a indústria farmacêutica.

Todos os setores de saúde ao redor do mundo estão passando por um período de transformação e modernização. Não é diferente no contexto do direito à saúde. Proteção de dados, compartilhamento de dados, inteligência artificial, modernização da assistência e diagnóstico de saúde por meio da adoção de novas tecnologias e avaliação científica mais ágil.

Avaliações e análises, tanto no espaço de pesquisa e desenvolvimento quanto no espaço regulatório (por exemplo, abordagem baseada em evidências do mundo real e processos de aprovação de revisão contínua), são apenas alguns exemplos das oportunidades e desafios que os Estados-nação enfrentam para construir uma maneira mais moderna, eficiente, eficaz e rápida de fornecer cuidados de saúde para sua população.

Entre as conexões relacionadas às raridades cite-se, apenas como exemplo, o Consórcio Internacional de Pesquisa de Doenças Raras – IRDiRC⁹⁷ – formado em 2011 entre a European Commission e o US National Institutes of Health com vistas a facilitar a cooperação e colaboração global em escala entre diversos *stakeholders* que se relacionam com a temática de pesquisa das doenças raras, de modo a se tentar maximizar esforços globais sobre o tema.

A sistemática de captação de recursos via *crowdfunding* também se relaciona com o tema, como o caso da Índia em que o governo lançou uma plataforma digital para receber doações de forma voluntária para um programa de doenças raras estatal.⁹⁸ Nos Estados Unidos

⁹⁶ A coleta de dados pessoais é tema que enseja cada vez mais debate ético e legal com o avanço da inteligência artificial. Isso pode ser visto em decisões de autoridades mundiais de proteção de dados. Caso recente comum ocorreu em 2024, quando a Autoridade Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) determinou que uma empresa excluísse todos os dados de íris coletados, citando violações do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR). Em 2025 foi a vez da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) brasileira que decidiu aplicar medida preventiva a uma empresa para suspender a oferta de criptomoeda ou de qualquer outra compensação financeira pela coleta de íris de titulares de dados no Brasil (disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-determina-suspensao-de-incentivos-financeiros-por-coleta-de-iris> Acesso em 18.08.2025).

⁹⁷ Sobre o IRDiRC, vide Letinturier-Valencia MC, Chan C-H, Rath A, Julkowska D, Eds. “IRDiRC State of Play: Rare Diseases Research Initiatives 2019-2021”, February, 2022.

⁹⁸ Maiores informações em: <https://rarediseases.nhp.gov.in>. Acesso em 29.01.2023.

o FDA lançou uma iniciativa de integração de dados através de uma plataforma digital objetivando acelerar informações sobre a caracterização de doenças raras (RDCA-DAP – Rare Disease Cures Accelerator-Data and Analytics Platform).⁹⁹

A regulamentação de devices e aplicativos médicos segue aumentando ao redor do mundo.¹⁰⁰ Em 2021 a Cyprus Alliance for Rare Disorders lançou um projeto denominado RARE-e-CONNECT consistente em uma rede de colaboração virtual entre profissionais de saúde e pessoas que convivem com doenças raras.¹⁰¹

Para doenças raras que ainda não foram sequer bem definidas, a genômica de última geração e o crescente compartilhamento de dados já resultaram na descoberta mais rápida do gene da doença e, consequente, no desenvolvimento de novos diagnósticos.¹⁰² A conexão global e digital tende a permitir, em breve, que os pacientes consigam diagnosticar sua raridade em tempo muito inferior ao de anos da realidade atual.

Na esteira evolutiva há uma grande tendência de que diversas novas terapias para doenças raras estejam disponíveis no mercado,¹⁰³ de modo que essa relação entre saúde, tecnologia, direito à saúde e acesso à saúde traz consigo um desafio cada vez maior em relação ao custo dos sistemas de saúde mundiais, em cada Estado-nação.¹⁰⁴ Em especial em sistemas de saúde universais, regiões com alto índice de desigualdade social e Estados-nação que estão em acirradas disputas no jogo de poder político e econômico global.

Diante desse cenário torna-se evidente que a efetivação do direito dependa cada vez mais da capacidade dos sistemas de saúde em garantir que os recursos tecnológicos – atuais e futuros – cheguem a todos os indivíduos que deles necessitam. E isso é realizado através do acesso à saúde. O acesso à saúde passa a ser o elemento central de concretização do direito à saúde. Este é o tema que será abordado no próximo capítulo.

⁹⁹ Para maiores informações sobre o tema consulte: <https://portal.rdca.c-path.org>. Acesso em 09.01.2023.

¹⁰⁰ Exemplo desta regulamentação pode ser visto na Europa com o Regulamento (UE) 2017/745, que revogou a anterior Directiva 93/42/CEE e introduziu mudanças no marco regulatório que regem a temática de dispositivos médicos no mercado europeu. No Brasil, vide Resolução Anvisa nº 751/2022, de 15 de setembro de 2022.

¹⁰¹ Sobre o projeto, consulte: <https://rare-e-connect.eu/en>. Acesso em 09.01.2023.

¹⁰² BOYCOTT, K.M. et al. *International cooperation to enable the diagnosis of all rare genetic diseases*. Am. J. Hum. Genet. 100(5), 695–705 (2017).

¹⁰³ A informação pode ser auferida na divulgação informacional do *pipeline* de indústrias farmacêuticas. Para maiores detalhes sugere a consulta dos websites destas empresas ou perante websites de registro sanitário de agências reguladoras sanitárias ao redor do mundo.

¹⁰⁴ DOUGLAS, Conor M. W et al. *Social pharmaceutical innovation and alternative forms of research, development and deployment for drugs for rare diseases*. Orphanet J of Rare Dis 17, 344, 2022. Disponível em: <https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-022-02476-6>. Acesso em 08.04.2023.

2. ACESSO À SAÚDE

“Health cannot be a question of income; it is a fundamental human right.”

Nelson Mandela

Este capítulo se dedica a analisar o acesso à saúde como princípio jurídico estruturante, reconhecendo-o como a dimensão que torna possível a fruição do direito à saúde, cuja efetividade depende de sua articulação com critérios normativos capazes de lhe conferir densidade prática. O acesso à saúde, em qualquer Estado-nação, é tema complexo e multidisciplinar. Assunto transversal que ultrapassa as ciências jurídicas e adentra ao campo da ética, bioética, ciências médicas, farmacêuticas dentre outras. Como será visto adiante é através do acesso à saúde que o direito à saúde (exemplo: o diagnóstico e tratamento) são viabilizados aos indivíduos-pacientes.

O acesso à saúde é fator essencial para a vida do paciente raro e o início de sua inclusão, e do seu entorno, na sociedade. Em uma concepção ampla pode-se afirmar que o acesso à saúde é o meio pelo qual o ser humano alcança (ou não) o seu direito à saúde. Sem acesso não há como viabilizar o direito à saúde. O acesso é a entrada. A origem. O princípio e início para se chegar ao fim/objetivo. E o fim é o direito à saúde que está imantado na DUDH, voluntariamente aceita pelos Estados-nação que integram a ONU, e que segue a pactuação do PIDESC na busca pelo mais alto padrão possível de saúde física e mental.

No recorte das ciências sociais e jurídicas – que é o objeto deste trabalho – o tema abraça direitos fundamentais individuais e sociais relacionados à saúde e vida, direito de minorias, justiça social, eficácia e eficiência estatal, planejamento e orçamento. A temática transborda uma série de questionamentos: Existe limite ao direito fundamental à vida e a saúde? Saúde e vida são apenas dados estatísticos e podem ser resumidas ao PIB de um país ou região, já que conceitos de saúde variam com base nas relações socioculturais vivenciadas pelo ser humano, no exercício de cidadania e da conjuntura política, econômica e social de cada Estado-nação?

Os questionamentos permitem respostas com posições antagônicas e pensamentos diversos que fazem parte de um mundo plural. A diversidade é a vida cotidiana das raridades que querem ser incluídas na sociedade, como qualquer indivíduo e ser humano que busca sua inclusão social. E neste contexto, o que esta pesquisa busca resposta é sobre quais são os

fundamentos para se construir um direito global à saúde sob a perspectiva das doenças raras e frente aos desafios de diagnóstico, tratamento e custo dos direitos.

Assim, o acesso à saúde pode ser compreendido como a dimensão estruturante do direito fundamental à saúde, responsável por viabilizar a sua fruição. Trata-se de conceito jurídico e multidisciplinar que representa a porta de entrada para a fruição da saúde no conceito de saúde que este trabalho adota e que foi tratado no primeiro capítulo.

Antes de avançar ao estudo e papel desempenhado pelo direito na conformação do acesso à saúde – tema central do capítulo terceiro – é necessário aprofundar o estudo do acesso à saúde a partir de uma análise ampla de como o acesso à saúde se concretiza. Neste contexto e, já tendo definido o conceito de acesso à saúde, este capítulo avançará expondo a pesquisa que foi realizada para entender como ocorre o acesso à saúde em diferentes Estados-nação e, em seguida como o acesso à saúde se molda e evoluiu no tempo e no espaço.

2.1. Como ocorre o acesso à saúde no espaço

O acesso à saúde varia entre os diferentes Estados-nação ao redor do mundo de acordo com os sistemas de saúde e normatividade de cada país. O território-espaço de cada Estado é o local político-jurídico em que um país define como promoverá o direito à saúde aos seus cidadãos ou indivíduos que ali estiverem.

Apesar das diferenças normativas internas que versam sobre o direito à saúde e, afora a possibilidade teórica de acessar os sistemas de saúde através de recursos financeiros próprios, os principais modelos de prestação de cuidados em saúde se resumem ao sistema de saúde público financiado pelo governo, ao sistema de saúde privado baseado em seguros e a um sistema misto entre financiamento público e oferta privada.

Há dezenas de Estados-nação (exemplo: o Brasil, Reino Unido, Itália e Israel), que afirmam em sua normatividade interna que o acesso à saúde é considerado um direito universal. Isso significa que – em teoria – o Estado é responsável por garantir que os cidadãos obtenham cuidados de saúde necessários que podem incluir consultas médicas, hospitalização, medicamentos e outros tratamentos essenciais. Os custos são cobertos pelo Estado, embora possa haver alguns custos compartilhados com os usuários do sistema.

Diz-se em teoria pois, a universalidade no acesso à saúde pode ser desigual e dependente de fatores socioeconômicos dentro de cada Estado, com desafios que de alguma forma impactam a qualidade e a disponibilidade desta universalidade. Isso ocorre especialmente em regiões mais pobres ou em desenvolvimento (como África do Sul,

Argentina, Brasil, etc.), em que há falta de infraestrutura médica adequada, recursos limitados e alcance limitado a serviços de saúde básicos. Mesmo a normatividade de tais Estados-nação estando sob a égide da universalidade e da própria DUDH.

Por outro lado, em países onde prevalece o sistema de saúde baseado em seguros e sem universalidade providenciada pelo Estado – como os Estados Unidos da América –, o acesso à saúde está fortemente ligado à posse de um seguro de saúde e sob gestão de entes privados. As pessoas podem obter seguro de saúde por meio do empregador, comprar diretamente de seguradoras privadas ou receber assistência governamental se atenderem a determinados critérios. O acesso à saúde pode ser limitado por custos, exclusões de cobertura e limitações impostas pelas seguradoras e, até mesmo, pelo próprio sistema de saúde estatal.

As políticas de acesso à saúde variam entre cada Estado-nação e estão sujeitas a mudanças ao longo do tempo. Debater o acesso à saúde das raridades pressupõe, primeiro, entender a normatividade do direito à saúde e, ao mesmo tempo, os sistemas de saúde dos diversos países mundo afora. Pressupõe olhar como o acesso à saúde se relaciona com o direito à saúde no espaço territorial dos Estados.

O espaço em debate neste trabalho é transnacional. A incursão em um debate transnacional de direito à saúde obriga que este trabalho apresente as formas de acesso à saúde de cada Estado-Nação. Mas, analisar o sistema de saúde individual de cada Estado-Nação tornaria inviável a conclusão desta pesquisa. Assim, recortes e limites se tornam necessários para que o trabalho possa ser viabilizado.

Um recorte pressupõe fazer escolhas. Toda escolha carrega consigo um grau de subjetividade. Para a mitigação da subjetividade, nada melhor do que a definição de critérios o tanto mais objetivo quanto possível. É o que a seguir tenta-se fazer.

No capítulo primeiro deste trabalho foi explicado que a OMS define as doenças raras como aquelas que afetam até 65 em cada 100.000 indivíduos. Em teoria, quanto mais indivíduos estiverem em um determinado espaço, maior a probabilidade de serem encontradas raridades neste espaço. Assim, o silogismo lógico nos leva a adotar o critério populacional como recorte objetivo da pesquisa.

Segundo a ONU, os dez países mais populosos do mundo são Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Brasil, Bangladesh, Rússia e México. Somadas as populações destes países representam mais da metade da população mundial.¹⁰⁵ A conclusão

¹⁰⁵ ONU. World Population Prospects 2022. Disponível em: <https://population.un.org/wpp/>. Acesso em 04.06.2023.

é direta: esses são os países que tendem a ter número relevante de raridades vivendo dentro de suas fronteiras territoriais.¹⁰⁶ Vejamos, pois, como estes países abordam o tema.

A normatividade do direito à saúde na Índia advém da interpretação constitucional dada pela suprema corte do país¹⁰⁷ obrigando o Estado-nação a prover tal direito aos indianos. No país há um sistema público de saúde administrado, principalmente, por faculdades de medicina estatais, em concomitância com um sistema privado. Este pago e aquele gratuito.¹⁰⁸

Já na China a temática do direito à saúde está prevista de forma macro na Constituição do país¹⁰⁹ e o acesso ocorre pela população chinesa através de serviços divididos em cuidados de saúde básicos e em cuidados de saúde especiais. No âmbito dos serviços básicos existem os serviços de saúde pública em que o estado chinês supre o custo aos cidadãos e os serviços de assistência médica, adquiridos por indivíduos e pagos ou subsidiados pelo indivíduo e pelo governo. Os serviços especiais de saúde, tidos como bens de consumo, são adquiridos e pagos por indivíduos, sem a participação do ente estatal.¹¹⁰

Nos Estados Unidos da América do Norte o acesso à saúde ocorre de forma privada. Os usuários do sistema precisam arcar com seus custos de forma direta ou através de planos de saúde privados.¹¹¹ Na Indonésia a legislação¹¹² declara que a saúde é um direito humano e

¹⁰⁶ Informação sobre Bangladesh não é apresentada neste estudo por não ter sido localizado fonte de dado confiável que pudessem garantir a veracidade das informações.

¹⁰⁷ *State of Punjab & Ors. v. Mohinder Singh Chawla* (1997 2 SCC 83). Nesta decisão, a Suprema Corte da Índia reafirmou que o direito à saúde é um aspecto integral do direito à vida, conforme garantido pelo Artigo 21 da Constituição da Índia. A Corte concluiu que o direito à saúde inclui o direito a tratamentos médicos e hospitalares gratuitos, especialmente para os pobres e necessitados.

¹⁰⁸ ABROL, Dinesh *et. all.* *A criação de sistemas inclusivos de inovação em saúde: lições da Índia.* Cad. Saúde Pública, 32 (Supl 2), Rio de Janeiro/RJ, Nov/2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00045215>. Acesso em 04.06.2023.

¹⁰⁹ A Constituição da República Popular da China, de 1982 reconhece a saúde como um direito do cidadão dentro das políticas públicas do país (arts. 21, 33 e 45). Disponível em: <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml>; Acesso em 07.04.2023.

¹¹⁰ WANG, L., WANG, Z., MA, Q. *et al.* *The development and reform of public health in China from 1949 to 2019.* Global Health 15, 45, 2019. Disponível em: <https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-019-0486-6#citeas>. Acesso em: 07.04.2023.

¹¹¹ Por meio de uma lei de assistência acessível o país criou mecanismos para fomentar o acesso dos cidadãos aos planos de saúde. Em paralelo, pelos programas Medicare e o Medicaid o acesso ao sistema para determinados americanos também foi aumentado (ex.: maiores de 65 anos que tenham contribuído com o pagamento de impostos para a saúde durante seus anos de trabalho e não tenham condição financeira de ter um plano de saúde através da Lei de Assistência Acessível). Fonte: <https://www.hhs.gov/answers/health-insurance-reform/what-is-the-affordable-care-act/index.html>. Acesso: 04.06.2023.

¹¹² Indonesia. Act of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 on Health. Disponível em: [https://leap.unep.org/countries/id/national-legislation/act-republic-indonesia-no-36-2009-health#:~:text=This%20Act%2C%20consisting%20of%20205%20articles%20divided%20into,responsibility%2C%20justice%2C%20gender%20and%20non-discriminating%20and%20religious%20norms](https://leap.unep.org/countries/id/national-legislation/act-republic-indonesia-no-36-2009-health#:~:text=This%20Act%2C%20consisting%20of%20205%20articles%20divided%20into,responsibility%2C%20justice%2C%20gender%20and%20non-discriminating%20and%20religious%20norms.). Acesso: 04.06.2023.

um dos objetivos de bem-estar social em referência à Constituição da República da Indonésia de 1945. Existe no país um sistema público de saúde nacional e o acesso ao sistema se dá mediante a coparticipação dos usuários.¹¹³

O Paquistão possui um sistema misto de saúde que é composto por serviços de saúde público e privado. O governo paquistanês tem a responsabilidade de fornecer serviços de saúde acessíveis e de qualidade para a população por meio do sistema público de saúde.¹¹⁴ Embora o acesso ao serviço de saúde pública seja subsidiado pelo governo existem custos associados a certos tratamentos, medicamentos e procedimentos.¹¹⁵

Na Nigéria, a legislação principal que trata do direito à saúde é a Lei Nacional de Saúde de 2014¹¹⁶, que estabeleceu um marco legal abrangente para a prestação de serviços de saúde acessíveis, de qualidade e equitativos em todo o país, para a população Nigeriana. Já no Brasil o sistema de saúde foi aspirado constitucionalmente¹¹⁷ como um sistema universal e gratuito, o que significa que, qualquer pessoa em território brasileiro (não necessariamente apenas um cidadão brasileiro), pode acessar o sistema público de saúde.

O sistema de saúde público brasileiro deve ser garantido à população através de políticas sociais e econômicas por todos os entes federativos do país.¹¹⁸ No país também há um sistema de saúde suplementar.¹¹⁹ Enquanto o sistema público de saúde é financiado por

¹¹³ World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. The Republic of Indonesia health system review. Health systems in transition. Vol-7, Number -1. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254716/9789290225164-eng.pdf>. Acesso: 04.06.2023. Vide, também, SURYANTO, Plummer V, BOYLE M. *Healthcare System in Indonesia*. Hosp Top. 2017 Oct-Dec;95(4):82-89. doi: 10.1080/00185868.2017.1333806. Epub 2017 Jun 21. PMID: 28636456.

¹¹⁴ Paquistão. The Public Health Service Act, 2075 (2018). Disponível em: https://senate.gov.pk/uploads/documents/1528868742_798.pdf. Acesso 04.06.2023.

¹¹⁵ TASSADUQ R; HAMID S; ABDUL Ghaffar. *Health laws of Pakistan: compilation and commentary*. East Mediterr Health J. 2021;27(6):538–541. Disponível em: <https://doi.org/10.26719/2021.27.6.538>. Acesso: 04.06.2023.

¹¹⁶ Nigéria. National Health Act, 2014 (Act No. 8 of 2014). Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104157/126947/F-693610255/NGA104157.pdf>. Acesso: 04.06.2023.

¹¹⁷ Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Art. 196. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 07.04.2023.

¹¹⁸ Constitucionalmente, desde 1998, o Brasil é uma república federativa. É formado pela União Federal, pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal que unidos de forma indissolúvel e constituem um Estado Democrático de Direito (art. 1º CF/1988), sendo que a competência para legislar e executar temas de saúde no país é comum (art. 23, II CF/1988) e concorrente (art. 24, XII CF/1988) entre todos estes entes.

¹¹⁹ O sistema de saúde suplementar brasileiro tem como marco principal as diretrizes da Lei Federal n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em conjunto com a regulamentação emanada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, autarquia federal instituída pela Lei Federal n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000.

meio de “impostos em geral”,¹²⁰ o acesso à saúde suplementar é financiado diretamente pelos usuários do sistema.

O sistema público brasileiro – SUS – é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, oferecendo cobertura gratuita, integral e universal.¹²¹ Estruturado de forma descentralizada, funciona em regime de cooperação entre os entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), com participação da sociedade civil por meio de conselhos e conferências de saúde. O desenho institucional garante desde serviços básicos de atenção primária (como a vacinação, pré-natal e consultas), até procedimentos de alta complexidade (como transplantes e tratamentos de doenças raras).

O SUS é uma referência internacional em abrangência e amplitude de serviços oferecidos. Apesar dos desafios de financiamento¹²² de um país de extensão continental e de alta desigualdade social, trata-se de um dos sistemas de saúde de caráter universal mais abrangentes do mundo e com similaridades ao sistema de saúde pública do Reino Unido, o NHS – National Health Service, que foi criado em 1948 e é considerado um dos primeiros sistemas universais de saúde do mundo.¹²³

Financiado por meio de “impostos em geral”, o NHS funciona com base na universalidade, em que os residentes do Reino Unido têm direito a atendimento médico gratuito, em que pese alguns serviços considerados não essenciais pelo sistema serem pagos ou parcialmente cobrados. Apesar do NHS ser o sistema predominante no Reino Unido, existe também um sistema privado de saúde que funciona de forma suplementar ao sistema público e que é pago pelos usuários deste sistema.

Na Rússia o acesso à saúde é garantido por um sistema de saúde público abrangente. Os cidadãos russos têm direito a cuidados de saúde no sistema público, conforme as políticas

¹²⁰ No contexto deste trabalho, os “impostos em geral” significam toda e qualquer forma de arrecadação financeira realizada em um determinado Estado-nação. O termo, portanto, é utilizado no sentido mais amplo possível, não devendo ser entendido como uma “espécie” ou forma específica de arrecadação, dado as especificidades conceituais dos sistemas tributários de cada país ao redor do mundo.

¹²¹ BRASILEIRO, Tambelini Gustavo. *Gestão pública municipal da saúde: desafios à efetivação do direito à saúde*. Tese (doutorado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

¹²² CHIARELLO, Felipe; MENEZES, Daniel Francisco Nascimento; PINTO, Felipe da Costa Silva. *O financiamento da saúde na Região Metropolitana da Baixada Santista – disparidades entre a Constituição e a realidade*. Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP, v. 1, p. 9-26, 2014.

¹²³ Cada nação do Reino Unido administra separadamente seu serviço de saúde, com diferenças organizacionais e de prioridades (NHS England, NHS Scotland, NHS Wales e Health e Social Care - Irlanda do Norte). Contudo, todos os países seguem a ideia de serviço público universal. Mais informações sobre o NHS disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/9-10/81/enacted>. Acesso: 25.09.2025.

definidas no país, sendo este financiado por meio de “impostos em geral”. O país também possui um sistema de saúde privado.¹²⁴

Com alta fragmentação, no México, o acesso ao sistema de saúde é determinado pela situação profissional do indivíduo, ou seja, se este encontra-se empregado ou desempregado no setor formal da economia mexicana. Assim, enquanto algumas instituições de saúde pública exigem afiliação e contribuição financeira de empregado e do empregador para acesso ao sistema, outras atendem pessoas que não possuem previdência social e, portanto, não exigem nenhuma contribuição financeira.¹²⁵

De modo geral o que se vê, neste recorte de estudo, é que há muitas semelhanças entre os Estados-nação, a despeito da normatividade interna de cada um deles. Mesmo nos países que possuem sistemas bem antagônicos e não universais, como é o caso dos Estados Unidos da América. Esta semelhança macro é o que nos permite defender a existência de um direito global para as raridades. Mas, será que essa representatividade populacional é suficiente para a defesa de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras?

Orientar o recorte de como ocorre o acesso à saúde nas fronteiras territoriais de Estados-nação mais populosos no mundo deixaria de fora do estudo todo o Continente Europeu que, sob um olhar comunitário e de indicador de desenvolvimento humano possui alta representatividade mundial. Também estariam de fora do estudo países como Canadá e Austrália, que integram a lista dos dez Estados-Nação com maior IDH mundial.¹²⁶

Com esta reflexão parece ser prudente alargar os critérios de recorte do estudo para incluir uma análise de países sob o aspecto populacional e, também, relacionado ao IDH já que este índice avalia o desenvolvimento humano e o bem-estar das pessoas nos Estados-nação e, portanto, está diretamente ligado à temática da saúde.

¹²⁴ Rússia. Federal Law No. 323-FZ “On the fundamentals of protection of the public health. Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/102297/123594/F-1477641865/323-FZ.pdf>. Acesso: 04.06.2023.

¹²⁵ México. Ley General de Salud, 07/02/1984. “Art. 1. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.”. Disponível em: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4652777&fecha=07/02/1984#gsc.tab=0. Acesso em 07.03.2023. Para mais informações vide, também: DANTÉS, Octavio Gómez; SESMA, Sergio; BECERRIL, Victor M.; KANUL, Felicia M.; ARREOLA, Héctor; FRENK, Julio. *Sistema de salud de México*. Salud pública México, vol.53, supl.2, Cuernavaca ene. 2011. Disponível em: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800017. Acesso em 07.04.2023.

¹²⁶ ONU. Relatório de Desenvolvimento Humano 2022. Disponível em: <https://hdr.undp.org/>. Acesso em 04.06.2023. A relação dos 10 países com maior IDH mundial neste estudo anota: Noruega, Suíça, Irlanda, Hong Kong, Islândia, Alemanha, Suécia, Austrália, Holanda e Dinamarca.

Deste recorte é possível verificar que a Noruega não possui um marco normativo único para o direito à saúde, sendo que o acesso à saúde é baseado em diversas normas que estabelecem os direitos e responsabilidades dos cidadãos, a organização do sistema de saúde, a prestação de serviços de saúde e a proteção dos direitos dos pacientes.¹²⁷

Já no sistema de saúde suíço existem prestadores de serviços públicos e privados. Embora vários aspectos sejam regulamentados em nível federal e, portanto, uniformes em toda a Suíça (como seguros obrigatórios de saúde e acidentes, ou o combate a doenças humanas e animais generalizadas), outras disposições do sistema são regulamentadas no nível regional. Por princípio, os serviços de saúde estão acessíveis a todos os residentes na Suíça, independentemente de o paciente ser cidadão suíço ou não.¹²⁸

Na Irlanda o acesso à saúde é fornecido por meio do Sistema de Saúde Pública, conhecido como HSE. O acesso à saúde é baseado em uma combinação de serviços gratuitos e subsidiados e a disponibilidade de serviços depende do tipo de cuidado necessário.¹²⁹ Além do sistema público, a Irlanda também tem um setor privado de saúde, em que os pacientes têm a opção de pagar por serviços médicos.

Em Hong Kong¹³⁰ o acesso à saúde é garantido por meio de um sistema de saúde público e privado com normatividade esparsa e não se confunde com o sistema chinês, a despeito de ser uma região administrativa especial da China. Na Islândia, o acesso à saúde está baseado em um sistema de saúde universal, fornecido principalmente pelo Serviço Nacional de Saúde.¹³¹

¹²⁷ A despeito da esparsa normatividade a Lei de Serviços de Saúde e Assistência Social na Noruega é a norma central sobre serviços de saúde e assistência social no país. Noruega. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Disponível em: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30>. Acesso: 04.06.2023.

¹²⁸ Suíça. Federal Constitution of the Swiss Confederation (SR 101). Art. 117. “Health and accident insurance. 1 The Confederation shall legislate on health and accident insurance. 2 It may declare health and the accident insurance to be compulsory, either in general terms or for individual sections of the population.”. Disponível em: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/en#art_117. Acesso: 10.04.2023.

¹²⁹ Irlanda. Health Act 2004. Disponível em: <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/42/enacted/en/html>. Acesso: 04.06.2023. A Lei de Serviços de Saúde de 2004 estabelece os direitos dos cidadãos à saúde, define as responsabilidades do governo e dos provedores de serviços de saúde e estabelece o quadro geral para a organização e financiamento dos serviços de saúde. O país conta com outras normas e regulamentações sobre o acesso à saúde.

¹³⁰ Hong Kong. Overview of the Health Care System in Hong Kong. GovHK. Disponível em: <https://www.gov.hk/en/residents/health/hosp/overview.htm>. Acesso: 04.06.2023.

¹³¹ Islândia. Health Service Act, No. 40/2007, as amended by Act No. 160/2007, No. 12/2008, No. 112/2008, No. 59/2010, No. 162/2010, No. 126/2011, No. 28/2012 and No. 106/2014. Disponível em: https://www.government.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-enskar_sidur/Health-Service-Act-No-40-2007-as-amended-2016.pdf. Acesso: 04.06.2023.

O acesso à saúde na Islândia é um direito fundamental para todos os cidadãos e residentes do país e financiado por meio de impostos em geral. Os cuidados de saúde são acessíveis e abrangentes, com foco na atenção primária à saúde e prevenção de doenças. Um segmento privado também coexiste no país.

Já o acesso ao sistema de saúde alemão é caracterizado pela existência de um seguro de saúde legal obrigatório em conjunto com um sistema de segurados de forma privada.¹³² No centro do sistema de saúde alemão está o princípio da autoadministração, em que a estrutura da assistência médica e suas responsabilidades são definidas pelo Estado de forma centralizada. Trata-se de um sistema com grande ênfase na relação de efetividade e de custo-benefício¹³³, um assunto que será tratado oportunamente.

Como princípio geral de saúde e cuidados médicos a Suécia deve oferecer à população cuidados de saúde adequados, eficientes e de boa qualidade (iguais e acessíveis). Através do sistema de seguro social, geralmente todos os que vivem ou trabalham na Suécia têm uma certa proteção financeira em caso de doença prolongada. Para além deste seguro existem seguros privados complementares. Embora a saúde e os cuidados médicos na Suécia sejam financiados majoritariamente por fundos estatais os pacientes acabam por pagar um montante financeiro para obter maior disponibilidade de serviço.¹³⁴

Os serviços de saúde na Austrália, por sua vez, fornecem acesso gratuito ou de baixo custo para todos os australianos. O seguro de saúde privado, financiado pelos usuários do sistema é alternativa ao sistema público,¹³⁵ ao passo que tanto na Holanda quanto na Dinamarca o acesso à saúde é garantido por meio de sistemas de saúde público universais.

Na Dinamarca o sistema de saúde é financiado por meio de impostos em geral. É gratuito para todos os cidadãos e residentes legais.¹³⁶ Na Holanda o sistema de saúde é baseado no sistema de seguro de saúde obrigatório.¹³⁷ Todos os residentes são obrigados a ter um

¹³² Blümel M, Spranger A, Achstetter K, Maresso A, Busse R. *Germany: Health system review*. Health Systems in Transition, 2020; 22(6): pp.i–273. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34232120/>. Acesso em 08.04.2023.

¹³³ VOLKWEIN, Tobias. *The healthcare law review: Germany*. D+B Rechtsanwälte, 2022. Disponível em: <https://thelawreviews.co.uk/title/the-healthcare-law-review/germany>. Acesso em 08.04.2023.

¹³⁴ Suécia. The Health and Medical Service Act. Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1643/health%20a%20nd%20medical%20insurance%20act.pdf>. Acesso em 10.04.2023.

¹³⁵ Austrália. Australia Government. Department of Health and Aged Care. Disponível em: <https://www.health.gov.au/about-us/the-australian-health-system>. Acesso em 10.04.2023.

¹³⁶ Dinamarca. The Health Act N. 546 of 2005. Medical care and sickness benefit. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=70825. Acesso: 04.06.2026.

¹³⁷ Holanda. Zorgverzekeringswet. Geraadpleegd op 05-06-2023. Geldend van 01-01-2006 t/m 30-09-2006. Disponível em: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2006-01-01/1/>. Acesso: 04.06.2023.

seguro de saúde básico, que cobre uma ampla gama de serviços médicos essenciais. Fornecido por empresas de seguro de saúde privadas é altamente regulamentado pelo governo.

Deste segundo recorte é possível extrair que o acesso à saúde em países de alto IDH é altamente regulamentado. Tal fato joga luz a uma terceira variável com relação direta com este trabalho, que se relaciona com o risco inerente ao tema da saúde e a existência de agentes e agências de regulação e regulamentação sanitária especializadas em diversos Estados-nação.

São entes estatais que tratam do risco sanitário relacionado ao acesso à saúde, ou seja, do risco que o acesso à diagnósticos e meios de tratamento podem ensejar para um indivíduo e/ou coletividade como é o caso da ANVISA, no Brasil, EMA na Comunidade Europeia, FDA, nos Estados Unidos da América, dentre outras.

Esta variável, que aqui se denomina como regulatória, é um dos pilares deste estudo. Existe na atuação destes entes reguladores uma normatividade estatal harmonizada e global quando o tema é o risco sanitário e o direito ao acesso à saúde. A coalização e organização harmônica destas agências reúne os chefes das principais autoridades reguladoras mundiais (ex.: Canadá, Brasil, União Europeia, EUA, França, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul, Japão, Nigéria, Austrália, México, Argentina, entre outros).¹³⁸

É diante desta nova variável – regulatória – que é trazido para a pesquisa a análise de acesso à saúde de mais alguns Estados-Nação, iniciando-se com o Canadá que tem um sistema de saúde universal com financiamento público acessível apenas aos residentes canadenses.

A lei de saúde do Canadá¹³⁹ é a norma federal que define as diretrizes de como os cuidados de saúde serão prestados no país com o objetivo de garantir que todos os residentes

¹³⁸ A Coalizão Internacional das Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) é uma entidade estratégica que reúne os chefes das autoridades reguladoras de 30 países, dentre eles: Brasil, União Europeia, México, Rússia, EUA, França, Canadá, Singapura, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul, Japão, Nigéria e Austrália, para discutir desafios regulatórios mundiais relacionados aos medicamentos de uso humano. Da mesma forma a Coalização Internacional de Pesquisa em Ciência Regulatória – GCRSR, um foro internacional de autoridades reguladoras dos EUA, Japão, Brasil, União Europeia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Argentina e Cingapura. Esta coalizão contempla o tema “pesquisa em ciência regulatória”, que atualmente ocupa espaço importante da agenda internacional dos países. Estes parceiros entendem a ciência regulatória como a ciência do desenvolvimento de novas ferramentas, padrões e abordagens para avaliar a segurança, eficácia, qualidade e desempenho de produtos. Ela é aplicada para tomar decisões regulamentares por órgãos e agências, podendo se estender a muitos campos em que os dados científicos são usados para desenvolver políticas e normas para proteger a população. No campo da regulação farmacêutica, pode ser definida pela necessidade de dados científicos que podem ser usados por uma agência reguladora para desenvolver regulamentos sobre a segurança de um produto médico ou alimento.

¹³⁹ Constitucionalmente a autoridade competente para regulamentar a temática da saúde no Canadá não é o governo federal, mas, as províncias e territórios que constituem esta federação. Entretanto é o governo federal quem provém o grande volume de recursos financeiros ao sistema de saúde canadense para o fim de equalizar as diferenças regionais conforme definido no art. 36 da Constituição do país (*Consolidation of Constitution Acts, 1867 to 1982* – Disponível em: https://laws.justice.gc.ca/PDF/CONST_TRD.pdf. Acesso em 07.04.2023). Neste

canadenses elegíveis tenham acesso – *razoável*¹⁴⁰ – a este sistema público. O país também possui um mercado para serviços de saúde privados que está fora do sistema universal público.¹⁴¹

O sistema de saúde argentino foi concebido legalmente para atender toda a população, de forma universal, incluindo os não cidadãos. A constituição do país prevê o acesso à saúde como um direito constitucional de todos.¹⁴² Trata-se de um sistema que, ideologicamente e na teoria, busca equidade e acesso amplo. Entretanto, os serviços prestados pelo setor público na Argentina coexistem com um sistema de saúde privada e, também, com um sistema de previdência social que funciona como um seguro social obrigatório organizado em torno de entidades que agrupam os seus trabalhadores, de acordo com o ramo da atividade.¹⁴³

Na Coreia do Sul os cidadãos do país estão todos inscritos no programa nacional de seguro de saúde para que todas as instituições médicas forneçam o acesso aos serviços médicos de acordo com o programa nacional de saúde. Trata-se de um sistema de acesso à saúde em que o paciente paga uma parcela em coparticipação ao Estado.¹⁴⁴ Há serviços médicos, contudo, que não são cobertos pelo seguro nacional de saúde. Nesses casos, o paciente paga diretamente pelo mesmo ou, se o paciente tiver cobertura de seguro de saúde privado, uma seguradora privada arca com os custos.¹⁴⁵

contexto normativo foi instituída a Lei de Saúde do Canadá objetivando estabelecer os critérios e as condições que as províncias e territórios devem atender para receber a transferência dos recursos (Canada Health Act - R.S.C., 1985, c. C-6, disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-6/page-1.html>. Acesso em 07.04.2023). Para mais informações sobre o sistema de saúde público canadense, vide: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-health-care-system.html>. Acesso em 07.04.2023.

¹⁴⁰ Registre-se que a palavra “razoável” (em inglês: “reasonable”) é mencionada em 8 dispositivos do *Canada Health Act*, [3, 12(1) “a” e “c”, 2, 14 (1), (2) “c”, (3)].

¹⁴¹ Para mais informações sobre o sistema de saúde privado canadense, vide: <https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/payroll/benefits-allowances/private-health-services-plan-premiums/private-health-services-plan.html>. Acesso em 07.04.2023.

¹⁴² Constitución de La Nación Argentina. Ley Nº 24.430. Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24430-804/texto>. Acesso em 07.04.2023. Para mais informações sobre o sistema público de saúde argentino vide: <https://www.argentina.gob.ar/salud>. Acesso em 07.03.2023.

¹⁴³ Argentina. Obras Sociales. Ley nº 23.660. Promulgada: Enero 5 de 1989. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23660-62/texto>. Acesso em 07.04.2023.

¹⁴⁴ Lee Y, Kim S, Kim SY, Kim G. *Ethical Consideration of National Health Insurance Reform for Universal Health Coverage in the Republic of Korea*. Asian Bioeth Rev. 2019 Mar 29;11(1):41-56. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7747280/>. Acesso em 07.04.2023.

¹⁴⁵ Jung, H.W., Kwon, Y.D. & Noh, JW. *How public and private health insurance coverage mitigates catastrophic health expenditures in Republic of Korea*. BMC Health Serv Res 22, 1042, 2022. Disponível em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08405-4#citeas>. Acesso em 08.04.2023.

A Constituição italiana reconhece o direito à saúde como um direito fundamental de cada pessoa, bem como um interesse de toda a comunidade.¹⁴⁶ A Itália determina que o acesso à saúde seja prestado a todos os cidadãos com base em três princípios: universalidade, igualdade e equidade.¹⁴⁷ Os cuidados de saúde são prestados de forma gratuita ou com a participação dos pacientes na despesa, conforme definido pelas políticas públicas do país, sendo que os cidadãos italianos podem optar pela contratação de um seguro complementar.¹⁴⁸

O sistema nacional de saúde espanhol é um dos esteios do Estado. O direito à saúde na Espanha possui previsão constitucional e deve ser garantido através de políticas sociais e econômicas.¹⁴⁹ Financiado por impostos em geral, o sistema espanhol proporciona aos cidadãos acesso gratuito. A cobertura de acesso à saúde no país é uma das mais amplas da União Europeia e não há sistemática de coparticipação como em outros países membros da Comunidade Europeia.¹⁵⁰ A saúde privada também é acessível e bastante utilizada no país, coexistindo com o sistema público espanhol.

Em Portugal existe um direito fundamental à proteção da saúde expressamente consagrado na Constituição da República Portuguesa.¹⁵¹ O direito à proteção da saúde deve

¹⁴⁶ Itália. Costituzione della Repubblica Italiana, 1947. Art. 32. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Disponível em: https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/ROSSA_Costituzione_testo%20vigente_agg_7_11_2022.pdf. Acesso em 08.04.2023.

¹⁴⁷ Itália. Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Art. 1. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale”

¹⁴⁸ DALLARI, Sueli Gandolfi; OLIVEIRA, Ana Maria Caldeira. *Reflexões sobre o Sistema Único de Saúde e o Servizio Sanitario Nazionale: a reforma da reforma - a adoção do Ticket Sanitario*. Saude soc. 25 (4) Oct-Dec 2016. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sausoc/2016.v25n4/895-901/pt/>. Acesso em 08.04.2023.

¹⁴⁹ Espanha. Constituição Espanhola, 1978. Art. 43. “1. É reconhecido o direito à proteção da saúde. 2. Compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública através de medidas preventivas e das prestações e serviços necessários. A lei estabelecerá os correspondentes direitos e deveres de todos.”. Disponível em: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-40008. Acesso em 10.04.2023.

¹⁵⁰ Espanha. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715>. Acesso em 10.04.2023.

¹⁵¹ Portugal. Constituição da República Portuguesa de 02 de abril de 1976. Art. 64. “1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. 2. O direito à proteção da saúde é realizado: a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável. 3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde; c) Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos; d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade; e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico; f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento

ser garantido através de um serviço nacional de saúde universal que, atendendo especialmente às condições econômicas e sociais dos cidadãos que o utilizam, tenderá a ser gratuito. Os cuidados de saúde em Portugal são prestados através de três sistemas coexistentes e sobrepostos que são, o serviço nacional de saúde, os regimes especiais de seguro de saúde para determinadas profissões e os seguros privados de saúde voluntários.¹⁵²

Por fim, na África do Sul também coexistem os sistemas de saúde público e privado. A lei nacional de saúde do país dispõe que o sistema de saúde público seja estruturado de modo uniforme e concentrado no acesso com equidade, eficiência, qualidade e sustentabilidade.¹⁵³ Mas, e no contexto das raridades? Como ocorre o acesso à saúde no local e espaço?

Olhar o acesso à saúde nos sistemas dos diversos Estados-nação aqui estudados – seja pelo critério populacional, IDH ou de regulação – é instigante. Isto, pois, a universalidade e equidade dos sistemas (seja a aspiracional de alguns Estados-nação seja a da Declaração dos Direitos Humanos), aparenta ser ainda mais desafiadora no campo prático e no recorte das doenças raras como será observado a seguir.

O Canadá lançou uma Estratégia Nacional para Doenças Raras em 2015. Devido à oferta limitada de financiamento disponível nos planos de saúde provinciais do Canadá, os pacientes podem encontrar dificuldades para obter financiamento para tratamentos de saúde inovadores, incluindo as raridades. Já na Argentina, a despeito de coberturas específicas para certas minorias e tratamentos específicos em legislações infraconstitucionais e regulamentações federais, não há uma regra específica que diga respeito às raridades.

Na China, dentre as coberturas básicas em serviços de saúde pública não está o acesso ao completo diagnóstico e tratamento de doenças raras.¹⁵⁴ Na Coreia do Sul existe uma tensão natural na cobertura de doenças raras pelo governo ante o forte apego ao sistema de custo-efetividade do país. Igualmente o sistema alemão. O país não oferece soluções claras para

da toxicodependência. 4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada.”. Disponível em: <https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art64>. Acesso em: 10.04.2023.

¹⁵² LOURENÇO, Alexandre. *Retrato da Saúde em Portugal: “Health at a Glance 2021”*. Acta Médica Portuguesa, v. 35, n. 2, p. 84-86, 2022.

¹⁵³ África do Sul. National Health Act 61 of 2003. Disponível em: <https://www.gov.za/documents/national-health-act>. Acesso em 10.04.2023.

¹⁵⁴ Há anos, acadêmicos ao redor do mundo de diversas áreas do saber trazem a necessidade de se debater um quadro regulatório para as doenças raras com um olhar mais sustentável e para o futuro. Na China os debates começaram por volta de 2010. Até a conclusão desta tese, entretanto, eram apenas debates. Sobre a temática na China, vide WANG, Chenguang e LI, Dingguo. *Esforços legislativos para o cuidado de doenças raras na china – análise dos fundamentos jurídicos e chamada para um quadro regulatório*. R. Dir. sanit., São Paulo, v. 14, n. 1, p. 11-33, mar./jun. 2013.

terapias medicinais mais avançadas relacionadas as raridades ante a ausência de dados completos sobre o tema. A abordagem alemã assume um benefício financeiro adicional até um certo limite financeiro¹⁵⁵ para estes tratamentos.

Portugal instituiu em 2015¹⁵⁶ um plano visando o desenvolvimento e a melhoria das políticas públicas relativas às doenças raras no país, tendo como pilares a coordenação dos cuidados aos pacientes, o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento, a cidadania e inclusão social, além da informação clínica e epidemiológica. Trata-se de política pública ainda em construção que enfrenta os desafios comuns de outros países no que diz respeito ao impacto financeiro-orçamentário, acesso ao diagnóstico, tratamento e a inclusão social e cidadã das raridades.¹⁵⁷

Na Suécia há cuidados médicos nacionais altamente especializados que são realizados em apenas alguns lugares do país com o objetivo de concentrar os cuidados mais raros ou avançados e garantir o que seja o melhor atendimento possível ao paciente.

As políticas públicas de prestação de serviços de saúde na Espanha estão expostas à dificuldade adicional de garantir que o sistema de saúde atual seja sustentável e acessível em vista do envelhecimento da população e de ter produtos e tecnologias novas e de alto custo em combinação com as crescentes demandas dos pacientes para saúde e benefícios sociais. Uma reforma legal em 2012 enfatizou que a decisão de preços deve levar em conta, entre outros fatores, custo-efetividade e impacto orçamentário.¹⁵⁸

Ressalte-se que o envelhecimento populacional não constitui fenômeno exclusivo da Espanha. Tendência semelhante é observada em outros países como, por exemplo, Japão, Portugal e Brasil. Esse fator exerce impacto significativo sobre os sistemas de saúde de caráter universal, em razão do aumento da expectativa de vida, da maior prevalência de doenças crônicas e da incorporação contínua de novas tecnologias e terapias, conforme já mencionado

¹⁵⁵ Busse R, Blümel M, Knieps F, Bärnighausen T. Statutory health insurance in Germany: a health system shaped by 135 years of solidarity, self-governance, and competition. *Lancet*. 2017 Aug 26;390(10097):882-897. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28684025/>. Acesso em 10.04.2023.

¹⁵⁶ Portugal. Despacho nº 2129-B, de 2015. Lisboa. Disponível em: https://fedra.pt/wp-content/uploads/2017/09/Despacho2129B_2015-EstrategiaIntegrada-para-as-doencas-raras.pdf. Acesso em: 07.04.2023.

¹⁵⁷ LUNA, Víctor Vidal. *Doenças raras e políticas públicas de saúde no Brasil e em Portugal: um estudo comparado*. (Re)pensando Direito, Santo Ângelo/RS. v. 09. n. 17. jan./jun. 2019, p. 190-220. Disponível em: <http://local.cneccsan.edu.br/revista/index.php/direito/index>. Acesso em: 07.04.2023.

¹⁵⁸ Espanha. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Disponível em: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/04/20/16/con>. Acesso em: 29.05.2023.

em tópicos anteriores.¹⁵⁹ Trata-se de uma realidade que fomenta o debate sobre como operar a sustentabilidade dos sistemas de saúde ao redor do mundo.

Na Suíça a lei e as listas correspondentes aprovadas pelo governo determinam quais serviços e tratamentos de saúde são reembolsados pelo sistema de saúde. Como regra geral, todos os serviços prestados devem atender aos princípios de eficácia (*Wirksam*), utilidade (*Zweckmässig*) e custo-benefício (*Wirtschaftlich*), incluindo as raridades.¹⁶⁰

No Brasil há raridades que possuem cobertura mediante políticas públicas, enquanto outras não.¹⁶¹ Em 2014 o país estabeleceu uma Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras¹⁶² como um primeiro passo para o início do aprimoramento da saúde das raridades.

O México também, desde 2017, vem tentando implementar um programa de atenção às doenças raras com objetivos semelhantes ao brasileiro. O programa visa promover a detecção precoce, a pesquisa clínica, o acesso a serviços de saúde especializados e o suporte social às pessoas com doenças raras e suas famílias.¹⁶³ O país também trabalha na criação de registros e bancos de dados nacionais de doenças raras, tal qual o Brasil.

A despeito dos Estados Unidos da América ter legislação específica para a temática dos chamados medicamentos órfãos (Orphan Drug Act), promulgada em 1983, que abrangeria as doenças raras, fato é que o sistema de saúde americano não promove o acesso ao direito à

¹⁵⁹ O Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde da OMS (2015), confirma que o envelhecimento populacional é uma tendência global – incluindo países de média e baixa renda – e destaca que, entre 2015 e 2050, a proporção de pessoas acima de 60 anos quase dobrará, passando de 12% para 22% da população mundial. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/186468/who_fw_c_alc_15.01_por.pdf?sequence=6. Acesso em: 25.08.2024.

¹⁶⁰ Suíça. Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2018) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34bis de la constitution^{1,2}. "Art. 32. Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. (...)" Disponível em: https://lex.weblaw.ch/lex.php?norm_id=832.10&source=SR&lex_id=14106. Acesso em 29.05.2023.

¹⁶¹ Especialmente pelo fato de que, a partir do final de 2022 o país passou a considerar critérios de custo-efetividade em análises para cobertura de tratamentos de alto custo. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm. Acesso em: 29.05.2023; e, O uso de limiares de custo-efetividade nas decisões em saúde: proposta para as incorporações de tecnologias no Sistema Único de Saúde, Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/pdf/2022/20221106_relatorio-uso-de-limiar-de-custo-efetividade-nas-decisoes-em-saude.pdf. Acesso em: 29.05.2023. Para melhor compreensão, o custo-efetividade é uma abordagem – em teoria técnica, mas, que tem alta carga política – utilizada para avaliar a relação entre os custos envolvidos em um tratamento ou intervenção de saúde e os benefícios resultantes da intervenção em termos de saúde ou qualidade de vida dos pacientes e, por consequência, para o auxílio na tomada de decisões sobre alocação de recursos na área da saúde, especialmente em sistemas de saúde com recursos limitados.

¹⁶² Maiores informações disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/educamunicacao-em-doencas-raras/pnaipdr>. Acesso: 30.07.2023.

¹⁶³ Maiores informações em: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477535&fecha=24/03/2017 Acesso: 25.08.2025.

saúde de forma universal e, como consequência, traz restrições ao acesso à saúde pelas raridades.

A Austrália desenvolveu o Plano Nacional de Ação para Doenças Raras em 2018 e possui um tratamento específico para a temática das raridades dentro do sistema de saúde do país, administrado pelo governo australiano (PBS), que subsidia o custo de uma ampla gama de medicamentos para seus residentes e decide sobre a concessão (ou não) de tratamento aos pacientes de doenças raras com foco na eficácia, segurança e o custo-benefício ao paciente e sistema de saúde.¹⁶⁴

Enfim, este olhar macro de local e espaço, de como ocorre o acesso à saúde em diversos Estados-nação de todos os continentes globais – inclusive na perspectiva das doenças raras – permite verificar a presença de uma alta regulação e regulamentação do Estado sobre os sistemas de saúde, sejam estes de natureza pública ou privada.

Em sistemas universais, cujo financiamento é realizado a partir do ente público (seja com arrecadação oriunda de impostos em geral ou mediante uma coparticipação do paciente), as aspirações de distintos Estados-nação mostram que o conceito de universalidade está diretamente vinculado a políticas públicas, sociais e econômicas.

Já no recorte das raridades, o que se enxerga das pesquisas realizadas, na legislação dos Estados-nação que se debruçam ou começam a se debruçar sobre as raridades, é a existência de um plano nacional, regado de abstração, para a temática das doenças raras. Um plano que inclui ideias de promoção de acesso a serviços mais especializados e apoio social e emocional aos pacientes e seus familiares, com proposições para criação de centros de referência e redes de colaboração visando a troca de conhecimentos e melhores práticas.

De qualquer modo, no contexto da temática do acesso à saúde no local e no espaço como um todo, ao olhar com lupa é possível auferir, cada vez mais, que a norma de cada Estado-Nação tem sua especificidade, particularidade e diferenças.

Contudo, ao olhar o tema de forma holística observa-se que todas as normas têm objetivos muito semelhantes e em comum. Não é à toa que termos como “razoável”, “adequado”, “eficiente”, e “sustentabilidade” são encontrados nos textos normativos.

¹⁶⁴ Pacientes com doenças raras que preenchem certos critérios de elegibilidade podem acessar os medicamentos que salvam vidas totalmente subsidiados sob o *Life Saving Drugs Program* na Austrália. Esta assistência era fornecida para 18 terapias para 11 doenças raras em agosto/2024, data que esta pesquisa foi realizada. O Governo Australiano financia e administra o programa e os medicamentos solicitados são entregues à farmácia indicada pelo paciente. Disponível em: <https://www.health.gov.au/our-work/life-saving-drugs-program/about-the-ldsp#:~:text=The%20LSDP%20covers%20medicines%20if%3A%201%20they%20are,pharmaceutical%20company%20%28sponsor%29%20applies%20for%20an%20LSDP%20listing>. Acesso em 06.11.2024.

Conceitos jurídicos indeterminados e normas de textura aberta estão presentes na maioria das disposições normativas que tratam do direito à saúde e do acesso à saúde nos mais diversos Estados-nação ao redor do mundo.

Ao aproximar o olhar para os termos abstratos encontra-se e percebe-se a alta conexão das normas existentes entre os distintos Estados-Nação e como estes estabelecem o funcionamento da sociedade em suas fronteiras territoriais. Não é de se esperar algo diferente dado se tratar de uma temática que envolve a vida e objetivos aspiracionais.

E são aspiracionais não apenas pela importância que a temática da saúde e vida possuem, mas, pelo fato de terem sido criadas em razão da inconformidade relacionada ao passado e com a crença de que o futuro pode ser melhor. São oriundas de esperança buscando, ao mesmo tempo, efetividade jurídica e fático-prática. É por todo este contexto que termos abertos oriundos de normas aspiracionais existem. Cercados de retórica buscam progresso e estabilidade social e institucional. Tratam da saúde como um bem universal.

Contudo, como dito anteriormente, esta universalidade não é absoluta. Se não é absoluta nas normas internas dos Estados-nação, como será na aspiracional DUDH? Não será, pois a realidade mostra que o acesso à saúde possui um custo financeiro. A busca por uma vida digna, com saúde e qualidade tem um preço que pode ser definida pelo PIB de um Estado-nação ou região ou pelo critério de custo-efetividade muito usado na atualidade e que será um pouco mais detalhada adiante, ainda neste segundo capítulo.

Mesmo assumindo a realidade de que saúde – e ter direito a uma vida digna – tem um preço, isso não quer dizer que não existam formas de se remediar certas injustiças. É o que se propõe nesta tese que trata do presente e a ideia de um futuro melhor para o acesso à saúde de pacientes que convivem com doenças raras.

2.2. Acesso à saúde no tempo e a relação e impacto da tecnologia

O acesso à saúde e ao direito fundamental à saúde se originam a partir de um determinado regime político ou jurídico que está ligado à cultura de cada sociedade. Cada Estado-nação define de forma individual, através da sua normatividade jurídica interna, como será garantido o acesso à saúde nas linhas territoriais e de poder que este Estado-nação possui.

Essa definição decorre de uma ação política que, independentemente de ser ou não de cunho democrático, estabelece uma normatividade jurídica interna e constitui o vínculo entre o direito à saúde e o acesso a este direito dentro de cada Estado-nação. Isto ocorre

independentemente da efetividade de como o direito à saúde advirá de forma concreta ao ser humano. O acesso à saúde também varia e se altera no tempo em cada Estado-nação.

Essa relação entre a temporalidade e o acesso à saúde interessa a esta pesquisa por dois principais motivos. O primeiro diz respeito ao que se acabou de avaliar: sobre como se dá o acesso à saúde no espaço, ou seja, pela normatividade interna dos Estados-nação que, por sua vez, se assemelha com objetivos em comum, normas aspiracionais e de textura aberta. O segundo decorre de uma forte interconexão mundial na temática da saúde e da transfronteiriça inovação tecnológica e transformação digital em tecnologias em saúde que está ocorrendo e que foi detalhado ao final do primeiro capítulo.

Para além destes dois motivos destaca-se a última crise pandêmica ocorrida entre os anos de 2019 e 2022 que aumentou, ainda mais, a pressão pela transformação e modernização do direito à saúde em um mundo tecnologicamente interconectado; cuja velocidade de interação no tempo não parece mais ser uma mera questão de constituição, alteração e aplicação do direito em cada sociedade.

No contexto do tempo (aqui tratado como evolução cronológica da sociedade) e no contexto da tecnologia atual, na temática de um direito universal tão específico (como o é o direito à saúde), o que se coloca em perspectiva é a ideia de que o acesso à saúde não deveria ser comprimido a uma ação política aplicada em um determinado tempo em cada sociedade.

Noutras palavras, não deveria o acesso à saúde sofrer das mazelas das desigualdades sociais existentes ao redor do mundo. Ao contrário. Deveria ser harmônico e sistematizado de modo a se pensar na efetividade concreta das disposições da DUDH. E a razão por detrás da afirmação está no modo como interpretamos o tempo e o aplicamos no acesso à saúde. Não se trata de uma mera questão semântica, mas, de assimilar, entender e aplicar a realidade do presente e da correlação existente entre o passado e o futuro.

O presente nos mostra o modo como o acesso à saúde ocorre no tempo atual em uma determinada sociedade. Este presente está conectado com o passado e nos permite observar e entender a evolução do acesso no tempo. De modo distinto o presente se conecta com o futuro. O futuro impõe um dever de pensar no acesso à saúde frente à evolução das novas tecnologias e dos recursos finitos e escassos.

Estas conexões com o acesso à saúde no tempo – passado, presente e futuro – interagem de modo distinto. O tempo aqui tratado é o do presente com um olhar prospectivo para o futuro. Este tempo presente com olhar prospectivo denomina-se, neste trabalho, de “presente-futuro”. Ao mesmo tempo em que se olha para o presente-futuro, não podemos

deixar de lembrar o que foi o passado. Os atos do passado estão diretamente relacionados ao presente e, para lembrar este passado, no presente, usar-se-á o termo “presente-passado”.

Aprofundando o raciocínio, tem-se que o presente-passado é representado nas sociedades de forma linear e estruturada, bem definida e comum em gráficos lineares e segregações em séculos e décadas. Já o presente-futuro mostra ser uma conexão não linear e que está cada vez menos estruturado e menos previsível, não sendo capaz de ser inserido em linha temporal tradicional. É uma conexão tão veloz que não permite definições de longo prazo e pode ser exemplificado como eventos cada vez menos espaçados no tempo, com evolução, no máximo, em anos.

Essa mudança na forma de interação entre o acesso à saúde e o tempo traz para a sociedade o dever de repensar quais são os mecanismos que lidarão com o presente-futuro. A realidade é que – no presente – não se consegue mais olhar o presente-passado para estabelecer um pensamento de presente-futuro na temática do acesso à saúde, como o direito constantemente o faz dentro da normatividade.

A perspectiva aqui trazida com este raciocínio é a da necessidade da quebra de um paradigma relacionado ao pensamento de presente-passado, reorientando-o para um pensamento de presente-futuro. A razão lógica desta necessidade está na evolução tecnológica. Na velocidade das experiências pessoais de forma individual e coletiva. No que o mundo se transformou, seja essa transformação considerada caótica ou não por cada indivíduo que interpreta o mundo atual.

As experiências pessoais e individuais foram e estão sendo afetadas pelo cenário evolutivo mundial de um modo totalmente distinto do passado. O sujeito – seja o indivíduo ou coletividade – já não mais aceita ficar mantido a um padrão linear do presente-passado. As expectativas passam a ficar cada vez mais próximas da concretude da experiência vivida. O sujeito deseja o presente-futuro na sua consciência, na mesma velocidade das novas experiências advindas da evolução tecnológica que está entrelaçada e interconectada no mundo, ultrapassando as fronteiras formais, geográficas e de poder do Estado-nação.

Esse desejo e conexão que ultrapassa fronteiras dá um contorno imponente ao tempo quando olhado e interpretado na perspectiva jurídica. Afinal, o tempo como bem jurídico não pode ser interpretado como mera passagem de anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. Na perspectiva de um bem jurídico o tempo representa um período da vida do ser

humano em que atividades diversas são realizadas.¹⁶⁵ Um período que passou e não mais retornará. E a ausência de volta do tempo, no tema de estudo desta tese, pode ser fatal ao ser humano. É este tempo, cuja passagem é inevitável, que evidencia toda a fragilidade do ser humano e das raridades. É neste contexto evolutivo do tempo que o acesso à saúde desafia a temporalidade do direito.

O acesso à saúde que é desejado está fortemente ligado a uma reorientação e mudança que não se resume apenas ao aspecto temporal do presente. A sociedade já não se reproduz mais em termos de costumes e tradições de modo linear como no passado. Parâmetros gerais de comportamento surgem e passam a ser coordenados ou gerados socialmente de forma generalizada e não mais na linearidade do presente-passado.

O tempo não se resume mais a décadas, séculos ou milênios. Mas há anos, dias ou milésimos de segundos. Essa forma de medição do tempo na sociedade muda completamente a estrutura de se pensar o acesso à saúde na sociedade, abrindo mais espaço para uma dinâmica de pensamento globalizado que, ultrapassada as fronteiras do Estado-nação, descentralizaria a atuação hierarquizada dos Estados.

O fator tempo gerou uma aceleração gradual e exponencial ao acesso. Trouxe consigo uma mudança estrutural dos sistemas de saúde. A cultura tradicional das sociedades coloca ênfase no presente-passado como base normativa para o presente-futuro. A formação de horizontes e linhas de tempo é marcante em nossa sociedade. Entretanto, a dinâmica de uma sociedade que é interconectada globalmente rompe com essa forma de pensar da orientação do presente-passado para o presente-futuro. A visão do tempo não é mais linear, retilínea e espaçada entre séculos ou décadas. É incerta e mutável entre anos ou dias.

É no contexto desta mudança que a saúde, o direito à saúde e o acesso à saúde se conectam. Na instabilidade dessa relação e orientação. A ciência e tecnologia avançam cada vez mais rápido e possibilitam cada vez mais um horizonte flexível de experiência em menor lapso temporal. Isso exige do direito e da política a necessidade de adaptações e aprendizado menos voltado ao presente-passado e mais focado no presente-futuro.

¹⁶⁵ Sobre o tempo como um bem jurídico, vide *Da responsabilidade civil no Código de 2002: aspectos fundamentais*. In. TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson. *O Direito e o Tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Em uma perspectiva filosófica sobre o tempo, vide BERGSON, Henri. *Duração e Simultaneidade*. São Paulo: Martins Fontes, 2006, em que o autor narra que o tempo não pode ser compreendido apenas como uma sucessão mensurável de instantes. O tempo verdadeiramente humano é o da duração, um fluxo contínuo e irreversível da vida que se qualifica por experiências, afetos e mudanças subjetivas. Trata-se de um tempo vivido, que não retorna e cujo decurso marca a própria constituição do sujeito.

Advém desta realidade a necessidade de se reorientar a estrutura do pensamento sobre o acesso à saúde. Uma reorientação que vá além das fronteiras formais de um determinado Estado-nação para adentrar nas necessidades de diferentes esferas sociais e de organizações não estatais que, por sua vez, não estão limitadas às esferas territoriais de um Estado-nação e, ainda, estão de algum modo conectadas ao redor do mundo.

Nesse contexto de conexão e avanço da tecnologia é que nasce a hipótese de como o acesso à saúde deve ser tratado na ideia temporal de presente-futuro. Se um direito tratado exclusivamente no ambiente doméstico de cada Estado-nação ou um direito que transponha as fronteiras territoriais e que deva ser tratado de forma universal e globalizada. Afinal, como visto neste tópico, o acesso à saúde não se restringe mais, apenas, a uma dimensão cronológica. Ele passou a ser, também, uma variável tecnológica.

No cenário aqui delineado, o acesso à saúde aparece como oportunidade de construção de estratégia do futuro. Vincular o tempo ao acesso significa lidar com a realização do presente-futuro. Não se trata de delimitar o futuro, mas, de realizar o futuro no presente.

O futuro existe como um horizonte no presente. Esse presente-futuro possui custos que precisam ser debatidos. Integra a evolução social e o custo dos direitos individuais e sociais. Todos correlacionados com a posição social de cada Estado-nação. O poder econômico, vantagens, desvantagens e desigualdades existentes em cada Estado-nação. Um emaranhado de conexão não linear e complexo. Uma complexidade social que coloca a efetividade do direito fundamental à saúde, cada vez mais sob pressão.

O tempo não pode ser fixado. Mas a sociedade cria estruturas para lidar com esse presente-futuro. Das análises consequencialistas aos conceitos jurídicos indeterminados e abstração principiológica. Enxergar o direito à saúde sobre a perspectiva do tempo é mudar a forma de pensarmos o presente-futuro. Os impactos positivos e negativos relacionado aos custos dos direitos. Não é fácil, ainda mais quando tratamos de vida e saúde em que o objetivo é imediato.

Entretanto, aguardar que o presente-passado traga as pistas para a tomada de decisão do presente-futuro não parece se conectar com a sociedade globalizada em que vivemos. O futuro precisa ser projetado. O pensamento sobre acesso à saúde precisa se modernizar como a tecnologia o fez. Criando estruturas que sejam equânimes em busca do que a DUDH dispôs em uma textura aberta e abstrata que, de algum modo (direto ou indireto), está replicado na normatividade interna de cada Estado-nação.

A ideia de que o direito sempre olha para o passado enquanto a tecnologia olha para o futuro precisa ser ajustada. O direito pode continuar olhando para o passado e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro, sem perder a essência do passado. As estruturas de expectativas sociais impõem essa mudança. E os legisladores, executores e os julgadores precisam se adaptar.

Estabilizar essas expectativas no tempo é fundamental para manter sistemas de saúde sustentáveis ao redor do mundo. Estabilizar o direito é fundamental para a sociedade. É certo que não há como se garantir uma estabilidade absoluta. Mas há como buscar uma estabilidade social. Que ultrapassa as fronteiras territoriais e precisa ser avaliada de forma globalizada. Cujas implementações cotidianas podem ser realizadas através de normatizações regulatórias técnicas, harmônicas e muito mais ágeis do que o processo legislativo regular de cada Estado-nação.

Normatividade como, por exemplo, as chamadas *softlaw* que, como já mencionado antes, são normas de regulamentação, *a priori* não vinculantes, adotadas por organizações internacionais, governos, agências reguladoras e outras entidades abordando uma variedade de questões técnicas.¹⁶⁶ Ou normas de regulamentação vinculantes como o é, na nossa interpretação, a DUDH conforme defendido no capítulo inaugural deste trabalho.

Trata-se de um ajuste na positividade do direito diante de um novo contexto de sociedade. Em que o direito assume um papel de guardião macrosocial. De orientação coletiva mínima de modo a atuar contra as desigualdades e equilibrar o poder econômico relacionado ao custo dos direitos, uma temática que será explorada em tópico futuro.

Nascem aqui, dois pontos de debate. O “intra muros” com as performances e melhorias dentro do Estado-nação. E o “extra muros”, que vai além das fronteiras formais. É a partir daqui que se avança mais um pouco nesta tese sobre o acesso à saúde das minorias raras através do presente e do futuro do direito à saúde.

A interação entre o acesso à saúde e o tempo resulta na necessidade de se estruturar o acesso à saúde de outra forma. Isto, para garantir condições sociais que, de forma individual, os Estados-nação falham, mas, coletivamente, poderiam ter sucesso diante do estreitamento transfronteiriço decorrente das novas tecnologias. O como fazer está em reconhecer o desenvolvimento da ciência e de uma sociedade cada vez mais digital. Admitir que o acesso à saúde também precisa evoluir nesse sentido.

¹⁶⁶ Sobre as *softlaw* vide DIOGO, Elysabete Acioli Monteiro. *Softlaw e a Sociedade da Informação*. São Paulo: Juruá, 2022.

Trata-se, pois, de uma experimentação do acesso à saúde de forma globalizada, tal qual a tecnologia realiza experimentações globalizadas. Vinculada a uma sociedade em constante transformação no tempo. Estruturar uma teoria do acesso à saúde de modo universal global para pacientes de doenças raras (e ultrarraras) é abrir caminho para um novo marco temporal que olha o presente-futuro. É experimentar uma nova condição institucional. É buscar privilegiar a vida e reduzir desigualdades em um contexto mundial.

O caráter dinâmico e inovador proposto é para abertura de um novo contexto na temporalidade do acesso à saúde, proporcionando igualdade social e equidade, em um direito social que demanda alto investimento de recursos, sejam materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis. Sem que esse investimento, contudo, afete um ou apenas poucos Estado-nação de modo desproporcional.

Estamos diante de uma coevolução da sociedade em que a lógica de progresso se alterou. Da linearidade evolutiva para uma teia de conexões e redes emaranhadas e entrelaçadas, com mais probabilidades de variações e transformações. Com maior velocidade e impacto. Que, por sua vez, geram maior investimento e custo em espaço de tempo cada vez menor. É essa interação entre tempo e acesso à saúde que muda toda uma lógica evolutiva da cidadania atrelada à saúde, do custo (ou seria investimento?) do direito à saúde e do impacto que esse “custo” traz em uma sociedade.

Nesse cenário em que o tempo e os custos relacionados ao acesso à saúde se entrelaçam em uma lógica de crescente complexidade, torna-se necessário considerar como as inovações tecnológicas impactam diretamente essa equação. A velocidade com que novas soluções surgem, associada às demandas sociais por respostas rápidas e eficazes, coloca em evidência a necessidade de instrumentos capazes de filtrar, analisar e orientar o uso racional dessas inovações. É nesse ponto que emerge a Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS, tema que será explorado a seguir.

2.3. Acesso à saúde através da avaliação de tecnologias em saúde

É sabido que todo indivíduo que cuida de sua saúde passa por consultas com profissionais da área da saúde que fazem um diagnóstico do quadro clínico e prescrevem um determinado tratamento, quando e se aplicável (e tudo isso tem um custo). Pois bem, é no contexto de diagnóstico e tratamento que estão as chamadas tecnologias em saúde, que vão desde os equipamentos, dispositivos e procedimentos médico-cirúrgicos, aos tratamentos medicamentosos.

Como já tratado anteriormente a evolução tecnológica no campo da saúde vem promovendo alterações estruturantes nas tecnologias em saúde, o que acaba por afetar a organização dos sistemas de saúde, especialmente em razão do leque de novas tecnologias, custo das tecnologias e a limitação de recursos existentes para fazer frente ao tema.

Em uma sociedade globalizada e altamente conectada, o conhecimento de novas tecnologias e os anseios pelo seu uso destas novidades ocorrem de forma cada vez mais rápida, especialmente quando um indivíduo deseja tomar alguma medida de tratamento e preservação de sua vida. Aqui temos um fato vivenciado cotidianamente, que é o anseio pelo imediatismo conforme abordado antes.

Assim, da mesma forma que surgem as tecnologias com alta eficácia e segurança, também brotam produtos que não possuem segurança e podem, inclusive, colocar a vida de um indivíduo e até de toda uma coletividade em risco. É o fato de o risco sanitário relacionado às tecnologias em saúde ser capaz de gerar severos impactos na coletividade que faz com que tecnologias em saúde estejam sujeitas à altos controles e regulamentação técnica específica.

Foi a partir de toda a lógica de risco inerente a assuntos sanitários e a necessidade de buscar resposta a esse avanço tecnológico que nasceu a chamada Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS, que se trata de um subsídio técnico contínuo para auxiliar a tomada de decisão relacionada à regulação e regulamentação do ciclo de vida das tecnologias em saúde e de programas e políticas em saúde.¹⁶⁷

ATS é, pois, um processo multidisciplinar que utiliza métodos explícitos para determinar o valor de uma tecnologia de saúde em diferentes pontos de seu ciclo de vida buscando, assim, orientar a tomada de decisão para o fim de se promover um sistema de saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade; uma ferramenta que tem evoluído ao longo dos anos, ganhando reconhecimento e tornando-se relevante para a produção de conhecimento e formulação de políticas de saúde.

No entanto e a despeito da ATS ser ferramental já usado por todos os sistemas de saúde dos países que participam da OCDE, a implementação da ATS como política de saúde ainda enfrenta desafios significativos no mundo. O motivo macro é a inexistência de uma harmonia ao processo de incorporação de tecnologias em saúde e nos programas de ATS entre os

¹⁶⁷ Para mais informações sobre a história da ATS, vide NOVAES, Hillegonda Maria Dutilh. *Da produção à avaliação de tecnologias dos sistemas de saúde: desafios do século XXI*. Revista de Saúde Pública. 2006; 40 (N Esp): 133-140. Vide, também, ROURKE, O. B., ORTWIJN, W., & SCHULLER, T. (2020). *The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration*. Int J Technol Assess Health Care, 36(3). 187–190.

Estados-nação. De forma mais específicas, a causa está nas divergências quanto a fatores de atuação, metodologia para avaliação, participantes do processo de ATS e tomadores de decisão.¹⁶⁸

Dentre as estratégias para se enfrentar estes desafios está a criação de organizações e agências de ATS ao redor do mundo, objetivando a institucionalização sistemática do tema.¹⁶⁹ Uma institucionalização que agrega o papel normativo ou consultivo a depender da normatividade interna de cada Estado-nação. Somente o decurso do tempo nos dirá se a estratégia foi (ou não) bem-sucedida diante do que teremos no mundo de harmonização (ou não) das ATS e agências de ATS.

2.4. Avaliação de tecnologias em saúde e a análise econômica da saúde

Como visto há pouco a ATS é um dos principais meios atuais de garantir ou negar o acesso à saúde no que diz respeito à incorporação, alteração e manutenção de tecnologias, programas, projetos e políticas de saúde, mais especificamente no âmbito da saúde pública. A realização de um estudo de ATS pressupõe definir o escopo, o prazo de execução, a justificativa do estudo, a metodologia e demais avaliações técnicas que serão performedo no estudo de modo a definir a abrangência e recorte das etapas do estudo.¹⁷⁰

Dentre estes recortes e avaliações técnicas no âmbito da ATS está o cálculo econômico, com análises comparativas para medir os custos e resultados de cada tecnologia. O objetivo principal dos cálculos econômicos é o de informar aos tomadores de decisão, que atuam na regulamentação do direito à saúde, sobre as vantagens e desvantagens de uma nova tecnologia em comparação com alternativas existentes para tanto.

Pode-se dizer que avaliação econômica seria uma comparação de diferentes intervenções, realizada através de um determinado método, objetivando uma análise

¹⁶⁸ Apenas a título de exemplo, nos Estados Unidos, a ATS é um processo altamente descentralizado, conduzido por uma série de stakeholders, incluindo agências governamentais, seguradoras e planos de saúde, entidades privadas com e sem fins lucrativos. No Brasil, o processo de ATS também é realizado por diferentes instituições e órgãos, tanto governamentais quanto não governamentais, contudo, tem seu processo centralizado na saúde pública pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e na saúde suplementar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

¹⁶⁹ O desenvolvimento das organizações de ATS e seu processo de institucionalização pode ser observado pela criação de redes e pelo progressivo aumento do número de agências membros. Cite-se, como exemplo, International Network of Agencies for Health Technology Assessment – INAHTA, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research – ISPOR, Health Technology Assessment International – HTAi; bem como as redes regionalizadas, como a Rede de Avaliação de Tecnologias das Américas – RedETSA, que agrega instituições da região das Américas, e a European Network for Health Technology Assessment – EUnetHTA, formada por organizações europeias de ATS.

¹⁷⁰ Khangura S. Konnyu K. Cushman R. Grimshaw JMD. *Evidence summaries: the evolution of a rapid review approach*. Syst Rev. 2012;Feb 10(1):10.

econômica entre diferentes tecnologias para auxiliar uma tomada de decisão em saúde que pode ir de medidas de prevenção, ao diagnóstico e até o tratamento de uma enfermidade.

Atualmente existem quatro principais tipos de análises econômicas em saúde – *custo-benefício*; *custo-minimização*; *custo-efetividade* e *custo-utilidade* – sendo que as análises de custo-efetividade e de custo-benefício são as de uso mais comuns no âmbito do direito à saúde.¹⁷¹ Apenas para fins didáticos e para a plena compreensão do leitor resume-se, a seguir, o que constitui cada uma destas quatro análises econômicas¹⁷² e que, em grandes linhas, se diferenciam pelas características de resultado e forma de mensurar o desfecho do estudo.

A Análise Custo-Benefício – ACB, é uma abordagem da avaliação econômica em que os resultados de tecnologias são expressos em unidades monetárias. Todos os efeitos de um tratamento ou tecnologia são quantificados em termos financeiros, permitindo a comparação direta com os custos.

O valor líquido de uma tecnologia, representado pela diferença entre benefícios e custos, determina sua viabilidade econômica. Se os benefícios superarem os custos, com valor líquido positivo, a adoção é economicamente justificada. Caso contrário, diz-se que é preferível buscar alternativas para os recursos financeiros.

Já a análise de custo-minimização – ACM envolve a comparação de custos entre diferentes tecnologias, visando escolher a opção de menor custo. Essa abordagem é um caso específico da análise custo-efetividade, em que os resultados ou benefícios das alternativas são considerados praticamente idênticos.

Embora seja difícil encontrar tecnologias com efeitos exatamente iguais, faz-se uma aproximação razoável de seus benefícios quando se supõe que os resultados se assemelham. Portanto, se aceitarmos a premissa de benefícios iguais, esta análise apresentaria as diferenças de custos entre as tecnologias, apontando a de menor custo.

¹⁷¹ A OMS vem aceitando a intervenção econômica relacionada ao custo-efetividade, com algumas ressalvas. Sobre o tema, vide WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Macroeconomics and health: investing in health for economic development*. Report of the Commission on Macroeconomics and Health. Geneva: World Health Organization, 2001. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/924154550X>. Acesso em: 16.01.2024.

¹⁷² Ao leitor que desejar se aprofundar nas diferentes abordagens e metodologias utilizadas na avaliação econômica de programas de saúde recomenda-se para leitura: DRUMMOND, Michael F.; SCULPHER, Mark J.; CLAXTON, Karl; STODDART, Greg L.; TORRANCE, George W. *Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes*. 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. Outras obras sobre o tema vide: GEORGE, Benjamin; HARRIS, Anthony; MITCHELL, Adrian. *Economic Evaluation of Public Health Interventions*. Sydney: Oxford University Press Australia, 2001; e, NUNES, Rui. *Economia da Saúde*. Lisboa: Edições Sílabo, 2013.

A análise custo-efetividade – ACE é um modelo no qual se examinam os custos e as consequências das tecnologias. Aqui se busca comparar a efetividade de diferentes tecnologias em relação aos custos associados, tendo como principal objetivo determinar quão eficientemente os recursos limitados podem ser alocados para maximizar os resultados em termos de saúde.

Esta análise calcula o custo por unidade de efetividade, permitindo a comparação entre diferentes opções de tratamento. O resultado é expresso como o custo ganho em anos de vida ou QALY.¹⁷³ Com isso, a abordagem ajuda a identificar quais intervenções oferecem melhor resultados em relação aos custos incorridos.¹⁷⁴

Trata-se de uma ferramenta adotada em diversos países, como se pode observar na leitura do subcapítulo o acesso à saúde no espaço. Como cada Estado-nação que faz o uso dessa ferramenta adota critérios segundo suas realidades próprias, a adoção de um valor específico QALY como referência global é tema controverso e não uniforme. Eis, aqui, um espaço de oportunidade para atuação das agências de ATS e, inclusive, da própria OMS.

A análise custo-utilidade – ACU é centrada na qualidade das consequências das tecnologias em saúde, ou seja, nos desfechos que a tecnologia proporciona. Com efeito, essa abordagem compara o custo incremental de uma tecnologia desde um determinado ponto de vista com o incremento de melhora da saúde atribuível ao mesmo, medida esta última em anos de vida ajustados por qualidade (QALYs).

Trata-se de uma evolução da metodologia de custo-efetividade por agregar a temática da qualidade de vida à quantidade de vida no cálculo, uma variável fundamental a ser considerada diante das diferenças de perfis demográficos existentes entre os Estados-nação.

Para melhor didática, o Quadro 1, a seguir, apresenta um resumo das principais metodologias de avaliação econômica em saúde, permitindo visualizar suas vantagens e limitações no contexto das doenças raras.

¹⁷³ QALY – *Quality-Adjusted Life Year* (Ano de Vida Ajustado pela Qualidade). De forma bem sumarizada para melhor compreensão do leitor, a *quantidade de vida* refere-se ao número de anos adicionais de vida proporcionados por uma intervenção de saúde e a *qualidade de vida* ao estado de saúde durante esses anos adicionais. A qualidade é medida em uma escala de 0 a 1, em que 1 representa um ano de vida em perfeita saúde e 0 representa a morte. Valores entre 0 e 1 representam estados de saúde intermediários, com 0.5 indicando, por exemplo, um ano de vida com uma qualidade de vida reduzida pela metade. Exemplo: Se uma intervenção médica proporciona 2 anos adicionais de vida com uma qualidade de vida de 0.8, isso resultaria em 1.6 QALYs (2 anos x 0.8 qualidade de vida).

¹⁷⁴ TOWSE, Adrian; PRITCHARD, Clive; DEVLIN, Nancy. *Costeffectiveness thresholds: Economic and ethical issues*. Londres: King's Fund and Office of Health Economics, 2002.

Quadro 1 - Quadro comparativo de metodologias de avaliação econômica em saúde

Metodologia	O que mede	Vantagem	Limitação
ACB	Valor monetário de custos e benefícios	Permite comparação ampla com outras áreas	Redução da saúde a valores monetários
ACE	Custos em relação a desfecho clínico (ex.: anos de vida ganhos)	Foco direto em saúde	Nem sempre captura qualidade de vida
ACM	Identifica opção mais barata entre alternativas igualmente eficazes	Simplicidade	Restrita: exige eficácia comprovada igual
ACU	Integra custo e qualidade de vida (QALY, DALY)	Captura impacto mais real no paciente	Complexidade e subjetividade das medidas

(Fonte: o autor)

No contexto evolutivo econômico da saúde, surgiu um item incremental. Trata-se do conceito de limite ao custo-efetividade proposto na década de 1970 por Weinstein e Zeckhauser, objetivando apresentar uma referência para o nível de custos e efeitos que uma tecnologia poderia alcançar para que pudesse ser aceitável em um dado sistema de saúde.¹⁷⁵

Este limite, noutras palavras, seria o máximo valor que uma determinada sociedade estaria disposta a investir para se obter um QALY ou um ano de vida com uma nova tecnologia em saúde, o que gera um intenso debate sobre os valores a serem aplicados e, inclusive, sobre a aplicação e limites.¹⁷⁶

Como dito antes, o custo-efetividade representa uma medida de desempenho e eficácia da tecnologia em saúde pautando-se na busca pelo aumento do tempo de vida com qualidade do ser humano. O limiar entra nesse contexto para definir um limite, ou seja, um teto para os custos de incorporação de tecnologias em saúde. Um teto que é decidido por representantes políticos e agentes públicos de forma não heterogênea e que detêm o poder decisório em suas mãos dentro das regras constitucionais de cada Estado-nação.

O valor deste teto é, geralmente, definido pelo PIB per capita. Isso significa que o acesso à saúde estaria limitado ao PIB de uma determinada região. Por óbvio, um ser humano que habita um país de baixo PIB terá menos acesso à saúde do que outro que habita um país de alto PIB. No caso das doenças raras isso pode significar, inclusive, a completa falta de acesso a depender da equação econômico-financeira estabelecida para este limiar. Essa é uma dura realidade que se relaciona diretamente com os custos dos direitos, mas, que pode se contrapor à princípios basilares como a dignidade humana.

¹⁷⁵ WEINSTEIN Milton; ZECKHAUSER Richard. *Critical ratios and efficient allocation*. Journal of Public Economic, Vol. 2, Issue 2, April 1973; Pg. 147–157.

¹⁷⁶ CHARLTON, Victoria. *The ethics of aggregation in cost-effectiveness analysis or, “on books, bookshelves, and budget impact”*. Frontiers in Health Services, Lausanne, v. 2, 13 out. 2022. Hypothesis and Theory. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frhs.2022.889423/full> Acesso em: 25 ago. 2025.

Independentemente de qual metodologia seja usada por um ou por outro Estado-nação que faça o uso da ATS e de limiares de custo-efetividade,¹⁷⁷ fato é que, cada vez mais, a precificação do acesso à saúde – que sempre ocorreu – vem sendo debatida pelos estudiosos. De forma mais técnica e mais transparente são definidos critérios metodológicos de aceite (ou não), de novas tecnologias no sistema de saúde de cada Estado-nação, especialmente nos sistemas de saúde que possuem característica universal.

Entretanto, este debate é nitidamente fruto dos conceitos do presente e do presente-passado e oriundo de um modelo utilitário; e, não, do presente-futuro. Sendo assim é um debate que não é capaz de solucionar os desafios contemporâneos de acesso à saúde, ainda mais no contexto das doenças raras. Não se quer dizer, aqui, que a ATS deva ser completamente descartada. Ao contrário, ATS é um elemento importante na sistemática de estudo de acesso às tecnologias em saúde.

O que se coloca em perspectiva, pois, é que as análises deveriam fugir das interpretações extremadas e dicotômicas, que contrapõem a proteção e acesso à saúde ao custo dos direitos. Que se deve buscar um equilíbrio entre análises econômicas e fenômenos sociais, jurídicos e éticos.

Até porque não se encontra, nestas análises, todos os demais custos indiretos que as doenças raras trazem ao sistema social como, a título de exemplo, a perda de produtividade laboral, absenteísmos com afastamento por licenças médicas e redução da renda familiar. São eventos que impactam de alguma forma a sociedade (ex.: previdência social) e o custo total de administração e gestão da máquina estatal.

Como já dito antes, o debate em torno das doenças raras vai além do acesso ao diagnóstico e tratamento. Envolve integração, estudos, harmonização, dimensionamento de

¹⁷⁷ Aos que tiverem interesse em saber mais sobre o uso de limiares de custo-efetividade nas decisões em saúde pública no Brasil, vide Ministério da Saúde. *O Uso de Limiares de Custo-Efetividade nas Decisões em Saúde*. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde. Brasília – DF, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/artigos_publicacoes/20211202_relatorio_oficina_limiares.pdf. Acesso em 16.1.2024. Em uma crítica ao tema, vide CALLEGARI, Isabela. *Uso de Limiares de Custo-Efetividade nas Decisões em Saúde: recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS*. Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento (IFFD). Policy Note n. 4. Brasil, julho de 2022.

demanda real para se evitar desperdícios e aprimorar a sustentabilidade de recursos ao redor do mundo. Diante dessa complexidade, percebe-se que a análise do acesso à saúde não pode se restringir a métricas econômicas ou interpretações dicotômicas sobre custo versus benefício. É necessário considerar a multiplicidade de impactos indiretos, tais como, sociais, laborais, familiares e institucionais, que transcendem o simples investimento financeiro em diagnóstico e tratamento.

Ao expandir o olhar para essa diversidade de efeitos e interações evidencia-se que o acesso à saúde deve ser compreendido de forma plural, incorporando dimensões que vão além das fronteiras dos Estados e dos limites tradicionais do direito, preparando o terreno para uma abordagem que dialogue com a digitalização, as redes de conhecimento e a inovação tecnológica.

2.5. Acesso à saúde e a pluralidade

A digitalização da saúde, as atuais conexões em rede e a inovação tecnológica de diagnósticos e tratamentos à saúde transcendem as fronteiras, competências e limites territoriais dos Estados-nação. Estes novos eventos e fatos não estão mais ligados à essência pura do direito internacional que está centrado no Estado-nação. São fatos e eventos que ultrapassam a dicotomia classificatória de direito internacional público e privado.¹⁷⁸ Também moldam novas formas de administração das sociedades.

Não é objetivo deste trabalho aprofundar a literatura sobre o direito transnacional que, a partir dos ensaios de Philip C. Jessup,¹⁷⁹ passou a ser debatido e pesquisado de forma mais intensa. Entretanto, não há como deixar de lembrar que, é a partir de conceitos da transnacionalidade que surge a abordagem do pluralismo jurídico utilizado com intensidade normativa transnacional. E essa relação importa para este trabalho.

¹⁷⁸ É muito comum nos estudos jurídicos a classificação do direito em áreas de especialização, ou temáticas. Dentre estas está o chamado direito internacional público que regula as relações entre Estados soberanos e organizações internacionais, ao passo que o chamado direito internacional privado trata das disputas legais transfronteiriças envolvendo indivíduos, empresas e outros atores privados. Sobre o tema, vide REZEK, José Francisco. *O Direito Internacional No Século XXI: Textos Fundamentais*. Saraiva, 2002.

¹⁷⁹ Sobre o tema, vide JESSUP, Philip C. *Transnational Law*. New Haven, 1959. O autor explora como o aumento da interconexão entre Estados e a globalização influenciam a prática jurídica, levando a uma crescente necessidade de cooperação e harmonização legal em escala internacional. Examinando desafios e oportunidades apresentados pelo direito transnacional, o texto destaca a importância da cooperação internacional e da criação de mecanismos eficazes para lidar com questões legais globais.

Também importa a este trabalho parte dos debates sobre a estipulação teórica de um direito administrativo global,¹⁸⁰ uma vez que tratar do acesso à saúde é tratar de matéria de cunho administrativo, no conceito mais amplo de um tema de administração realizada *interna corporis* pelos países ao redor do mundo. Todavia, vale reforçar que aqui interessará os pontos de eventual convergência entre este trabalho e as teorias do direito administrativo global.

O motivo é que a diversidade e o pluralismo melhor se aproximam das bases desta pesquisa do que o direito administrativo global. A uma, pois um direito administrativo é um tema de construção ocidental oriundo do final do século 19 como instrumento de controle do poder público, mas, aqui, nos interessa temas convergentes entre ocidente e oriente; a duas, o valor central do direito administrativo está na ideia de que os Governos são limitados pelas normas que cercam a territorialidade do Estado e, ainda, nas disposições do que chamamos de comando e controle, ou seja, decisões centralizadas de autoridades com informações e ordens que fluem em uma comunicação vertical e rígida.¹⁸¹

Já o pluralismo jurídico pode ser entendido como a convivência de diferentes ordenamentos jurídicos válidos, de modo concomitante, em um determinado tempo e espaço. Trata-se, a bem da verdade, de fenômeno antropológico e sociológico que expõe a complexidade e multiplicidade das relações humanas e das relações comunitárias. Emerge deste complexo tecido social como alternativa legítima para suprir lacunas que o direito estatal não conseguiu alcançar.¹⁸²

Composto pela diversidade de normas sociais de forma simultânea, o pluralismo jurídico é o antagonismo ao monismo jurídico, que se caracteriza pelo monopólio e concentração de normas jurídicas exercidas pelo Estado. É reflexo da inefetiva atuação do Estado na implementação de políticas públicas e sociais, em especial frente a grupos vulneráveis. Também é reflexo da história político-constitucional de alguns Estados-nação

¹⁸⁰ Este debate foi lançado por um grupo de professores e estudiosos da Universidade de Nova York. Datado de 2003, o “*Project Overview Article*” dos pesquisadores foi publicado em 2005 e desde então passou por uma série de mesas redondas, conferências e seminários em diferentes continentes ao redor do mundo. Em uma dinâmica de trabalho estruturada em uma rede interconectada para o fomento da discussão e debates sobre o tema. Para maiores informações sobre o direito administrativo global, vide: CASSESE, Sabino. *Administrative Law without the state? The challenge of global regulation*. New York University Journal of International Law and Politics 37(4): 663- 694, 2005.; Outras referências: KINGSBURY, Benedict. *The Concept of ‘Law’ in Global Administrative Law*, The European Journal of International Law, v. 20, n. 1, p. 23-57, feb. 2009. ARANA, Jaime Rodríguez. *El derecho administrativo global: un derecho principal*. Revista Andaluza de Administración Pública, Sevilla, n. 76, p. 15-68, jan./abr. 2010.

¹⁸¹ Sobre o comando e controle, vide NASSIF, M.M. Instituições de controle e corrupção na nova lei de licitações e contratos administrativos. In *Debates contemporâneos em Direito* – Vol. 4. Org. FERREIRA, Pedro Paulo da Cunha. São Paulo: Editora Dialética, 2023.

¹⁸² WOLKMER, Antonio Carlos. *Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito*. Alfa Omega, 2001.

marcadas por evoluções e retrocessos que beneficiaram restrita parte de uma sociedade que é detentora de poder nas fronteiras internas de um Estado-nação.

Essa visão plural permite a criação de mais espaço à atividade normativa dos mercados globais e seus atores e, a longo prazo, promove uma perspectiva funcional de mecanismos de governança que podem – eventualmente – vir a substituir funções administrativas que hoje apenas o Estado exerce. Situação que pode, inclusive, gerar ganhos em escalas para os Estados.

O pluralismo jurídico busca a coexistência de diversos sistemas jurídicos em um mesmo espaço político, tendo como requisito único para sua legitimidade e validade a existência de áreas e espaços sociais descentralizados e participativos. Espaços que buscam interesses comuns e aspirações sociais para satisfação de direitos e necessidades fundamentais. Trata-se de uma fragmentação dos interesses sociais.¹⁸³

Já algum tempo que o debate do pluralismo jurídico ultrapassa as barreiras dos ordenamentos normativos locais de um Estado-nação incluindo, também, a coexistência dos ordenamentos jurídicos transnacionais e supraestatais que coexistem no sistema de normas global.¹⁸⁴ Apesar das críticas existentes ao pluralismo jurídico,¹⁸⁵ fato é que na atualidade do processo civilizatório globalizado, com rupturas e constante quebras de paradigmas, o pluralismo jurídico vem sendo utilizado com intensidade normativa transnacional.

Esse pluralismo normativo se relaciona com o acesso ao direito à saúde de diversas formas. Da DUDH às normas de direito comunitário de determinadas regiões. Dos pactos e tratados internacionais às Constituições de cada Estado-nação. Das legislações infraconstitucionais às regulamentações internas relacionadas a distintos entes estatais e não estatais.

A pluralidade normativa está cada vez mais presente nos sistemas de saúde e, portanto, no acesso à saúde. Em debates éticos e jurídicos sobre o uso da ciência e da medicina para

¹⁸³ SARTORI, Giovanni. *A Teoria da Democracia Revisitada*. v.1, São Paulo: Ática, 1994. p.126-127: “só as eleições manifestam um “consenso geral”, (...). Inversamente, as vozes que se fazem ouvir acima e além das eleições são as vozes da elite ou das minorias; são vozes de uma parcela do povo, em geral, uma parcela muito pequena

¹⁸⁴ SANTOS, Boaventura de Souza; GARCIA Mauricio Villegas (eds). *El caleidoscopio de las justicias em Colombia*. Bogotá: Univ. Nacional/Univ. De los Andes. Siglo de Hombre Editores, 2001. p.139.

¹⁸⁵ REALE, Miguel. *Teoria do direito e do estado*. São Paulo: 1984. p.246-263, que defende que o pluralismo não é tão diferente do monismo jurídico argumentando que, ao agregar tendências políticas e filosóficas de diversas origens, estas acabam contrastando-se entre si e assumem uma gradação na positividade jurídica que é parte integrante do monismo jurídico.

fins de melhoramentos genéticos,¹⁸⁶ no uso de informação em projetos relacionados ao uso de genoma humano,¹⁸⁷ nas reflexões sobre os limites da vida e de uma morte digna,¹⁸⁸ dentre outros. São debates regionais ou globais em que a pluralidade normativa atua para regulamentar, certos temas, antes do direito interno de cada Estado-nação.

No subcapítulo em se tratou sobre o acesso à saúde no espaço foi possível observar como ocorre o acesso à saúde em diversos Estado-nação e concluir que, a despeito da cultura normativa interna de cada país para tratar o acesso à saúde dentro de suas fronteiras, existem diversos pontos que se correlacionam entre os distintos sistemas de saúde de cada Estado-nação; alguns mais, outros menos. De qualquer modo, são pontos que se conectam com a pluralidade jurídica transnacional.

A correlação de sistemas aliada a digitalização da saúde, as atuais conexões em rede e a inovação tecnológica de diagnósticos e tratamentos à saúde permite avançar neste trabalho como uma proposta das ideias de uma melhor promoção ao diagnóstico e tratamento de doenças raras no contexto da universalidade defendida pela DUDH, conforme as propostas da OMS que foram acatadas pelos países que integram a ONU.

Uma universalidade que permita enfrentar desafios e injustiças que podem ser remediáveis de forma coletiva e benéfica para grande parte da sociedade global. Não se trata de uniformizar sistemas de saúde, mas, a partir de desafios e pontos harmônicos entre sistemas de distintos Estado-nação, traçar uma ideia de acesso ao diagnóstico e tratamento de doenças raras com pluralidade e normatividade global. Tendo o ser humano – a vida – como o principal bem tutelado e, ao mesmo tempo, buscando a sustentabilidade dos sistemas de saúde dos Estados-nação e reduzindo desigualdades sociais globais.

Quando uma nova dinâmica mundial social de conexão rompe com conceitos políticos-jurídicos tradicionais, a lógica desta estruturação também passa a ser colocada sob suspeita. A lógica da ciência em rede e uma sociedade conectada não poderia – ou ao menos

¹⁸⁶ SANDEL, Michael. (2013). p. 111: “Ao me opor ao melhoramento genético, argumentei contra o triunfo unilateral do domínio sobre a reverência e insisti que voltássemos a valorizar a vida como uma dádiva. Entretanto, também argumentei que existe uma diferença entre curar e melhorar. A medicina intervém na natureza, mas, por estar limitada pelo objeto de restaurar o funcionamento humano normal, não representa um ato de *hybris* desenfreada nem um apelo de dominação. A necessidade de curar vem do fato de que o mundo não é perfeito e completo, mas necessita constantemente da intervenção e reparação humanas. Nem tudo que nos é dado é bom. A varíola e a malária não são dádivas e seria bom erradicá-las. O mesmo vale para a diabetes, o mal de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica e as lesões medulares. (...)”.

¹⁸⁷ LUNA, Florencia; LÓPEZ, Eduardo Rivera (comps.). *Los desafíos éticos de la genética humana*. México: Fondo de Cultura Económica, 2005. p. 339-363.

¹⁸⁸ PESSINI, Leo. *Dignidade humana nos limites da vida: reflexões éticas a partir do caso Terri Schiavo*. Bioética, 2005, Vol. 13, nº 2, p. 65-76. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/108/113. Acesso em 18.01.2023.

não deveria – fazer com que um jogo de poder econômico reduzisse ou criasse desigualdades frente à vida.

Ao contrário, toda essa lógica deveria buscar uma equalização da acessibilidade sem constituir um custo maior para um determinado Estado-nação e menor para um outro, especialmente quando tratamos de minorias ou grupos vulneráveis.

A mudança não deve e não pode ser entendida como um programa normativo global. Trata-se de um particular processo social oriundo da evolução da sociedade e da cidadania e que precisa ser priorizado ante o fato de estamos tratando do direito à vida do ser humano.¹⁸⁹ A concretude pode formar-se a partir de uma verdadeira cooperação entre Estados-nação com o objetivo de estruturar um sistema de equilíbrio que possa garantir o acesso à saúde por minorias, equilibrando o custo que esse direito representa para cada Estado-nação e mantendo uma união social em ordem global, diante do colapso dos sistemas de saúde comprovados com a crise pandêmica da covid-19.

As dinâmicas sociais estão cada vez mais descentralizadas e impessoais. A conexão em redes e o contato entre sociedades diversas ao redor do mundo, os processos de imigração, consumo interconectado e inovação tecnológica não mais permitem que as dinâmicas sociais fiquem restritas as fronteiras de cada Estado-nação e não mais permite controlarmos os impactos desta abertura na saúde. Estrangeiros veem ao Brasil para usar o sistema de saúde público do país. O mesmo ocorre em outros países. Existe um custo que é pago por este Estado-nação em favor de um cidadão de outro Estado-nação e o é como ideal de justiça de direito à vida.

O estabelecimento de interações comunitárias já demonstra isso. Na covid-19, foi a atuação conjunta da Comunidade Europeia nas alocações em saúde em cada Estado-nação que permitiu ao bloco enfrentar a covid-19. Sem esse financiamento alguns países não teriam a capacidade de fazê-lo de forma isolada. O mesmo ocorreu em países mais pobres do continente Africano e, também, na Ásia e América Latina.

A realidade está posta. Extrapolar essa interação global é desafio político e jurídico. No campo jurídico, a atuação de forma dispersiva da sociedade permite que o direito tenha uma certa textura aberta e que não se destina tão somente a gerar e estabelecer regras

¹⁸⁹ AITH, Fernando; BODRA, Maria Eugenia F do Amaral. *Global Health and Economic Law: Private sector regulation on the global agenda*. Revista Brasileira de Política Internacional (online), v. 65, n. 1, art. e008 [17], 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpi/a/hKkqj455k9hBLTFpgNqdvBv/?format=pdf&lang=en>. Acesso em 20.08.2024.

vinculantes ou construir direitos e deveres. Desta dispersividade brota uma significativa mudança entre a soberania estatal e as redes de conexão como um novo tipo de gestão social.

O acesso à saúde precisa se compatibilizar com o aumento da complexidade das relações sociais mundiais e da inovação. Isso não quer dizer que temos de alterar o Estado-nação como uma pessoa jurídica soberana, até porque talvez isso seja impossível no jogo político e de poder mundial que existe há séculos (e talvez nunca deixe de existir) e que ainda é capaz de promover conflitos por soberania territorial, sejam estes conflitos denominados de guerra ou não, como Rússia-Ucrânia; Coreia do Norte-Sul; Israel-Palestina; Venezuela-Guiana, dentre outros.

Ou talvez até seja possível em razão do impacto e consequências ainda não mensuráveis das mudanças sociais e de poder oriundas da tecnologia e da geração massiva de dados, uso dos dados e da inteligência artificial e controle de poder a partir de dados reais ou manipulados. De qualquer forma, a tese que aqui se propõe visa respeitar as diferenças estatais existentes e, portanto, a soberania¹⁹⁰ de cada Estado-nação.

De qualquer forma, o aumento da complexidade social mostra que determinados temas impescindem de serem enfrentados apenas dentro das linhas geográficas de poder de um Estado-nação. Eles transbordam na complexidade de uma sociedade global que pode chegar a um compromisso com seus problemas e soluções. São processados de modo distinto. Em rede e em organizações. Em uma pluralidade e com diversidade.

E a operacionalização desse compromisso pode ocorrer a partir da especificação (1) do público regulado, que são as raridades, (2) da especificação das entidades (não limitadas aos Estados), que exercem uma grande influência regulatória no tema e (3) do aceite participativo do Estado-nação de que esse pluralismo tende a ser mais eficiente, menos custoso e, ainda, tende a auxiliar na redução de desigualdades e fomentar a equidade.

São relações – entre o *Público*, *Entidades* e *Estado* – que podem ser ajustadas de distintas formas já que o acesso à saúde e avanço científico-tecnológico se relacionam, entrelaçam e se conectam em forma de uma rede complexa. Se intensificam com o aumento das organizações plurais ao redor do mundo. E, nesta trilha que se percorre, o acesso à saúde

¹⁹⁰ Um Estado se diferencia das demais pessoas, justamente em virtude da soberania que lhe é inerente. Trata-se, a soberania, da faculdade suprema num dado ordenamento normativo e que detém o poder absoluto, acima de todo e qualquer outro poder. O Estado é reconhecido como a única instituição soberana, até o momento. Para um maior debate sobre soberania, vide BERCOVICI, Gilberto. *Soberania e Constituição: Por uma crítica do constitucionalismo*. 3ª Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2020. p. 18-29.

se conecta com a pluralidade e fomenta o debate sobre uma criação sistêmica de acesso à saúde em uma perspectiva global.

Em síntese, o acesso à saúde revela-se como um fenômeno complexo, marcado pela inter-relação entre espaço, tempo, tecnologia, custos sociais e econômicos, além da atuação de múltiplos atores em contexto plural e transnacional. Diante dessa complexidade, o direito à saúde não pode – ao menos não deveria – se limitar a normas abstratas. Assim, reconhece-se o acesso à saúde como a dimensão que permite a fruição do direito à saúde, cuja efetividade depende de sua articulação com critérios normativos capazes de lhe conferir densidade prática.

Sendo o acesso à saúde o garantidor do direito à saúde, cabe ao direito, enquanto sistema normativo, estruturar as condições de sua concretização institucional. Compreender o acesso à saúde exige analisar sua pluralidade de dimensões e reconhecer os limites estruturais que condicionam sua realização. É nesse ponto que o direito assume protagonismo: diante da escassez de recursos e do custo dos direitos sociais, cabe ao direito estabelecer parâmetros, tema que será trabalhado no capítulo seguinte.

3. PAPEL DO DIREITO NO ACESSO À SAÚDE

"In a democracy, the highest office is the office of citizen."

Cass R. Sunstein

Já foi dito que, para fins desta pesquisa, o direito à saúde é reconhecido internacionalmente como um direito humano básico, consagrado na DUDH. Neste contexto explicou-se que o direito à saúde implica que todos os indivíduos tenham direito a buscar os serviços de saúde, independentemente de sua condição socioeconômica, raça, gênero ou qualquer outra característica.

A normatividade universal relacionada ao direito à saúde não apenas estabelece normas para a prestação de serviços médicos em geral, mas, também, proíbe discriminação e objetiva assegurar a participação ativa dos cidadãos no processo de tomada de decisões relacionadas à saúde.¹⁹¹

Todo este contexto nos mostra que o direito desempenha um papel crucial na definição e implementação de políticas públicas que visam melhorar o acesso à saúde. Isso inclui a criação de programas de saúde preventiva, a decisão sobre alocação de recursos e a implementação de medidas para combater as disparidades no acesso aos cuidados em saúde.

A chamada judicialização da saúde também é uma ferramenta utilizada para garantir que as pessoas tenham acesso a tratamentos e medicamentos essenciais, quando e se necessário. Quando há falhas nas políticas de saúde é o Poder Judiciário (se e quando existente) que atua como um instrumento fundamental e viabilizador do direito à saúde.

Para melhor compreender o papel do direito no acesso à saúde este capítulo tratará sobre o custo dos direitos relacionando-o com a temática da avaliação de tecnologias em saúde e a análise econômica da saúde que foi tratado no capítulo anterior. Em seguida, explorará a

¹⁹¹ DHDU. Artigo 21. "Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto." | Artigo 25. "Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade."

necessidade de se conceituar o acesso à saúde como um princípio que integra o direito (em sentido amplo), além do papel dos Tribunais na garantia do acesso à saúde.

3.1. Escassez de recursos e o custo dos direitos

Um bom sistema de saúde – acessível, eficaz e eficiente – desempenha papel fundamental na promoção do bem-estar social e no desenvolvimento de uma sociedade. Essa importância social dos sistemas de saúde pode ser abordada de maneiras diversas que vão desde a proteção da saúde de um determinado indivíduo até a estabilidade social e política de um determinado Estado-nação.¹⁹²

Um sistema de saúde focado em atenção primária e que oferece serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação auxilia na prevenção de doenças, promove estilos de vida mais ou menos saudáveis, trata condições clínicas e contribui para a melhoria da expectativa de vida e a redução da morbidade e mortalidade.

Este mesmo sistema traz uma segurança financeira aos indivíduos e seu entorno, protegendo-os contra custos exorbitantes e imprevisíveis nos cuidados de saúde. Esta segurança financeira auxilia no desenvolvimento econômico da população vez que, uma população mais saudável é – teoricamente – mais produtiva e enseja menos custos sociais e econômicos ao sistema social (ex: de saúde e previdência), de um determinado Estado.¹⁹³

Todo esse contexto enseja a necessidade de se buscar, cada vez mais, a sustentabilidade de um sistema de saúde que esteja preparado para emergências e crises e, ainda, que seja preventivo, ágil e equânime.¹⁹⁴ Uma preparação para passar por crises como a vivenciada na pandemia da Covid-19 que, ao mesmo tempo, mostrou a solidez de alguns sistemas de saúde ao redor do mundo e a vulnerabilidade de outros sistemas. Vulnerabilidade que, por sua vez,

¹⁹² RAMOS, Carmen; ALVAR GONZÁLEZ, Mercedes, e MORENO, Blanca. *Factores determinantes de la reducción de la desigualdad en la distribución de la renta en países de América Latina*. Revista CEPAL, No. 126, Diciembre 2018. Neste artigo, as professoras da Universidade de Oviedo, na Espanha, analisam a desigualdade de renda na América Latina entre 2004 e 2013. Usando um modelo econômico as autoras mostram como fatores como PIB per capita, gastos em saúde, dentre outros, influenciam na desigualdade dos países.

¹⁹³ NASSIF, Murilo Meneghetti. *Entre tribunais e hospitais: o descompasso do acesso à saúde*. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/entre-tribunais-e-hospitais-o-descompasso-do-acesso-a-saude>. Acesso em 23.09.2025.

¹⁹⁴ ALMEIDA, Verônica Scriptore Freire; AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal; LAMY, Marcelo (coord.). *O direito da saúde na era pós-Covid-19*. Coimbra: Almedina, 2021. Nesta obra os autores ajudam a refletir como o direito da saúde deve se ajustar num cenário em que pandemias não sejam mais vistas como exceções, mas como riscos reais com implicações jurídicas sérias, propondo uma base para políticas mais resiliente, com melhor estrutura normativa, transparência, participação social, equidade.

teve e ainda tem o condão de aumentar a desigualdade social e até ocasionar instabilidade política e social.¹⁹⁵

Enfim, a conclusão é lógica: é plenamente aceitável afirmar que um sistema de saúde robusto contribui para o desenvolvimento de um Estado-nação e, da mesma forma, para a estabilidade política e social de um determinado local. Mas, para que haja robustez de um sistema é imprescindível o investimento em recursos materiais e imateriais. Ou seja, existe um custo a ser pago. Se existe um custo a ser pago por um sistema que forneça o direito à saúde é indiscutível que existe um preço que a sociedade está disposta a pagar para proporcionar uma vida digna e com qualidade para os cidadãos desta sociedade.

A realidade de que existe um preço para se ter um padrão de qualidade de vida e que certamente nos incomoda como seres humanos é uma temática que está sendo, cada vez mais, incorporada ao dia a dia dos debates jurídicos no âmbito acadêmico e prático através da chamada AED – Análise Econômica do Direito.¹⁹⁶

AED nada mais é do que a introdução de métodos de normatização e tomada de decisão ao direito mediante instrumental analítico, pragmático e com abordagens consequencialistas que traz à ciência jurídica a possibilidade de avaliar normas e decisões não apenas sob a ótica da validade formal ou da justiça abstrata, mas, também, sob seus efeitos concretos na eficiência, nos incentivos e no bem-estar social.

A pergunta que alguns leitores farão é: por qual razão precificar o custo em saúde para uma vida e analisar o direito de forma pragmática, com esse chamado viés “econômico”? A razão é a que já foi trazida antes: para cada direito criado existe um custo a ser pago, ou seja, existe a necessidade de se utilizar recursos para executar e garantir este direito que foi criado. São recursos que, por sua vez, tendem a ser escassos e finitos¹⁹⁷ conforme o espaço e o tempo em que os recursos se encontram.

¹⁹⁵ Foi a partir da crise pandêmica da Covid-19 que o Equador passou a sofrer de forma mais intensa uma forte instabilidade social e política. A falta de solução de problemas estruturais foi ampliada com a crise sanitária trazendo grande vulnerabilidade ao país e culminando em conflitos armados internos a partir do começo de 2024. Trata-se de um cenário que também pode ser encontrado em outros Estados-nação ao redor do mundo. Sobre o tema, CASTRO, Fabio Sousa Mendonça de; FUSER, Igor. *Bolívia em tempo de pandemia: crise humanitária e conflito político*. Intellèctus, 20(2), 2021. p.50–77; ARAUJO, Flavia Loss de; NEVES, Bárbara Carvalho. *Regionalismo, crise venezuelana e a pandemia do COVID-19: o impacto da fragmentação regional no cenário atual (2013-2020)*. Conjuntura Austral, 12(58), 2021. p19–37.

¹⁹⁶ Sobre a análise econômica do direito vide: TIMM, Luciano Benetti (coord.) *Direito e Economia no Brasil: estudos sobre a análise econômica do direito* - 5ª ed. – Indaiatuba/SP: Ed. Foco, 2023. CHARNOVITZ, Steve. *What is international economic law?* Journal of International Economic Law, v. 14, n. 1, 2014. p.3-22. CARREAU, Dominique; FLORY, Thiébault; JULLIARD, Patrick. *Droit international économique*. Paris: Persée, 1990.

¹⁹⁷ ELSTER, Jon. *Local Justice*. New York: Russel Sage Foundation, 1992, p.21: “Dizer que um bem é escasso significa que não há o suficiente para satisfazer a todos”.

Mas, o que seriam os recursos escassos e o custo dos direitos? A escassez de recursos refere-se à limitação dos recursos disponíveis em relação às demandas e necessidades existentes ao passo que o custo dos direitos se refere aos recursos necessários para garantir e implementar direitos existentes.¹⁹⁸

Quando se diz que os recursos são finitos, significa dizer que não é possível atender plenamente todas as demandas e desejos. Isto, porque, quando há escassez de recursos é natural que surja uma tensão entre a garantia dos direitos e a capacidade de atendê-los plenamente. A alocação de recursos limitados implica fazer escolhas difíceis sobre como e para quem esses recursos serão distribuídos. Isso pode resultar em situações em que é necessário priorizar certos direitos em detrimento de outros, ou em que nem todos os indivíduos podem ter acesso pleno aos direitos estabelecidos.

Já o custo dos direitos, como dito antes, refere-se aos recursos necessários para garantir e implementar direitos existentes. Isso inclui os investimentos financeiros, humanos e institucionais necessários para garantir o acesso aos serviços, programas e infraestrutura que sustentam a realização dos direitos.

Toda tecnologia em saúde possui um custo, ou seja, há custo em todos os esforços para prover um sistema de saúde a ser disponibilizado ao cidadão. Programas de saúde e bem-estar também possuem um custo. Com efeito, o direito à saúde e o acesso à saúde possuem um custo, sendo que, em um contexto de escassez de recursos, o custo destes direitos é um fator importante a ser considerado nas decisões de alocação de recursos e na formulação de políticas públicas de um Estado-nação.

É aqui que entram os desafios dos Estados-nação para equilibrarem as demandas dos direitos com a realidade dos recursos disponíveis, buscando maximizar o impacto dos recursos limitados para garantir o cumprimento dos direitos. É aqui que entram as decisões políticas que estão sujeitas, nos países democráticos, ao crivo do Poder Judiciário que caberá interpretá-las com base no direito posto no espaço e local de sua aplicação.

Para tratarmos da temática de recursos escassos e finitos vis a vis o custo dos direitos referencia-se como fonte de pesquisa a obra de Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, denominada “The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes.”¹⁹⁹

¹⁹⁸ HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. *O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos*. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla – São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2019.

¹⁹⁹ HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. *O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos*. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla – São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2019.

Explicam os autores que “todo dia, toda hora, catástrofes privadas são evitadas e mitigadas por gastos públicos que às vezes são grandes e às vezes enormes, mas que nem sempre são reconhecidos”²⁰⁰ e que “os direitos e liberdades dependem fundamentalmente de uma ação vigorosa do Estado”,²⁰¹ uma vez que “os direitos custam dinheiro e não podem ser protegidos nem garantidos sem financiamento e apoio públicos”.²⁰²

A partir destas premissas os autores definem a expressão “custo dos direitos” como:

(...) uma expressão rica e ambígua, pois as palavras são dotadas de significados múltiplos e inevitavelmente controversos. Para que esta análise se mantenha tão centrada e – nesta dimensão – tão pouco controversa quanto possível, entenderemos “custo” aqui como *custo orçamentário*, e “direitos” como *interesses importantes que possam ser protegidos de modo confiável por indivíduos ou grupos mediante o uso dos instrumentos disponibilizados pelo Estado*.²⁰³

Estes “interesses importantes” que devem ser protegidos estão relacionados com um direito constituído, ou seja, um direito descritivo que é dotado de eficácia. Um direito descritivo que uma determinada sociedade visa proteger através do seu organizado sistema político e jurídico. Portanto, estes “interesses importantes” não se relacionam com o conceito de direito que está associado a princípios e ideais morais e que, segundo os autores, seriam meras aspirações e não dotadas de eficácia.

Noutras palavras, o argumento da obra é no sentido de que, quando se trata de direitos constituídos, que são os chamados “interesses importantes”, é imprescindível considerar: (i) os custos e benefícios associados ao exercício desses direitos; e, (ii) se os benefícios de determinados direitos superam os custos envolvidos, especialmente quando há impactos negativos para outras pessoas ou para o bem-estar coletivo.

A teoria defendida pelos autores tem como premissa a existência de uma estrutura estatal que é permanente para garantir os direitos e que, portanto, quaisquer direitos representam o Estado, ou seja, a própria sociedade. A conclusão dos autores é de racionalidade e lógica no sentido de que direitos somente existirão quando e se atrelados a um fluxo financeiro e orçamentário.²⁰⁴

Trata-se de um olhar empírico, concreto, pragmático e consequencialista. O oposto dos conceitos jurídicos indeterminados, abstratos e principiológicos. Este olhar que os autores nos

²⁰⁰ ____p. 4.

²⁰¹ ____p. 4.

²⁰² ____p. 5. E para maior detalhe do leitor: “À verdade óbvia de que os direitos dependem do governo, ou seja, do Estado, deve-se acrescentar uma consequência lógica rica em implicações: os direitos custam dinheiro e não podem ser protegidos nem garantidos sem financiamento e sem apoio públicos. (...) Todos os direitos impõem exigências ao tesouro público.”

²⁰³ ____p. 5.

²⁰⁴ GALDINO, Flávio. *Introdução à teoria dos custos dos direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.204.

apresentam está diretamente relacionado com o custo do acesso à saúde e dignidade da vida que vimos no segunda capítulo ao abordar avaliação de tecnologias em saúde e a análise econômica da saúde (ex.: custo-efetividade e os mais recentes limiares para o investimento de recursos em saúde), que trata de estudos pragmáticos e econômicos sobre o acesso à saúde.

Essa concretude que apresenta o custo orçamentário relacionado ao exercício do direito é demasiadamente polêmica. Aliás, todo debate que vincula direitos a custos ou orçamento é polêmico e, portanto, é alvo de críticas que argumentarão que essa abordagem é excessivamente utilitarista. Isto, porque, coloca demasiado peso nos custos e benefícios econômicos em detrimento dos direitos fundamentais e da dignidade humana.²⁰⁵

O principal argumento alegado nestas críticas é de que a abordagem do custo dos direitos pode minar a importância da proteção constitucional e a primazia dos direitos individuais na tomada de decisões políticas. Especialmente pelo fato de que existem custos orçamentários que vão além dos custos sociais.

Estes custos orçamentários que vão além dos custos sociais é exatamente o que foi escrito há pouco, quando mencionou-se que um bom sistema de saúde desempenha papel fundamental na promoção do bem-estar social, no desenvolvimento de uma sociedade e na própria estabilidade social e política de um determinado Estado-nação.²⁰⁶ Este argumento provém de empirismo.²⁰⁷

Apesar das críticas feitas aos autores, a importância deste custo, que vai além do social, foi em parte reconhecida na teoria de Holmes e Sustain. Sobre o tema, assim argumentam na obra:

Alguns direitos, embora sejam manifestamente custosos, aumentam a tal ponto a riqueza social tributável que se pode considerar que financiam a si mesmos. (...). O investimento público na

²⁰⁵ A teoria de Dworkin em *Levando os direitos a sério* (ob. cit.), concebe que o direito tem uma abordagem baseada em princípios, de modo que uma teoria do custo dos direitos subestimaria o valor intrínseco dos direitos individuais e não levaria em conta, de forma adequada, os benefícios sociais associados a eles. Já a teoria Mark Tushnet sugere que a abordagem de Holmes e Sunstein não levaria em conta adequadamente as complexidades do sistema jurídico e político. De se lembrar que Tushnet defende que o juiz deve considerar apenas textos normativos e propósitos do legislador, esquecendo-se da realidade prática (TUSHNET, Mark Victor. *Following the Rules Laid down: A Critique of Interpretivism and Neutral Principles*. Harvard Law Review 96, no. 4, 1983. p781–827).

²⁰⁶ SEN, Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p.160. Segundo Sen, a saúde e a educação não são apenas fins do desenvolvimento, mas também meios fundamentais para ampliarmos as liberdades reais das pessoas”, o que se comprova empiricamente pela correlação entre sistemas de saúde sólidos, maior bem-estar social e estabilidade política.

²⁰⁷ DEATON, Angus. *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*. Princeton: Princeton University Press, 2013. Observa o autor que observa que “a melhoria da saúde não apenas aumenta a expectativa de vida, mas também contribui diretamente para o crescimento econômico e para a estabilidade social”, evidenciando, a partir de dados empíricos, que investimentos em sistemas de saúde sólidos geram retornos que extrapolam os custos sociais imediatos.

proteção desses direitos ajuda a aumentar a base tributária da qual depende também a proteção ativa de direitos em outras áreas.²⁰⁸

O que emerge desta afirmação é o fato de que, ao se reconhecer que os direitos possuem um custo e que os recursos são finitos, isso significa que será necessário renunciar a algo. Talvez um outro direito social garantido pela Constituição de um Estado-nação ou pela DUDH. Mas essa escolha – se legítima e legal for – seria frustrante pois consentiria em aceitar que há inexequibilidade das disposições Constitucionais.²⁰⁹

Defensores dos direitos fundamentais argumentam que a ênfase nos custos e benefícios de direitos pode subestimar ou desconsiderar a importância dos direitos fundamentais intrínsecos. Certos direitos são inalienáveis e não podem ser tratados meramente como uma questão de cálculo utilitário. Afinal, aceitar o caráter financeiro destes direitos seria o mesmo que aceitar que tais direitos seriam, sim, alienáveis.²¹⁰

Para contrapor os argumentos do constitucionalismo liberal e de defensores dos direitos fundamentais, lança-se mão de argumentos diversos tais como: sem dinheiro, um Estado-nação não consegue proteger direitos; os direitos não podem ser absolutos;²¹¹ os

²⁰⁸ ____p. 11.

²⁰⁹ DALLARI, Maria Paula Bucci. O conceito de políticas públicas. In BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). *Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico*. São Paulo: Ed. Saraiva, 2006. p. 10. “No contexto brasileiro, a polêmica é ainda mais acirrada. De um lado, porque a Constituição Federal brasileira de 1988 foi carregada com os direitos compreendidos na tarefa de redemocratização do país e sobrecarregada com as aspirações relativas à superação da profunda desigualdade social produzida ao longo de sua história. O desafio da democratização brasileira é inseparável da equalização de oportunidades sociais e de eliminação da situação de subumanidade em que se encontra quase um terço da sua população. De outro lado porque, sendo um texto mais recente, a implementação constitucional, no caso brasileiro, vale-se das figuras apenas esboçadas em outros contextos, nos quais a Constituição não tinha a centralidade na vida política que a Constituição brasileira de 1988 adquiriu. Por essa razão, seria absolutamente frustrante, do ponto de vista político, aceitar a inexequibilidade dos direitos sociais. Do ponto de vista jurídico, isso representaria tornar inócuo o qualitativo de “Estado social de Direito”, afirmado no art. 1º da Constituição. (...). Avançando a partir dessa discussão, o fato é que a Constituição brasileira enumerou um rol bastante generoso de liberdades e direitos, em especial os sociais (...).”

²¹⁰ A teoria de John Rawls é nesse sentido, afinal, ele defende em sua teoria uma posição deontológica na qual certos direitos são considerados invioláveis (RAWLS, John. *Uma teoria da justiça*. 4ª ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2016). Não diferente a base teórica Kantiana cujas ideias influenciaram a visão dos direitos fundamentais como inalienáveis.

²¹¹ ____p.77 e 78. “Nada que custa dinheiro pode ser absoluto. Nenhum direito cuja garantia pressuponha um gasto seletivo do dinheiro dos contribuintes poderá, no fim das contas, ser protegido unilateralmente pelo poder judiciário sem levar em consideração as consequências orçamentárias pelas quais os outros poderes do Estado são, em última análise, responsáveis. Uma vez que a proteção contra a violência cometida por particulares não é barata e necessariamente utilizará recursos escassos, o direito a uma tal proteção, supondo-se que de fato exista, não pode ser completo ou absoluto. O mesmo vale para os direitos individuais à proteção contra os abusos do Estado, direitos que são mais conhecidos. (...). Os direitos diminuirão quando os recursos diminuïrem e poderão se expandir à medida que se expandem os recursos públicos.

direitos acarretam responsabilidades²¹² que passam por pagamento de “impostos em geral”;²¹³ o uso transparente de recurso público é necessário; e, existe um dever de punição de quem não cumpre com suas obrigações.²¹⁴

Assim, tentando mostrar a responsabilidade dos cidadãos e a limitação dos direitos, Holmes e Sustain adicionam em sua argumentação que as decisões sobre o quanto um Estado-nação deve gastar com um direito é de cunho político em uma análise do que trará maior probabilidade de benefícios à sociedade²¹⁵. Assim sendo, os autores concluem que os direitos deveriam ser entendidos como acordos de interesses da própria sociedade:

Uma sociedade justa tenta garantir oportunidades razoáveis para todos e também assegurar que ninguém caia abaixo de um piso mínimo decente. Isso faz parte da ideia liberal essencial de que a sociedade é um empreendimento cooperativo (...). De qualquer modo, o esforço particular assume sua forma atual e recebe suas recompensas atuais por causa de arranjos institucionais escolhidos politicamente, administradores pelo Estado e impostos pelo sistema jurídico.²¹⁶

Foi dito ser premissa desta tese o fato de que o direito à saúde é um direito humano fundamental, inalienável e inegociável. Portanto, por mais que não se admita negociar no plano teórico o direito fundamental à saúde que visa preservar o que há de mais importante para o ser humano, que é a vida; e, por mais polêmico que possa ser a ideia de aceitar que é necessário considerar os custos e benefícios associados ao exercício dos direitos frente à direitos fundamentais e inalienáveis, essa é a realidade em que vivemos: Existe um preço para todo acesso à saúde e tecnologia em saúde, em busca de uma vida digna e um determinado padrão de qualidade de vida e saúde.

A questão, portanto, não é argumentar qual teoria está correta, mas, analisar como fazer com que toda a cooperação social e os acordos de interesses que são celebrados cotidianamente tragam a menor desigualdade possível. Como manter um olhar empírico,

²¹² ____p. 113. “Não obstante, direitos e responsabilidade não podem ser separados; são correlativos.

²¹³ ____p.128. “Pelo fato de serem custosos, os direitos não poderiam ser protegidos nem garantidos se os cidadãos, na média, não fossem responsáveis o suficiente para usar a receita assim obtida para fins públicos, em vez de embolsá-la para enriquecerem enquanto particulares;”

²¹⁴ ____p.127. “Os direitos são garantidos quando uma sociedade politicamente organizada pune, de maneira regular e previsível, aqueles que espezinham de modo ilegal os interesses mais importantes de outras pessoas. Inibir a conduta abusiva de quem ganha com a violação de direitos é impossível sem fazer uso do dinheiro público”

²¹⁵ ____p.143. “(...) os direitos impõem responsabilidades, assim como as responsabilidades dão origem a direitos. Para proteger os direitos, o Estado responsável terá de gastar, com responsabilidade, recursos coletados de cidadãos responsáveis. Em vez de lamentar um fictício sacrifício das responsabilidades no altar dos direitos, devemos nos perguntar qual é o pacote de direitos e responsabilidades complementares que terá probabilidade de conferir mais benefícios à sociedade que os custeia”

²¹⁶ ____p. 162.

concreto, pragmático e consequencialista e, ao mesmo tempo, respeitar os conceitos jurídicos indeterminados, abstratos e principiológicos. Como chegar na melhor harmonização possível.

E a busca de uma boa harmonização é um dos papéis centrais do direito, já que toda a abordagem sobre os custos dos direitos não leva adequadamente em conta as desigualdades estruturais e as disparidades de poder que podem afetar a distribuição de custos e benefícios dentro de um determinado Estado-nação e, mais ainda, ao redor do mundo. Especialmente quando tratamos de direitos de minorias, como é o caso das raridades.

É na interseção entre essas disparidades estruturais, as dinâmicas de poder decisório e a necessidade de transparência na alocação de recursos que se definem os contornos da efetivação do acesso à saúde. Compreender essa articulação permite situar o tema em uma perspectiva mais ampla, que transcende o nível nacional e se projeta para a saúde global. É sobre essas disparidades, o jogo de poder decisório, a tomada de decisão e a transparência na alocação de recursos que se relaciona e conecta com a viabilização do acesso à saúde.

Diante desse quadro, torna-se evidente que a análise sobre os custos e desigualdades não pode permanecer restrita ao espaço interno de cada Estado-nação. A própria natureza da saúde, marcada pela interdependência entre povos e pela circulação de pessoas, bens e tecnologias, exige que se ultrapasse as fronteiras nacionais e que se adote uma perspectiva mais ampla. Assim, compreender o custo dos direitos e o acesso à saúde demanda um olhar que alcance também o plano internacional, em que se desenha o conceito contemporâneo de saúde global.

3.2. Acesso e a saúde global

A expressão saúde internacional é oriunda do final do século XIX, quando Estados-nação começaram a debater a necessidade de controlar epidemias que transcendiam as fronteiras geográficas de um determinado Estado. Essa expressão, na esteira da evolução mundial, foi além do controle de crises e culminou na expressão *saúde global* que foi trazida para o contexto deste trabalho.²¹⁷

Em grandes linhas, o chamado direito global da saúde estuda a prática do direito internacional que define e molda a normatividade sobre saúde no mundo todo em busca do mais alto nível de saúde física e mental possível, tal qual o anseio da OMS e a definição do

²¹⁷ BROWN, Theodore; CUEZO, Marcos. FEE, Elizabeth. *A transição de saúde pública internacional para global e a Organização Mundial da Saúde*. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 13, n.3, 07-09/2006. p. 624.

termo saúde na perspectiva deste trabalho, conforme abordado no primeiro capítulo. Neste contexto amplo, a saúde global busca oportunidades para a criação, mobilização e novas formas de incentivos para os atores sociais, além de monitorar e trabalhar o que já existe.²¹⁸

Não se objetiva debater, aqui, se o direito global da saúde (*stricto sensu*) seria um ramo jurídico autônomo ou um ramo específico do direito internacional.²¹⁹ O objetivo é outro. É demonstrar que a dimensão da saúde global está intrinsicamente conectada com a pluralidade jurídica e, portanto, já teria o condão de ser tratada além da normatividade interna de cada Estado-nação e, mais ainda, além da normatividade do direito internacional que tem sua forma usualmente apresentada por meio de compromissos multilaterais ou regionais.

E isso é possível uma vez que, do ponto de vista das suas fontes, o direito global da saúde é constituído por um conjunto de inúmeras normatividades nacionais e internacionais que impõe a cada Estado-nação ao redor do mundo a obrigação de cumprir suas obrigações de cooperação sanitária e, ao mesmo tempo, aprimorar o nível de saúde de suas populações.²²⁰

De mais a mais, isso também é possível pelo fato de que, no contexto global, o termo saúde está diretamente ligado ao senso de comunidade com a participação de *stakeholders* que vão além dos Estados-nação. São organizações não governamentais, associações de pacientes, entidades filantrópicas, entidades privadas, além de instituições diversas que vão desde a própria OMS ao Banco Mundial; de Fundos Globais de Luta Contra a Aids, Tuberculose e Malária à Cruz Vermelha, dentre outros *stakeholders*. E isso se conecta com a raridade e o senso de comunidade das raridades, que tratamos no primeiro capítulo do trabalho.

Retomando o eixo central da análise, relativo ao direito à saúde e ao acesso à saúde: tem-se que a normatividade existente ao redor do mundo, que compõe as fontes do direito global à saúde é, geralmente, elaborada com textos que determinam aos Estados-nação atuarem de forma positiva (*tomar uma determinada ação*) e/ou negativa (*abster de praticar uma determinada ação*).²²¹ Mas, pode-se observar nos dois capítulos anteriores deste trabalho que a temática da saúde vai muito além de ações positivas ou negativas de atuação dos Estados.

²¹⁸ GOSTIN, Lawrence O. *Global Health Law*. Cambridge: Harvard University Press, 2014. p. 59.

²¹⁹ Sobre o tema, sugere-se a leitura de TOEES, Brigit. *International health law: an emerging field of public international law*. Indian Journal of International Law. 2015, vol.55, n.3. p. 299-328.

²²⁰ GOSTIN Lawrence O., TAYLOR, Allyn L. *Global Health Law: A definition and grand challenges*. Public Health Ethics. 2008, vol.1, n.1, p. 53-63.

²²¹ RUGER, Jennifer Prah. *Normative Foundations of Global Health Law*. Georgetown. Law Journal, Washington DC, vol.96, n.2, 2008, p. 423-443.

O ser humano exige cada vez mais dos sistemas de saúde e da regulamentação destes sistemas. É o mundo conectado, tecnológico, sem fronteiras nas conexões virtuais e digitais que impõe esse “ir muito além” das atuações meramente de constituição do direito por ações negativas e positivas dos Estados. Essa exigência do que é o direito no mundo atual que traz novos ideais de justiça e os ideais de uma saúde global.

É neste contexto que a expressão saúde global visa tratar o tema a partir de uma compreensão deste direito como um bem social e juridicamente reconhecido como valioso, que deve ser protegido, promovido e efetivado por meio de um conjunto de atuações orientadas pelos princípios da bioética e pelo acesso à saúde em escala global, que vai além de interesses exclusivos sobre segurança sanitária, política econômica e comercial.

É esta saúde global que se conecta com o acesso à saúde. O acesso e avanço científico-tecnológico que se relaciona, entrelaça e se conecta em forma de uma rede complexa. Se intensifica com o aumento das organizações plurais ao redor do mundo. Uma conexão plural que envolve tanto os procedimentos que permitem o acesso à saúde quanto as decisões sobre o acesso.

Assim, a expansão do acesso à saúde torna-se o principal meio para a consecução final do direito à saúde. O acesso é, ao mesmo tempo, a origem e o instrumento para o direito à saúde. Esse acesso é global e, no âmbito do direito – ainda mais de um direito global sobre saúde – o acesso à saúde tem como característica própria ser um princípio de direito e uma norma de direito conforme será mais bem explicado a seguir.

3.3. Acesso à saúde como um princípio

O direito fundamental à vida e saúde insculpido no artigo 25 da DUDH é o mais amplo possível. A condição *sine qua non* para se alcançar a magnitude deste direito fundamental é alcançar e obter o máximo dos anseios que ali foram expostos. Isso quer dizer que, para que uma pessoa tenha um nível de vida que lhe assegure a saúde e bem-estar, essa pessoa precisa ter o acesso à saúde e ao bem-estar.

Da mesma forma, o indivíduo necessita de acesso à alimentação, ao vestuário, ao alojamento e aos demais bens essenciais previstos nos instrumentos internacionais de direitos humanos para a realização dos objetivos ali consagrados. Nesse contexto, o direito fundamental à vida encontra no acesso à saúde um de seus eixos centrais de concretização.

Fato é que a impossibilidade de uma determinação prática inequívoca e uniforme do acesso à saúde impõe um caráter multifacetário à execução do direito fundamental à saúde.

Essa impossibilidade ocorre independentemente de qual Estado-nação se debate o tema do direito à saúde. Trata-se de um fato que sempre torna o debate sobre o direito à vida e saúde um tema moderno. E sempre o tornará, pois, a saúde, está direta e intrinsecamente emaranhada à vida, a evolução, inovação, ao espaço e ao tempo como visto nos tópicos antecedentes.

Com a crise pandêmica da covid-19 a lógica de pensamento sobre o direito à saúde colapsou. E uma nova lógica começou a ser debatida,²²² mas, com poucas mudanças relevantes até o momento. O direito à saúde não mais pode ser visto – apenas – em normas que estejam circunscritas à territorialidade de cada Estado-nação. As constantes e aceleradas evoluções tecnológicas levaram o direito à saúde a transcender os limites territoriais. Como já abordado antes, mudanças no debate sobre o indivíduo e o coletivo da saúde ocorreram.

Muito bem. No contexto tratado neste trabalho, de que o acesso é a origem de tudo, o meio pelo qual o ser humano alcança (ou não) o seu direito à saúde e que, sem acesso à saúde não há como viabilizar este direito, a indagação que se levanta é se o acesso à saúde poderia ser um termo que integraria a principiologia do direito à vida, aqui entendida como saúde e bem-estar. Noutras palavras, seria o *acesso à saúde* princípio-chave do direito fundamental da saúde e bem-estar?

3.3.1. Os princípios

Princípios integram sistemas jurídicos de todo Estado-nação, sejam estes originários da *civil law* ou da *common law*.²²³ Etimologicamente o termo “princípio” encerra a ideia de começo, fundamento e ponto de partida. Do latim *principium, principii*, o termo que é oriundo dos debates filosóficos foi consignado por Immanuel Kant como toda proposição geral que pode servir como premissa maior num silogismo.²²⁴

Para Ronald Dworkin os princípios são normas que podem ser utilizadas como razões para os direitos individuais, sendo os direitos coletivos objeto da política²²⁵ ao passo que para

²²² NUNES, Silvo Gabriel Serrano, SERRANO, Antonio Carlos Alves Pinto, GALIL, João Victor Tavares *Como a COVID-19 afetou a interpretação das normas jurídicas durante o período pandêmico: a situação excepcional e o impacto nas decisões dos gestores públicos*. Brazilian Journal of Development, [S. l.], v. 8, n. 5, p. 41991-42013, 2022.

²²³ Enquanto a *civil law* é um sistema jurídico baseado em códigos e leis escritas (predominante na Europa continental e em países de tradição romano-germânica), a *common law* baseia-se em precedentes judiciais e decisões anteriores (predominantemente no Reino Unido e países de tradição anglo-saxônica).

²²⁴ KANT, Immanuel. *Crítica da Razão Pura*. 5ª Edição. Trad.: Manuela Pinto e Alexandre Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

²²⁵ DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos à sério*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 73-125.

Niklas Luhmann²²⁶ os princípios somente possuem relevância se positivados na constituição do Estado-nação.

Em teoria dos direitos fundamentais, Robert Alexy faz longa explanação sobre os princípios e como estes incorporam o sistema jurídico e convive com as regras do sistema. Teorizando com base na tipologia das normas jurídicas, cujas espécies são regras e princípios, Alexy distingue os princípios e as regras, conceituando princípios como norma que ordena que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. São normas que se relacionam com o ponto de partida dos direitos fundamentais.²²⁷

Bonavides trata os princípios na inserção constitucional como “a congruência, o equilíbrio e a essencialidade de um sistema jurídico legítimo. Postos no ápice da pirâmide normativa, elevam-se, portanto, ao grau de norma das normas, de fonte das fontes”.²²⁸ Canotilho afirma que os princípios – constitucionais – possuem três funções principais, quais sejam, o impedimento de que regras contrárias a eles sejam criadas; a compatibilização das interpretações das regras do direito; e, o de dar direção ao caso concreto na ausência de regras.²²⁹

Jesús Gonzáles Perez assevera que “os princípios jurídicos constituem a base do Ordenamento jurídico, a parte permanentemente eterna do Direito e, também, o fato combinante e mutável que determina a evolução jurídica da Nação”.²³⁰ O debate ao redor dos princípios é intenso.²³¹

Independentemente da corrente teórica que se queira seguir, fato é que os princípios jurídicos, no mínimo são fontes do direito e, portanto, pilstras estruturantes que, por sua vez, orientam a vida em sociedade e a interpretação e aplicação de toda uma normatividade jurídica

²²⁶ LUHMANN, Niklas. *El derecho de la sociedad*. Herder: Universidad Iberoamericana, 2005, p. 391.

²²⁷ Teoriza Alexy que os *princípios* não possuem um “*mandamento definitivo*”, mas apenas “*prima facie*” e, portanto, podem existir princípios antagônicos entre si e colidentes e, no caso de colidência, um princípio cederá lugar a outro quando um peso maior lhe for conferido sem que isso o invalide (ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. p.90-106). Sua teoria está ligada ao direito alemão e sofreu críticas de que não seria capaz de diferenciar regras e princípios (SIECKMANN, Jan-R. *La teoria del derecho de Robert Alexy: Análisis y crítica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 201.).

²²⁸ BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Malheiros, 9ª ed., 2001. p. 265.

²²⁹ CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. Coimbra: Almedina, 1999. p. 122.

²³⁰ PEREZ, J. González. *El principio general de la buena fe en el derecho administrativo*. Madri: Real Acadêmica de Ciências y Políticas, 1983. p. 45.

²³¹ Deste debate até surgiu um novo termo no Brasil: o “*pan-principiologismo*”. Este termo foi cunhado para os princípios que a doutrina enumera, mas, no entanto, estão desprovidos de força normativa expressa. Segundo os defensores do termo, estes princípios desprovidos de força normativa não poderiam ser chamados de princípios. STRECK, Lenio Luiz. *Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas*. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 517.

integrante do sistema legal de cada Estado-nação. São os princípios jurídicos²³² que fornecem a base para a vida em sociedade ao introduzirem um critério de racionalidade em um sistema jurídico.

A despeito dos princípios serem o introito é fato que, por vezes, os princípios não são tão claros como parecem. Não à toa estão suscetíveis à frequentes e várias interpretações de cunho político e jurídico. De qualquer modo, são princípios que fornecem a base para o direito à saúde. Uma base que, a despeito de comportar interpretações, é sólida e robusta.

3.3.2. Princípio do acesso à saúde ou princípio da acessibilidade

Na concepção deste trabalho os princípios são normas que estão positivadas no contexto jurídico-constitucional de um Estado-nação e, também, são normas que – mesmo não positivadas em uma Constituição – decorrem de tratados internacionais e declarações globais como vetores de um novo sistema de interação e integração global. Sistema esse que, oriundo da globalização e do avanço tecnológico, trouxe uma nova forma de atuação comunitária e de se interpretar o direito.

Na lógica de pensamento aqui defendida, quando Estados-nação aprovam determinada resolução ou emitem declaração, em comunidades multilaterais, da qual a participação do Estado-nação é voluntária, é ilógico pensar que este Estado-nação atuará de forma a não promover o cumprimento do quanto deliberado voluntariamente por ele próprio.

O que é lógico, portanto, é afirmar que um princípio não positivado em uma Constituição, mas, cuja construção decorre de tratado internacional e declaração global prolatada com a participação e anuência deste Estado-nação, também é um princípio com caráter normativo.

Não se quer dizer, contudo, que qualquer princípio criado pela doutrina tenha caráter normativo. O que se assevera é que princípios oriundos de políticas globais, mesmo que ainda não formalmente inseridos na Constituição de um Estado-nação, devem ser considerados como normas e, portanto, devem ser cuidadosamente aplicáveis pelos intérpretes do direito como normas qualificadas para tanto.

Nesse contexto os princípios possuem um lastro que decorre da constituinte do Estado-nação ou da deliberação política deste Estado-nação ao integrar organismos internacionais globais com interesse político. Mesmo que as normas destes organismos não estejam

²³² Para mais informações sobre *princípios jurídicos* vide CANOTILHO, J.J. Gomes. *Direito Constitucional*. Coimbra: Almedina, 1993.

formalmente inseridas na constituição deste Estado-nação. Essa premissa é relevante em relação ao que se defende nesta pesquisa sobre a estipulação de um direito global em saúde para as raridades.

Os princípios importam para o direito pois, é a partir destes, que ideais de justiça são estabelecidos. É a partir dos princípios que as regras são estabelecidas em ordenamentos normativos dos Estados-nação e, por sua vez, é a partir dos princípios e das regras que os sistemas jurídicos de cada Estado-nação deliberam sobre a aplicação das normas nos casos concretos. Os princípios são enunciados lógicos – implícitos ou explícitos – que ocupam uma posição de destaque no direito, suplantando ordens na vida jurídica e, portanto, vinculando a aplicação das normas que com eles se conectam.²³³

A generalidade das normas principiológicas é maior do que a das demais normas jurídicas. O direito à saúde, por exemplo, não consta expressamente na Constituição da Índia. Entretanto, esse fato não impediu que a corte suprema do país impusesse ao governo obrigações constitucionais de manter um padrão mínimo relacionado ao direito à saúde do povo indiano, interpretando a constituição do país de forma conexa a um direito que é vital ao ser humano.²³⁴

No Brasil, o direito à saúde é constitucionalmente definido como um direito fundamental. Em sua sistemática universal e gratuita acaba por ensejar um alto grau de litígios perante o Judiciário deste país, inclusive a corte máxima.²³⁵ Nos Estados Unidos da América

²³³ Uma das grandes questões que circundam a principiologia do direito é como lidar com o conflito de princípios e a abstração destes. Sobre o tema, a título exemplificativo, vide BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001; CLÈVE, Clèmerson Merlin; SIQUEIRA, Alexandre Reis. Algumas notas sobre colisão de direitos fundamentais. In: GRAU, Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérulo da (Coords.). Estudos de Direito Constitucional. São Paulo, Malheiros, 2003. p. 231-242; STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.

²³⁴ State of Punjab vs. R.L.B. (AIR 1998 SC 1703); P.B.K.M.S. & others vs. State of West Bengal (1996 SCC 37).

²³⁵ A quantidade de litígios envolvendo a temática do direito à saúde no Brasil é objeto de diversas obras jurídicas, dissertações de mestrado e teses de doutorados em distintas áreas de conhecimento. Sobre o tema, a título de exemplo, vide: BUCCI, Maria Paula Dallari e DUARTE, Clarice Seixas. *Judicialização da saúde: a visão do poder executivo*. São Paulo: Saraiva, 2017. Especificamente sobre as raridades, quando do início do estudo desta pesquisa ainda pendia a deliberação final da corte máxima brasileira sobre os critérios de excepcionalidade para o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Tratava-se do chamado Tema 6 de repercussão geral do STF. Vide NASSIF, Murilo Meneghetti. *Saúde no STF: a tese do tema 6 da repercussão geral*. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/saude-no-stf-a-tese-do-tema-6-da-repercussao-geral-04122020>. Acesso em 02.06.2024. Tema este que, ao longo desta pesquisa, mais especificamente em outubro de 2024, foi modulado pela corte máxima brasileira estipulando critérios limitadores para o fornecimento de terapias medicamentosas através da via do Poder Judiciário. Vide NASCIMENTO, Anderson Ribeiro; NASSIF, Murilo Meneghetti. *Judicialização da saúde: o cidadão pode questionar a Conitec?* Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/judicializacao-da-saude-o-cidadao-pode-questionar-a-conitec>. Acesso em 05.11.2025.

a legislação de reforma da saúde aprovada em 2010²³⁶ resultou em mudanças significativas no sistema de saúde do país que, por sua vez, aparenta estar sendo mantida nos Tribunais do país (por detrás das decisões políticas e jurídicas, o direito fundamental à saúde).²³⁷

O acesso à saúde até poderia ser uma mera norma específica em um Estado-nação. Contudo, sendo o acesso à saúde a origem de tudo, ou seja, o meio pelo qual o ser humano alcança (ou não) o seu direito à saúde e, considerando que, sem acesso à saúde não há como viabilizar o direito à saúde, o que se defende aqui é que a terminologia “acesso à saúde” detêm um conceito que integra a principiologia do direito à vida e, portanto, é um princípio-chave do direito fundamental da saúde e bem-estar.

Essa relevância jurídica do acesso à saúde como um princípio é corroborada pela interpretação da DUDH e do PIDESC (artigo 12), conforme o que se extrai da leitura do Comentário Geral nº 14 do CESCR (2000)²³⁸ ao explicitar que o direito à saúde depende do acesso à saúde como um elemento estruturante e orientador do direito à saúde.

Eis, pois, o princípio da *acessibilidade*. E, aqui, não importa se o princípio da *acessibilidade* ou do *acesso à saúde* é implícito ou explícito. O que importa é o princípio existir no mundo jurídico. Ao existir na teoria do direito os operadores poderão dele fazer uso – como o meio – para a obtenção do fim. Trata-se, pois de um vetor e balizador do quanto almejado pelo direito fundamental à vida (saúde e bem-estar).

Defender o contrário é admitir a posição jurídica de que a DUDH não é vinculante. E, ainda, admitir que as disposições do artigo 12 do PIDESC não integram o ordenamento normativo do Estado-nação que não aceita o acesso à saúde como um princípio. Talvez seja algo factível para países como Cuba, Botswana, Malásia e Estados Unidos que não ratificaram

²³⁶ Lei de Proteção ao Paciente e Cuidados Acessíveis de 2010 (PPACA) que ficou amplamente conhecida como *Obamacare*. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/3590>. Acesso em: 29.7.2023.

²³⁷ Nesse sentido, vide *California et al. v. Texas et al. Certiorari to the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit* No. 19–840. Argued November 10, 2020—Decided June 17, 2021. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-840_6jfm.pdf. Acesso em 29.7.2023.

²³⁸ O Comentário Geral nº 14 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CESCR), de 2000, é um documento interpretativo oficial que detalha o significado e o conteúdo do artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que trata do direito à saúde: “‘The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness’ (art. 12.2 (d)), both physical and mental, includes the provision of equal and timely access to basic preventive, curative, rehabilitative health services and health education; regular screening programmes; appropriate treatment of prevalent diseases, illnesses, injuries and disabilities, preferably at community level; the provision of essential drugs; and appropriate mental health treatment and care. A further important aspect is the improvement and furtherance of participation of the population in the provision of preventive and curative health services, such as the organization of the health sector, the insurance system and, in particular, participation in political decisions relating to the right to health taken at both the community and national levels.”. Disponível em: file:///C:/Users/10201134/Downloads/E_C.12_2000_4-EN.pdf. Acesso em 21.08.2025.

o PIDESC em seus ordenamentos jurídicos internos. Mas, de difícil aceitação para a grande maioria dos Estados-nação que de alguma forma admitem o PIDESC como parte do ordenamento jurídico interno como, por exemplo, o Brasil, Portugal, África do Sul, Alemanha, Argentina, França, Holanda, Costa Rica, Espanha, Itália, Dinamarca, Suíça, dentre outros.

Foi dito há pouco que o acesso à saúde até poderia ser apenas uma regra específica em alguns Estados-nação. Entretanto, antes de ser uma regra específica e, considerando que sem acesso à saúde inexistente o direito à saúde, parece lógico conceder ao termo acesso à saúde o status de princípio-chave que integra o direito fundamental à saúde de cada Estado-nação. Independentemente se tal conceito está previsto em Constituição do Estado ou se decorre de obrigações internacionais e globais voluntariamente assumidas pelo Estado-nação.

A realidade é que o acesso à saúde é uma complexa teia e emaranhado social. A necessidade de se conceder normatividade ao acesso à saúde pelos Estados-nação, definindo-o como um princípio – com mesmo status de norma constitucional – revela as mazelas sociais e o que de pior pode haver nos seres humanos: o entendimento equivocado de que o custo do acesso à saúde em busca de uma vida digna com qualidade, que é distinto em cada Estado-nação, conforme suas políticas internas de saúde e padrões metodológicos de aplicação de ATS, seria a precificação da vida.

Na concepção deste trabalho e conforme já tratado antes, a vida não tem preço. O que tem preço são as ações e medidas necessárias para se implementar um determinado padrão de acesso à saúde e a busca de um viver com dignidade. O preço está no custo de implementação dos direitos que foram constituídos pelo poder político e/ou pelo poder jurídico.

O acesso à saúde, como princípio fundamental do direito à saúde, é essencial para garantir que cada ser humano tenha a oportunidade de alcançar o seu pleno potencial de saúde. Trata-se de uma estratégia para alcançar sociedades mais justas e sustentáveis. O princípio da acessibilidade é um dos caminhos para se alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, relativo à Agenda 2030.

Sendo o acesso à saúde um princípio do direito fundamental à saúde e determinante para a vida (aqui posta em sentido amplo); o fato da impossibilidade de uma determinação inequívoca e uniformização prática de se garantir o fenômeno do acesso à saúde ao ser humano (especialmente diante da rápida inovação tecnológica medicamentosa e de tratamentos); e, em conjunto com a realidade de que o investimento em saúde tem um preço, o que se coloca em perspectiva, a partir de agora é, como fazer para avançar na (re)formulação de um melhor direito de acesso à saúde para as raridades, a partir do presente-futuro.

No contexto das raridades este trabalho é construído com a premissa de que não há mais como encarar o direito fundamental à saúde destas minorias, sem o princípio da acessibilidade e, apenas e tão somente, nos limites fronteiriços de cada país. A razão de ser está em toda a transformação tecnológica inovativa que existe no mundo, conforme exposto no primeiro capítulo deste trabalho, e que pode ter o condão de alterar, inclusive, o comportamento do ser humano em linha com o avanço de estudos de neurociência.²³⁹

Lidar com uma complexidade indeterminada transnacional que gera inquietação existencial é um desafio do direito moderno. Primitivamente, o ponto de partida escolhido não é uma questão normativa. É uma questão de existência e realidade presente. Que se conecta à rede social, tecnologia, filosofia e que, em dado momento, se conecta com a normatividade, a teoria do direito, ao futuro e, quiçá, poderá até chegar a um debate sobre o direito à felicidade²⁴⁰ para as raridades.

Dito isso é importante antecipar um tema que será abordado mais adiante, que é o fato de que, apesar do caráter principiológico aqui defendido ao acesso à saúde passando a integrar as normas constitucionais de forma implícita ou explícita de cada Estado-nação, isso não significa dizer que este acesso será ilimitado e irrestrito. Tanto pelo fato de que o acesso possui conexão com a temporalidade, quanto pelo fato de que toda teoria dos princípios se conecta com teorias administrativas de proporcionalidade, razoabilidade²⁴¹ e disponibilidade de recursos que são finitos e escassos.

Normas aspiracionais não existem por si. Por sua natureza são frequentemente criticadas pela falta de concretude e executoriedade prática. Carecem, pois, da precisão e especificidade encontradas em normatividade mais detalhada e menos interpretativa. Da mesma forma, termos abstratos e com textura aberta também não garantem executoriedade prática ao cidadão que busca ver seus anseios e seu direito respeitado.

Para superar estas críticas e as limitações das normas aspiracionais e de termos abstratos e de textura aberta é necessário que se adote uma abordagem que integre temas

²³⁹ KANDEL, Eric R. et. all. *Princípios de Neurociência*. Porto Alegre: Ed. AMGH, 2014.

²⁴⁰ LEAL, Saul Tourinho. *Direito à felicidade*. São Paulo: Almedina, 2017. “A investigação geral constituiu em identificar se a felicidade se relaciona com o constitucionalismo moderno. A essa relação demos o nome de “conexões”. (...) O trabalho parece ter provado que não só há essas conexões como, em verdade, o constitucionalismo moderno nasceu pretendendo assegurar a todos a felicidade e, mais do que isso, concretizar um projeto de felicidade coletiva (p.448).

²⁴¹ Aliás, sobre a razoabilidade é válido lembrar que essa “*analisa basicamente o equilíbrio entre meios e fins, especialmente no tocante à adequação dos meios, tendo em vista a aptidão para atingirem determinadas finalidades*” NOHARA, Irene Patrícia. *Direito Administrativo*. 12 ed. rev. e ampl. Barueri, SP : Atlas, 2023. p. 80.

aspiracionais a mecanismos mais concretos e executáveis. Isso pode ser alcançado, de forma teórica, mediante diretrizes claras com argumentação racional, mecanismos de transparência, independência de atuação e de monitoramento, por meio da participação da sociedade civil e, também, com incentivos e penalidades.

Nesse contexto, o princípio da acessibilidade ou princípio do acesso à saúde, por si só e analisado de forma isolado, pode ser considerado uma norma aspiracional e abstrata. Assim, para que este princípio-chave do direito à saúde não permaneça como um ideal inatingível é necessário que o acesso à saúde esteja cercado de direcionadores que o integram e possuem o condão de trazer as diretrizes claras para a concretude da aplicação do acesso à saúde como a dimensão que torna possível a fruição do direito à saúde.

Estes direcionadores são a *equidade*, um *racional científico* e a *transparência*. Tais direcionares atuam como mecanismos de execução capazes de garantir que o acesso à saúde seja efetivamente operacionalizado. São estes elementos direcionares que serão detalhados a seguir e que também estão conectados com a bioética²⁴², combinando o progresso da ciência com a herança humanista para beneficiar o indivíduo e a sociedade.²⁴³

3.3.2.1. Equidade como direcionar de operacionalização do acesso à saúde

Equidade é um conceito complexo. A equidade está fundamentada no princípio da justiça distributiva²⁴⁴ e, muitas vezes, é confundida com a igualdade.²⁴⁵ A igualdade pressupõe

²⁴² POTTER, V.R., *Bioethics, Bridge to the future*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, Inc., 1971, 1, em *Bioética: ponte para o future* / Van Rensselaer Potter; tradução de Diego Carlos Zanella. São Paulo: Edições Loyola, 2016.

²⁴³ BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. *Princípios de ética biomédica*. 3ª ed. São Paulo: Loyola, 2013. A bioética está fundada em 4 pilares principiológicos que não possuem uma relação hierárquica entre si e que visam proteger o ser humano e a vida, quais sejam: (1) não maleficência, que estabelece a obrigação de se evitar causar um dano intencional ou injustificado ao ser humano; (2) beneficência, entendido como a obrigação moral de agir de forma benéfica para o melhor interesse da dignidade e vida do paciente; (3) autonomia da vontade, entendido como a oportunidade de fazer escolhas autônomas ou intencionais, por agentes capazes e que sejam livres de influências quando de suas decisões; e, (4) justiça, que é alcançado no campo da bioética pelo modo de tratar cada pessoa conforme o que é considerado imparcial, de maneira que a prática clínica não sofra quaisquer interferências que não técnicas (ex.: sociais, culturais, religiosas ou econômicas).

²⁴⁴ A justiça distributiva estuda, em um determinado tempo na história, o modo como os bens de uma sociedade são distribuídos visando determinar se essa distribuição é justa ou aceitável. Conceito muito comum nas filosofias do igualitarismo que, atualmente, está focada principalmente em temas de distribuição de renda, riqueza e oportunidades. Distinto dos conceitos aristotélicos que se referia a essa justiça como o meio que as autoridades políticas distribuíam cargos e honrarias. “À primeira vista, a resposta parece óbvia – equanimemente, claro. Um indivíduo, um voto. Qualquer alternativa seria discriminatória. Mas Aristóteles adverte que todas as teorias de justiça distributiva discriminam. A questão é: Quais discriminações são justas? E a resposta depende do propósito da atividade em questão” SANDEL, Michael. *Justiça. O que é fazer a coisa certa*. 24. Ed. Trad. Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p.239.

²⁴⁵ Charles Taylor, usa o conceito de igualdade para tratar de equidade. Segundo Taylor, há divergência no que seja a igualdade de modo que coexistem na mesma sociedade cidadãos de *primeira* e *segunda* classe, ante a

que a justiça forneça os mesmos recursos e/ou oportunidades, igualmente para todos. Implica que todos devem obter o mesmo para alcançar uma situação igual.

Já a equidade é a crença de que a justiça requer o reconhecimento de diferentes circunstâncias e desafios que cada ser enfrenta. Implica no fato de que todos devem receber de acordo com o que cada indivíduo realmente precisa para que, ao final, todos possam atingir a mesma linha de chegada. A equidade é uma forma de restaurar a igualdade de resultados, não apenas uma forma de chances e oportunidades.

Para se alcançar uma cobertura universal de saúde relacionada às raridades e construir sociedades inclusivas, o foco de cada Estado-nação precisa estar na equidade de modo a viabilizar a restauração da igualdade de resultados. Ações para alcançar uma maior equidade deve responder às diversas realidades e às múltiplas formas de desigualdade, incluindo as desigualdades experimentadas por populações vulneráveis ao longo da vida, como as raridades e suas famílias. A equidade é ponto de partida de sociedades que objetivam assegurar a igualdade e a liberdade.²⁴⁶

A literatura sobre equidade é vasta e integra debates sobre ética, justiça social e direitos. O filósofo John Rawls, em sua teoria da justiça como equidade, defende que a sociedade esteja abalizada nos princípios da liberdade e igualdade. Adotando os princípios de liberdade igual e da diferença como base de sua teoria, Rawls defende um Estado garantidor do básico a todas as pessoas. Rawls formulou a igualdade com um postulado de igualdade de

disparidade de riquezas. Nesse sentido, a sociedade deve formalizar ações compensatórias através da igualdade em favor desta segunda classe que se encontram “impedidos de usufruírem ao máximo dos seus direitos de cidadania”. TAYLOR, Charles. (Org.). *Multiculturalismo*. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. p. 56-58. Vicente Ráo designa a equidade como “uma particular aplicação do princípio da igualdade às funções do legislador e do juiz, a fim de que, na elaboração das normas jurídicas e em suas adaptações aos casos concretos, todos os casos iguais, explícitos ou implícitos, sem exclusão, sejam tratados igualmente e com humanidade, ou benignidade, corrigindo-se, para este fim, a rigidez das fórmulas gerais usadas pelas normas jurídicas, ou seus erros, ou omissões”. RÁO, Vicente. *O direito e a vida dos direitos*. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. Volume 1. p. 69. Miguel Reale, trata a equidade como um instituto destinado a superar as lacunas do direito positivo. Os juízos de equidade possibilitam compatibilizar a norma geral às particularidades que circundam determinadas hipóteses da vida social. REALE, Miguel. *Lições preliminares de direito*. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 298. Robert Alexy afirma que “A assimetria entre a norma de tratamento igual e a norma de tratamento desigual tem como consequência a possibilidade de compreender o enunciado geral de igualdade como um *princípio da igualdade*, que *prima facie* exige um tratamento igual e que permite um tratamento desigual apenas se isso for justificado por princípios contrapostos”. ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. 2. Ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. Malheiros: São Paulo, 2017. p.411.

²⁴⁶ BINENBOJM, Gustavo. *Liberdade igual*. O que é e por que importa. 1. Ed. Rio de Janeiro: História Real, 2020.

oportunidades a todos e, ao mesmo tempo com a possibilidade de se aceitar as desigualdades, desde que estas gerem benefícios aos menos favorecidos.²⁴⁷

Para Rawls, a maneira como as coisas são não determina o modo como as coisas deveriam ser dentro de todo contexto social dos Estados-nação. Parafraseando Rawls e com a ideia de mostrar a diferença entre como as coisas são e como deveriam ser, Michel Sandel escreve que:

Devemos repudiar a alegação de que as instituições sejam sempre falhas porque a distribuição dos talentos naturais e as contingências da circunstância social são injustas, e essa injustiça deve inevitavelmente ser transferida para as providências humanas. Eventualmente essa reflexão é usada como desculpa para que se ignore a injustiça, como se a recusa em aceitar a injustiça fosse o mesmo que ser incapaz de aceitar a morte. A distribuição natural não é justa nem injusta; tampouco é injusto que as pessoas nasçam em uma determinada posição na sociedade. Esses fatos são simplesmente naturais. O que é justo ou injusto é a maneira como as instituições lidam com esses fatos.²⁴⁸

Ronald Dworkin, por sua vez, defende que a equidade seria “uma questão de encontrar os procedimentos que distribuem o poder político da maneira adequada”²⁴⁹ para garantir a todos os cidadãos o direito de participar ativamente das decisões emanadas do governo; enquanto o economista Amartya Sen trata a equidade com um olhar ao indivíduo e em conjunto com a necessidade de atuação de todos com imparcialidade:

O que é então equidade? Essa ideia fundamental pode ser conformada de várias maneiras, mas em seu centro deve estar uma exigência de evitar vieses em nossas avaliações levando em conta os interesses e as preocupações dos outros também e, em particular, a necessidade de evitarmos ser

²⁴⁷ Rawls trouxe significativos estudos para a ciência no mundo moderno e contemporâneo. Abordando o debate sobre o ideal e os fundamentos de uma sociedade justa, ao propor uma concepção de justiça chamada *Justiça como Equidade*. (RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 4ª ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2016). Rawls revigorou a tradicional teoria do contrato social, apresentada por Lock, Rousseau e Kant. Contrapondo alguns ideais de Rawls, cite-se Robert Nozick. Em sua teoria da titularidade Nozick defende que a sociedade esteja fincada no princípio da liberdade. Sua teoria tem uma visão mais individualista, em defesa do estado mínimo. Nozick apresenta objeções aos conceitos de Rawls afirmando que a liberdade teorizada por Rawls subverte padrões de distribuição de riquezas, não sendo compatível com intervenções do estado. Ainda, defende que o postulado de se ter desigualdades que gerem benefícios aos menos favorecidos viola o ideal liberal clássico kantiano de que cada homem é um fim em si mesmo, não podendo ser mero instrumento de outros homens (NOZICK, Robert. *Anarquia, Estado e Utopia*. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2011).

²⁴⁸ SANDEL, Michael. *Justiça*. O que é fazer a coisa certa. 24. Ed. Trad. Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p. 204.

²⁴⁹ DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 200; p. 483: “A justiça diz respeito ao resultado correto do sistema político: a distribuição correta de bens, oportunidades e outros recursos. A equidade é uma questão da estrutura correta para esse sistema, a estrutura que distribui a influência sobre as decisões políticas da maneira adequada. O devido processo legal adjetivo é uma questão dos procedimentos corretos para a aplicação de regras e regulamentos que o sistema produziu. A supremacia legislativa que obriga Hércules a aplicar as leis, mesmo quando produz uma incoerência substantiva, é uma questão de equidade porque protege o poder da maioria de fazer o direito que quer. As doutrinas rigorosas do precedente, as práticas da história legislativa e a prioridade local são em grande parte, embora de maneira distintas, questões de processo legal adjetivo, porque estimulam os cidadãos a confiar em suposições e pronunciamentos doutrinários que seria errado trair ao julgá-los depois do fato”.

influenciados por nossos respectivos interesses pelo próprio benefício, ou por nossas prioridades pessoais ou excentricidades ou preconceitos.²⁵⁰

Sen tem como foco a qualidade da vida humana. Tal qual o direito universal à saúde. A ideia de justiça, para Sen, é entendida não somente como renda e riqueza. Assim, sendo os indivíduos agentes de afeto e de produção, a mera análise do PIB como parâmetro único para auferir o desenvolvimento e bem-estar seria insuficiente. O que Sen propõe consiste em um “deslocamento fundamental do foco de atenção, passando dos meios de vida para as oportunidades reais de uma pessoa”.²⁵¹

Apresentando críticas tanto em relação a Rawls quanto a Dworkin, o que Sen sustenta em sua teoria de justiça é que o Estado, quando distribui as vantagens, deve levar em consideração também a capacidade de cada indivíduo para poder usufruir essa vantagem. Dworkin, por sua vez, um crítico teórico de Sen, defende a igualdade de recursos e não a equidade.²⁵²

A despeito das críticas, parece-nos que a teoria de Sen se conecta diretamente com esse trabalho pois, ao invés de medir o desenvolvimento humano de cada Estado-nação utilizando como parâmetro receita, riqueza, conforto ou contentamento individual, o economista volta sua visão para a liberdade como fim, ou seja, um fim do qual todos os outros referenciais existentes são apenas considerados meios para alcançá-la.²⁵³

Na concepção de Sen, a liberdade e a participação política dos indivíduos são instrumentos indispensáveis na escolha das opções consideradas mais importantes para cada Estado-nação.²⁵⁴ O autor não acredita em um modelo único de alcance do desenvolvimento, da mesma forma que entendemos que tanto o direito a um julgamento justo quanto o direito à saúde não fornecem receitas, mas, insistem em princípios-chave.

De qualquer modo é importante registrar que é válida a crítica de Dworkin a Sen, sobre a subjetividade de sua teoria de justiça e da executoriedade prática da mesma. Como um

²⁵⁰ SEN, Amartya; *A ideia de justiça*. Tradução: Denise Bottmann, Ricardo Doninelli Mendes – São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 84.

²⁵¹ SEN, Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. Tradução: Laura Teixeira Motta; revisão técnica Ricardo Doninelli Mendes – São Paulo: Companhia das Letras, 2000. SEN, Amartya. *A ideia de justiça*. Tradução: Denise Bottmann, Ricardo Doninelli Mendes – São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 215.

²⁵² Para Dworkin, Sen não propõe nada concreto e politicamente passível de ser realizável para a instituição de sua concepção de igualdade.

²⁵³ MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Amartya Sen como intérprete e crítico da teoria da justiça de John Rawls. *Revista PGM - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza*, [S.l.], v. 17, p. 427-440, dez. 2009. p. 436. ISSN 2595-0789.

²⁵⁴ SEN, Amartya. *Desenvolvimento como Liberdade*. Tradução: Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 48.

Estado-nação definirá suas políticas com grau de impessoalidade e destinadas a todos os indivíduos, se cada indivíduo é diferente um do outro? Como fazê-lo em escala global?

Transpor a equidade para a temática da saúde é buscar a redução de diferenças criando igual oportunidade e reduzindo as diferenças injustas, tanto quanto possível. Ao olhar para a causa das causas, ou seja, as causas das estruturas que determinam renda, *status* e poder em uma sociedade, além dos tomadores de decisão das políticas e ingressarmos no contexto das raridades – assumindo e mantendo a premissa de que a saúde é um direito humano fundamental –, conjuntamente com a tecnologia e integração global atual, conclui-se que a equidade é um dos direcionadores do princípio do acesso à saúde no contexto das doenças raras.

3.3.2.2. Racional científico como direcionar da operacionalização do acesso à saúde

Para assegurar que a tomada de decisões relacionadas ao acesso à saúde seja o mais imparcial e tecnicamente fundamentada possível, um segundo direcionador essencial do princípio da acessibilidade reside na argumentação científica. O racional científico constitui o alicerce central sobre o qual se estruturam as práticas de saúde, sendo imprescindível para a formulação de políticas, avaliação de tecnologias e definição de prioridades em contextos clínicos e regulatórios.

A argumentação com base em racional científico refere-se a um processo sistemático, lógico e fundamentado, mediante o qual hipóteses, análises ou posicionamentos são apresentados e sustentados à luz de evidências obtidas por profissionais especializados, devidamente capacitados e tecnicamente habilitados para atuar nesse campo.

Essa abordagem científica busca não apenas explicar fenômenos observáveis, mas, também, validar teorias e apresentar descobertas de forma coerente, clara e logicamente estruturada, ancorada em dados empíricos confiáveis, obtidos por meio de observações rigorosas, experimentações controladas e/ou outras metodologias sistemáticas de coleta de informação. Todo esse processo é consolidado no âmbito da metodologia científica, que compreende a formulação de hipóteses, a coleta organizada e padronizada de dados, a análise estatística crítica, a interpretação fundamentada dos resultados e a validação por meio da revisão por pares.

No entanto, quando se trata das doenças raras que é o foco desta pesquisa, a obtenção de evidências empíricas se apresenta como um desafio, em razão da escassez de dados, da limitada disponibilidade de estudos e do reduzido número de indivíduos afetados. Como já foi

discutido no primeiro capítulo, essas condições configuram contextos de minorias, nos quais a argumentação científica deve ser necessariamente adaptada.

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível recorrer tanto à lógica dedutiva, que parte de princípios gerais para fundamentar conclusões específicas, quanto à lógica indutiva, que extrapola observações particulares para inferir padrões ou princípios mais amplos, garantindo que as decisões sejam embasadas de forma coerente e abrangente, mesmo diante de lacunas de informação.

Dada a importância pública e social do direito à saúde e do acesso equitativo a serviços de saúde, é inegável que as políticas públicas nesse setor estão frequentemente sujeitas a pressões políticas e econômicas, assim como a interesses externos que podem privilegiar determinados grupos em detrimento de outros. Além disso, essas políticas enfrentam desigualdades estruturais, disparidades sociais, assimetrias informacionais e outros fatores que tornam extremamente desafiador alcançar decisões verdadeiramente equânimes e alinhadas ao bem público.

Nesse contexto, especialmente no caso das raridades, o direcionador do racional científico precisa ser avaliado de maneira mais abrangente, considerando sua aplicação na aprovação e regulamentação de terapias e tecnologias de saúde por órgãos técnicos nacionais e internacionais. Isso inclui instituições de referência global, como as que compõem o GCRS, um fórum internacional que reúne autoridades reguladoras de países como Japão, Brasil, União Europeia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Argentina, Cingapura e Estados Unidos.

O respeito à independência dessas autoridades sanitárias, compostas por profissionais multidisciplinares altamente qualificados, é fundamental para garantir que as decisões sejam livres de influências externas, políticas ou econômicas. Essa independência assegura que os agentes envolvidos ajam de forma técnica, objetiva e imparcial, promovendo a tomada de decisões que priorizem a saúde, especialmente quando analisam tecnologias em saúde voltadas para a população mais vulnerável ou para condições médicas raras.

O racional científico permanece como pilar estruturante da saúde, oferecendo a base necessária para que o princípio da acessibilidade seja efetivamente operacionalizado, orientando decisões de forma objetiva e tecnicamente fundamentada, mesmo diante de contextos de dados limitados e complexidade regulatória.

Dessa forma é necessário respeitar a aprovação de uma determinada tecnologia em saúde por autoridades de renome internacional com competências análogas incluindo Anvisa, FDA, EMA, PMDA, SWISSMEDIC, entre outras, no que se refere à avaliação científica,

aprovação sanitária e regulação de medicamentos e tecnologias em saúde, garantindo que apenas produtos seguramente testados, eficazes e de qualidade comprovada possam ser disponibilizados no mercado de consumo.

Quando essas autoridades atuam em conformidade com a normatividade técnica que delas se espera, observando rigor científico e protocolos reconhecidos internacionalmente, suas decisões não configuram atos arbitrários, mas refletem o resultado de uma avaliação sistematicamente fundamentada no racional científico. Em outras palavras, a liberação de uma tecnologia para o mercado expressa a convicção, baseada em evidências robustas e metodologias validadas, de que a intervenção apresenta segurança e eficácia adequadas para seu uso clínico.

Após a obtenção dessa aprovação, exceto por novos fatos ou requerimentos destas autoridades conforme regulamentação das mesmas, não se requer a apresentação de provas adicionais sobre a eficácia ou segurança da tecnologia como critério central do direcionador científico, uma vez que esses elementos já foram criteriosamente avaliados e validados pelo processo técnico de referência, sendo que a discussão sobre o custo da tecnologia, a alocação de recursos e a definição de quem arcará com os encargos financeiros constituem questões distintas.

No âmbito do direcionador científico, portanto, a preocupação central é garantir que as tecnologias aprovadas pelas autoridades técnicas estejam fundamentadas em rigor científico, independência e evidência empírica, assegurando que o princípio da acessibilidade seja efetivamente operacionalizado com base em critérios científicos, objetivos e confiáveis.

3.3.2.3. Transparência como direcionador de operacionalização do acesso à saúde

Eis o terceiro direcionador de operacionalização do acesso à saúde: transparência. A transparência integra um dos pontos chave para qualquer debate sobre regulação e regulamentação administrativa global. Ao acessar o dicionário de língua portuguesa, inglesa, francesa, italiana (e assim por diante) e buscar o significado da palavra transparência encontrar-se-á algo comum como a característica ou estado do que é transparente, que permite a luz ultrapassar e é fácil de se ver por trás, ou seja, que é límpido, evidente, claro, inequívoco.

Inexiste um conceito único para o termo transparência.²⁵⁵ O que se sabe é que o conceito do termo decorre do significado da própria etimologia da palavra transparência e de

²⁵⁵ FUENTES, Carlos Iván. *Transparency as a Global Goal: towards an unity of principles in Global Administrative Law*. 2008. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1134122>. Acesso em: 23.01.2024.

um dever de promoção e disseminação de informações precisas e relevantes com livre acesso a todos os interessados.²⁵⁶

A temática da transparência é assunto que vai além da literatura jurídica, tanto dentro das fronteiras internas de um determinado Estado-nação quanto no plano internacional.²⁵⁷ Na literatura jurídica o tema ganha cada vez mais escala de debate em diferentes vertentes.²⁵⁸ As legislações sobre proteção de dados pessoais ao redor do mundo, por exemplo, são um reflexo da busca de mais transparência informacional.²⁵⁹

No âmbito estatal não é diferente. É o grau de transparência que existe em um determinado Estado e na administração que traz mais ou menos confiança nos atos tomados pela administração.²⁶⁰ É, pois, o significado da palavra transparência que a torna um dos pilares de direito, no que tange à administração de um Estado que busca os ideais democráticos em sua gestão.

A transparência vai além da publicidade, integra o direito à informação e permite, no âmbito administrativo de gestão estatal, a participação pública e fiscalização das atividades exercidas pelo Estado. É a transparência que atua como um dos pilares da OMC,²⁶¹ auxilia na definição dos graus de corrupção existentes mundo afora²⁶² e, no contexto informacional tecnológico atual, é a transparência que auxilia no combate e na disseminação de informações falsas e inverídicas.²⁶³

²⁵⁶ Amartya Sen advoga que a transparência é um princípio como um direito humano em favor da liberdade. SEN, Amartya. *Desarrollo y libertad*. Trad. Esther Rabasco e Luís Toharia. Buenos Aires: Planeta, 2000. p. 59.

²⁵⁷ Sobre o tema além da perspectiva jurídica vide como exemplo o movimento global denominado Transparência Internacional, presente em diversos países do mundo e com foco na luta contra à corrupção. Disponível em: <https://www.transparency.org/en/>. Acesso em 11.02.2024.

²⁵⁸ MARCHAND, Jennifer. *Réflexions sur le principe de transparence*. In *Reveu Du Droit Public* n. 3, 2014.

²⁵⁹ MOURBY, Miranda. Ó CATHAOIR, Katharina. COLLIN, Catherine Bjerre. *Transparency of machine-learning in healthcare: The GDPR & European health law*. *Computer Law & Security Review* 43 (2021) 105611. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364921000844>. Acesso em 12.2.2024.

²⁶⁰ MOSER, Cornelia. *How open is 'open as possible'?* Three different approaches to transparency and openness in regulating access to EU documents. *Reihe Politikwissenschaft / Institut für Höhere Studien, Abt. Politikwissenschaft*, 80). Wien: Institut für Höhere Studien (IHS), Wien. Disponível em: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-246314>. Acesso em 11.02.2024.

²⁶¹ A transparência para a OMC, em conjunto com outros princípios, é pilar essencial do sistema multilateral de comércio pois visa evitar barreiras comerciais e incentivar países membros a adotarem políticas claras, promovendo previsibilidade e a estabilidade do comércio global.

²⁶² ONU. *Convenção das Nações Unidas contra Corrupção*. Geneva: UNODOC, 2007. Disponível em: http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf. Acesso em: 23.01.2024. Mais especificamente, vide arts. 5, 7, 9 e 10 da Convenção.

²⁶³ RAIS, Diogo (coord.). *Fake news: a conexão entre a desinformação e o direito*. 2. ed., rev., atual. e ampl. Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2020.

Transparência tem diversas vertentes e facetas²⁶⁴ que caminha a partir do simples acesso informacional à vigilância e controle; ou, da compreensão dos cidadãos sobre os atos adotados pelo Estado-nação até a participação social efetiva no ato decisório em um empoderamento da cidadania através da reivindicação de espaços próprios e com respeito ao espaço dos demais, inserido no contexto de um determinado ato decisório.²⁶⁵

Dentre as diversas vertentes que a transparência traz aos debates, a que interessa nesta tese é a de minimizar ao máximo as influências externas indevidas e dar clareza a todos os atos para que a sociedade como um todo possa participar das decisões sociais. Para que as minorias possam exercer a cidadania e reivindicar seu espaço próprio e com respeito ao espaço dos demais.

O recorte da transparência que se trabalha nesta tese é, portanto, o da transparência administrativa no âmbito da gestão interna da saúde de cada Estado-nação. Isso se dá através da publicização e processualização das decisões administrativas exaradas pelos Estados-nação sobre o acesso à saúde das minorias com o objetivo de: (i) criar mais consciência cívica e política dos cidadãos de cada Estado-nação; e, (ii) permitir que através da transparência os cidadãos possam atuar e participar de modo mais eficaz e eficiente nas decisões tomadas sobre o acesso ao diagnóstico e tratamento das doenças raras.

Aqui, portanto, o sentido que se busca da transparência tem como enfoque garantir a informação a quem dela se beneficiará (ou não) com a tomada de uma decisão sobre política pública estatal. É a transparência na forma de agir do Estado-nação no que diz respeito à tomada de decisão sobre o acesso ao diagnóstico e tratamento das doenças raras, de forma a propiciar uma teoria decisória mais equânime e sustentável possível.

Essa aproximação da sociedade com o poder decisório do Estado tem o condão de promover clareza nas decisões e, por consequência, reduzir incertezas e especulações dos cidadãos sobre o processo decisório. Ao mesmo tempo, portanto, incrementa a participação social na tomada das decisões administrativas dos Estados e reduz a assimetria informacional que levou à tomada de uma decisão.²⁶⁶

²⁶⁴ MESSA, Ana Flávia. Transparência administrativa e a nova lei de licitações. In *A nova lei de licitações e os indicadores de integridade: novo paradigma para a sociedade*. Carlos Eduardo do Nascimento (coord.) et. al.. Uberaba, MG: Thales Vilela, 2023. p.130-145.

²⁶⁵ COVRE, Maria de Lourdes Manzini. *O que é cidadania*. São Paulo: Brasiliense, 1995.

²⁶⁶ Artigos e textos acadêmicos tratam da baixa representatividade social. Especialmente quando o tema em debate envolve minorias. Esse debate precisa continuar a ser fomentado em busca de maior inclusão social e a estipulação de políticas públicas mais equânimes ao redor do mundo. Sobre o tema na seara da saúde e sob uma perspectiva global vide ROCHA, Cristianne Maria Famer; MARTINS, Mariana da Rosa; FARIAS, Mateus

É a partir da realidade do mundo atual de conectividade global que se traz a ressignificação da transparência na formulação e gestão de políticas pública; que vai além da mera acessibilidade informacional e caminha para um sistema mais inclusivo do cidadão e, portanto, no exercício da cidadania²⁶⁷.

Como consequência, essa transparência fomenta uma sociedade mais responsiva e interativa que, por sua vez, poderá buscar compreender seus direitos e suas obrigações junto ao Estado. O raciocínio é lógico: essa transparência ressignificada permite ao cidadão de um determinado Estado-nação entender o porquê todo direito possui um custo e a razão pela qual os recursos são escassos.²⁶⁸

Mas, como dito antes, a transparência vai além do direito. A transparência aproxima o direito da ética e, transparência é um dos elementos mitigadores da corrupção que sempre ocorreu e infelizmente sempre ocorrerá. Assim, é utópico acreditarmos que todos os atos praticados pelas instituições, ou seja, pelo ser humano que as gerencia (sejam públicas ou privadas), atingirá um ideal de plena transparência.²⁶⁹

O direito é (e sempre será) incapaz de assegurar a plena transparência. Contudo, o direito pode (e deve) atuar nas medidas repressivas e preventivas através da normatividade jurídica. É neste contexto que a transparência integra os direcionadores do acesso à saúde.

Aparecido de. *Saúde para todos: a participação da sociedade civil na governança global em saúde*. Saúde Debate, 44 (spe1), Jan-2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/4Td3zrcD4tsCt7s8rv8rRVz/?lang=pt#> Acesso em 15.8.2024. Sobre a participação social no processo administrativo no Brasil, vide NOHARA, Irene. *Participação popular no processo administrativo*: consulta, audiência pública e outros meios de interlocução comunitária na gestão democrática dos interesses públicos. In: NOHARA, Irene; PRAXEDES, Marco (org.). *Processo administrativo: temas polêmicos da Lei nº 9.784/99*. São Paulo: Atlas, 2011.

²⁶⁷ DE ARRUDA, Carmen Silvia Lima. *O princípio da transparência*. Imprensa: São Paulo, Quartier Latin, 2020. Esta obra faz uma análise da transparência como princípio jurídico autônomo, distinto da publicidade, destacando sua função de assegurar acesso qualificado à informação, participação social e motivação dos atos administrativos, com ênfase em sua consolidação no Brasil. É a transparência como dever público independente, que vai além da publicidade e que, na visão da autora, deveria ser incluso no texto constitucional para fortalecimento da administração pública.

²⁶⁸ Podemos dizer, também, que a transparência é um dos elementos que integram a ética, a integridade e o chamado “compliance”, que diz respeito à conformidade de normas e regulamentos legais, éticos e internos de uma organização. A transparência garante que a conformidade seja efetiva e visível. Além de auxiliar nos processos decisórios, constrói confiança entre os *stakeholders* e mitiga o risco de práticas questionáveis. Mais sobre o tema vide: *Compliance na área da saúde* / Andre Pontin *et al*; coordenado por Angélica Carlini, Giovani Agostini Saavedra. Indaiatuba/SP: Editora Foco, 2020.

²⁶⁹ Sobre transparência na administração pública, válida a leitura dos trabalhos de: SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. *Diálogos público-privados: da opacidade à visibilidade na administração pública*. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016. 361 f.; e, SANT’ANNA, Marília Mendonça Moraes. *Transparência e controle social da administração pública: limites e possibilidades no cenário brasileiro*. Tese (Doutorado). Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2018. 233 f.

3.3.3. Síntese do princípio do acesso à saúde ou princípio da acessibilidade

O princípio do acesso à saúde, ou princípio da acessibilidade, afirma-se como elemento estruturante do direito à saúde. Sua relevância se confirma na medida em que orienta a formulação e aplicação de políticas públicas, evitando que o direito à saúde permaneça um ideal abstrato e permitindo sua concretização na vida das pessoas. Este princípio, por sua vez, articula três direcionadores essenciais: *equidade, racional científico e transparência*.

A equidade, ao reconhecer as diferentes necessidades e contextos dos indivíduos, assegura que o acesso à saúde seja distribuído de maneira justa, promovendo igualdade de resultados mesmo diante de desigualdades estruturais como ocorre na perspectiva das raridades. O racional científico, por sua vez, garante que as decisões sobre tecnologias em saúde sejam fundamentadas em metodologias reconhecidas e avaliação técnica, inclusive em contextos de escassez de dados, como ocorre nas doenças raras. A transparência atua como mecanismo de controle e participação social, permitindo que cidadãos compreendam os processos decisórios, minimizando influências externas indevidas.

Esta articulação evidencia que o acesso à saúde é um elemento estruturante do direito à vida e ao bem-estar, essencial para a implementação de sociedades justas, equitativas e sustentáveis. Ao consolidar essa compreensão o caminho se abre para o enfoque final deste capítulo que é o papel dos Tribunais no acesso à saúde.

3.4. O papel dos Tribunais no acesso à saúde

Os Tribunais existem ao redor do mundo para proporcionar um sistema imparcial e independente de solução de conflitos. Tribunais são os responsáveis (ou ao menos deveriam ser) para administrar o remédio para a estabilidade da ordem jurídica e social de Estados-nação e, assim, atuar ao redor do mundo garantindo a dosagem e aplicação dos remédios apropriados para o cumprimento de direitos e obrigações individuais e coletivas de ordem pública ou privada.²⁷⁰

²⁷⁰ Não é objetivo deste artigo debater temas relacionados ao chamado ativismo judicial e teses acerca da atuação mais (ou menos) positivista; mais (ou menos) garantista; mais (ou menos) intervencionista dos Tribunais. No recorte, aqui, é lembrar que os Tribunais são grandes detentores de Poder e, portanto, suas decisões influenciam diretamente na vida social individual e coletiva. Sobre o papel dos Tribunais vide a título exemplificativo CLÉVE, Clémerson Merlin. *Poder Judiciário: Autonomia e Justiça*. Revista Informação Legislativa. Brasília A 30, n. 117, jan/mar 1993, 293-308; HIRSCHL, Ran. *The Global Expansion of Judicial Power* (March 1, 2023). Oxford Handbook of Comparative Judicial Behavior (Lee Epstein, Gunnar Grendstad, Urška Šadl, and Keren Weinshall, eds., Oxford University Press, 2023), University of Texas Law, Legal Studies Research Paper. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4373693. Acesso em 19.01.2024; ou, VIEIRA, Oscar Vilhena; GLEZER, Rubens (org.). *A razão e o voto: diálogos constitucionais com Luís Roberto Barroso*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017.

É a razão de ser dos Tribunais que faz com que exerçam um papel de intervenção crucial, se e quando necessário, na garantia de acesso à saúde. Desempenhando seu papel de forma correta, os Tribunais – que são detentores de um grande espaço de poder – influenciam direta e indiretamente as políticas de saúde. São os Tribunais que, na omissão ou ação equivocada de outros poderes, teriam o condão de impor a concretude ao princípio da acessibilidade.

Através do remédio dos Tribunais são interpretados e aplicados direitos relacionados aos problemas sociais. Direitos que são reanalisados para uma nova interpretação e reformulação de aplicabilidade à medida em que a sociedade evolui no espaço e no tempo, em conjunto com o nascedouro de novos problemas sociais.

Trata-se de uma realidade que concede imensa responsabilidade aos Tribunais e lhes permite, inclusive, atuar como um agente fomentador de desenvolvimento de Estados-nação.²⁷¹ Aliás, foi a força decisória dos Tribunais que, historicamente, trouxe a eficácia dos direitos fundamentais para o contexto da União Europeia.²⁷² São os Tribunais que continuam a fomentar e dar concretude aos direitos fundamentais²⁷³; e que em alguns países – talvez por conta da globalização – introduziram um certo direito comparado em algumas decisões, especialmente quando relacionadas à temática de direitos fundamentais²⁷⁴.

²⁷¹ RÊGO, Nelson Melo de Moraes. *Poder Judiciário e Direito ao Desenvolvimento*. Curitiba: Juruá, 2023. Abordando aspectos teóricos e práticos o autor examina como o Poder Judiciário pode influenciar e promover o desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Objeto de sua tese de doutoramento o jurista, magistrado, explora a interseção entre o Poder Judiciário e o direito ao desenvolvimento, concluindo que o desenvolvimento somente poderá ser alcançado, plenamente, quando todos os direitos humanos forem respeitados e protegidos.

²⁷² MARTINS, Ana Maria Guerra. *Les Valeurs Communes et la Place de la Charte en Europe*. In Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. XLIII, n.1. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 123. “Ces valeurs ont progressivement acquis un statut privilégié pendant le cours du processus d’intégration. En fait, elles ont constitué la base sur laquelle la Cour de Justice s’est inspirée plusieurs reprises pour entamer sa jurisprudence”.

²⁷³ CALAHORRO, Augusto Aguilar. *A eficácia da carta de direitos fundamentais da União Europeia à luz da jurisprudência mais recente do tribunal de justiça*. Joaçaba, v. 21, n. 2, p. 389-418, jul./dez. 2020. “A recente jurisprudência do TJUE não só recupera a intocabilidade dos direitos subjetivos (fundamentais), mas também o faz em relações horizontais e, além disso, no quadro dos direitos de conteúdo socioeconômico. Não se é sujeito de direitos se não se pode fazer valer em garantia de pretensões subjetivas. Não se é sujeito de direitos se uma parte essencial da globalização econômica é imune aos limites dos direitos fundamentais da Carta. O caso Bauer, sem dúvida, representará um ponto de pressão para a evolução das doutrinas da eficácia mediata dos sistemas constitucionais internos e para repensar as relações entre a ação processual e o direito subjetivo. O diálogo entre tribunais que envolve o sistema multinível de proteção dos direitos está também a transformar-se num diálogo entre categorias jurídicas. É importante salientar que a eficácia jurídica dos princípios gerais do direito europeu começa a ser combinada com a eficácia das cartas de direitos. Embora, como disse Cruz Villalón, não é um debate entre “direitos fundamentais vs. direitos humanos”, mas sobre a eficácia do próprio Direito na esfera externa aos Estados. Âmbito onde se joga o verdadeiro jogo”. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/23781/15787>. Acesso em 22.01.2024.

²⁷⁴ Sobre o uso crescente do direito comparado por tribunais de diversos países, vide JORDÃO, Eduardo. *Três problemas do recurso judicial ao direito comparado: legitimidade, seletividade e deformidade*. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, v. 13, n. 41, p. 319-339, jul./dez. 2019.

Dentre os conflitos que chegam aos Tribunais estão os embates relacionados a assistência à saúde e as limitações orçamentárias dos Estados-nação, com a dificuldade de acesso a terapias e tecnologias em saúde, especialmente tecnologias de alto custo, para diagnóstico e tratamento de moléstias em que os pacientes estão incluídos em grupos específicos, como nos casos de doenças raras.

Na esteira da evolução de aplicação e interpretação de direitos dos velhos problemas sociais com a reinterpretação de direitos aos novos problemas sociais surgiu a popularmente chamada judicialização da saúde, que nada mais é do que a busca (seja essa busca legítima ou não) pelo acesso ao direito à saúde através do arbítrio do poder dos Tribunais.

Esta busca do direito a saúde pelas decisões dos Tribunais é um fenômeno que ocorre no mundo todo, especialmente em sistemas de saúde que buscam a universalidade da assistência à saúde. Por mais criticada que possa ser, a judicialização da saúde é um evento que permite o aprimoramento do debate social sobre o direito à saúde, seus limites, seus custos, dentre outros. Mas, mais do que isso, a judicialização da saúde é um evento basilar para o controle e ajuste do poder decisório, especialmente em relação a minorias e aos que não detêm o controle decisório do poder.

Como já mencionamos neste trabalho, na Índia, a normatividade do direito à saúde advém da interpretação constitucional dada pelos Tribunais. Foi a suprema corte do país que obrigou o Estado a prover tal direito aos indianos²⁷⁵ e que continua a forçar o governo indiano a buscar executoriedade prática ao direito à saúde, inclusive das raridades.²⁷⁶

²⁷⁵ State of Punjab & Ors. v. Mohinder Singh Chawla (1997 2 SCC 83). Nesta decisão, a Suprema Corte da Índia reafirmou que o direito à saúde é um aspecto integral do direito à vida, conforme garantido pelo Artigo 21 da Constituição da Índia. A Corte concluiu que o direito à saúde inclui o direito a tratamentos médicos e hospitalares gratuitos, especialmente para os pobres e necessitados.

²⁷⁶ Em 2021 a corte máxima do país impôs ao governo indiano a necessidade de finalizar a instituição de uma “Política Nacional para Doenças Raras” no país ainda naquele ano. Em 2024, toda a temática das doenças raras foi analisada pela corte suprema em uma perspectiva holística e, inclusive, de custo destes direitos conforme pode ser visto na decisão do caso Master Arnesh Shaw VS Union of India, julgado em 04.10.2024, na qual o Tribunal impôs diretrizes para que o governo indiano aumentasse o suporte para o tratamento de doenças raras, considerando o direito à saúde como um direito fundamental: “(...) 297. It is now well settled that Right to health is an integral part of Right to Life under Article 21 of the Constitution of India. The said Right cannot distinguish between persons with more prevalent diseases on one hand and rare diseases on the other hand. To discriminate between patients suffering from more prevalent diseases, and those who suffer from rare diseases would also be discriminatory and violative of Article 14 of the Constitution of India. Right to health has to be equally recognised for persons suffering from rare diseases. 298. While there is no doubt that the Constitutional obligation to provide healthcare rests upon the State, the same is to be balanced with the available constraints. However, the recognition of the Right to Health and Healthcare cannot be completely negated due to these constraints. The country ought to strive to provide adequate healthcare to persons with rare diseases within the available limitations and in the best possible manner. (...)”.

Os Tribunais da África do Sul, assim como muitos outros países, também debatem o acesso a saúde na interpretação da normatividade constitucional local, que reconhece o direito à saúde como um direito fundamental e estabelece o direito de todas as pessoas terem acesso aos cuidados de saúde.²⁷⁷ Foi desta interpretação normativa que foi possível aos pacientes lutarem pelo acesso a medicamentos antirretrovirais para o tratamento do HIV/AIDS.²⁷⁸

No velho mundo os Tribunais também são acessados. Foi a partir de casos julgados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia que esse direito passou a ser aplicado em um contexto mais global dentro da comunidade ali constituída.²⁷⁹

Os conflitos existem, também, dentro das fronteiras de cada Estado-nação que integra a comunidade europeia. Interpretando o direito constitucional²⁸⁰ espanhol da saúde, em 2014, o Tribunal Constitucional da Espanha decidiu a favor de uma família que havia recorrido à justiça para obter um medicamento inovador para seu filho, que sofria de uma doença rara chamada Síndrome de Sanfilippo.²⁸¹

O Tribunal considerou que o acesso ao medicamento era um direito constitucional à saúde. No mesmo caminho foi a decisão a favor de um paciente com uma doença rara chamada

²⁷⁷ O artigo 27 da Constituição da República da África do Sul dispõe que “27. (1) Everyone has the right to have access to health care services. (2) The state must take reasonable legislative and other measures, within its available resources, to achieve the progressive realisation of each of these rights. (3) No one may be refused emergency medical treatment.”. Disponível em <https://www.gov.za/sites/default/files/images/a108-96.pdf>. Acesso em 02.06.2024.

²⁷⁸ O caso *Treatment Action Campaign (TAC) vs. Government of South Africa* foi uma ação judicial histórica que teve um papel crucial na luta contra a AIDS na África do Sul e na garantia do acesso aos medicamentos antirretrovirais (ARVs) para pacientes soropositivos. O TAC, uma organização não governamental sul-africana dedicada à defesa dos direitos dos pacientes com HIV/AIDS, argumentou que o governo sul-africano estava violando os direitos constitucionais dos pacientes soropositivos ao não fornecer tratamento antirretroviral acessível e eficaz para aqueles que necessitavam. Na época, a África do Sul tinha uma das mais altas taxas de infecção pelo HIV do mundo, e o custo dos medicamentos antirretrovirais os tornava inacessíveis para a maioria da população. Em 2002 a Corte determinou que o Estado tinha a obrigação constitucional de garantir o acesso aos medicamentos antirretrovirais para pacientes soropositivos. Isso foi um marco significativo, pois estabeleceu o princípio de que o acesso aos cuidados de saúde, incluindo medicamentos essenciais, é um direito constitucional na África do Sul.

²⁷⁹ Tribunal de Justiça da União Europeia. Direção da Comunicação. Unidade Publicações e Meios de Comunicação Eletrónicos. Set/2018. ISBN 978-92-829-2941-4. DOI 10.2862/40568. Disponível em: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/qd-04-18-747-pt-n.pdf>. Acesso em 22.01.2024.

²⁸⁰ O artigo 43 da Consituição espanhola estabelece o direito à proteção da saúde, a responsabilidade dos poderes públicos de organizar e supervisionar a saúde pública através de medidas preventivas e serviços necessários, e a promoção da educação sanitária, educação física e esporte: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.”

²⁸¹ Trata-se do caso Peralta González, que gerou repercussão internacional e foi visto como uma vitória significativa para os pacientes com doenças raras e suas famílias, demonstrando a importância da proteção dos direitos à saúde e do acesso a tratamentos médicos adequados.

Síndrome de Pearson²⁸² e a imposição à Administração de Saúde da Comunidade de Madri ao fornecimento de medicamento e tratamento necessário para tratar uma raridade.²⁸³

Já em sentido oposto, em uma decisão sobre terapias para doenças raras, o Tribunal Constitucional da Alemanha avaliou a recusa de cobertura pelo seguro de saúde público de uma terapia *off-label* com uma determinada tecnologia em saúde para uma criança diagnosticada com a doença de Tay-Sachs.²⁸⁴

A corte alemã analisou se a negativa violava os direitos fundamentais do paciente, considerando a gravidade da doença, a falta de alternativas terapêuticas e o caráter experimental do tratamento e concluiu que, embora a situação apresentasse alto risco e urgência clínica, não houve violação constitucional, já que os dados científicos disponíveis não demonstravam evidência suficiente de eficácia clínica relevante do medicamento.

A decisão ilustra o desafio enfrentado pelos sistemas jurídicos em equilibrar a proteção do direito à saúde e a necessidade de base científica robusta para financiar terapias de alto custo em doenças raras.

Subindo na geografia do mapa do mundo, em 2022, os Tribunais do Reino Unido autorizaram um hospital a desligar os aparelhos médicos que mantinham um adolescente de 12 anos em coma²⁸⁵ e, em 2023, outra decisão dos Tribunais autorizou fossem desligados os aparelhos que mantinham à vida de uma bebê de 8 meses.²⁸⁶

Voando para os Estados Unidos da América também nos deparamos com a judicialização da saúde que, geralmente, envolve questões como o acesso a planos de saúde,

²⁸² Em 2016 o Tribunal Constitucional da Espanha decidiu a favor de Alejandro Laínz, um paciente com Síndrome de Pearson, uma doença rara e grave que afeta a produção de energia celular. Alejandro necessitava de tratamento com o medicamento Elosulfase alfa (Vimizim), uma terapia enzimática de reposição. O Serviço de Saúde da Galícia havia se recusado a fornecer o tratamento, alegando que o medicamento não estava incluído no sistema de saúde pública. Essa decisão estabeleceu um precedente importante na jurisprudência espanhola, reconhecendo o direito dos pacientes com doenças raras a receber tratamentos médicos essenciais, mesmo que não estejam incluídos no sistema de saúde pública.

²⁸³ Ana Carmen Martín Puerta era uma paciente que sofria de uma doença rara chamada mastocitose sistêmica. Em 2016 a Corte Constitucional espanhola decidiu que a Administração de Saúde da Comunidade de Madrid tinha a obrigação de fornecer a paciente o medicamento necessário para tratar sua condição de saúde. O tribunal levou em consideração os princípios gerais do sistema de saúde público espanhol, que incluem o acesso universal e equitativo aos cuidados de saúde. Ao negar o acesso ao medicamento a Administração de Saúde da Comunidade de Madrid estava violando princípios constitucionais à vida e saúde, no entendimento da Corte máxima.

²⁸⁴ Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 25. September 2023 – 1 BvR 1790/23. Disponível em: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/09/rk20230925_1bvr179023.html. Acesso em 21.08.2028.

²⁸⁵ The Archie Battersbee Case. Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/08/FD22P00346-Battersbee-5-August-2022-Judgment-Final-Approved.pdf>. Acesso em 22.01.2024.

²⁸⁶ The Indi Gregory case. Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/10/Nottingham-University-Hospitals-NHS-v-Gregory-judgment-121023.pdf>. Acesso em 22.01.2024.

direitos dos pacientes, custos médicos e cobertura de tratamentos.²⁸⁷ De se registrar que neste país tais disputas não chegam às cortes sob a perspectiva de um direito fundamental, mas, sob a ótica do direito privado, especialmente no âmbito contratual entre usuários e operadoras. Trata-se de uma judicialização distinta do que ocorre em países como Brasil, Índia, dentre outros, em que o centro do debate é o ser humano e direitos fundamentais e universais.

Descendo pelo continente americano passa-se pela Colômbia que, a despeito da aspiracional constituição do país versar sobre o direito à saúde, a corte máxima estabeleceu diretrizes para o fornecimento de medicamentos não incluídos na lista de medicamentos básicos do sistema de saúde colombiano, quando sua falta pode vir a representar uma ameaça à vida ou à saúde dos pacientes.²⁸⁸

Argentina também possui judicialização do seu sistema de saúde. A corte máxima do país estabeleceu que os beneficiários do Programa de Assistência Médica Integral – PAMI²⁸⁹ têm o direito de exigir judicialmente o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos necessários.²⁹⁰

No Brasil são diversos casos relevantes já apreciados pelos Tribunais do país e outros ainda pendentes de apreciação.²⁹¹ A suprema corte brasileira já enfrentou temas de acesso ao

²⁸⁷ Na seara pública, cite-se o caso "*California v. Texas*", decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 2021, que tratou da constitucionalidade da Lei de Proteção ao Paciente e Cuidado Acessível (*Affordable Care Act* – ACA), também conhecida como “Obamacare”. No caso em questão, por uma maioria de 7-2, foi reafirmada a legalidade da ACA, que é um programa de saúde nos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito ao acesso a seguros de saúde para parte da população norte americana. De se registrar que a decisão proferida foi no sentido de ilegitimidade legal de parte. Portanto, a Suprema Corte não analisou o mérito da constitucionalidade da lei em si.

²⁸⁸ Sentença T-760 de 2008. Nesta decisão a Corte colombiana afirmou o direito à saúde como um direito fundamental dos cidadãos colombianos. Esta decisão é particularmente significativa porque estabeleceu parâmetros para garantir que o sistema de saúde colombiano atenda às necessidades da população e garanta o acesso universal aos serviços de saúde.

²⁸⁹ O PAMI é uma instituição na Argentina dedicada à prestação de serviços de saúde para pessoas idosas e aposentadas. Criado em 1971 é um dos maiores sistemas de seguridade social do país e tem como objetivo fornecer uma gama abrangente de serviços médicos e sociais. O PAMI oferece uma variedade de benefícios, incluindo cobertura médica, assistência farmacêutica, serviços de reabilitação, cuidados domiciliares, assistência social e programas de promoção da saúde. Ele opera através de uma rede de prestadores de serviços de saúde em todo o país, incluindo hospitais, clínicas, médicos e farmácias conveniadas. O programa é financiado principalmente através de contribuições dos trabalhadores e empregadores, bem como de fundos públicos do governo argentino.

²⁹⁰ O caso PAMI c/ Estado Nacional s/ Amparo" (2014), reconheceu o direito de paciente a receber o tratamento médico necessário para sua condição de saúde, mesmo que o procedimento não estivesse incluído no plano de saúde ou no sistema público. Neste caso, a Suprema Corte argentina determinou que os beneficiários do PAMI têm o direito constitucional de acessar tratamentos médicos essenciais, e que o Estado, por meio do PAMI, tem a obrigação de fornecer esses tratamentos.

²⁹¹ LIMA, Fernando Rister de Souza. *Decisões do STF em direito à saúde: aspectos econômicos e políticos*. São Paulo : Almedina, 2020. Na obra, explorando não apenas os aspectos jurídicos, mas, também, aspectos econômicos e políticos, o autor oferece uma análise aprofundada de decisões da corte suprema Brasileira relacionadas ao direito à saúde no Brasil.

direito à saúde previsto na constituição brasileira.²⁹² Mas, neste país, a judicialização ocorre em excesso.

A alta demanda pela busca do direito à saúde levou o Poder Judiciário a criação do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus),²⁹³ com o objetivo de monitorar e aprimorar a gestão das demandas judiciais relacionadas à saúde, propondo políticas, ações e sistemas que qualifiquem as decisões judiciais nesse campo e, ainda, promovendo a articulação entre o Judiciário e os sistemas de saúde do país em busca da sustentabilidade dos sistemas.

Mais recentemente a corte constitucional máxima do país definiu que a judicialização da saúde no âmbito do sistema público e estatal deverá ocorrer apenas em casos de exceção e, desde novembro de 2024 este Tribunal estipulou 6 critérios para que o Poder Judiciário possa intervir na política de saúde pública. Esclareceu ainda que, a despeito do direito à saúde ser uma disposição constitucional, são as políticas públicas que devem definir os limites para tanto.²⁹⁴

²⁹² A Constituição Federal brasileira dispõe em seu art. 196 que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

²⁹³ Instituído pela Resolução nº 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no Brasil, é um dos fóruns nacionais permanentes do Poder Judiciário para debater e propor soluções sobre áreas sensíveis da Justiça.

²⁹⁴ A decisão da maioria dos Ministros da corte constitucional brasileira foi no sentido de que a judicialização da saúde é uma exceção e, para tanto, 6 critérios precisam ser mandatoriamente observados e evidenciados pelo autor da ação para que se possa obter o fornecimento de uma tecnologia em saúde pela via do poder judiciário: (1) a decisão negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (2) uma ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento no sistema público de saúde – SUS –, ausência de pedido de incorporação ou atraso na apreciação fora dos prazos e critérios previstos na lei; (3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (4) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e, (6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Parece-nos que a decisão é equivocada. Os critérios “(1)”, “(5)” e “(6)” são razoáveis e não encontram óbice ao direito à saúde e acesso à saúde. Não é o que ocorre com os critérios “(3)” e “(4)”. A exigência “(3)” caminha contra o direcionador da equidade e do conceito de saúde e do direito à saúde. A exigência “(4)” é contrária ao direcionador racional científico do princípio do acesso à saúde na medida em que obriga um indivíduo a apresentar provas de elementos que não detêm acesso informacional e é de competência das agências sanitárias. A exigência “(2)” é uma peculiaridade do sistema de saúde do Brasil e compactua com os conceitos de saúde, direito à saúde e acesso à saúde deste trabalho, bem como o princípio da acessibilidade e seus direcionares, desde que facultado ao julgador ingressar no mérito administrativo da ilegalidade do ato de não incorporação. Caso contrário um sistema perverso contra o princípio de acessibilidade poderá se fazer presente.

Discussão semelhante também vem ocorrendo no sistema de saúde suplementar deste país. Em setembro de 2025 o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 7265, que questionava a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 14.454/22, norma que alterou a Lei de Planos de Saúde para permitir a cobertura de exames e tratamentos ainda não incluídos no rol da ANS. A decisão do STF reconheceu a constitucionalidade parcial da norma e estabeleceu que a ausência da tecnologia no rol da ANS impede a sua concessão, salvo quando preenchidos os seguintes requisitos: (1) prescrição por médico ou odontólogo; (2) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol; (3)

Até então diversas ações judiciais bem-sucedidas obrigavam o SUS a fornecer medicamentos de alto custo. As decisões tensionavam o poder político a atuar e proporcionar o acesso à saúde. Contudo, a partir da determinação de 2024, em razão de falhas estruturantes do sistema de saúde brasileiro²⁹⁵ é possível que um sistema perverso de negativa de acesso à saúde – especialmente para as doenças raras – venha a ocorrer no país.²⁹⁶ A realidade do tempo dirá. Espera-se, apenas, que não seja tarde já que as raridades não podem esperar.²⁹⁷

Esses casos evidenciam a tensão entre recursos limitados e o direito à saúde, mostrando como a judicialização pode funcionar como mecanismo de equidade para pacientes com condições raras. Ao mesmo tempo, ressaltam a necessidade de políticas públicas estruturadas e planejamento orçamentário eficiente para assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Embora os casos ilustrem a judicialização como instrumento de acesso a tratamentos para doenças raras, os contextos estruturais e sociais moldam resultados e estratégias de forma significativamente diversa.

O que se pode observar, por exemplo, é que em países como Brasil, Índia e África do Sul, a judicialização da saúde decorre, em parte, de falhas históricas no acesso e de profundas desigualdades sociais. Já em países como Alemanha, Portugal²⁹⁸ e Canadá, a existência de cobertura universal e a confiança no sistema de saúde reduzem a necessidade de recorrer aos Tribunais como garantidores de último recurso, uma vez que o acesso à saúde nesses contextos é provido com maior equidade, racional científico, transparência e previsibilidade tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde.

ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS; (4) comprovação de eficácia e segurança do tratamento, com fundamento na medicina baseada em evidências ou Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise); e, (5) existência de registro na Anvisa, quando aplicável.

²⁹⁵ D'IPPOLITO, Pedro Ivo Martins Caruso; GADELHA, Carlos Augusto Grabois. *The treatment of rare diseases in Brazil: the judicialization and the health economic-industrial complex*. Saúde Debate: Rio de Janeiro, V.43, n.especial 4, p.219-231, Dez/2019. Disponível em: https://www.scielo.org/pdf/sdeb/v43nspe4/en_0103-1104-sdeb-43-spe04-0219.pdf. Acesso em 19.08.2025.

²⁹⁶ Uma mudança estrutural no sistema de oferta de tecnologias em saúde para a população é necessário e os conceitos desta tese e o princípio do acesso à saúde com seus direcionadores é fundamental que pode auxiliar o poder político e jurídico deste país nesta reestruturação.

²⁹⁷ Em certos contextos como é o das doenças raras, existe um dever jurídico e moral do Estado de incorporar e fornecer o medicamento aos pacientes. Neste sentido: SANTOS, André Felipe; AKAUI, Fernando Reverendo Vidal. *Dever de incorporação de medicamentos para doenças raras: o caso Spinraza*. In: LAMY, Marcelo (Org.). *Temas avançados de Direito da Saúde*. 1. ed. São Paulo: Matrioska, 2020. v. 1, p. 295-304.

²⁹⁸ Em Portugal, por exemplo, Medicamentos de alto custo, inclusive para doenças raras, passam por processos de avaliação de eficácia e custo-benefício pelo INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento). Quando há aprovação, o acesso é garantido pelo sistema. Se um tratamento não é aprovado, há caminhos administrativos antes que o paciente possa recorrer à justiça, e a judicialização é rara. Informação disponível em: <https://www.gov.pt/entidades/infarmed-autoridade-nacional-do-medicamento-e-produtos-de-saude>. Acesso em: 21.08.2025.

Não há como negar, ao vermos alguns exemplos sobre decisões de Tribunais de diferentes Estados-nação, que os Tribunais ao redor do mundo são grandes detentores de poder e, portanto, que as decisões dos Tribunais influenciam direta e indiretamente na vida social individual e coletiva. É por todas estas explicações que entender “o como” decidem os detentores do poder – inclusive os Tribunais – é importante para a sociedade. Especialmente pelo fato de que é este “como” se decide que traz mais (ou menos) segurança jurídica para os cidadãos de cada Estado.

A dogmática jurídica tradicional historicamente tem como foco o estudo do intérprete do direito sobre a coerência lógica e sistemática das normas (princípios e regras jurídicas) de acordo com os textos constitucionais e infraconstitucionais. Trata-se de uma visão do processo decisório que se resume à aplicação da normatividade já posta. Essa visão tradicional do processo decisório pouco leva em conta a repercussão que a decisão trará (ou poderá trazer) para a sociedade, ou seja, a sua consequência.

No entanto, no mundo real, já sabemos que há muita consequência por detrás de decisões das cortes. São as consequências das decisões dos Tribunais que podem acarretar mais ou menos segurança social e jurídica dentro das fronteiras de um Estado-nação. São as implicações das decisões que fizeram com que, na evolução dos debates jurídicos, a normatividade de alguns Estados-nação fosse ajustada para que Tribunais comesçassem a incorporar uma análise consequencialista e econômica na aplicação das normas.

Os Tribunais conformam as expectativas dos indivíduos com incentivos positivos ou negativos sobre o funcionamento social do Estado-nação ao qual estão inseridos. Noutras palavras, os Tribunais – detentores de poder – atuam diretamente sobre os agentes de mercado, influenciando positivamente ou negativamente a decisão sobre políticas públicas e o desenvolvimento, estabilidade ou retrocesso de um Estado-nação.²⁹⁹

Douglass North, Prêmio Nobel de Economia em 1993, escreveu que instituições como os Tribunais ou o Direito criam incentivos diversos sobre a ação dos agentes em sociedade e, portanto, o Direito pode ser visto como uma dessas instituições criadas pelo homem que, no modelo democrático de freios e contrapesos, possui posição de proeminência em termos de

²⁹⁹ COASE, Ronald Harry. *The Problem of Social Cost*. The Journal of Law & Economics, v. 3, p.1-44, 1960. “Uma vez que os custos da transação realizados no mercado são levados em conta, fica claro que a aludida realocação de direitos somente ocorrerá quanto o aumento no valor da produção por ela gerado for maior do que os custos incorridos para implementá-la. (...). Nessas condições, a delimitação inicial dos direitos exerce influência sobre a eficácia com a qual o sistema opera.” p. 13

influências exercidas sobre o comportamento humano em sociedade e, por óbvio, nas demais instituições.³⁰⁰

É assim que o direito influencia e é influenciado pela economia. O direito influencia a sociedade e os Tribunais. É por isso que os intérpretes e aplicadores do direito são grandes garantidores da concretude do princípio da acessibilidade. Mas, há de se levar em conta que os Tribunais podem vir a ser responsáveis por resultados diametralmente opostos sobre o acesso ao direito à saúde.

A complexidade e os desafios do sistema de saúde, a falta de acesso adequado a serviços e recursos médicos, e as demandas individuais dos pacientes são alguns dos fatores que contribuem para a judicialização da saúde. É por isso que os Tribunais possuem fundamental papel na garantia do acesso à saúde.

A chamada judicialização da saúde é um evento de controle e ajuste do poder decisório que circunda o acesso ao direito à saúde para as raridades. E esse evento ocorre no mundo todo. Essa expansão global é o que nos traz ao cerne desta tese. O ponto comum de que a saúde é um direito humano fundamental; que o direito à saúde representa um alto custo nos direitos sociais; que desafios sobre o sistema de saúde dos Estados-nação possuem alta conexão; que no sistema de conectividade de tempo e espaço atual é possível defender (ao menos pensar), uma tese a favor de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras.

O percurso deste terceiro capítulo se encerra. Aqui pode-se compreender melhor que o papel do direito no acesso à saúde é um instrumento fundamental e viabilizador do direito à saúde. É o direito que fornece, ao mesmo tempo, a base principiológica de acessibilidade à saúde e a execução e aplicação deste princípio com eficácia normativa. Com esta compreensão e nos recortes desta pesquisa o trabalho seguirá para entender como as decisões são tomadas e quem toma as decisões para, em seguida, adentrar na propositura de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras.

³⁰⁰ NORTH, Douglass Cecil. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. 59262nd Edition. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 1990: “Instituições são as regras do jogo na sociedade ou, mais formalmente, são as coações criadas pelo homem que moldam a interação humana. Consequentemente elas estruturam os incentivos das trocas humanas, quer políticas, sociais ou econômicas....] No jargão dos economistas, instituições definem e limitam o leque de escolhas dos indivíduos [...] Instituições incluem qualquer forma de coação que seres humanos criam para moldar a interação humana” (P. 3–4).

4. ENTENDENDO O PODER E A TOMADA DE DECISÃO PARA CONSTRUIR UM DIREITO GLOBAL EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DAS DOENÇAS RARAS

“E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa.”

Ulisses Guimarães

O capítulo anterior apresentou como o papel do direito é crucial na saúde. Independentemente de onde o direito advém – se de um poder político ou um poder jurídico –, tem-se que o direito é elemento fundamental para que o acesso à saúde possa ser proporcionado ao ser humano através do que se chamou, nesta tese, de princípio do acesso à saúde ou princípio da acessibilidade.

A despeito de tudo o que se demonstrou sobre a importância do direito no acesso à saúde, fato é que esta relevância não se encerra na principiologia e em conceitos abstratos. Imprescinde de aplicação prática ao campo jurídico. É necessário, assim, buscar a executoriedade deste papel que o direito possui na sociedade.

Esta executoriedade também passa pela necessidade de se incrementar a participação social na tomada das decisões administrativas dos Estados, reduzindo a assimetria informacional que leva a uma tomada de decisão. É pela necessidade de incremento da participação social que se faz necessário entender como funciona o poder político decisório e a tomada de decisão política na temática da saúde.

A partir deste entendimento será possível compreender em definitivo os fundamentos para se construir um direito global à saúde sob a perspectiva das doenças. Com um acesso à saúde (e ao diagnóstico e tratamento) mais equânime, técnico, transparente e frente aos desafios do custo dos direitos.

Antes de avançar e para o melhor entendimento do leitor, volta-se ao tema da limitação de recursos que foi tratada no capítulo anterior para o fim de estressar o conceito do que são os recursos finitos e escassos. Não fossem as limitações de recursos e o custo dos direitos não seria necessário debruçar sobre a problemática real e desafiadora desta tese: o direito à saúde de um grupo minoritário.

Explicação interessante sobre as limitações de recursos foi apresentada por Elster Jon ao dizer que a escassez de recursos pode ser natural ou artificial. É natural quando se está no extremo de que nada pode ser feito até o ponto em que algo possa ser feito para se atingir a

satisfação geral, pela ação espontânea dos cidadãos. É artificial quando o governante pode, se assim decidir, tornar o bem acessível a todos a ponto da satisfação universal.

Dizer que um bem é escasso significa que não há o suficiente para satisfazer a todos. Escassez pode ser natural-fraca ou natural-forte, quase-natural, ou artificial. Escassez natural-forte ocorre quando não há nada que possa ser feito para aumentar a oferta. Pinturas de Rembrandt são um exemplo. Escassez natural-fraca ocorre quando não há nada que possa ser feito para satisfazer a todos. O fornecimento de petróleo é um exemplo; o suprimento de órgãos para transplante é outro exemplo. Escassez quase-natural ocorre quando o suprimento pode ser fomentado, possivelmente até o ponto em que haja satisfação geral, somente pela ação espontânea dos cidadãos. A provisão de crianças para adoção e de esperma para inseminação artificial são exemplos. Escassez artificial ocorre quando o governo pode, se assim decidir, tornar o bem acessível a todos a ponto da satisfação universal. Dispensa do serviço militar e vagas em creches são exemplos.³⁰¹

A partir desta explicação pode-se afirmar que a questão da disponibilidade financeira – dentro desta conceituação – estaria emoldurada pela escassez artificial que, por sua vez – quase sempre – é resultado de uma decisão de política alocativa. De forma pragmática o que se está a dizer é que: se não há recursos suficientes para promover um determinado direito, essa falta de recursos decorre do fato de que o recurso existente foi manejado para uma outra finalidade. Não é que ele não existia. O recurso existia, mas, foi alocado para outro fim.

Apenas dizer que o recurso financeiro não existe não é uma afirmação totalmente verdadeira e não pode ser aceita como retórica argumentativa. Aceitá-lo seria sucumbir a um aparente argumento de autoridade. Isto, pois, o Estado pode extrair estes recursos financeiros da sociedade por meio de tributos em geral. Essa extração poderá ocorrer até o limite de uma escassez natural completa, momento em que – aí sim – estar-se-ia sem recursos e diante da necessidade de se fazer as chamadas escolhas trágicas.

Noutras palavras, apenas neste momento de escassez natural é que deveriam ser adotadas as escolhas que tratam de situações nas quais indivíduos ou sociedades enfrentam decisões difíceis, sem uma solução ideal e onde qualquer curso de ação possível resultará em danos, sofrimento e até a morte.³⁰² Portanto, até que se chegue a uma escassez natural completa, o recurso financeiro existe e a alocação para onde o recurso irá advém de uma tomada de decisão de quem detém o poder para tanto.

³⁰¹ ELSTER, Jon. *Local Justice*. New York: Russel Sage Foundation, 1992, p.21-22.

³⁰² CALABRESI, Guido; BOBBIT, Philip. *Scelte Tragiche*. Milano: Giuffrè editore, 2006. No contexto das escolhas trágicas Calabresi e Bobbit defendem que os métodos alocativos adotados devem levar em consideração, de um lado, os valores pelos quais a sociedade determinou os beneficiários dos bens escassos, e, de outro, valores morais que exaltem a vida e o bem-estar - p.9: “In tali conflitti (...) devono infatti tentare di operare delle allocazioni in modo da preservare i fondamenti morali della collaborazione sociale e, se ci riescono, ta scelta tragica si tranformerà in uma allocazione, che no sembra implicare alcuna contraddizione morale, evitando cosi conseguenze moralmente riprovevoli.”

Esse conceito é importante, pois, como tratado ao longo desta tese, o direito à saúde e o acesso à saúde possuem um custo. Existe um custo e uma demanda de recursos para se acessar o direito à saúde e prover uma vida com dignidade ao ser humano. Recursos que, por sua vez, podem findar-se em um contexto de escassez natural ou artificial. Quando finalizado em razão de escassez natural estar-se-á diante de uma escolha trágica.

Mas, se findado sob a escassez artificial não estar-se-ia diante do mesmo véu decisório de uma escolha trágica. O que está por detrás deste tema não é apenas o quanto custa o direito à saúde em si, mas, as fontes de despesas que concorrem com os direitos sociais em conjunto com a tomada de decisão alocativa do recurso.

São as decisões alocativas e de formulação de políticas públicas que definem quanto uma sociedade quer investir na saúde de seu povo, ou seja, quanto os Estados-nação reservam do seu recurso para destinar a saúde, precificar o sistema de saúde e os limites de acesso à saúde. Esse contexto quase sempre está relacionado a um contexto de escassez artificial e não de escassez natural. A questão que sobrevém deste ponto é a seguinte: estando diante de decisões alocativas, *quem* decide onde fazer as alocações, ou seja, *quem* detém esse poder? E, indo além, *como* é que se decide?

Poder e tomada de decisão, no mundo todo, independentemente de qual seja o Estado-nação, são temas intrinsecamente relacionados e de grande importância para se entender como as escolhas e direções globais são moldadas.³⁰³ Aqueles que possuem maior poder têm maior influência na definição das agendas políticas, econômicas e sociais, assim como na condução dos processos decisórios que podem abranger uma ampla gama de questões.

Esta capacidade de influenciar, controlar ou direcionar os outros e os recursos disponíveis pode ser executada de diferentes formas. Através do poder político, econômico, militar, cultural, empresarial, midiático e, inclusive, através da tecnologia e interconexão instantânea e em rede hoje existente.³⁰⁴

Dentre as diversas formas de poder, o político desempenha um papel central na tomada de decisões globais, dado que governos e líderes políticos têm o domínio de tomar decisões que afetam seus respectivos Estados-nação e influenciar outros Estados-nação e organizações internacionais. Decisões tomadas pelos líderes políticos em fóruns como a ONU, G7, G20³⁰⁵,

³⁰³ FOUCAULT, Michael. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 2012.

³⁰⁴ MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Direito da Participação Política*. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p.18

³⁰⁵ Cite-se os grupos de trabalho de saúde do G-20, criados para tentar alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; o fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde inclusivos, eficientes e de qualidade, com ênfase

CELAC, dentre outros órgãos multilaterais existentes, desempenham (ou ao menos podem desempenhar), um papel importante na determinação de políticas e diretrizes globais.

Não diferente é o poder econômico, um fenômeno complexo e em constante evolução. A distribuição de poder econômico varia de acordo com setores, regiões geográficas e mudanças econômicas globais. Indivíduos e grupo de pessoas, sejam em ambiente público ou privado, podem desempenhar um papel significativo com influência direta e indireta no cenário econômico global e no poder decisório de temas que lhe interessam. Essa influência que o poder econômico traz para a sociedade tem o condão de, ora criar patrimonialismos e ambientes propícios para a corrupção, minando princípios democráticos; ora potencializar o progresso social e econômico de um determinado Estado-nação ou região.

O poder afeta diretamente as estruturas decisórias de políticas públicas e a tomada de decisões. Assim, não é incomum que decisões sejam influenciadas por interesses particulares; não é incomum a desigualdade de poder e/ou agenda oculta que podem levar a consequências negativas, como a perpetuação de desigualdades sociais e políticas públicas ineficientes que levam a debates que transcendem o direito.³⁰⁶

Da mesma forma, a falta e a abstenção na tomada de decisão, como parte do controle de poder, especialmente quando relacionada a temas complexos e de minorias, também é capaz de ensejar consequências negativas a uma sociedade e/ou a certo grupo de indivíduos. Abster-se de tomar uma decisão de forma proposital é uma tomada de decisão (de quem decide) para não enfrentar o dilema da realidade.

Decisões que atendam maiorias são razoavelmente fáceis de se deliberar. Ainda mais quando a decisão envolve uma ação política em que a satisfação da maioria permite manter toda a estrutura e base de apoio da ação política e dos tomadores da decisão. Como explana Gilberto Bercovici, “quanto mais densa e absoluta a homogeneidade do povo, mais forte e decidido será o governo.”³⁰⁷ Mais fácil será governar, controlar, impor e dominar.

na atenção primária à saúde. Maiores informações em: <https://www.g20.org/pt-br/trilhas/trilha-de-sherpas/saude>. Acesso: 01.11.2024.

³⁰⁶ Sob uma perspectiva sociológica do tema, vide CARNEIRO, Laura Elizandra Machado; NUNES, Silvio Gabriel Serrano. *A lógica do respeito e seu impacto na formulação de políticas públicas*. Peer Review, v. 5, n. 20, 2023. p. 381-394. Em uma análise a partir das teorias de Axel Honneth e Emmanuel Renault, os autores discutem a persistência de hierarquias sociais e examinam a influência da lógica do respeito (ou lógica do reconhecimento), na formulação de políticas públicas. Destacam como as relações de poder e as demandas sociais por reconhecimento afetam as decisões políticas. E o fazem explorando o impacto das hierarquias sociais e da dominação no reconhecimento de direitos e igualdade, sugerindo que as políticas públicas frequentemente refletem interesses ocultos que perpetuam desigualdades.

³⁰⁷ BERCOVICI, Gilberto. *Soberania e Constituição: Por uma crítica do constitucionalismo*. 3ª Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2020. p. 26.

Já o inverso não é verdadeiro. Deliberar sobre temas que envolvam minorias sempre gera um maior desgaste e impacto nas ações políticas. Ainda mais quando – e se – a decisão tomada ensejar um alto custo a ser suportado por maiorias (inclusive tomadores de decisão). Ainda mais quando estes tomadores de decisão tendem a não se beneficiar individualmente de forma direta ou indireta da decisão tomada.

É aqui que o direito entra em cena e vai ao palco mais uma vez. Buscar o equilíbrio decisório e decisões menos desiguais e mais equânimes faz parte do papel do direito. O direito tem esse objetivo e é nesse contexto que o direito se conecta umbilicalmente com a justiça, como um conceito mais amplo e subjetivo de equidade, imparcialidade e moralidade. O direito, em seu conjunto normativo, é quem define a (i) forma de se fazer escolhas (*o como decidir*) e, (ii) quem são os participantes da tomada decisória (*o quem decide*).

Uma sociedade é formada por diferentes grupos. São grupo plurais e que podem ser formados por partidos políticos, associações, sindicatos etc., que possuem uma certa influência e poder. Mesmo em sociedades não democráticas existem grupos de poder que de alguma forma influenciam a tomada decisória.

Nesse contexto, a compreensão do poder não pode limitar-se à constatação empírica da existência de grupos socialmente organizados ou dotados de capacidade de influência. Como observa Vicente Ráo,³⁰⁸ o poder que interessa ao direito não é a mera força social, econômica ou política em sentido amplo, mas aquele que se encontra juridicamente estruturado, isto é, transformado em autoridade dotada de competência para produzir decisões vinculantes. A distinção entre poder fático e poder jurídico é fundamental para compreender por que determinadas decisões, ainda que influenciadas por múltiplos interesses sociais, apenas se tornam obrigatórias quando canalizadas por instituições reconhecidas pelo ordenamento.

Sob essa perspectiva, o problema central não reside na pluralidade de grupos que compõem a sociedade, mas na forma como o direito organiza e legitima o exercício do poder decisório. A autoridade estatal, ao assumir a função de decidir sobre a alocação de recursos e a formulação de políticas públicas, não atua de maneira neutra ou automática, mas dentro de uma arquitetura institucional que pode ampliar ou restringir a participação, a transparência e a heterogeneidade dos processos decisórios. Quando essa arquitetura é excessivamente homogênea ou autorreferente, as decisões tendem a reproduzir interesses majoritários, mesmo

³⁰⁸ RÁO, Vicente. *O direito e a vida dos direitos*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

sem violação explícita da legalidade. É precisamente nesse ponto que o direito revela sua função corretiva. Cabe ao ordenamento jurídico não apenas reconhecer a autoridade, mas disciplinar o modo de seu exercício, estabelecendo limites, procedimentos e deveres que condicionem a tomada de decisão. Assim, a exclusão sistemática de minorias não decorre, em regra, de uma ausência de poder decisório, mas de sua concentração institucional sem mecanismos adequados de controle, participação e racionalização, o que reforça a necessidade de um desenho jurídico capaz de equilibrar autoridade, legitimidade e justiça material nas decisões relativas ao acesso à saúde.

Assim, compreender as organizações de poder é fundamental para encontrar o caminho de *como* as escolhas são feitas e *quem* as decide e, a partir daí, trabalhar através do direito em um sistema mais equilibrado e mais equânime para as raridades. É a partir dessa compreensão que se poderá avançar para a conclusão e resposta da indagação inicial da pesquisa, tema que será objeto do quinto e último capítulo.

4.1. Como se decide: teorias decisórias

Tomar decisões é fazer escolhas. Teorias decisórias foram desenvolvidas objetivando entender e explicar como os seres humanos tomam decisões em diferentes contextos e situações. Identificar os processos mentais, fatores emocionais, influências sociais e fatores cognitivos que moldam as escolhas individuais e coletivas são temas abordados em teorias decisórias que, de alguma forma, são usadas em políticas públicas (inclusive de saúde pública) e tem como fonte primária o comportamento humano.

Como as teorias decisórias estão intrinsecamente relacionadas ao comportamento humano, essas têm por base uma abordagem econômica e de política social. Em que pese o direito também ser um campo de regulação de comportamentos, esse não possui uma teoria bem definida sobre o comportamento humano. O que mais se aproxima, aqui, é a AED que outrora foi mencionada e que dialoga com a análise do custo dos direitos sociais. Afinal, toda escolha distributiva implica custos de oportunidade, o que exige que a sociedade delibere não apenas sobre o quanto gastar, mas sobre o como e para quem.

O objetivo aqui não é ingressar no detalhe de cada teoria decisória já existente. Muito menos confrontar as teorias. O que se pretende é passar pelo conceito de teorias que mais se conectam com a temática deste trabalho para, depois, compreender quais são as principais formas de se fazer escolhas em políticas públicas (*o como decidir*).

Escolhas que, no âmbito da saúde, como visto no segundo capítulo deste trabalho, estão intrinsicamente conectadas com a economia. A partir desta compreensão acredita-se será possível traçar um panorama sobre o como decidir em prol de um direito global em saúde para as raridades. Um como decidir que vá além do viés econômico e que hoje é quase que um mantra para a execução do acesso à saúde em que o culpado seria o custo dos direitos.

4.1.1. Teoria dos jogos

Trazendo uma abordagem matemática para a tomada de decisão, a teoria dos jogos explora situações em que as decisões de um indivíduo afetam os resultados de outros indivíduos. O cerne da teoria é a análise de jogos, que são situações em que as ações de um participante afetam as possibilidades de outros participantes, criando cenários de interdependência estratégica.³⁰⁹

Em um jogo um dos atores tende a “perder” para que o outro possa “ganhar”.³¹⁰ Para evitar a derrota, cada uma das partes tem incentivos para adotar a estratégia que pode maximizar seus ganhos. Ao final, o melhor dos resultados ainda não necessariamente será o mais eficiente para as partes, mas, será o melhor resultado para o vencedor.³¹¹

Através de modelos matemáticos e conceitos específicos a teoria dos jogos objetiva compreender como as escolhas individuais de cada jogador afetam o resultado geral e, ainda, como as estratégias ótimas podem ser identificadas para maximizar o resultado próprio ou coletivo.³¹² Com diversas aplicações práticas esta teoria é muito utilizada no debate de temas internacionais e globais, especialmente quando envolve um ambiente de recursos limitados e

³⁰⁹ A teoria dos jogos tem sua origem frequentemente atribuída a John von Neumann e Oskar Morgenstern, que em 1944 publicaram o livro *"Theory of Games and Economic Behavior"*.

³¹⁰ É o caso, por exemplo, do dilema do prisioneiro. Aqui temos um problema clássico da teoria dos jogos que ilustra um conflito entre interesse próprio e cooperação mútua, em uma narrativa que busca facilitar a compreensão da matriz matemática que o sustenta para que, intuitivamente, se perceba qual é a dificuldade em se encontrar uma única resposta, uma única solução para um caso (daí o “dilema”). Este é um “jogo” já aplicado em dinâmicas internacionais com o envolvimento de atores auto interessados em situação na qual os atores devem necessariamente optar por uma estratégia. Nesta teoria, os atores podem escolher buscar seus próprios interesses ou atuarem de forma coordenada ou cooperativa, sendo que quando os atores buscam seus próprios interesses tendem a obter resultados piores do que se optassem pela cooperação. Mesmo com a cooperação, isso não quer dizer que o resultado obtido será o melhor.

³¹¹ GEISINGER, Alex e STEIN, Michael Ashley. *Rational Choice, Reputation and Human Rights Treaties*. Michigan Law Review, Vol. 106, Nº 6, 2008.

³¹² Na esteira da evolução da teoria dos jogos, em 1950 John Nash propôs um conceito central que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Economia em 1994. Trata-se do equilíbrio de Nash que, em síntese, descreve uma situação em um jogo em que cada jogador está fazendo a melhor escolha possível, levando em consideração as escolhas dos outros jogadores. De se pontuar, contudo, que nem todos os jogos têm um equilíbrio de Nash único, e alguns jogos podem até não ter equilíbrio de Nash. Além disso, pode haver equilíbrios de Nash que não são eficientes em termos globais.

escassos, em que a modelagem analisa como os recursos devem ser alocados de forma eficiente e equitativa.

Ao se transpor a teoria dos jogos para o campo da saúde, observa-se que ela parte de uma lógica inerente de escassez: recursos limitados devem ser distribuídos de modo a maximizar resultados coletivos. Essa racionalidade pode ser eficaz em contextos como vacinação, prevenção ou controle de epidemias, em que os benefícios alcançam grandes parcelas da população.

No entanto, no caso das doenças raras e ante a própria natureza dos custos elevados, do pequeno número de pacientes e da ausência de dados robustos, cria-se um viés estrutural – o “jogo” – que tende a excluir esses indivíduos, uma vez que a decisão ótima sob critérios puramente estratégicos prioriza ganhos imediatos e mais amplos. O que se apresenta como uma escolha racional e inevitável acaba por institucionalizar a invisibilidade das raridades.

Em outras palavras, o modelo de análise proposto pela teoria dos jogos, embora relevante para a macrogestão de recursos em saúde, mostra-se insuficiente para enfrentar os dilemas éticos e o direcionador de equidade na perspectiva do princípio do acesso à saúde para as doenças raras.

Se o melhor resultado do “jogo” ainda não é eficiente para as partes, muito menos o será para os pacientes raros, que acabam sistematicamente posicionados no papel de perdedores. Essa limitação revela que para pensar políticas de acesso à saúde em doenças raras é necessário buscar referenciais teóricos que superem a lógica puramente estratégica e incorporem o princípio da acessibilidade e seus direcionadores no processo decisório.

4.1.2. Escolha racional

A teoria da escolha racional é uma abordagem amplamente utilizada nas ciências sociais, com ênfase em ciência política e sociologia, para explicar o comportamento humano em cenários e situações de tomada de decisão. Partindo do pressuposto de que os indivíduos são agentes racionais, a teoria afirma que os indivíduos buscam tomar decisões que maximizem seus interesses e objetivos, dados os recursos, suas preferências e as informações disponíveis.³¹³

Noutras palavras, a escolha a ser feita passa pelas preferências do decisor com a premissa de que todas as informações estariam disponíveis para a tomada da decisão de modo

³¹³ TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. *Rational Choice and the Framing of Decisions*. The Journal of Business 59, no. 4 (1986): S251–78.

racional.³¹⁴ Assim, com essa ideia teórica, a escolha racional seria aplicada em política pública de saúde para analisar o comportamento dos atores envolvidos como pacientes, profissionais de saúde, governos, produtores de medicamentos, seguradoras, dentre outros; e, com isso, permitiria prever como esses atores podem tomar decisões baseados em seus interesses e objetivos.

Em temas relacionados ao direito de minorias, ainda mais, vinculado à saúde de raridades – em que nada é exato e há muita incerteza –, a teoria da escolha racional parece não permitir processar todas as informações disponíveis para uma tomada decisória, especialmente pelo fato de que as doenças raras convivem com muita assimetria informacional, externalidades e complexidade decisória, ensejando decisões com racionalidade bem mais limitada. Da mesma forma que na teoria dos jogos, a teoria da escolha racional mostra-se insuficiente para enfrentar o direcionador de equidade e, ainda, de racional científico, na perspectiva do princípio do acesso à saúde.

4.1.3. Teoria da racionalidade limitada

Se o contexto das raridades impõe decisões com racionalidade bem mais limitada, eis a teoria da racionalidade limitada que foi introduzida por Herbert Simon, Nobel de Economia em 1978. Sua teoria reconhece que os indivíduos possuem limitações em sua capacidade de processar informações e tomar decisões completamente racionais. Simon argumenta que os seres humanos têm recursos cognitivos limitados e, portanto, não podem processar todas as informações disponíveis antes de tomar uma decisão. O que esta teoria afirma é que as pessoas recorrem a regras simplificadas e heurísticas (atalhos) para a tomada de decisão.³¹⁵

Estes atalhos mentais permitem que as pessoas cheguem a soluções satisfatórias, mas, não necessariamente ótimas, em um tempo e esforço razoáveis. Ao enfatizar que as escolhas humanas são frequentemente satisfatórias, busca-se por essa teoria uma solução que seja “boa o suficiente” para atender às necessidades do momento, mesmo que não seja a melhor possível. Reconhece-se, assim, que decisões são frequentemente tomadas em condições de incerteza e sob restrições de tempo e recursos e que, portanto, os seres humanos tendem a buscar soluções mais simples dada a natureza imperfeita e complexa da tomada de decisão.

³¹⁴ JORDI, Ferrer Beltrán. RATTI, Giovanni Battista (eds). *The Logic of Legal Requirements: Essays on Defeasibility*. Oxford, 2012; online ed. Oxford Academic, 24 Jan. 2013.

³¹⁵ SIMON, Herbert. *A behavioral model of rational choice*. The Quarterly Journal of Economics, v. 69, n. 1, p. 99-118, feb. 1957. As heurísticas (atalhos mentais) e os vieses cognitivos destacam como os seres humanos recorrem aos atalhos e podem ser influenciados por vieses, no processo decisório, resultando em desvios sistemáticos do comportamento totalmente racional.

A aplicação desta teoria em política pública de saúde fornece uma base para entender o comportamento de atores envolvidos, levando em conta preferências individuais e os incentivos para melhorar a eficiência e a eficácia do sistema de saúde. No âmbito das doenças raras, parece que a teoria enfrenta uma certa dificuldade quando o decisor se depara com as externalidades e a complexidade intrínseca ao tema das raridades que vai além da perspectiva da doença e do paciente, afetando todo o seu entorno social como explicado no primeiro capítulo desta pesquisa.

Essa complexidade acentua as tensões entre escolhas pragmáticas e o imperativo normativo do direito à saúde e do acesso à saúde. Assim, a teoria da racionalidade limitada, embora útil para descrever os mecanismos de tomada de decisão em contextos de escassez, revela suas limitações quando confrontada com a exigência do amplo conceito do direito à saúde e da execução do acesso à saúde de modo equitativo. Diante das doenças raras, não basta buscar soluções que sejam boas o suficiente. Impõe-se enfrentar o desafio de compatibilizar restrições práticas com o direito à saúde, sob pena de que a racionalidade se converta em barreira à própria efetivação desse direito fundamental.

4.1.4. Escolha ou preferência social

Aplicada principalmente em ciência política e economia do bem-estar, a teoria da escolha social explora como decisões coletivas são tomadas e como as preferências individuais se agregam para formar decisões coletivas. Ao contrário da tomada de decisão individual, a agregação de preferências individuais nem sempre leva a uma decisão coletiva clara e consistente.³¹⁶

Explora-se, aqui, o conceito de “paradoxos sociais”, nos quais diferentes métodos de agregação de preferências podem levar a resultados contraditórios e inconsistentes. Esses paradoxos, como o paradoxo de Condorcet ou o dilema do votante,³¹⁷ evidenciam que não existe um método perfeito para transformar preferências individuais em decisões coletivas sem violar alguns critérios de justiça ou coerência. Algo será violado.

³¹⁶ ARROW, Kenneth Joseph. *Social choice and individual values*. Yale University Press, 2012 (original publicado em 1951).

³¹⁷ Trata-se de um fenômeno que ocorre quando os resultados das eleições são inconsistentes e não existe um vencedor claro, mesmo quando os eleitores expressam suas preferências de forma coerente e consistente. Esse paradoxo foi inicialmente identificado pelo matemático e filósofo francês Marquês de Condorcet no século XVIII. O paradoxo demonstra que não existe um método de votação perfeito que sempre leve a uma escolha social consistente e sem ambiguidades.

Para lidar com os desafios da escolha social alguns teoremas já foram propostos.³¹⁸ Tais teoremas foram sugeridos mais como um modo de governança, do que solução, na busca de resultados de processos mais democráticos. A complexidade e os desafios inerentes à tomada de decisão coletiva, clara e consistente, em um contexto social, é um dos grandes desafios mundiais e temática que vem contribuindo para o debate sobre como alcançar resultados mais justos e representativos em ambientes coletivos.

Ao se aplicar a teoria da escolha social em política pública de saúde os tomadores de decisão podem considerar adequadamente as preferências e necessidades da população. Não obstante, também podem deixar de lado interesses de minorias em detrimento do interesse coletivo de maiorias. Especialmente se a política decisória estiver arraigada em um fundamento de modelos matemáticos e diante de recursos limitados.

Quando aplicada ao contexto das doenças raras, a teoria expõe uma tensão fundamental que é o risco de que os interesses da maioria se sobreponham às necessidades de minorias. Se, por um lado, a escolha social pode favorecer processos mais democráticos e representativos, por outro, é insuficiente para assegurar, por si só, políticas equitativas em áreas de alta complexidade e custo, como as doenças raras.

4.1.5. Teoria da escolha pública

Esta teoria se concentra na análise das decisões coletivas tomadas por governos e instituições públicas. Examina como os interesses individuais se traduzem em políticas públicas e como as instituições podem ser projetadas para produzir resultados democráticos e eficientes. Noutras palavras, como as preferências dos eleitores influenciam as políticas públicas e como os governos respondem aos incentivos e pressões políticas.³¹⁹

O marco desta teoria está na afirmação de que não importa quais são os incentivos em um ambiente público ou privado pois, ao fim e ao cabo, os indivíduos sempre estarão sujeitos aos seus próprios interesses e na maximização destes.

Esta teoria se diferencia da teoria da escolha social pelo fato de que, enquanto a teoria da escolha pública explora como as decisões são tomadas dentro das instituições governamentais e políticas, a teoria da escolha social analisa como as preferências individuais

³¹⁸ Cite-se o teorema da impossibilidade de Kenneth Arrow que estabelece que não existe um sistema de votação que atenda a todos os critérios desejáveis de uma escolha social, como unanimidade, independência de alternativas irrelevantes e ausência de ditadores. ARROW, Kenneth Joseph. *Social choice and individual values*. Yale University Press, 2012.

³¹⁹ BUCHANAN, James; TULLOCK, Gordon. *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Indianapolis: Liberty Fund, 1999.

são agregadas para formar uma vontade coletiva ou decisão social. São teorias que, analisadas conjuntamente, auxiliam no entendimento dos processos de tomada de decisão em sociedades mais complexas.

No recorte do direito à saúde, a teoria da escolha pública analisa como os formuladores de políticas decidem alocar recursos para diferentes programas de saúde, considerando os incentivos e preferências dos diferentes grupos de interesse. Isso inclui a análise de como as decisões são influenciadas por fatores políticos, econômicos e sociais.

Através desta teoria é possível identificar o desenho das instituições políticas e fazer sua conexão com o direito em busca da aplicação dos princípios jurídicos na tomada de decisão e, mais do que isso, da melhora institucional da transparência e de responsabilização dos decisores. A teoria traz um norte do se busca para compreender o como se decide e revela-se parcialmente compatível com o acesso à saúde em doenças raras ao permitir compreender como os incentivos, interesses individuais e pressões de grupos de poder moldam as decisões estatais na alocação de recursos.

Ao explicitar que mesmo em ambientes públicos os decisores perseguem seus próprios interesses, a teoria oferece um diagnóstico realista sobre os limites da racionalidade coletiva e a tendência de privilegiar maiorias em detrimento de minorias, como é o caso das raridades. Essa mesma característica expõe sua fragilidade diante do princípio do acesso à saúde. Ora, se a lógica da maximização individual ou política prevalece, os custos elevados e o baixo impacto eleitoral das doenças raras podem conduzir a exclusões. Assim, a teoria ajuda a explicar a assimetria decisória, mas, por si só, não fornece mecanismos para corrigi-la.

A teoria da escolha pública mostra exatamente o *como* se decide, mas é o direito que deve impor limites normativos, ampliar a transparência, garantir participação social e reduzir a assimetria de poder na formulação de políticas de saúde. Ainda mais quando se está diante da escassez artificial de recursos. É aqui que o direito tem a possibilidade de entrar em cena e impor o cumprimento do princípio do acesso à saúde e de seus direcionadores.

4.1.6. Economia comportamental

Da integração de conceitos oriundos de estudos teóricos e análises empíricas provenientes da psicologia, neurociência e ciências sociais, fundidos com os princípios da

economia, surgiu a chamada economia comportamental³²⁰ como uma linha de pensamento que desafia a visão tradicionalista da economia baseada no conceito do *homo economicus*.³²¹

Enquanto as teorias decisórias clássicas, como a teoria da escolha racional, assumem que os agentes econômicos são perfeitamente racionais e maximizam sua utilidade ou lucro de acordo com preferências consistentes, a economia comportamental reconhece que os seres humanos muitas vezes se desviam desses pressupostos tidos como ideais pela economia.

Essa linha de pensamento defende que os hábitos, aliados à vivência de cada pessoa, são os direcionadores da tomada de decisão dos indivíduos, ou seja, as pessoas se utilizam dos seus atalhos mentais para a tomada de decisão de forma intuitiva. Na prática, o que isso significa: decisões são tomadas com base no que o decisor está ancorado (*heurística de ancoragem*), no que ele representa (*heurística de representatividade*) e no que está acessível e disponível momentaneamente ao decisor (*heurística de disponibilidade*).³²²

O que se quer dizer com esses atalhos mentais é que a tomada de decisão – por mais racional que possa ser – possui vieses. São os vieses, entretanto, que podem distorcer ou limitar a capacidade decisória trazendo erros na tomada da decisão (ex. a criação de um estereótipo ou pré-conceitos). Não é diferente o que ocorre com as raridades que, muitas vezes sofrem de vieses dos decisores de políticas públicas quando estes – que não são representativos das raridades – tomam suas decisões sobre alocação dos recursos financeiros para o acesso à saúde.

Essas decisões, por sua vez, geralmente estão ancoradas na ATS e em um daqueles quatros critérios de análises econômicas que foi tratado no capítulo segundo (ACB, ACM, ACE e ACU), além do limiar ou limites de custo-efetividade. É nesse contexto que a economia comportamental se relaciona com esse trabalho. Pelos vieses – alguns inconscientes – que

³²⁰ Daniel Kahneman e Amos Tversky foram os pioneiros dos estudos da chamada economia comportamental aos desenvolverem muitas das teorias fundamentais sobre os vieses cognitivos e heurísticas que influenciam o processo de tomada de decisão. Para os autores existem dois grandes sistemas cognitivos a uma tomada de decisão: o de julgamento analítico, baseado na lógica racional e o de componente intuitivo, baseado em variáveis emocionais e em atalhos mentais (heurísticas), sendo que esse segundo sistema, por vezes, contradiz o primeiro. Sobre o tema, vide TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniela. *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*. Science, v. 185, n. 4157, 1974. p. 1124-1131. THALER Richard; SUSTEIN Cass R., *Nudge – Improving decisions about health, wealth and happiness*. New Heaven & London: Yale University Press, 2008.

³²¹ O Homem Econômico é o conceito segundo o qual o homem é um ser racional, perfeitamente informado e centrado em si próprio, um ser que deseja riqueza, evita trabalho desnecessário e tem a capacidade de decidir de forma a atingir esses objetivos. Sobre o tema, vide THALER, Richard. *From Homo Economicus to Homo Sapiens*. Journal of Economic Perspectives, v. 14, 2000. p.133-141.

³²² LEWIS, Alan. *The Cambridge handbook of psychology and economic behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

decorrem das decisões tomadas por quem faz as escolhas sobre saúde pública em cada Estado-nação.

Ao integrar a economia comportamental à análise das decisões em saúde, evidencia-se que as escolhas públicas não são apenas moldadas por incentivos racionais e estruturas institucionais. Também o são por vieses cognitivos que afetam diretamente a alocação de recursos. Esses vieses, quando não corrigidos, tendem a reforçar a invisibilidade das doenças raras, perpetuando decisões baseadas em percepções limitadas, heurísticas imediatas ou estereótipos que desfavorecem grupos minoritários.

Portanto, compreender a influência desses atalhos mentais e reconhecer seus efeitos sobre os decisores é fundamental para propor mecanismos de correção que pode ser feito por meio de maior participação social com a aplicação do direcionador de transparência do princípio do acesso à saúde.

4.2. Concluindo as teorias decisórias e o como se decide

Para melhor didática, sintetiza-se a partir do quadro 2 as principais teorias decisórias discutidas, destacando como essas teorias podem ser aplicadas ao campo da saúde, em especial nas doenças raras.

Quadro 2 - Quadro resumo das teorias decisórias

Teoria	Ideia Central	Aplicação na Saúde
Teoria dos Jogos	Atores estratégicos reagem uns aos outros	Negociações internacionais sobre preços de medicamentos. Risco de exclusão de raridades por lógica de maximização coletiva
Escolha racional	Decisores maximizam utilidade	Governo prioriza maior impacto populacional; raridades pode ficar em desvantagem pela assimetria informacional e alto custo por paciente
Racionalidade limitada	Decisores têm informação e tempo restritos	Profissionais de saúde escolhem terapias mais conhecidas, mesmo sem dados completos; risco de soluções “boas o suficiente” que negligenciam doenças raras
Escolha ou preferência social	Preferências individuais agregadas para formar decisão coletiva; presença de paradoxos	Políticas majoritárias tendem a suprimir necessidades de minorias; risco de invisibilidade das raridades diante da lógica do voto da maioria
Escolha pública	Decisões moldadas por incentivos e interesses políticos dentro das instituições (ex.: interesses eleitorais)	Alocação de recursos responde a pressões eleitorais e de grupos; doenças raras têm baixo peso eleitoral, favorecendo exclusão
Economia comportamental	Decisões moldadas por vieses cognitivos e heurísticas (atalhos mentais)	Percepções sociais de risco e estereótipos distorcem decisões sobre raridades; dependência de critérios econômicos como limiares de custo-efetividade

(Fonte: o autor)

O que se extrai de todas as teorias analisadas é que não existe uma única teoria que, por si só, auxiliará a compreender o como se decide. Ao contrário. É do conjunto de todas as teorias que se chega às conclusões desta pesquisa. Isto, porque, o que se viu do todo é que as teorias mostram que governos apresentam falhas, da mesma forma que o mercado e que não há uma forma única de se decidir.

Não há fórmulas nem teorias completas para lidar com a irracionalidade. Inexiste um manual para se seguir. A premissa é que o agente decisor é racionalmente limitado e, ainda, que o auto interesse que determina escolhas individuais na esfera privada também motiva escolhas na esfera pública. O ser humano também procura economizar ao agir na condição de agente público a fim de maximizar os resultados que deseja obter com o mínimo de gasto ou esforço.

As pessoas têm valores, motivações e desejos. Buscam seus atalhos mentais. São influenciadas pelos meios em que vivem. Possuem desejos e interesses. O interesse próprio é, pois, um fator de motivação dentro de todo o sistema de como se decide. A falibilidade humana é um fato. Ainda, por mais que as pessoas estejam a serviço de uma sociedade, os vieses existem e sempre existirão.

A existência de vieses pode ser minimizada até certo ponto. Inexiste romantismo na realidade institucional. Em um ambiente público também se convive com uma racionalidade limitada que é inerente à toda cognição humana. Sim, os decisores públicos recorrem a heurísticas para lidar com tarefas complexas.

É, no mínimo, incômodo aceitar que os tomadores de decisão nem sempre estão imbuídos da defesa do interesse público, tal qual é difícil aceitar que os direitos possuem um custo. Mas essa é a realidade fática que envolve a temática da saúde e que a sociedade (em sentido amplo) pode querer negar, aceitar sem questionamentos ou, ainda, compreender e trabalhar a partir do acesso à saúde de modo a garantir o direito à saúde.

É aqui que o direito atua. O direito pode – e deve – explorar os *insights* derivados das teorias decisórias em busca da interface para a melhora da normatividade entre o *como* se decide e *quem* decide. O marco teórico de como se decide já restou exposto através deste capítulo e dos antecedentes. No conceito da saúde pública o como se decide está na forma como se proporciona o acesso ao direito à saúde. O que se faz necessário compreender, agora, é *quem* faz as escolhas. Quem faz as escolhas alocativas dos recursos e impõe a escassez artificial.

4.3. Quem faz as escolhas: quem detêm o poder

Abordou-se antes que os donos do poder, ou quem detêm o poder, são aqueles que possuem a capacidade de influenciar, controlar ou direcionar os outros e os recursos disponíveis. Também foi dito que o poder pode ser executado de diferentes formas, sendo que a busca pelo equilíbrio e decisões mais justas e equânimes respeitaria tanto a forma de se fazer escolhas (*o como decidir*), quanto aos participantes da decisão (*o quem decide*). É dos participantes da decisão que este tópico tratará.

O surgimento do poder político está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento das sociedades humanas. Surge da necessidade de organização de grupos de indivíduos para garantir a ordem social, resolver conflitos e tomar decisões coletivas que afetam um todo. Já o poder econômico se origina, geralmente, do acúmulo de riquezas em conjunto com um certo grau de monopólio e influência política.

Na organização da ordem social o direito cria uma ampla normatividade que deve ser observada pelos indivíduos na sociedade. A conduta humana passa a ser valorada por esta normatividade. São normas que, quando e se descumpridas, estarão sujeitas ao crivo dos órgãos de controle que terão por objetivo restabelecer um *status quo*. O objetivo é simples: de forma dinâmica, tentar controlar o jogo e os donos do poder.

No Brasil, por exemplo, por conta da tradição histórica que remonta à própria formação do Estado Português, o país se constituiu como uma ordem jurídica antes de ser constituído como nação, tendo suas bases enraizadas no patrimonialismo, centralismo monárquico e burocracia estatal, fazendo com que o Estado fosse uma mera organização administrativa de atuação portuguesa e, não, um ente protetor dos interesses da população.³²³

É do contexto histórico do país que advém o autoritarismo e que faz com que os governantes se comportem como “donos do poder”, apesar de decorridos mais de 200 anos de sua independência e já passadas décadas de vigência da constituição mais democrática que o país já teve. Não diferente ocorre em outros Estados-nação em que os governantes tentam se comportar como verdadeiros donos do poder conforme se confere da recente polarização política que vem ocorrendo no mundo.

Os modelos patrimonialistas, que ainda remanescem no Brasil³²⁴ e outros países ao redor do mundo, são comumente centrados em nepotismo (o governante fazendo a

³²³ FAORO, Raymundo. *Os donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. p.1-15.

³²⁴ NOHARA, Irene Patrícia. *Reforma Administrativa E Burocracia: Impacto Da Eficiência Na Configuração Do Direito Administrativo Brasileiro*. Atlas, 2012.

distribuição de cargos conforme sua vontade e conveniência), clientelismo (contratações feitas com base nos grupos de interesses dos governantes) e fisiologismo (concessão de vantagens aos governantes), em uma dinâmica em que os donos do poder atuam em um sistema de benefícios próprios e de grupos de interesses próprios. Trata-se de uma típica troca de favores.³²⁵

Para “quebrar” esse jogo de poder entram as decisões dos Tribunais que, como falamos antes, permite o controle e ajuste do poder decisório, especialmente em relação a minorias e aos que não detêm o controle decisório do poder. São as cortes que possuem papel central para equilibrar o sistema. Cortes que, quando inexistem ou quando falham, desequilibram ainda mais o sistema e possuem o condão de negar o princípio da acessibilidade.

É por isso que se faz necessário a existência de sistemas de justiça robustos, independentes e forte pois, como dito antes, a judicialização da saúde é uma ferramenta que garante o cumprimento de direitos fundamentais, quando e se necessário, para que um indivíduo ou grupo de indivíduos possam conquistar o direito fundamental à saúde. Apesar da força e importância das cortes, não é objetivo desta tese depender do sistema judiciário interno ou internacional para tanto. Quer-se que os Tribunais atuem – sempre e quando necessário – mas, o que se sonha aqui é o momento em que a necessidade de se buscar as cortes não seja mais necessário, nem em caráter de exceção.³²⁶

Afinal, é dolorosa a situação real de uma pessoa que precisa acessar os Tribunais para ver um direito humano fundamental ser concretizado. Somente aqueles seres humanos que já vivenciaram essa realidade talvez saibam o que é essa dor! Não há como saber a razão pela qual o indivíduo sofre, mas, há como saber quem e o como o mundo decide que este sofrimento sobrevirá para alguns indivíduos.³²⁷

Colocar luz nas batalhas que enfrentam os cidadãos que vivem com doenças raras e que lutam, muitas vezes, de forma solitária e incompreendida pela sociedade é fundamental

³²⁵ NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa para além do discurso do “cidadão-cliente”: do paradigma econômico da eficiência ao ingrediente político da participação. In SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva; SIQUEIRA NETO, José Francisco. *60 desafios do Direito: política democracia e direito*. v.3. São Paulo: Atlas, 2013. p.35-36.

³²⁶ AITH, Fernando; BUCCI, Maria Paula Dallari. “O direito à saúde no Brasil: seus fundamentos e sua judicialização.” In: *Saúde, Estado e Democracia: estudos sobre a judicialização da saúde no Brasil*. São Paulo: Fiocruz, 2015. Destacam os autores que: “a efetividade do direito à saúde depende de políticas públicas que articulem recursos escassos com princípios de equidade, universalidade e integralidade, sob risco de o reconhecimento normativo permanecer apenas no plano formal” (p.43)

³²⁷ CALABRESI Guido e BOBBIT Philip. *Tragic Choices: The conflicts society confronts in the allocation of tragically scarce resources*. Norton, New York, 1978. p.17.

para que esses indivíduos consigam executar o seu direito à saúde. Para que não sintam que este direito seja tão distante quanto o Monte Olimpo.

Quem decide precisa conhecer a realidade. Precisa tê-la sob perspectiva no momento decisório para que, conhecendo a realidade, possa aprimorar e tornar mais equânime o como se decide. Entender o jogo de poder decisório e mudá-lo, sem de ter de se socorrer aos limites dos Tribunais é o que se anseia com um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras.

Para tanto, o direito novamente entra em cena com o objetivo de promover o acesso à saúde através de seus direcionadores. E aqui, mais especificamente, o direcionar de transparência através da publicização e processualização do processo decisório administrativo sobre o acesso à saúde para as minorias.

O objetivo é criar consciência cívica e política dos cidadãos de cada Estado-nação e permitir que através da transparência, um dos direcionadores do acesso à saúde, os cidadãos possam atuar e participar de modo mais eficaz e eficiente nas decisões de alocação de recursos que impacto os direitos sociais. É a transparência prévia na forma de agir do Estado-nação para que a sociedade participe e tenha acesso aos canais de comunicação com os formuladores das políticas públicas.

A história mostra que um pequeno grupo detentor de poder tem a capacidade de legitimar atos de exclusão social.³²⁸ De tal modo, não basta – apenas – que um Estado-nação adote um regime político para garantir que não ocorram exclusões sociais. É necessário que este Estado atue para inserir os grupos sociais (inclusive minorias), nos debates e nos processos decisórios. A participação e inclusão dos atores que são afetados em um determinado tema é o meio para aperfeiçoar a inclusão social e garantir decisões mais justas e equânimes.

Dentre os aperfeiçoamentos está a necessidade de se institucionalizar as regras pelas quais são estabelecidas o exercício do poder; como são escolhidos os representantes de cada um dos entes decisórios e, com isso, legitimar o poder diverso e inclusivo. No contexto do direito à saúde é buscar um pragmatismo à teoria da reserva do possível³²⁹ que foi difundida

³²⁸ SANTOS, Boaventura de Sousa. *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência*. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

³²⁹ Essa teoria tem origem em um debate do Tribunal Constitucional da Alemanha no julgamento da decisão conhecida como *numerus clausus*, que versava sobre o direito de acesso ao ensino superior. O Tribunal alemão concluiu que a prestação reclamada deveria corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, não se podendo falar em uma obrigação estatal fora dos limites do que é proporcional e razoável. Sobre o tema, vide ALEXY, Robert. *Teoria de Los Derechos Fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.

no mundo como uma forma de se impor razoabilidade à execução dos direitos que estão constituídos ao redor do mundo.³³⁰

Em uma outra perspectiva esta teoria também trata do custo do acesso à saúde e uma vida vivida com dignidade. A teoria da reserva do possível funciona como o limite para a efetivação do direito (e no contexto deste trabalho o direito à saúde), considerando restrições financeiras e estruturais de cada Estado.³³¹ Ela limita os recursos financeiros e administrativos do Estado que condiciona a concretização de direitos, como o acesso à saúde.

Contudo, parece-nos que essa teoria não é passível de oposição e aplicação para o contexto das doenças raras³³² já que mesmo diante de limitações orçamentárias, um Estado-nação deve assegurar o acesso à saúde (minimamente para diagnóstico e tratamentos essenciais) para indivíduos com doenças raras. Isto, pois, este acesso à saúde das raridades está intrinsecamente relacionado à garantia do mínimo existencial, que foi abordada no primeiro capítulo deste trabalho e que, na perspectiva e recorte das doenças raras, resguarda o patamar mínimo de dignidade para que o acesso à saúde pelas raridades não se converta em promessa vazia. A única exceção seria em um momento de escassez natural de recursos.

4.3.1. Controle do poder e os anseios sociais

Os decisores ou donos do poder que moldam a história do mundo tinham sua origem na aristocracia, em uma nobreza hereditária dotada de lideranças com poder e status, ou à grupos de interesses detentores de grandes recursos e capazes de proporcionar capturas

³³⁰ No Brasil, Sarlet e Filchtiner defendem que se faz necessário conferir uma dimensão tríplice à reserva do possível e que consiste na: (i) efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais; (ii) disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos; (iii) proporcionalidade da prestação, em especial à exigibilidade e razoabilidade. SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. *Reserva do possível, mínimo existencial e direitos à saúde: algumas aproximações*. In: SARLET, Ingo Wolfgang e TIMM, Luciano Benetti e BARCELLOS, Ana Paula de [et al]. *Direitos Fundamentais: orçamento e reserva do possível* – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. Mais sobre reserva do possível vide BARROSO, Luis Roberto. *A nova interpretação constitucional: fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro*. Rio de Janeiro. Renovar, 2002. Vide, também, TORRES, Ricardo Lobo. *O mínimo existencial e os Direitos Fundamentais*, Revista Brasileira de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 177, 1989.

³³¹ CALIENDO, Paulo. Reserva do possível, direitos fundamentais e tributação. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). *Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”*. 2 Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013.

³³² A conclusão não é nova e já foi abordada de forma bem estruturada na dissertação de mestrado acadêmico em direito médico, no âmbito do programa de pós-graduação da Universidade Santo Amaro por PEREIRA, Gabriel Massote. *DOENÇAS RARAS: A inaplicabilidade da reserva do possível em seu custeio. Supremacia do Mínimo Existencial como balizador de direitos fundamentais*. São Paulo, 2023.

normativas para manter o poderio.³³³ Estes decisores, direta ou indiretamente, detinham forte influência política no jogo de poder interno dos Estados-nação.³³⁴

Séculos passaram e, a despeito de toda evolução social e ideais democráticos existentes em alguns Estados-nação, ainda persiste a principal semelhança entre os donos de poder do passado com os do presente: a homogeneidade. É a partir da homogeneidade de interesses, falas, pensamentos e decisões que o mundo vem sendo tradicionalmente gerido e controlado pelos poderes político e econômico.

Uma homogeneidade que, mesmo em momentos disruptivos davam sinais de mudanças, mas, em uma evolução linear em que permitia-se definir, de forma clara, marcos históricos significativos que perdurariam por décadas até uma nova mudança. Em ciclos lineares e longínquos o poder era mantido ou alternado, mas, quase sempre, um poder arraigado pela homogeneidade.

Contudo, este ciclo vem sofrendo pressão para mudanças. E pode ser que não sejam mudanças para uma sociedade mais justa e democrática.³³⁵ Já foi visto ao longo deste trabalho como a tecnologia se conecta com o direito e a saúde no tempo e no espaço. Uma conexão global e digital que em breve tende permitir que pacientes consigam diagnosticar sua raridade em tempo muito inferior ao de anos da realidade atual, mas, ao mesmo tempo, impõe um desafio cada vez maior em relação ao custo dos sistemas de saúde mundiais, em especial em sistemas de saúde universais, regiões com alto índice de desigualdade social e polarizações do jogo de poder político e econômico global.

A crescente sofisticação tecnológica e a expansão das redes de conexão têm pressionado os ordenamentos jurídicos de cada Estado-nação a um ponto em que estes já não conseguem mais absorver, estabilizar ou controlar plenamente a complexidade gerada. Essa realidade desafia as teorias tradicionais do direito e do Estado. Como observa Ricardo Campos, em sua tese de doutorado, os impactos do tempo e da tecnologia estão promovendo uma profunda metamorfose do direito em escala global.³³⁶

Campos argumenta que a crescente complexidade tecnológica e a aceleração temporal desafiam as estruturas jurídicas tradicionais, exigindo uma reconfiguração das bases normativas para que o direito se mantenha eficaz e relevante. O direito não pode mais ser visto

³³³ MOSCA, Gaetano. *A classe política*. Brasília: Editora da UnB, 1982.

³³⁴ MILLS, Charles Wright. *A elite do poder*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

³³⁵ LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. *Como as democracias morrem*. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

³³⁶ CAMPOS, Ricardo. *Metamorfoses do direito global: sobre a interação entre o direito, tempo e a tecnologia*. São Paulo: Editora Contracorrente, 2022.

como uma entidade estática e deve evoluir em resposta às mudanças rápidas, conjuntamente com abordagens interdisciplinares.

A mesma complexidade tecnológica e aceleração temporal que desafiam o direito global também se refletem na saúde. Para garantir o direito à saúde, o direito precisa se adaptar, incorporando os direcionados do princípio do acesso à saúde nas políticas de saúde. Essa é uma forma de responder à metamorfose do mundo digital e globalizado sem se restringir às estruturas jurídicas tradicionais.

Aumentando a tensão desta metamorfose, recentes avanços da psicologia comportamental e das neurociências trazem novos questionamentos sobre a regulação de conduta e a forma como os seres humanos reagem à incentivos. Os avanços ainda incipientes, dado que a neurociência ainda não foi capaz de explicar detalhes com um todo da consciência e o completo mecanismo decisório, apontam que a racionalidade de cada indivíduo é determinada por sua biologia: decisões tomadas pelos indivíduos não estariam completamente revestidas do livre arbítrio³³⁷ como visto anteriormente na abordagem das teorias decisórias.

Do grau de racionalidade das decisões aos vieses que estão submetidos os tomadores de decisão, os estudos da psicologia comportamental e das neurociências, geralmente com suporte empírico, apresentam respostas mais aprofundadas do que as tradicionais teorias jurídicas e econômicas. Essa realidade pressiona os Estados-nação e tomadores de decisão de políticas públicas para que busquem – sem aparente êxito³³⁸ – atingir os anseios sociais com base nas tradicionais formas de atuação.

Todo esse contexto também se interrelaciona com os tomadores de decisão. Os poderes político e econômico são dinâmicos e podem evoluir ao longo do tempo, respondendo a mudanças sociais, culturais, econômicas e, mais, recentemente a mudanças e inovações tecnológicas do mundo globalizado.³³⁹ É a partir da evolução, especialmente quando uma sociedade vivencia momento disruptivos e/ou momentos de crise, que brotam as mudanças de

³³⁷ MARDEN, Carlos; WYKROTA, Leonardo Martins. Neurodireito: o início, o fim e o meio. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 8, nº 2, 2018 p.48-63.

³³⁸ Se as decisões sobre políticas públicas estivessem sendo exitosas, em pleno século XXI vivenciar-se-ia uma guerra (Ucrânia desde 2022), tentativas de golpes de Estado (Peru, 2022-2023) e invasões em parlamentos como ocorreram nos EUA (2021) e no Brasil (2022), além dos constantes e mais acentuados conflitos (a partir de 2024) entre Israel e Irã e Hezbollah e, os EUA (2025) impondo taxas à diversos países com uma gestão política sendo realizada a base da ameaça?

³³⁹ BOLLERMAN, Michael. Digital Sovereigns: Big Tech and Nation-State Influence. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.21066>. Acesso em: 26.08.2025. Este ensaio argumenta que corporações tecnológicas, com gigantescos valores de mercado, estão se transformando em verdadeiros poderes semelhantes a Estados-nação: regulam, moldam infraestruturas globais, influenciam normas e desafiam o controle estatal tradicional

controle de poder e dos tomadores de decisão por detrás do poder. Especialmente quando este poder é o poder político.

A partir de cenários evolutivos e, como forma de manter controle e poder, surgem as respostas (ou ao menos tentativas de respostas), aos anseios sociais. Assim, como forma de tentar mitigar impactos e os anseios sociais, os decisores políticos tentam inserir a sociedade civil no processo decisório. Um ente público ou órgão governamental com poder decisório tenta deliberar um determinado assunto com a participação de seu público. O faz através de um modelo deliberativo, cuidadoso, com o enquadramento de argumentos e motivações que genuinamente abarcam todos os que falaram.

Entretanto é comum falharem. O motivo: a decisão tomada, geralmente, foi proferida por pessoas que, não necessariamente, são (ou serão) afetadas pela deliberação final. A razão pela qual esse evento ocorre está na baixa heterogeneidade e diversidade dos tomadores de decisão. Como a decisão tomada não tende a afetar (ou não afeta) de forma direta ou indireta o tomador da decisão, é provável que a falha decisória ocorra.

4.3.2. Heterogeneidade na tomada da decisão

A participação dos destinatários na tomada de decisão de normas que os afetam é fortemente defendida pelo teórico frankfurtiano Jürgen Habermas que considera, a partir da teoria do discurso, que somente serão válidas as normas que contemplarem a participação dos seus destinatários.³⁴⁰ As sociedades de modo geral se caracterizam por suas tradições e as instituições acabam por reproduzir ideias de homogeneidade vinculadas às tradições as quais, no dia a dia, acabam por produzir normas que não albergam a heterogeneidade.³⁴¹

A ideia de Habermas é que, a partir da democracia, este fator seja institucionalizado pelo direito de modo a buscar um mecanismo que coíba a colonização do mundo da vida. Uma institucionalização factível já que os sistemas como um todo estão de alguma forma conectados no mundo através do direito formal.³⁴²

Partindo da teoria de Alexy³⁴³ no âmbito da argumentação jurídica, Habermas enumera os pressupostos necessários para a argumentação (pressupostos lógicos, procedimentais e

³⁴⁰ HABERMAS, Jürgen. *O discurso filosófico da modernidade – Doze lições*, São Paulo: Martim Fontes, 2019.

³⁴¹ HABERMAS, Jürgen. *Teoría de la acción comunicativa, II: crítica de la razón funcionalista*. Madrid: Grupo Santilla de Ediciones, S/A, 1999.

³⁴² HABERMAS, Jürgen. *Agir comunicativo e razão destranscendentalizada*. Tradução Lúcia Aragão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012.

³⁴³ ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. 2. Ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. Malheiros: São Paulo, 2017.

processuais), indicando ser legítimo que todo falante (que neste trabalho são as raridades), possa participar dos discursos, problematizar e introduzir questões ou expressar atitudes, desejos e necessidades. Ainda, defende ser ilegítimo impedir que um falante possa fazer uso desses direitos.³⁴⁴

Transpondo a teoria para as doenças raras poder-se-ia argumentar que a ênfase na razão comunicativa sugere que para o enfrentamento dos desafios das doenças raras haja um diálogo inclusivo e democrático, que considere as vozes dos pacientes, profissionais de saúde e formuladores de políticas. Isso implica em uma abordagem mais humana e ética, que vai além da lógica econômica e técnica, reconhecendo a dignidade e os direitos dos indivíduos afetados.

A efetivação desse diálogo inclusivo, entretanto, depende de que a heterogeneidade seja realmente considerada na prática decisória. Imagine que decisões sejam tomadas com a efetiva presença e participação das minorias em um grupo heterogêneo de decisores. A escolha foi feita e deliberou-se a favor da garantia do princípio do acesso à saúde. Decidir implica em fazer escolhas, e toda escolha possui consequências (e um custo), que afetam a todos, inclusive os grupos majoritários.

Perspectivas heterogêneas podem influenciar a tomada decisória e torna-la mais equânime. Sem esta perspectiva – muitas vezes por falta de conhecimento e, não, por uma intenção deliberada de prejudicar direitos – a probabilidade de falha na tomada de decisão será elevada. Essa probabilidade de falha na tomada decisória não é oriunda de uma incerteza, mas, de uma decisão de risco que foi assumida estruturalmente quando da composição do quadro de controle de poder e tomador de decisão.

Este ponto é relevante pois existe diferença prática entre o que é risco e o que é incerteza. Enquanto o risco consiste no nível de uma probabilidade ocorrer e as possíveis mudanças que podem ocorrer dentro no nível do risco, a incerteza se caracteriza pela imprecisão que está envolvida na avaliação dos níveis de risco.³⁴⁵

O modo pelo qual o risco e a incerteza entram no processo de decisão é relevante, pois, em políticas públicas, o pressuposto decisório adotado geralmente está baseado na comparação dos custos, benefícios e probabilidades de sucesso esperado com a política a ser implementada. Incertezas tendem a levar a não implementação de uma política. Já a

³⁴⁴ Para o aprofundamento acerca da legitimidade democrática do direito a partir das teorias de Habermas, Alexy, Dworkin e Luhmann, vide SAAVEDRA, Giovani Agostini. *Jurisdição e democracia*. Uma Análise A Partir Das Teorias De Jürgen Habermas, Robert Alexy, Ronald Dworkin e Niklas Luhmann. 1ª Ed., Livraria do Advogado Editora: Porto Alegre/RS, 2006.

³⁴⁵ Sobre o tema, vide KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. *Prospect Theory: an analysis of decision under risk*. *Econometrica*, n. 2, 1979.

probabilidade de risco poderá – ou não – levar a implementação da política a depender de quem participa da tomada de decisão.

Como estes indivíduos decisores poucas vezes são heterogêneos e diversos, a probabilidade de implementação de políticas públicas para minorias é baixa. É o que ocorre, também, com as raridades que, além de serem pouco representadas no processo decisório ainda convivem com a incerteza do diagnóstico e tratamento das suas enfermidades.

Neste contexto, parece que o critério de análise econômica, de benefícios, custos e riscos não é o melhor critério a ser adotado para se observar o princípio da acessibilidade no contexto das doenças raras. O critério precisa ser outro. Precisa ser mais inclusivo, em busca de maior heterogeneidade decisória. Ao mesmo tempo, tem de observar os direcionadores que integram o princípio da acessibilidade.

Isso não quer dizer que custos serão relegados. Ao contrário. O custo dos direitos precisa ser considerado, mas, estes custos não podem ser o critério decisório final para a tomada de decisão quando o tema é a saúde. Exceto, claro, se o cenário for de uma escassez natural absoluta.

4.4. Conclusão sobre quem faz as escolhas com o olhar para as raridades

Seguindo o racional teórico exposto no tópico anterior, defende-se que a promoção de uma tomada de decisão mais equânime, justa e eficaz passe pela heterogeneidade das decisões. Entende-se que é necessário garantir a representação de diferentes atores e perspectivas. A necessidade de se buscar a interação e participação social em busca da heterogeneidade de decisões é ainda mais latente no contexto das doenças raras, ante todas as peculiaridades já debatidas nos capítulos iniciais desta tese. É tema, que inclusive, já foi trazido por outros estudiosos do assunto.³⁴⁶

Entretanto, essa visão teórica não é fácil de ser implementada na prática. Cada Estado-nação tem sua cultura, suas especificidades, seu regime de governo e a sua forma própria de tomada de decisão. Neste contexto de especificidade local de cada Estado-nação é praticamente impossível pensarmos em uma forma de aumentar a heterogeneidade decisória nos limites internos geográficos de cada ente estatal. Não obstante, esse pensamento poderá ser possível se olharmos o tema sob uma perspectiva global em saúde das raridades.

³⁴⁶ Um pouco mais sobre o tema, vide AITH, Fernando, BUJDOSO, Yasmim, DO NASCIMENTO, Paulo Roberto e DALLARI, Sueli Gandolfi. *Os princípios da universalidade e integralidade do SUS sob a perspectiva da política de doenças raras e da incorporação tecnológica*. Revista Direito Sanitário, São Paulo v.15 n.1, p. 10-39, mar./jun. 2014.

Alguns instrumentos tradicionais de tomada de decisão e participação (ex.: consulta pública e audiência pública), podem ser fortalecidos ao mesmo tempo em que novos instrumentos podem ser implementados em busca da adequação da realidade do tempo tecnológico que vivemos.³⁴⁷ A rede mundial de computadores e as conexões em rede tem se mostrado um espaço adicional, já há um tempo, possibilitando a reunião de diferentes *stakeholders*, nas mais diversas escalas, em que “público e os políticos podem se comunicar, trocar informações, consultar e debater, de maneira direta, rápida e sem obstáculos burocráticos”.³⁴⁸

Essa perspectiva global se conecta com a DUDH e o direcionador de transparência do princípio do acesso à saúde. Busca-se a efetividade prática de outras decisões globais que caminham no mesmo sentido, como a já tratada resolução de caráter social de 2021 da ONU que objetiva enfrentar os desafios das pessoas que vivem com uma doença rara e suas famílias, além da ODS n.º 3 da Agenda 2030 da ONU e a resolução “*Rare diseases: a global health priority for equity and inclusion*” da OMS, de fevereiro de 2025.

Todo esse contexto de tentativa de redução de homogeneidade decisória passa pela adoção de um procedimento de descentralização e delegação do poder decisório que não é perfeito e não é isento de riscos. Os riscos da participação heterogênea precisam ser estudados, conhecidos e debatidos na mitigação de capturas, cooptação, disseminação de comunicação falsa, manipulada e viciada. Delegar e descentralizar poder possui seus desafios que tendem a ser maiores quando as normas que se relacionam com a delegação são principiológicas e de textura aberta.³⁴⁹

A delegação implica arbítrio e discricionariedade. Enseja um ciclo de novos poderes discricionários que se relaciona diretamente com o direito administrativo e que, nas palavras de Martin Shapiro, seria um jogo interminável em que discricionariedades previamente concedidas são transformadas em regras, surgindo novas discricionariedades e arbítrios que não foram objetos de regras e, ao final, nenhuma discricionariedade concedida será

³⁴⁷ SMITH, Graham. *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

³⁴⁸ MAIA, Rousiley. *Democracia e a internet como esfera pública virtual: aproximando as condições do discurso e da deliberação*. Universidade de Brasília, 2001. p.84.

³⁴⁹ Decisões participativas não podem, também, ignorar a participação dos especialistas. Válido, aqui, a observação de DAHL, Robert. *Sobre a Democracia*. Tradução Beatriz Sidou. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001. p.92. “Cidadãos e funcionários do governo não precisam da ajuda de especialistas? É claro que precisam! É inegável a importância dos especialistas e do conhecimento especializado para o bom funcionamento dos governos democráticos. A política pública por vezes é tão complexa (e cada vez mais!), que nenhum governo poderia tomar decisões satisfatórias sem a ajuda de excelentes especialistas de formação.”

completamente reduzida a regras.³⁵⁰ É para mitigar esses riscos que o direito atua através do princípio da acessibilidade e seus direcionadores. É para mitigar esses riscos que um direito global em saúde poderia ser construído na perspectiva das doenças raras.

4.5. Considerações finais do poder decisório

O desenvolvimento deste capítulo evidenciou que a análise do poder e da tomada de decisão não é um exercício meramente teórico, mas, uma condição indispensável para compreender os limites e as possibilidades de efetivação do direito à saúde. Ao examinar diferentes teorias decisórias e suas repercussões no campo das políticas públicas, demonstrou-se que nenhuma delas, isoladamente, oferece uma resposta suficiente para o dilema colocado pelas doenças raras.

A racionalidade limitada, os vieses comportamentais, a lógica estratégica da teoria dos jogos, a agregação de preferências na escolha social ou mesmo o pragmatismo da escolha pública revelaram-se instrumentos úteis para interpretar a realidade. Todavia, evidenciaram a incapacidade estrutural dos sistemas decisórios tradicionais de lidar com a complexidade e incertezas inerentes as doenças raras.

O ponto nodal que se extrai é que a alocação de recursos em saúde é, em larga medida, resultado de decisões políticas condicionadas pela escassez artificial. O reconhecimento de que a escassez financeira, salvo em situações de absoluta impossibilidade material, decorre de escolhas alocativas e não de uma inexistência real de recursos, desloca a questão do acesso à saúde do plano econômico para o plano normativo.

Isto significa que o direito não apenas pode, mas deve, intervir na definição dos limites e parâmetros dessa alocação, estabelecendo balizas que assegurem a observância do princípio da acessibilidade e de seus direcionadores: equidade, participação social e transparência.

Paralelamente este capítulo mostrou que a concentração decisória em atores homogêneos acarreta exclusão sistemática de minorias e reforça assimetrias de poder. Essa homogeneidade, que historicamente estrutura o exercício do poder político e econômico, constitui um obstáculo central à efetividade do direito à saúde em grupos vulneráveis.³⁵¹ A

³⁵⁰ SHAPIRO, Martin, The Institutionalization of European Administrative Space, in Alec Stone Sweet, Wayne Sandholtz, and Neil Fligstein (eds), *The Institutionalization of Europe*. Oxford, 2001: online Oxford Academic, 7 Apr. 2004. <https://doi.org/10.1093/019924796X.003.0005>. Acesso em 17.01.2023.

³⁵¹ No debate específico da temática da saúde é válida a leitura do artigo de SERAPIONI, Mauro, ROMANÍ, Oriol. Potencialidades e desafios da participação em instâncias colegiadas dos sistemas de saúde: os casos de Itália, Inglaterra e Brasil. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 22(11):2411-2421, nov, 2006. A despeito da data

experiência das doenças raras, nesse sentido, é paradigmática. Representam uma minoria estatística, de baixo retorno eleitoral, que custam caro para os Estados-nação e acabam relegadas à invisibilidade decisória. O resultado é um ciclo de exclusão que perpetua desigualdades e transforma a promessa da DUDH em mera retórica.

Nesse quadro o direito é protagonista. Cabe-lhe incentivar processos decisórios mais heterogêneos incluindo os destinatários das normas – neste caso, os pacientes raros e suas comunidades – no processo decisório, sob pena de se produzir normas formalmente legítimas, mas, materialmente excludentes. Noutras palavras, o direito pode reduzir a distância entre quem decide e quem é afetado pela decisão.

Esse percurso demonstra que o debate não se esgota em identificar o *como se decide* ou *quem decide*. É justamente nesse ponto que se abre a ponte para o capítulo final. A compreensão das engrenagens internas do poder, bem como de suas limitações teóricas e práticas pavimenta o caminho para o pensamento de um direito global à saúde na perspectiva das doenças raras.

O exame das teorias decisórias e da heterogeneidade de atores evidencia que a saúde, em especial no campo das doenças raras, é governada por múltiplos centros de poder. Buscar um novo arranjo institucional mais coeso, capaz de alinhar soberania estatal, cooperação internacional e incentivos econômicos é o desafio que se dedica o capítulo seguinte, ao propor os fundamentos de um direito global em saúde

da publicação e de mudanças legislativas que já ocorreram na sistemática de participação social em saúde nestes países (ex.: introdução de consultas públicas e possibilidade de audiência pública no Brasil), é fato que esta participação ainda está muito aquém do ideal, especialmente para o que se propõe nesta tese.

5. DIREITO GLOBAL EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DAS DOENÇAS RARAS

“If access to health care is considered a human right, who is considered human enough to have that right?” |
Se o acesso aos cuidados de saúde é considerado um direito humano, quem é considerado humano o suficiente para ter esse direito?

Paul Farmer

A construção de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras exige a descrição dos problemas que marcam a temática em estudo e a formulação de fundamentos que sejam capazes de orientar a ação coletiva de Estados-nação para a construção deste direito.

Conforme se verificou ao longo desta pesquisa, as doenças raras não podem ser reduzidas à categoria de exceções estatísticas. Elas revelam, em verdade, uma das faces mais vulneráveis do direito à saúde com indivíduos invisibilizados, tratamentos de alto valor agregado, tecnologias de acesso limitado e barreiras normativas que, somadas, traduzem desigualdades.

A transposição desta temática dos planos nacionais de cada Estado-nação para o plano global não é mero deslocamento geográfico ou institucional. Trata-se de uma exigência decorrente da própria natureza das doenças raras, que ultrapassam fronteiras nacionais, demandam cooperação internacional, troca de informações e soluções multidisciplinares integradas entre o direito e outras áreas de conhecimento que, de alguma forma, tenham uma relação com a saúde e foram mencionadas ao longo deste trabalho.

O desafio do capítulo final é apontar os caminhos pelos quais o direito pode seguir. Assim, este capítulo buscará sistematizar os fundamentos acadêmicos e potencialmente práticos para essa construção global e plural. Para tanto, necessário iniciar respondendo a indagação inicial desta pesquisa sobre quais são os fundamentos para se construir um direito global à saúde para doenças raras e frente aos desafios de diagnóstico, tratamento e custo dos direitos.

Eis a resposta: Os fundamentos jurídicos para tanto encontram-se no reconhecimento do direito à saúde como um direito humano fundamental e multidisciplinar, ancorado na DUDH, no respeito à normatividade interna de cada Estado-nação e nas normatividades (vinculantes e não vinculantes) sobre saúde e direito à saúde da ONU, OMS e órgãos internacionais multilaterais em que os Estados-nação participam de forma voluntária.

Tais fundamentos repousam, sobretudo, na afirmação da dignidade da pessoa humana como princípio estruturante, cuja consolidação exige cooperação internacional e o reconhecimento de que a efetividade do direito à saúde de cada indivíduo raro depende da aplicação do princípio do acesso à saúde com os seus direcionadores (equidade, racionalidade científica e transparência).

A conclusão é de que não se demanda a criação de novos direitos para se construir um direito global à saúde. Impõe-se, na verdade, a colaboração de Estados-nação (que estejam interessados em construir este direito global) para a implementação do princípio da acessibilidade, precedida de uma harmonização normativa conceitual necessária para transformar a promessa normativa do direito à saúde em resultados concretos para os pacientes que convivem com doenças raras.

Para transpor esses fundamentos para a sua efetiva viabilização, não basta reafirmar o direito à saúde como um direito fundamental e universal. É necessário desenhar instrumentos que concretizem essa promessa no plano global, de modo a compatibilizar diversidade normativa, respeitar a soberania estatal e criar incentivos para que os Estados-nação realizem essa cooperação internacional.

Os subcapítulos que seguem buscam apresentar os principais caminhos para essa construção e podem ser sistematizados em quatro eixos centrais que são complementares entre si. O primeiro é o da harmonização normativa, entendida como uma etapa necessária para o alinhamento de conceitos, a redução de assimetrias e a criação das bases estruturantes deste direito global. O segundo é a conformação de uma arquitetura global inclusiva e participativa, capaz de buscar assegurar legitimidade, transparência e heterogeneidade decisória na formulação de políticas e diretrizes internacionais. O terceiro eixo envolve a criação de mecanismos de incentivos econômicos, necessários para viabilizar a cooperação entre Estados, equalizar desigualdades estruturais e sustentar financeiramente as políticas voltadas às doenças raras. Por fim, o quarto eixo é a governança, que se faz necessária para gerenciar toda esta temática.

5.1. Harmonização como um caminho para o direito global à saúde em doenças raras

A construção de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras não pode prescindir de um esforço de harmonização normativa. Não se trata de um conceito meramente teórico, mas, de um instrumento prático para reduzir assimetrias entre os Estados-nação, enfrentar a escassez de recursos e viabilizar o direito global objeto desta pesquisa.

Como demonstrado nos capítulos anteriores o direito à saúde é um direito humano fundamental. A efetividade deste direito depende do acesso à saúde e este, por sua vez, da capacidade dos sistemas de saúde responderem a demandas complexas. Nesse contexto, a harmonização normativa se apresenta como um meio viável de conexão do direito à obra que se objetiva edificar.³⁵²

É necessário, desde logo, distinguir harmonização de uniformização. A uniformização pressupõe a existência de um único texto normativo, aplicável de modo idêntico a todos os países. Harmonização, ao contrário, representa a aproximação de conceitos jurídicos e parâmetros regulatórios, de modo que sistemas diferentes possam dialogar e interagir.³⁵³ A harmonização é flexível.³⁵⁴

Essa flexibilidade encontra respaldo no pluralismo jurídico, que admite a coexistência simultânea de múltiplos ordenamentos válidos em um mesmo espaço e tempo. Ao invés de se buscar eliminar as diferenças normativas entre Estados-nação, a harmonização inspirada nesse pluralismo reconhece a legitimidade da diversidade jurídica e busca pontos de convergência que permitem o diálogo e a cooperação prática.³⁵⁵

Por ser flexível a harmonização compatibiliza soberania estatal com cooperação internacional. Cria pontos de convergência, sem eliminar a diversidade normativa. Mitiga o risco de conflitos uma vez que estabelece parâmetros mínimos comuns de atuação, favorecendo a previsibilidade das relações jurídicas e ampliando a confiança mútua entre os Estados-nação.

³⁵² AITH, Fernando et. all. *La révision du règlement sanitaire international (RSI) au G20*. Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, 2023, 37. A ideia de harmonização em saúde não é nova. Neste artigo os autores analisam a revisão do Regulamento Sanitário Internacional no âmbito do G20, destacando propostas para fortalecer a coordenação global em emergências de saúde e a necessidade de harmonização regulatória entre Estados, de modo a reduzir assimetrias e garantir maior equidade no acesso às medidas sanitária.

³⁵³ CASELLA, Paulo Borba. Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito – o Brasil e as convenções interamericanas de direito internacional privado. In: ARAUJO, Nadia de Araujo; CASELLA, Paulo Borba (Orgs.). *Integração jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado (CIDIPS) e o direito brasileiro*. São Paulo: LTr, 1998. p. 77-105. O autor explica que a harmonização atua no plano das normas de conflito, a uniformização combina elementos de direito material e conflitual, e a unificação substitui normas nacionais por regras comuns, refletindo diferentes graus de integração jurídica internacional. Havendo harmonização reduz-se a possibilidade de conflitos.

³⁵⁴ Essa compreensão coincide com a literatura administrativista que analisa a necessidade de coordenação entre centros decisórios diversos e de processos normativos capazes de articular diferentes ordens jurídicas sem eliminá-las, como demonstra a Juliana Bonacorsi de Palma ao estudar a atividade normativa da Administração Pública e a importância de procedimentos que promovam racionalidade, diálogo institucional e coerência regulatória. PALMA, Juliana Bonacorsi de. *Atividade normativa da administração pública: estudo do processo administrativo normativo*. 2014. 279 f. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

³⁵⁵ CALIXTO, Ângela Jank; CARVALHO, Luciani Coimbra de. *Pluralismo jurídico: uma nova perspectiva a respeito da relação entre os sistemas jurídicos internacional e interno*. Disponível em: https://cidhsite.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/05/ar_gt7_4.pdf. Acesso em: 26 ago. 2025.

A distinção não é apenas conceitual. Trata-se de um argumento político-jurídico relevante, pois uma das principais resistências de governantes à harmonização decorre exatamente do temor de perda de soberania. Entretanto, no campo das doenças raras, essa objeção não se sustenta.

A razão é que nenhum Estado-nação isoladamente tende a ter escala suficiente de pacientes para justificar investimentos isolados em pesquisa, desenvolvimento e oferta de terapias em saúde que possuem alto custo de investimento para cobertura populacional pequena. Tampouco existe um mercado nacional isolado que seja atraente o suficiente para que a iniciativa privada invista de maneira autônoma em soluções locais.

A ausência de harmonização gera um paradoxo. Multiplicam-se os custos individuais e coletivos, muitas vezes com resultados marginais, enquanto a cooperação internacional poderia reduzir despesas e concretizar o princípio do acesso à saúde. Nesse contexto, a harmonização se torna condição necessária para que o acesso à saúde seja efetivo e, ao mesmo tempo, orientado pelo direcionador da equidade, garantindo que os pacientes com doenças raras não sejam os últimos a usufruírem de diagnósticos e terapias inovadoras.

O argumento encontra eco relevante ao considerarmos a ideia de Amartya Sen de que a previsão normativa de direitos é importante, mas, é a capacidade real das pessoas viverem vidas dignas o que realmente importa.³⁵⁶ Nesse sentido, a harmonização atua como instrumento de expansão de capacidades humanas, transformando a promessa do direito à saúde em liberdade concreta.

A pressão por harmonização também é fruto das limitações materiais dos sistemas de saúde. A saúde, como direito social e fundamental, enfrenta a limitação estrutural que envolve o custo dos direitos. Cada Estado-nação aloca capital humano e financeiro em suas estruturas de vigilância sanitária, pesquisa e regulação. Todavia, a velocidade com que novas tecnologias são desenvolvidas supera a capacidade de avaliação de muitas agências sanitárias nacionais.

Agências mais frágeis, com menor orçamento ou menos técnicos especializados, demoram mais para avaliar as terapias em saúde. Esse atraso repercute no tempo em que uma terapia poderá chegar ao mercado e estar disponível ao indivíduo. Quanto menores os recursos investidos, maior o risco de aprovação inadequada e mais morosa é a análise das tecnologias em saúde.

³⁵⁶ SEN, Amartya. *Desenvolvimento como Liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

Essa pressão sobre os sistemas de saúde é comum a todos os países, do Norte ao Sul global. Mesmo países tidos como desenvolvidos pela OCDE convivem com dilemas sobre financiamento, custo-benefício de terapias inovadoras e sustentabilidade do sistema. A experiência da pandemia de covid-19 evidenciou esse fenômeno. A corrida por vacinas e insumos demonstrou que a fragmentação regulatória gera atrasos, ineficiência e desigualdade.³⁵⁷

A necessidade de harmonização pode se tornar mais evidente e palatável quando se analisa, por exemplo, a cadeia produtiva global de medicamentos. Essa cadeia envolve múltiplas etapas interconectadas que vão desde a pesquisa básica até a disponibilização do produto ao paciente. Os chamados insumos farmacêuticos ativos (IFAs), em sua maioria, são produzidos em poucos polos mundiais, sendo a China responsável por mais de 60% da produção e a Índia por aproximadamente 20%.³⁵⁸ Poucos países possuem autossuficiência nessa etapa.

A pesquisa e desenvolvimento é realizada majoritariamente em grandes centros acadêmicos e privados, concentrados nos Estados Unidos, União Europeia e Japão que, juntos, juntos respondem por mais de 80% dos investimentos globais em inovação.³⁵⁹ A produção industrial é desempenhada por empresas públicas ou privadas, que fabricam medicamentos e dispositivos em escala e os exportam e distribuem para diversos mercados.

A distribuição e o comércio internacional são marcados por importações e exportações diárias de medicamentos, vacinas e outras tecnologias em saúde. Esses fluxos obedecem aos princípios gerais do comércio internacional – como livre concorrência, previsibilidade e segurança jurídica – que estruturam o sistema multilateral de trocas comerciais.³⁶⁰

Cada Estado, por meio dos seus órgãos sanitários competentes, avalia a segurança e a eficácia das tecnologias em saúde conforme critérios e prazos internos que, muitas vezes, criam atrasos e barreiras adicionais. Embora não existam dados uniformes e plenamente confiáveis que permitam comparar com exatidão os tempos de aprovação entre diferentes jurisdições, é possível, por dedução lógica, reconhecer que países em que os produtos chegam mais rapidamente ao mercado de consumo – como geralmente é o caso dos Estados Unidos

³⁵⁷ OECD. *Ready for the Next Crisis? Investing in Health System Resilience*. OECD Health Policy Studies. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/1e53cf80-en

³⁵⁸ Informação disponível em: https://www.eda.gov/sites/default/files/2024-07/APM_Tech_Hub_Overarching_Narrative.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 22.08.2025.

³⁵⁹ Informação disponível em: https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20246/cross-national-comparisons-of-r-d-performance#utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 22.08.2025.

³⁶⁰ TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Ângela T. Gobbi. *Direito do Comércio Internacional*. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

(FDA) e, em seguida, países da União Europeia (EMA) – tendem a contar com processos de avaliação mais céleres e estruturados.

Essa assimetria regulatória resulta em atrasos que, no campo das doenças raras, podem significar a diferença entre a oportuna disponibilidade a terapias inovadoras e a morte precoce de um indivíduo que não têm tempo para esperar. A disponibilidade final ao paciente não depende apenas da aprovação regulatória. Carece de políticas nacionais de disponibilidade da terapia nos sistemas de saúde que dependem de burocracia administrativa e recursos.

O exemplo das terapias gênicas e celulares é ilustrativo. Desenvolvidas em centros altamente especializados, essas terapias dependem de ensaios clínicos multicêntricos para validar segurança e eficácia.³⁶¹ Contudo, quando cada agência nacional repete do zero suas avaliações, os pacientes em países periféricos acabam sendo os últimos a receberem acesso, consolidando uma desigualdade global.

Toda essa rota demonstra que o fluxo de tecnologias em saúde é intrinsecamente global. Insumos atravessam fronteiras, medicamentos circulam entre continentes, evidências científicas são compartilhadas em tempo real. É incongruente, portanto, que a normatividade permaneça fragmentada quando ela pode ser minimamente harmonizada.

Exemplos concretos de harmonização já existem em diversas áreas da saúde. O *International Council for Harmonization* – ICH,³⁶² por exemplo, é uma organização internacional criada em 1990 com o objetivo de harmonizar os requisitos técnicos para o registro de medicamentos entre os principais mercados mundiais. Reúne autoridades regulatórias e associações privadas para discutir critérios de registro de medicamentos, articulando atores estatais e privados em ideia de governança horizontal e transparente.

Há também a cooperação FDA-EMA, que permite compartilhamento de informações e reconhecimento mútuo de inspeções; o trabalho conjunto da Anvisa com agências como SwissMedic e Health Canada, em projetos-piloto de convergência regulatória; e as redes transnacionais de reguladores que trocam informações sobre segurança de medicamentos, reduzindo a duplicação de esforços e já mencionado antes (ICMRA). Essas experiências demonstram que a harmonização é factível, inclusive em áreas de alta complexidade técnica e de interesse estratégico.

³⁶¹ ADAIR, J. E. et al. *Towards access for all: 1st Working Group Report for the Global Gene Therapy Initiative (GGTI)*. *Gene Therapy*, v. 30, p. 216–221, 2023.

³⁶² Maiores informações em: <https://www.ich.org/>. Acesso em 22.08.2025.

Ainda assim, pode-se seguir a retórica argumentativa contra a harmonização, invocando razões de soberania, segurança nacional, autossuficiência produtiva e proteção econômica. Os argumentos possuem validade em certas circunstâncias como, por exemplo, quando se busca erradicar doenças prevalentes em determinado território ou quando há interesse estratégico em desenvolver uma indústria nacional.³⁶³

No campo das doenças raras, a harmonização ganha relevância ainda maior. Os pacientes constituem minorias invisibilizadas que, geralmente, dependem de tecnologias em saúde com alto custo de tratamento e baixa atratividade econômica. É neste contexto que se justifica uma harmonização normativa.

O direito à saúde possui caráter multidisciplinar e encontra expressão tanto em normas de *hardlaw* quanto em instrumentos de *softlaw*. Como já tratado antes, o *hardlaw* se traduz em tratados e normas vinculantes, que impõem obrigações claras. O *softlaw*, por sua vez, corresponde a resoluções, recomendações e planos de ação que, embora não vinculantes, criam expectativas legítimas e orientam a prática estatal.³⁶⁴

No campo das doenças raras o *softlaw* desempenha papel estratégico ao permitir avanços sem a necessidade de complexos tratados internacionais. Exemplo disso é a já mencionada resolução da OMS de fevereiro de 2025, que reconheceu as doenças raras como prioridade global e estabeleceu a elaboração de um Plano Global de Ação de dez anos. Trata-se de um instrumento que orienta políticas nacionais e induz a convergência normativa.

Para além do *softlaw* há, também, o chamado direito flexível, composto por leis-modelo, códigos de conduta e recomendações dirigidas ao legislador interno de cada Estado-nação.³⁶⁵ Esse direito influencia tanto no desenvolvimento legislativo futuro quanto na interpretação normativa, funcionando como elemento de harmonização e sem a necessidade de imposição externa. Com isso, o pluralismo jurídico passa a oferecer uma moldura teórica

³⁶³ BITENCOURT, Caroline Müller; GABARDO, Emerson. *O mito da subsidiariedade e as reformas do estado social: um brainstorm sobre governo e a administração no Brasil atual*. In: SIQUEIRA NETO, José Francisco; NOHARA, Irene Patrícia; SALGADO, Rodrigo Oliveira (coord.). *Gestão pública, infraestrutura e desenvolvimento: 20 anos do programa de pós-graduação em direito político e econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Mais sobre o lado inovador do Estado vide, também, MAZZUCATO, Mariana. *O Estado Empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado*. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.

³⁶⁴ ABBOTT, Kenneth W.; SNIDAL, Duncan. *Hard and Soft Law in International Governance*. International Organization, v.54, n.3, 2000.

³⁶⁵ ABBOTT, Kenneth W.; SNIDAL, Duncan. *Hard and Soft Law in International Governance*. International Organization, v. 54, n. 3, p. 421-456, 2000. Os autores demonstram que a normatividade internacional não se limita à dicotomia rígida entre obrigações vinculantes (*hardlaw*) e instrumentos não obrigatórios (*softlaw*), mas opera em um espectro contínuo de arranjos jurídicos graduais e flexíveis, que exercem efeitos concretos mesmo sem caráter formalmente vinculante.

para compreender a harmonização não como submissão de uma ordem jurídica à outra, mas, como articulação entre diferentes camadas normativas que operam em paralelo.

Ao se propor um direito global em saúde a harmonização aparece como um elo que conecta teoria e prática. Harmonização pode possibilitar maior rapidez com protocolos compartilhados, ampliação da base de evidências clínicas com estudos multicêntricos, redução de custos pela divisão de esforços regulatórios e científicos, dentre outros ganhos.

Também poderá possibilitar uma eventual negociação de preços mais sustentáveis com compras em maior volume e melhor planejamento de demanda, em uma relação ganha-ganha entre comprador e vendedor que evitaria desperdícios e proporcionaria mais sustentabilidade ambiental e social ao planeta.

Se assistência médica é tida por muitos como cara, já que essa é uma retórica comum de que há falta de recursos financeiros para a viabilização de direitos sociais, imagine o que pode ser realizado se o gasto que um Estado-nação possuir com o direito à saúde diminuir ou aumentar com ganho de eficiência e produtividade, já que indivíduos saudáveis geram receitas ao invés de despesas.³⁶⁶

A harmonização normativa se apresenta como um pavimento concreto para a construção de um direito global em saúde. Ao alinhar conceitos e processos, sem eliminar a soberania nacional de cada Estado-nação, ela permite que indivíduos com doenças raras não sejam reféns de fronteiras nacionais, mas, beneficiários de um esforço coletivo de cooperação.

Em um mundo globalizado, em que cadeias produtivas, fluxos de informação e desafios sanitários são transnacionais, insistir em soluções puramente nacionais parece uma rota para condenar pacientes à exclusão. A harmonização normativa dos temas correlatos à saúde e doenças raras oferece uma nova rota que é juridicamente viável para tornar efetivo o direito humano fundamental à saúde.

5.2. Arquitetura global inclusiva e participativa

A efetividade do direito global em saúde, na perspectiva das doenças raras, não se limita à harmonização normativa. A harmonização aproxima conceitos jurídicos, reduz assimetrias regulatórias e facilita a cooperação, mas, por si só, não assegura que decisões globais sejam legítimas, transparentes e orientadas ao interesse público.

³⁶⁶ NASCIMENTO, Leon; RABAH, Marcelo; SOUZA, Mônica; KOZLOWSKY, Iury; FARJUN, Bruna; FIDALGO, Antonio. *Custos sociais da DPOC: o impacto sobre os anos de vida saudável e a perda de produtividade no Brasil entre os anos de 2017 e 2022*. *Jornal Brasileiro de Economia da Saúde*, v. 16, n. 2, p. 87–97, 2024.

Para que a promessa de um direito à saúde transnacional se converta em resultados concretos é necessário desenhar uma arquitetura global inclusiva e participativa. Trata-se de um arranjo institucional flexível e plural,³⁶⁷ construído sob os pilares do pluralismo jurídico, da transparência e da inclusão social, que permita responder às demandas específicas das doenças raras sem sacrificar a soberania dos Estados-nação conforme debatido nos capítulos antecedentes deste trabalho.

Essa arquitetura não corresponde a um governo mundial da saúde, tampouco a uma estrutura hierárquica que substitua instituições nacionais. Ao contrário, trata-se de um sistema de articulação entre diferentes níveis decisórios, no qual países, organizações internacionais, sociedade civil, setor privado e comunidades de pacientes compartilham responsabilidades e legitimidade. Ao invés de um centro único de poder, a arquitetura global em saúde se organiza como uma rede de múltiplos atores, refletindo a complexidade da sociedade global contemporânea.

Um de seus pilares é a transparência no conceito já destacado no capítulo terceiro, como um dos direcionadores do princípio do acesso à saúde. A transparência é condição de legitimidade democrática e elemento da arquitetura inclusiva.³⁶⁸ Ela não se limita à publicidade formal de normas ou relatórios, mas envolve clareza nos critérios de incorporação tecnológica, abertura dos dados utilizados para avaliação de medicamentos, divulgação de metodologias de análise econômica e prestação de contas sobre negociações internacionais.

No campo das doenças raras, em que tecnologias em saúde de alto custo são objeto de intensa negociação entre Estados-nação e sociedades empresariais, a opacidade decisória pode vir a fragilizar a confiança pública, aumentar a judicialização e acentuar desigualdades. Uma arquitetura inclusiva exige, portanto, mecanismos globais de governo aberto em saúde, capazes de reduzir a assimetria informacional que existe entre reguladores, empresas e cidadãos.

Outro fundamento desta arquitetura é enfrentar a pergunta central trabalhada no capítulo 4 sobre quem decide. Viu-se ao longo deste trabalho que o direito à saúde é multidisciplinar e envolve escolhas jurídicas, técnicas, econômicas, éticas e políticas. Decisões sobre incorporação de tecnologias em sistemas de saúde, financiamento de terapias

³⁶⁷ SANTOS, Boaventura de Sousa. *Toward a New Legal Common Sense*. 2. ed. London: Butterworths, 2002.

³⁶⁸ KICKBUSCH, Ilona; GLEICHER, David. *Governance for Health in the 21st Century*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2012.

ou distribuição de recursos não podem ser monopólio do poder político ou de burocracias estatais.

É necessário criar espaços decisórios que combinem conhecimento técnico especializado com legitimidade política e social. Isso implica a participação de múltiplos atores: agências regulatórias, profissionais de saúde, economistas, bioeticistas, representantes do setor privado, organizações da sociedade civil e, sobretudo, associações de pacientes.³⁶⁹

No caso das doenças raras, a inclusão dos pacientes e de suas famílias é especialmente relevante. Como o número absoluto de indivíduos afetados é reduzido e sua dispersão geográfica é ampla, sem canais globais institucionais suas vozes permanecem invisíveis. A arquitetura inclusiva deve corrigir essa assimetria, criando mecanismos permanentes de consulta e representação como a EURORDIS³⁷⁰ vem tentando fazer.

Trata-se de reconhecer que a legitimidade decisória não se constrói apenas pela autoridade formal de cada Estado-nação. Ela também se reconhece pela capacidade de incluir quem vivencia diretamente as consequências das escolhas normativas. Quem é afetado pelas escolhas. A arquitetura global também deve ser, portanto, responsiva.

A crise pandêmica de covid-19 demonstrou que modelos de cooperação entre agências reguladoras – como Anvisa, EMA e outras –, ou acordos de reconhecimento mútuo de inspeções, podem acelerar decisões sem reduzir o rigor científico. Transportar essa lógica para o campo das doenças raras significa criar redes regulatórias globais, nas quais evidências clínicas, protocolos de avaliação e análises de custo-efetividade sejam compartilhados em tempo real, evitando duplicações e acelerando a disponibilização de terapias.

Até porque, a velocidade da inovação em saúde não para de avançar e em crescimento exponencial.³⁷¹ O campo das terapias gênicas e personalizadas, que é um dos que mais preocupa o impacto de custos dos sistemas de saúde, também é um campo que exige processos de decisão que acompanhem o ritmo tecnológico, sem comprometer a segurança dos pacientes.

Essa proposta não é utópica. Existem experiências concretas de arquiteturas globais participativas em outras áreas do direito internacional que podem inspirar o campo da saúde.

³⁶⁹ BIEHL, João; PETRYNA, Adriana. *When People Come First: Critical Studies in Global Health*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

³⁷⁰ EURORDIS. *Rare Diseases Europe: Policy and Advocacy*. Disponível em: <https://www.eurordis.org>. Acesso em: 22.08.2025.

³⁷¹ DELOITTE Center for Health Solutions. *Scaling advanced therapies*. Deloitte, 2025. Disponível em: https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/cell-and-gene-therapies-growth-innovation.html?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 28.11.2025.

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco – CQCT,³⁷² por exemplo, criou uma conferência das partes que reúne Estados-nação, organizações internacionais e observadores da sociedade civil para negociar e monitorar a implementação de medidas.

No campo ambiental, a Convenção do Clima e os Acordos de Paris³⁷³ estabeleceram um modelo de governança flexível, no qual metas nacionais são acompanhadas globalmente em um sistema de transparência e revisão. No campo digital, arranjos multissetoriais como o Internet Governance Fórum – IGF³⁷⁴ demonstram que é possível criar fóruns horizontais, nos quais Estados-nação, sociedades empresariais e sociedade civil participam em pé de igualdade de debates regulatórios.

No campo da saúde, o já mencionado ICH foi criado, inicialmente, para alinhar critérios técnicos de registro de medicamentos e evoluiu para uma estrutura que envolve reguladores, indústrias e especialistas em um processo transparente e orientado por consensos. A experiência do ICH mostra que uma arquitetura global não precisa ser baseada em tratados formais para ser efetiva. Pode florescer de arranjos voluntários, sustentados pela confiança e pela necessidade mútua de cooperação.

A arquitetura global inclusiva e participativa, para ser efetiva, deve incorporar o princípio da heterogeneidade decisória. Como discutido no quarto capítulo deste trabalho, a concentração de decisões em poucos atores aumenta o risco de captura por interesses privados ou nacionais de Estados-nação.³⁷⁵ A diversidade de vozes, ainda que torne o processo mais complexo, é uma garantia de equilíbrio e legitimidade. A inclusão de pacientes, pesquisadores independentes, órgãos de controle e organizações da sociedade civil funciona como contrapeso ao risco de captura.

Essa arquitetura não elimina a soberania dos Estados. Apenas redefine seu exercício. Ao invés de concebê-la como barreira à cooperação, a soberania é entendida como capacidade de atuar em conjunto para enfrentar desafios globais que nenhum país consegue resolver isoladamente. No campo das doenças raras tem o condão de ampliar o acesso à saúde, gerar ganhos de legitimidade perante suas populações e, ainda, otimizar despesas.

A experiência da OMS ao longo dos anos de atuação reforça esse caminho. A resolução de 2025 que reconheceu as doenças raras como prioridade global e instituiu um Plano de Ação

³⁷² WHO. *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. Geneva: WHO, 2003

³⁷³ UNFCCC. *The Paris Agreement*. Bonn: UNFCCC, 2015

³⁷⁴ MUELLER, Milton; MATHIASON, John; KLEIN, Hans. *The Internet Governance Forum: A Multistakeholder Approach to Global Governance*. Berlin: Springer, 2007.

³⁷⁵ KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph. *Power and Interdependence*. 4.Ed. New York: Pearson, 2012.

de dez anos representa um marco inicial de arquitetura inclusiva. A ideia de envolver Estados-nação, sociedade civil e setor privado na elaboração e execução do plano, a OMS assumiu o papel de articuladora de um espaço decisório global, capaz de transformar princípios em políticas concretas. O desafio agora é garantir que essa arquitetura se torne permanente, transparente e participativa, evitando que seja capturada por interesses econômicos ou geopolíticos.

Em síntese, a arquitetura global inclusiva e participativa é o complemento da harmonização normativa. Enquanto a harmonização reduz barreiras regulatórias e aproxima conceitos, a arquitetura garante que as decisões sejam legítimas, transparentes, heterogêneas, inclusivas e orientadas ao interesse público.

Esta arquitetura combina instrumentos normativos diversos, inclusão de múltiplos atores e transparência, criando as condições institucionais para que um direito global em saúde se materialize no campo das doenças raras. Mais do que um arranjo técnico, essa arquitetura pode ser a expressão de um novo pacto global em saúde para reconhecer que a dignidade da pessoa humana, enquanto princípio estruturante do direito internacional, exige que nenhuma vida seja invisibilizada pela lógica do mercado ou pelas fronteiras nacionais.

A efetividade desse pacto dependerá da capacidade de construir instituições inclusivas, de assegurar a transparência das decisões e de garantir que – quem decida – seja uma estrutura plural, democrática e heterogênea.

5.3. Mecanismos de incentivos econômicos como viabilizador do direito global em saúde nas doenças raras

Se a harmonização normativa oferece os instrumentos conceituais e a arquitetura global inclusiva organiza a tomada de decisão, resta ainda mais uma pergunta: por qual razão um Estado-nação se engajaria nesse esforço coletivo, sobretudo quando enfrenta restrições orçamentárias internas e pressões políticas imediatas?

A resposta está na criação de mecanismos de incentivos econômicos, capazes de alinhar interesses divergentes, reduzir assimetrias financeiras e induzir os países a assumirem compromissos concretos³⁷⁶ em favor do acesso à saúde das doenças raras.

Os incentivos, contudo, não podem ser pensados como mera transferência de recursos. Devem vir acompanhados de contrapartidas claras, que obriguem os Estados-nação a

³⁷⁶ MACKENBACH, Johan P.; MCKEE, Martin. *Successes and Failures of Health Policy in Europe: Four Decades of Divergent Trends and Converging Challenges*. Open University Press, 2013

demonstrarem eficiência, transparência e resultados mensuráveis. Noutras palavras, o incentivo só cumpre sua função se estiver atrelado a mecanismos de responsabilização que evitem o risco de captura por interesses particulares ou de ineficiência crônica.

A experiência brasileira ilustra bem a magnitude do problema. Segundo dados da OMS, o gasto público anual em saúde no Brasil tem sido historicamente inferior à média mundial, alcançando apenas 3,8% do PIB em 2019, contra uma média de 6,5% nos países da OCDE.³⁷⁷

Enquanto nações como Alemanha, França e Japão aplicam entre 9% e 10% do PIB no setor, o Brasil permanece na faixa mais baixa, ao lado do México. Essa diferença revela não apenas a desigualdade de esforços, mas, também, a urgência de um arranjo global que compense disparidades estruturais e permita que países de renda média ou baixa possam integrar-se em condições minimamente equânimes a uma rede de cuidados globais em doenças raras.

Nesse contexto, os incentivos econômicos podem assumir diferentes formas. Uma delas é a criação de fundos multilaterais³⁷⁸ dedicados às doenças raras, com aportes de Estados-nação, organismos internacionais e setor privado, destinados a financiar pesquisa, diagnóstico precoce e terapias de alto custo. Exemplo desse tipo de iniciativa é o Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, criado em 2002,³⁷⁹ que reúne esforços multilaterais para financiar o combate a doenças de grande impacto global.

O acesso a esses fundos deve ser condicionado ao cumprimento de requisitos de transparência, equidade na distribuição interna e implementação de protocolos mínimos de acesso à saúde que podem estar vinculados ao cumprimento do princípio da acessibilidade através de seus direcionadores. Se o Estado comprovar que está aplicando recursos em conformidade com os padrões globais acordados, recebe financiamento adicional. Caso contrário, o acesso é restringido ou suspenso.

Outra forma de incentivo é a adoção de modelos de compras compartilhadas e negociação conjunta de preços,³⁸⁰ em que blocos regionais ou consórcios de países adquirem

³⁷⁷ OECD/World Health Organization. *Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020*. Paris: OECD Publishing, 2020

³⁷⁸ KICKBUSCH, Ilona; HEIN, Wolfgang; SILBERSCHMIDT, Gaudenz. *Addressing Global Health Governance Challenges through a New Mechanism: The Proposal for a Committee C of the World Health Assembly*. Journal of Law, Medicine & Ethics, v. 38, n. 3, 2010

³⁷⁹ Maiores informações disponíveis em: <https://www.theglobalfund.org/en/>. Acesso em 26.08.2025.

³⁸⁰ MCEVOY, Emma; FERRI, Delia. *The Role of the Joint Procurement Agreement during the COVID-19 Pandemic: Assessing Its Usefulness and Discussing Its Potential to Support a European Health Union*. European Journal of Risk Regulation, v. 11, n. 4, p. 851-863, 2020.

medicamentos exclusivos (ou medicamentos órfãos) em escala, obtendo melhores condições financeiras.

Esse mecanismo que reduz custos pode, ao mesmo tempo, garantir maior previsibilidade de demanda, evitando desperdícios e aumentando a sustentabilidade orçamentária. Mais uma vez, a contrapartida é indispensável: países que aderirem a um eventual consórcio devem comprovar distribuição equitativa, evitar práticas de estoque estratégico desproporcionais e manter canais transparentes de prestação de contas.

Um mecanismo inovador a ser considerado é a negociação confidencial de preços coordenada diretamente pela OMS. Diferentemente da confidencialidade imposta unilateralmente pelas empresas, esse modelo permitiria que a OMS estruturasse acordos multilaterais sigilosos, preservando a estratégia comercial dos fornecedores, mas também aumentando a competição entre eles e reduzindo as assimetrias de informação que prejudicam Estados com menor poder de barganha. A coordenação internacional poderia, assim, gerar maior previsibilidade e estabilidade para países que enfrentam forte volatilidade de preços causada por negociações fragmentadas.

O argumento central que sustenta esse modelo está no fato de que a transparência total e irrestrita de preços pode produzir efeitos adversos, especialmente em mercados farmacêuticos globais baseados em descontos confidenciais. A OCDE alerta que políticas de divulgação completa dos preços transacionais podem levar fornecedores a reduzir ou eliminar descontos ofertados a países menores, temendo que esses valores sirvam de referência para grandes mercados, que usam mecanismos de *external reference pricing*.³⁸¹

Como resultado, a transparência absoluta pode, paradoxalmente, elevar preços globais e prejudicar justamente aqueles Estados que buscam ampliar o acesso a tecnologias críticas para a saúde. Esse fenômeno é particularmente sensível em terapias avançadas de alto custo, nas quais pequenas variações de preço têm impacto significativo nas decisões de incorporação.

Se os sistemas de saúde têm enfrentado crescente dificuldade para acompanhar o ritmo de inovação tecnológica e modelos tradicionais de avaliação e negociação não conseguem lidar com a complexidade e a velocidade dos lançamentos atuais, sobretudo nas áreas de

³⁸¹ OECD. Organization for Economic Co-Operation and Development. *Exploring the consequences of greater price transparency on the dynamics of pharmaceutical markets*. Paris: OECD, 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/09/exploring-the-consequences-of-greater-price-transparency-on-the-dynamics-of-pharmaceutical-markets_6a8ef807/c9250e17-en.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em 10.12.2025.

terapias gênicas e personalizadas, a estrutura precisa ser revisitada. Nesse sentido, a OCDE³⁸² destaca que a troca estruturada e controlada de informações entre países, inclusive sob acordos sigilosos, poderia fortalecer a capacidade coletiva de negociação, preservar a segurança dos pacientes e evitar distorções nos mercados internacionais. Assim, a negociação confidencial coordenada pela OMS protegeria a estratégia comercial dos fornecedores e, ao mesmo tempo, criaria um ambiente multilateral mais eficiente, permitindo decisões de preço e acesso à saúde alinhadas ao interesse público global e à sustentabilidade dos sistemas de saúde.

Ou seja, ao centralizar informações sensíveis e negociar em nome de blocos de países, a OMS poderia obter condições mais vantajosas de preço e garantir previsibilidade de fornecimento. A contrapartida, nesse caso, é que os Estados beneficiários assumissem compromissos de transparência na aplicação interna dos recursos, de equidade na distribuição e de não repasse indevido dos custos ao cidadão. Trata-se de uma transformação ao modelo atual de confidencialidade para que seja um instrumento de cooperação internacional e de fortalecimento do direito global à saúde.

Importante registrar aqui que, uma negociação em blocos não implica em uma uniformização de preços, mas, na possibilidade de se estabelecer parâmetros e negociações mais amplos, em uma relação ganha-ganha. Que quando transportada para os Estados observe a realidade de que os Estados-nação possuem custos de transação que não são idênticos por fatores internos e, portanto, uma uniformização de preços não traria os melhores resultados a todos os *stakeholders* envolvidos podendo criar, inclusive, desincentivos de investimentos em saúde em Estados-nação que possuem maior custo de transação.

A experiência internacional demonstra que os incentivos econômicos podem ser poderosos motores de inovação como pode ser visto pelo *Orphan Drug Act* dos Estados Unidos, de 1983.³⁸³ Ao oferecer exclusividade de mercado, subsídios e incentivos fiscais para pesquisa de medicamentos órfãos, a lei gerou uma explosão de desenvolvimento científico. No entanto, também mostrou os riscos de incentivos sem contrapartida, já que algumas sociedades empresariais foram acusadas de manipular o sistema para maximizar lucros. A

³⁸² OEDE. Organization for Economic Co-Operation and Development. *Exploring the feasibility of sharing information on medicine prices across countries*. Paris: OECD, 2024. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/09/exploring-the-feasibility-of-sharing-information-on-medicine-prices-across-countries_927c5a9a/5e4a7a47-en.pdf?utm_source=chatgpt.com.

Acesso em 10.12.2025.

³⁸³ INSTITUTE OF MEDICINE. *Rare Diseases and Orphan Products: Accelerating Research and Development*. Washington, DC: National Academies Press, 2010.

lição é clara: sem mecanismos de controle e responsabilização, os incentivos podem ser apropriados por interesses privados em detrimento do interesse público.

Modelos híbridos adotados em outros países reforçam essa conclusão. O Programa Conjunto Europeu para Doenças Raras foca em pesquisa colaborativa transnacional, enquanto o NHS da Inglaterra condiciona a disponibilização de tratamentos de alto custo à publicação de diretrizes científicas pelo NICE, o que garante racionalidade e transparência.

Em Singapura, a criação de um fundo específico para doenças raras estabelece critérios claros de elegibilidade, enquanto Austrália e Malásia vinculam subsídios a parâmetros de custo-efetividade, o que se mostra ser um cenário perverso para o contexto das doenças raras. Em todos esses casos, o incentivo econômico não é entregue de forma incondicional, mas, subordinado a critérios técnicos.

A própria OMS reconheceu essa urgência na 78ª Assembleia Mundial da Saúde de 2025, ao aprovar uma resolução sobre fortalecimento do financiamento global em saúde.³⁸⁴ O documento destacou que, diante da redução da ajuda externa e do aumento dos gastos diretos das famílias, seria necessário adotar fontes inovadoras de financiamento e condicionar repasses internacionais ao cumprimento de padrões de gestão e transparência.

Essa diretriz pode ser aplicada de forma específica às doenças raras, de modo que o engajamento dos Estados seja estimulado tanto por benefícios econômicos tangíveis quanto por atuarem para prover o direito à saúde que está insculpido na DUDH.

Além dos incentivos financeiros diretos, podem ser concebidos incentivos políticos e simbólicos, como reconhecimento internacional, acesso a redes privilegiadas de pesquisa, prioridade em processos de aprovação regulatória ou participação em conselhos decisórios globais. Esses elementos funcionam como moedas de prestígio que aumentam o interesse dos Estados em aderir ao arranjo global.

Em síntese, os mecanismos de incentivo econômico cumprem uma dupla função: atrair os Estados-nação para a cooperação global e forçá-los a serem responsivos por meio de contrapartidas verificáveis. O Estado-nação que deseja acessar recursos, participar de compras compartilhadas ou receber apoio técnico precisa demonstrar transparência, equidade e responsabilidade. Assim, cria-se um círculo virtuoso em que o engajamento internacional é recompensado, mas também fiscalizado.

³⁸⁴ Disponível em: [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_\(15\)-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_(15)-en.pdf). Acesso em 18.08.2025.

No campo das doenças raras, essa lógica é ainda mais necessária. Como não há escala para justificar investimentos isolados, a cooperação só se sustenta se os incentivos forem suficientemente atrativos e, ao mesmo tempo, condicionados a critérios claros de transparência e responsabilidade pública. Dessa forma, os incentivos econômicos não são apenas um mecanismo de financiamento, mas o motor que impulsiona a transformação da promessa normativa do direito à saúde em realidade concreta para as raridades que estão espalhadas em todo o mundo.

5.4. Governança de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras

Com o advento dos processos de globalização diversas esferas da vida social e internacional passaram a fazer parte de uma agenda de discussões em âmbito global no contexto de que problemas em escala global exigem responsabilidades globais. Surge, pois, o termo *governança* como uma forma de dar um contorno institucional e conceitual aos desafios de escala global.³⁸⁵

A partir de então a governança passa a ser identificada como um sistema de direção e coordenação que ocorre em várias escalas que ultrapassam as ações de governos e de Estado. Ao passo que o termo *governo* indica a ideia de uma autoridade formal, responsável pela implementação de políticas, o termo *governança* traz consigo o conceito de atividades diversas que são apoiadas em objetivos comuns e compartilhados por diferentes esferas, que incluem tanto instituições governamentais como não governamentais.³⁸⁶ Em outros termos a governança seria um padrão de articulação e cooperação entre atores sociais, representado por um plano mais amplo da sociedade como um todo.

Três são as dimensões mais relevantes que albergam o conceito de governança: uma que diz respeito a seu caráter de instrumento (meio e processo capaz de produzir resultados eficazes); a segunda que envolve a participação ampliada nos processos de decisão (o quem decide); e a terceira que enfatiza quem será afetado pelos processos decisórios através da persuasão nas relações e de ações institucionais. Vê-se que a forma de gerar resultados da governança decorre da articulação e da construção de consensos para a solução de problemas.

³⁸⁵ O termo governança global parece ter sido cunhado na década de 1980, quando o Banco Mundial trouxe o termo com o objetivo de criar um modelo adequado de gestão pública, com foco em países em desenvolvimento. Este termo teria evoluído a partir do relatório da Comissão sobre Governança Global, publicado em 1996 que o conceituou como as diversas maneiras pelas quais os indivíduos e instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL. Nossa comunidade global: relatório da comissão sobre Governança Global. Rio de Janeiro: FGV, BRASIL, 1996.

³⁸⁶ KRAHMAN, Elke. *National, Regional and Global Governance: One Phenomenon or Many*. In: Global Governance 9, 2003, p.323-346.

No contexto de temáticas de saúde pública a OMS é o órgão reconhecido por quase todos os Estados-nação ao redor do mundo como uma instituição que tem o condão de cuidar da governança global em saúde, articulando e persuadindo os Estados-nação na implementação de políticas voltadas para a saúde do ser humano, nos ideais e conceitos amplos de saúde e qualidade de vida que tratamos primeiro capítulo deste trabalho.³⁸⁷

A maioria das questões relacionadas a uma governança global, especialmente às relativas a uma governança instrumental e regulatória (que produz e aplica normas) são de uma atividade administrativa. Na prática deste espaço global se estabelece uma governança ampla, com redes transnacionais geradores de normas, intérpretes e aplicadores permitindo com as barreiras tradicionais estritas sejam derrubadas.

A similaridade existente entre os sistemas de saúde dos Estados-nação atuais em conjunto como as interações dinâmicas da sociedade, as rápidas mudanças tecnológicas e as especificidades relativas às raridades nos permite refletir sobre a possibilidade de se estabelecer uma metodologia e arranjos normativos de governança global sobre o tema da saúde voltado para as doenças raras.

A ideia de um “espaço global” para o diagnóstico e tratamento das doenças raras marca um afastamento dos entendimentos ortodoxos do direito internacional em que o internacional é, em grande parte, uma relação intergovernamental e com nítidas segregações entre as práticas domésticas de cada governo e o internacional.

Uma regulação global ao princípio do acesso à saúde para as raridades poderia ocorrer de formas distintas: Tanto por meio da administração realizada por instituições formais internacionais ou redes transnacionais de reguladores nacionais, não necessariamente baseadas em acordos formais, como ocorre com o mútuo reconhecimento de regras e decisões entre os Estados membros da OMC, por pressão difusa exercida pelos consortes; quanto pela administração de reguladores nacionais decidindo questões de interesse global ou regulando

³⁸⁷ Válido destacar que a OMS, como o “braço” de saúde da ONU, tem como papel contribuir com o direito no mundo todo em busca de convergência normativa em prol do direito à saúde, conforme as disposições de sua constituição e estatuto. Disponível em: <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1>. Acesso em 23.08.2024. De se pontuar que nem todo desenvolvimento de normas de saúde do sistema das Nações Unidas é oriundo da OMS. Outros membros do sistema da ONU estão envolvidos nessa tarefa. Há temas que são tratados em fóruns e programas específicos. Apenas a título de exemplo de programas e outros membros e organismos internacionais que tratam da temática em saúde em perspectiva global, cite-se: Programa das Nações Unidas para HIV/AIDS (Unaid); Fundo das Nações Unidas para a População (Unfpa); Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); Organização Internacional do Trabalho (OIT); a Organização Mundial do Comércio (OMC); Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Banco Mundial.

atividades que ocorrem fora do país, como as que visam cumprir metas internacionais de redução de carbono.

Estipula-se um espaço para uma atividade administrativa global com a participação de entes estatais e reguladores estatais em conjunto com os reguladores privados e órgãos híbridos e as mais diversas organizações internacionais, tendo como destinatários de suas ações – ou administrados – não apenas os Estados, mas também empresas, indivíduos e ONGs.

Nasce uma normatividade integrada e global que permitirá interpretar e aplicar o princípio do acesso à saúde para as raridades. É certo que enormes dificuldades serão inseridas em torno desta proposta, com alegações de inconsistências, como ocorre em qualquer ciclo de introdução de novidades disruptivas.

A primeira etapa do novo, que muda completamente um modo de pensar e trabalhar, é a negação. Legisladores e reguladores tendem a ser reativos. Interpretam o novo de modo a fazê-lo o mais parecido possível (senão idêntico) com o velho. Buscam a ilegalidade e posições contrárias à inovação, em defesa do que já é conhecido. Por vezes, inclusive, por já estarem capturados por interesses de determinados agentes.

Uma proposta de acesso ao diagnóstico e tratamento global para as raridades obriga os Estados-nação a reconhecerem suas falhas no modelo atual e a compartilharem o poder e a tomada de decisão. Especialmente pelo fato de que determinadas decisões exigirão conhecimentos específicos e debates amplos. Em áreas que apenas o decisor político não possui afinidade. A limitação do conhecimento é um desafio que invariavelmente se colocará na frente decisor e que é superável mediante a realização de pesquisa, estudo e diálogo ativo.

A viabilidade de se fragmentar este tema de saúde para além da fronteira dos Estados-nação deve ser entendida como a fragmentariedade já existente no fenômeno global da sociedade moderna. Já há diferentes marcos regulatórios para os mercados financeiros, o meio ambiente, a internet, entre outros. Isso também é possível para a saúde em uma governança que poderia ser gerida pela OMS.

Diversas matérias são tratadas de formas diferentes pelas mais distintas tradições de cada Estado-nação. Isso, contudo, não os deixou de atuar nos marcos regulatórios já segmentados que existem no mundo. As distinções são positivas, inclusive, para permitir um direito comparado e a extração do que de melhor pode existir na cultura de cada Estado-nação.

É desta necessidade intrínseca de diálogo intercultural e desafio de escala global que se faz necessário o estabelecimento de uma governança para dar executoriedade prática ao

princípio da acessibilidade, em prol de um acesso mais equânime ao diagnóstico e tratamento dos pacientes que convivem com uma doença rara.

5.5. Síntese propositiva ao direito global em saúde na perspectiva das doenças raras

A construção de um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras não se esgota na análise isolada dos três eixos desenvolvidos nos subcapítulos anteriores. O verdadeiro desafio consiste em propor um modelo integrado, capaz de reunir coerência normativa, legitimidade institucional e sustentabilidade econômica em um arranjo que seja ao mesmo tempo viável e transformador.

Esse esforço de síntese, neste trabalho, se apresenta como uma etapa para transformar princípios em instrumentos, e expectativas em práticas efetivas, evitando que o direito global permaneça apenas no plano da retórica. O ponto de partida é a tipologia dos instrumentos que estruturam o direito global em saúde.

O primeiro eixo é o normativo, que engloba tanto os instrumentos de *hardlaw* quanto os de *softlaw*. Nesse campo, o direito flexível desempenha um papel estratégico, funcionando como um espaço intermediário entre obrigações formais e práticas persuasivas, com potencial para influenciar legislações nacionais e decisões judiciais.

A coerência normativa depende de uma harmonização progressiva desses instrumentos, de modo a reduzir barreiras e permitir que regulações nacionais dialoguem em termos comuns, sem sacrificar a diversidade jurídica.

O segundo eixo é o institucional, correspondente à arquitetura global inclusiva e participativa. A legitimidade do direito global não pode se assentar, apenas, em textos normativos, já que o direito à saúde e o acesso à saúde são temáticas multidisciplinares. A legitimidade precisa de uma estrutura decisória que seja plural, transparente e heterogênea.

A experiência da CQCT, do Acordo de Paris e do IGF mostra que modelos flexíveis, não baseados em hierarquias rígidas, podem oferecer legitimidade e efetividade quando incorporam múltiplos atores no processo decisório. O campo das doenças raras exige esse tipo de atuação, na qual pacientes, organizações da sociedade civil, reguladores, setor privado e Estados-nação compartilhem responsabilidades.

A legitimidade, nesse modelo, decorre não apenas da autoridade formal dos Estados, mas da capacidade de incluir quem vivencia diretamente as consequências das normas e políticas em saúde.

O terceiro eixo é o econômico, fundado na criação de mecanismos de incentivo capazes de alinhar interesses divergentes e induzir cada Estado-nação a compromissos concretos. Nenhum modelo global se sustenta apenas em princípios normativos ou arquiteturas participativas se não houver instrumentos financeiros que reduzam as assimetrias estruturais.

Fundos multilaterais, compras conjuntas, negociações de preços e incentivos fiscais são mecanismos que podem conferir sustentabilidade ao arranjo global. Entretanto, esses incentivos precisam ser acompanhados de contrapartidas claras em termos de transparência, equidade e responsabilidade, sob pena de degenerarem em instrumentos de captura por interesses privados. São incentivos que precisam estar umbilicalmente conectados com os direcionadores do princípio da acessibilidade.

O modelo integrado de direito global em saúde para doenças raras deve, portanto, articular esses três eixos de maneira complementar. A harmonização normativa que assegura coerência conceitual, a arquitetura inclusiva que garante legitimidade e participação e, por fim, os incentivos econômicos que viabilizam engajamento e sustentabilidade. São estes três eixos em conjunto com o eixo de uma governança para gestão do tema que possuem o condão de viabilizar o acesso à saúde em escala global para as doenças raras.

Mais do que uma justaposição, trata-se de uma engrenagem em que cada eixo depende do funcionamento dos outros, já que a normatividade será efetiva se respaldada por uma arquitetura legítima, enquanto a arquitetura terá impacto se sustentada por recursos e os incentivos produzirão resultados justos se ancorados em princípios normativos claros.

Reconhecer o acesso à saúde como garantidor do direito global em saúde, especialmente nas doenças raras, é reafirmar que dignidade, equidade e justiça social não são abstrações, mas compromissos concretos que a humanidade precisa assumir coletivamente. Nesse contexto, a pesquisa aqui realizada não se limita a uma reflexão teórica. Oferece um caminho prático e normativo para a Agenda 2030 da ONU ao Plano Global de Ação de 10 anos da OMS para, orientado por metas claras, garantir equidade, inclusão e efetiva proteção do direito à saúde para as pessoas com doenças raras.

Contudo, se o trabalho não auxiliar nestas agendas, que auxilie o direito e os poderes político e jurídico na compreensão do contexto das doenças raras e que o acesso à saúde é compreendido como a dimensão estruturante do direito fundamental à saúde, responsável por viabilizar a sua fruição concreta. Um conceito jurídico e multidisciplinar que representa a porta de entrada ao direito à saúde.

Por fim, se ainda assim essa tese não puder auxiliar o direitos e os poderes político e jurídico, espera-se – ao menos – que possa mostrar ao poder jurídico que o acesso à saúde é um princípio do direito, independentemente de estar implícito ou explícito na normatividade nacional ou internacional e precisa estar presente na teoria do direito para que os operadores façam o seu uso de forma apropriada em conjunto com os três direcionadores que o orientam: A equidade, como critério de priorização e redução de desigualdades no atendimento de grupos vulneráveis; O racional científico, que vincula escolhas distributivas a evidências, avaliação de tecnologias em saúde e critérios explícitos de custo-efetividade; e a transparência, assegurando publicidade de razões, participação social e responsabilidade pública dos decisores.

CONCLUSÃO

A investigação desenvolvida ao longo desta pesquisa permitiu reconstruir, sob novos fundamentos, o modo como o direito à saúde voltado para as doenças raras deveria ser compreendido, interpretado e operacionalizado diante das particularidades que circundam as doenças raras e foi tratado no início do trabalho.

Ao se partir da indagação inicial sobre quais seriam os fundamentos capazes de sustentar a edificação de um direito global em saúde aplicável às doenças raras, revelou-se, desde as primeiras etapas da pesquisa, que a resposta não residira na formulação de novos direitos, mas, na reinterpretação dos direitos humanos já consagrados e na adoção de instrumentos jurídicos, institucionais e cooperativos capazes de expandir sua eficácia para além das fronteiras nacionais.

Nesse sentido, o trabalho demonstrou que o direito à saúde, enquanto direito humano fundamental inscrito na DUDH e em amplos tratados/pactos internacionais, contém em si os elementos necessários para sustentar uma abordagem global, desde que reinterpretado sob a centralidade do acesso à saúde como dimensão estruturante e condição de fruição do próprio direito. E o fez através de longa pesquisa comparativa de como o direito à saúde está estabelecido em diferentes jurisdições ao redor do mundo, concluindo haver semelhanças normativas entre os diversos Estados-nação.

A partir daí, a tese sustenta que as doenças raras, longe de constituírem exceções estatísticas ou contingências marginais dos sistemas de saúde, representam um campo paradigmático de tensão entre a promessa normativa universal e a realidade concreta da exclusão. A baixa prevalência, o diagnóstico tardio, o elevadíssimo custo de tecnologias terapêuticas, a assimetria informacional e a invisibilidade social tornam esse grupo de indivíduos um espelho das vulnerabilidades mais profundas do direito à saúde contemporâneo.

Todo esse conjunto de fatores evidencia que os mecanismos tradicionais, centrados em sistemas nacionais isolados, não conseguem oferecer respostas adequadas, consistentes e tempestivas aos pacientes que convivem com uma doença rara. Se a saúde é um direito humano universal, conforme reiterado pelos marcos internacionais, é imperativo reconhecer que sua efetividade não pode continuar condicionada às variáveis demográficas, econômicas e políticas de cada Estado-nação.

Nesse contexto, a tese formula um argumento central: o acesso à saúde não pode ser compreendido como mero instrumento administrativo, nem como simples etapa operacional entre o direito e sua fruição. Ele é, em verdade, um princípio jurídico estruturante (o princípio

do acesso à saúde ou da acessibilidade), cuja densidade normativa se revela na capacidade de orientar decisões estatais, políticas públicas, avaliações tecnológicas e até mesmo a interpretação judicial.

Se o direito à saúde é reconhecido como um direito humano fundamental, sua concretização exige que o acesso à saúde opere como princípio jurídico estruturante, capaz de orientar a formulação, a implementação e o controle das decisões estatais. A partir dessa premissa, a pesquisa identificou três direcionadores essenciais para a operacionalização do princípio da acessibilidade: a equidade, a racionalidade científica e a transparência. A equidade assegura que grupos vulneráveis, como os indivíduos com doenças raras, não sejam relegados aos últimos lugares nas prioridades estatais; a racionalidade científica exige que as escolhas sejam informadas por evidências e avaliações claras, evitando decisões baseadas em conjecturas ou vieses; e a transparência garante publicidade das razões, participação social, responsabilidade pública e legítima confiança no processo decisório.

Outro ponto central recuperado pela tese diz respeito ao enfrentamento da chamada “escassez de recursos”. Por meio da distinção entre escassez natural e escassez artificial, o trabalho demonstra que a insuficiência material absoluta é excepcional; em contrapartida, a maior parte das restrições enfrentadas pelos sistemas de saúde decorre de decisões políticas, escolhas orçamentárias, prioridades governamentais e arranjos institucionais determinados historicamente.

Assim, antes de se invocar a reserva do possível como limite ao direito, é preciso analisar a natureza da escassez invocada. Quando se trata de doenças raras, a escassez é quase sempre artificial, fruto da fragmentação regulatória, da duplicação de processos, da ausência de harmonização e da falta de cooperação internacional. Não se pode aceitar, portanto, que tais condições sejam tratadas como fatalidades naturais, imunes ao controle jurídico. O que a tese demonstra é que, ao se reconhecer a artificialidade dessa escassez, torna-se evidente que existe espaço para reorganizar prioridades, reestruturar incentivos, harmonizar processos e criar mecanismos de cooperação que ampliem o acesso e reduzam desigualdades globais.

A reflexão teórica desenvolvida sobre as estruturas decisórias e sobre o comportamento dos agentes responsáveis por tomar decisões em saúde complementou esse diagnóstico. A partir de modelos oriundos da teoria dos jogos, da escolha racional, da racionalidade limitada, da teoria da escolha social, da teoria da escolha pública e da economia comportamental, a tese argumentou que nenhuma dessas teorias, isoladamente, seria capaz de explicar a complexidade das decisões em saúde.

Todas as teorias apontam para um mesmo núcleo: as decisões são tomadas por agentes limitados, sujeitos a vieses, influenciados por incentivos institucionais distorcidos e imersos em estruturas homogêneas de poder. As consequências são evidentes: quando se privilegia a maximização de resultados agregados, quando se tem preferência por grupos majoritários, quando se busca reduzir custos imediatos ou quando se opera sob forte pressão política, as doenças raras são sistematicamente preteridas. Nesse cenário, a exclusão não é acidental, mas, previsível.

É justamente diante desse quadro que o direito assume papel protagonista. As teorias decisórias permitem identificar as limitações estruturais do processo decisório, mas é o direito que tem a função de corrigi-las, criando mecanismos de heterogeneidade decisória, transparência, participação ampliada, controle judicial informado e desenho institucional adequado às especificidades das doenças raras. Esse papel do direito é reforçado pela própria arquitetura normativa internacional, que, embora fragmentada, já contém instrumentos de *hardlaw* e *softlaw* que, quando reinterpretados de forma coerente, fornecem base suficiente para um projeto global de saúde.

Foi nesse horizonte que a tese estruturou a proposta de um direito global em saúde para doenças raras, articulado em quatro eixos complementares: harmonização normativa, arquitetura global inclusiva e participativa, mecanismos de incentivos econômicos e governança global. Esses quatro elementos formam uma engrenagem conceitual e prática que traduz, em termos operacionais, o princípio da acessibilidade.

A harmonização normativa constitui a base conceitual e procedimental desse projeto. Diferenciando harmonização de uniformização, o trabalho demonstrou que a aproximação progressiva de conceitos, critérios e parâmetros mínimos pode reduzir assimetrias, acelerar processos, evitar duplicações e fortalecer cooperação, sem comprometer a soberania dos Estados.

No campo das doenças raras, onde a escala é limitada e o custo por paciente é extremamente elevado, a harmonização não apenas se mostra possível, mas necessária. A ausência de harmonização gera um paradoxo: os custos aumentam, a eficiência diminui, os processos se acumulam e o acesso se atrasa justamente para quem não possui tempo a esperar. Assim, a harmonização normativa se revela condição para a concretização do princípio da acessibilidade e para a implementação de soluções mais equânimes.

A arquitetura global inclusiva e participativa, por sua vez, adiciona legitimidade e transparência ao modelo. A tese reforçou que nenhuma política global pode ser concebida

apenas a partir da autoridade formal dos Estados-nação. O que se defende na tese é a necessidade de incluir múltiplos atores, especialmente aqueles que vivenciam diretamente os impactos das normas. As doenças raras, sendo um campo marcado por profunda invisibilidade, evidenciam essa necessidade. A participação estruturada de pacientes, famílias, associações, cientistas, reguladores e sociedades empresariais é condição de legitimidade democrática e de correção dos vieses decisórios já identificados.

Além disso, os modelos de transparência analisados demonstram que a opacidade, sobretudo em decisões que envolvem custos elevados e negociações complexas, agrava desigualdades e fragiliza a confiança pública. Por isso, a arquitetura global inclusiva não é mero ideal procedimental, mas componente estrutural da eficácia do direito global em saúde.

O terceiro eixo, relativo aos mecanismos de incentivos econômicos, oferece o elemento de viabilidade financeira e institucional necessário à adesão dos Estados. O trabalho mostrou que incentivos econômicos não são simples transferências de recursos, mas, instrumentos de alinhamento de interesses, desde que acompanhados de contrapartidas claras relacionadas à eficiência, transparência, equidade e responsabilidade pública.

Fundos multilaterais, compras compartilhadas, negociação conjunta de preços, participação coordenada em redes de pesquisa e incentivos simbólicos podem servir como motores da cooperação, especialmente em países de renda média ou baixa, que enfrentam restrições orçamentárias significativas. A experiência internacional, analisada em diversos capítulos, revela que incentivos bem estruturados podem gerar inovação, ampliar a escala de produção e reduzir custos. Ao mesmo tempo, essa experiência evidencia os riscos de incentivos desregulados, reforçando a necessidade de contrapartidas firmes, orientadas pelos direcionadores do princípio da acessibilidade.

Por fim, o eixo da governança global fornece o contorno institucional que permite articular todas essas dimensões. A governança global, entendida como um padrão de articulação entre atores públicos e privados, formais e informais, em múltiplos níveis de atuação, permite superar a dicotomia tradicional entre o doméstico e o internacional.

A OMS, como entidade legitimada pela comunidade internacional, possui papel natural de coordenação dessa governança, mas sua atuação não elimina a importância de redes regulatórias, organizações científicas e instâncias híbridas. A governança, ao mesmo tempo, reconhece a fragmentação já existente e utiliza essa pluralidade como fonte de criatividade institucional, aprendizado normativo e equilíbrio entre interesses diversos. A proposta é,

portanto, realista e compatível com a complexidade contemporânea, oferecendo uma moldura institucional capaz de tornar operacional o direito global em saúde para doenças raras.

A partir dessa construção a tese aqui defendida sustenta que, a centralidade do acesso à saúde como garantidor do direito à saúde em uma esfera global, constitui sua contribuição teórica mais relevante. A partir desse conceito, tornou-se possível identificar os obstáculos estruturais que impedem o acesso à saúde tais como a falta de escala, a fragmentação regulatória, a escassez artificial, a assimetria econômica e a ausência de cooperação; e, também, formular respostas concretas e viáveis para enfrentá-los.

O trabalho demonstrou que nenhum Estado-nação, isoladamente, possui escala de pacientes suficiente para justificar investimentos autônomos de pesquisa e desenvolvimento, tampouco dispõe de poder econômico para negociar em condições equânimes com sociedades empresariais globais. A inexistência de um mercado interno robusto e a baixa atratividade comercial tornam impossível, para a maioria dos países, prover respostas nacionais adequadas. Assim, a fragmentação normativa aumenta custos e reforça a exclusão de indivíduos que dependem de decisões rápidas e eficientes.

A pesquisa reafirma, portanto, que a harmonização, a arquitetura participativa, os incentivos econômicos e a governança global não são alternativas distantes. Essas são exigências estruturais da própria natureza das doenças raras. Elas traduzem a necessidade de uma atuação transnacional orientada pelo princípio da acessibilidade e pela dignidade da pessoa humana, que, conforme apresentado neste trabalho, constitui o fundamento último e universal do direito à saúde.

Em termos de impacto epistemológico, a tese contribui para o campo jurídico ao propor uma leitura inovadora e integrada do acesso à saúde, redistribuindo o centro gravitacional do debate e oferecendo uma chave de leitura capaz de orientar decisões políticas, jurídicas e administrativas. O trabalho afirma que o acesso à saúde, independentemente de constar expressamente em normatividade nacional, opera como princípio implícito ou explícito, mas sempre vinculante, e precisa ser reconhecido na teoria do direito e aplicado pelos operadores jurídicos em conjunto com seus três direcionadores.

Por fim, do ponto de vista ético, político e humano, a tese devolve centralidade à vida concreta das pessoas com doenças raras. Elas são o ponto de partida e o ponto de chegada desta construção teórica. E é precisamente nesse ponto que a contribuição social do trabalho se evidencia: ao propor um direito global em saúde na perspectiva das doenças raras, esta pesquisa revela as fissuras normativas e institucionais do presente e, ao mesmo tempo,

convoca o próprio direito a assumir a tarefa de construir um futuro mais equânime, transparente e digno.

O que se defende, ao final, é que toda vida importa e que o acesso à saúde, como garantidor do direito à saúde, deve operar como o eixo normativo capaz de orientar a construção de um direito global em saúde comprometido com a dignidade humana. A partir desse fundamento, esta tese oferece a base teórica e propositiva necessária para transformar a promessa normativa da universalidade em realidade concreta para aqueles que historicamente permaneceram à margem. Ao fazê-lo, reafirma a necessidade de um direito global em saúde que reconheça, proteja e promova, em escala verdadeiramente humana, o valor intrínseco de cada vida.

REFERÊNCIAS

- ABBOTT, Kenneth W.; SNIDAL, Duncan. **Hard and soft law in international governance. International Organization**, v. 54, n. 3, p. 421-456, 2000.
- ADAIR, J. E. et al. **Towards access for all: 1st Working Group Report for the Global Gene Therapy Initiative (GGTI)**. *Gene Therapy*, v. 30, p. 216–221, 2023.
- ÁFRICA DO SUL. **National Health Act 61 of 2003**. Disponível em: <https://www.gov.za/documents/national-health-act>. Acesso em: 10 abr. 2023.
- AITH, Fernando et al. **La révision du règlement sanitaire international (RSI) au G20**. *Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie*, n. 37, 2023.
- AITH, Fernando; BODRA, Maria Eugenia F. do Amaral. **Global Health and Economic Law: Private sector regulation on the global agenda**. *Revista Brasileira de Política Internacional*, v. 65, n. 1, art. e008, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpi/a/hKkqj455k9hBLTFpgNqdvBv/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 20 ago. 2024.
- AITH, Fernando; BUCCI, Maria Paula Dallari. **O direito à saúde no Brasil: seus fundamentos e sua judicialização**. In: AITH, Fernando; BUCCI, Maria Paula Dallari (orgs.). *Saúde, Estado e democracia: estudos sobre a judicialização da saúde no Brasil*. São Paulo: Fiocruz, 2015. p. 43.
- AITH, Fernando; BUJDOSO, Yasmim; NASCIMENTO, Paulo Roberto do; DALLARI, Sueli Gandolfi. **Os princípios da universalidade e integralidade do SUS sob a perspectiva da política de doenças raras e da incorporação tecnológica**. *Revista de Direito Sanitário*, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 10-39, mar./jun. 2014.
- ALEXY, Robert. **Teoria de los derechos fundamentales**. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.
- ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. 2. ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2017.
- ALMEIDA, Michelle Aparecida Ganho; DE SÉLLOS-KNOERR, Viviane Coelho; KNOERR, Fernando Gustavo. **O direito fundamental à saúde, o princípio da reserva do possível e o mínimo existencial: uma discussão em relação às doenças raras e o fornecimento de medicamentos**. *Revista Internacional Consinter de Direito*, v. 9, p. 437, 2023.
- ALMEIDA, Verônica Scriptore Freire; AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal; LAMY, Marcelo (coord.). **O direito da saúde na era pós-Covid-19**. Coimbra: Almedina, 2021.

ANDERSON, Matilda; ELLIOTT, J. Elizabeth; ZURYNSKI, A. Yvonne. **Australian families living with rare disease: experiences of diagnosis, health services use and needs for psychosocial support.** Orphanet Journal of Rare Diseases, v. 8, art. 22, 2013. Disponível em: <https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/1750-1172-8-22#citeas>. Acesso em: 09 mar. 2023.

ARANA, Jaime Rodríguez. **El derecho administrativo global: un derecho principal.** Revista Andaluza de Administración Pública, n. 76, p. 15–68, jan./abr. 2010.

ARAUJO, Flavia Loss de; NEVES, Bárbara Carvalho. **Regionalismo, crise venezuelana e a pandemia do COVID-19: o impacto da fragmentação regional no cenário atual (2013–2020).** Conjuntura Austral, v.12, n.58, p.19–37, 2021.

ARGENTINA. **Constitución de la Nación Argentina.** Ley N° 24.430, Art. 42. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24430-804/texto>. Acesso em: 07 abr. 2023.

ARGENTINA. **Obras Sociales – Ley n° 23.660.** Promulgada: 5 jan. 1989. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23660-62/texto>. Acesso em: 07 abr. 2023.

ARROW, Kenneth Joseph. **Social choice and individual values.** 2. ed. New Haven: Yale University Press, 2012. (Publicado originalmente em 1951).

AUSTRÁLIA. Department of Health and Aged Care. **The Australian health system.** Disponível em: <https://www.health.gov.au/about-us/the-australian-health-system>. Acesso em: 10 abr. 2023.

AUSTRÁLIA. **Life Saving Drugs Program.** Disponível em: <https://www.health.gov.au/our-work/life-saving-drugs-program/about-the-lsdp#:~:text=The%20LSDP%20covers%20medicines%20if%3A%201%20they%20are,pharmaceutical%20company%20%28sponsor%29%20applies%20for%20an%20LSDP%20listing>. Acesso em: 06 nov. 2024.

BARROSO, Luis Roberto. **A nova interpretação constitucional: fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro.** Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

BARROSO, Luís Roberto. **O direito constitucional e a efetividade de suas normas.** Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. **Princípios de ética biomédica.** 3. ed. São Paulo: Loyola, 2013.

BERGSON, Henri. **Duração e Simultaneidade.** São Paulo: Martins Fontes, 2006.

- BERCOVICI, Gilberto. **Soberania e Constituição: por uma crítica do constitucionalismo**. 3. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2020.
- BIEHL, João; PETRYNA, Adriana. **When people come first: critical studies in global health**. Princeton: Princeton University Press, 2013.
- BINENBOJM, Gustavo. **Liberdade igual: o que é e por que importa**. 1. ed. Rio de Janeiro: História Real, 2020.
- BITENCOURT, Caroline Müller; GABARDO, Emerson. **O mito da subsidiariedade e as reformas do estado social: um brainstorm sobre governo e a administração no Brasil atual**. In: SIQUEIRA NETO, José Francisco; NOHARA, Irene Patrícia; SALGADO, Rodrigo Oliveira (coord.). *Gestão pública, infraestrutura e desenvolvimento: 20 anos do programa de pós-graduação em direito político e econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
- BOLLERMAN, Michael. **Digital Sovereigns: Big Tech and Nation-State Influence**, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.21066>. Acesso em: 26 ago. 2025.
- BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
- BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Lei Orgânica da Saúde. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm. Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **O Uso de Limiares de Custo-Efetividade nas Decisões em Saúde**. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde. Brasília, DF, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/artigos_publicacoes/20211202_relatorio_oficina_limiares.pdf. Acesso em: 16 jan. 2024.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Tema 6 de repercussão geral**. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/saude-no-stf-a-tese-do-tema-6-da-repercussao-geral-04122020>. Acesso em: 2 jun. 2024.
- BRASILEIRO, Tambelini Gustavo. **Gestão pública municipal da saúde: desafios à efetivação do direito à saúde**. Tese (doutorado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.
- BRISCOE, Simon; MARTIN PINTADO, Clara; SUTCLIFFE, Katy; MELENDEZ-TORRES, G. J. et al. **Evidence of inequities experienced by the rare disease community with respect to receipt of a diagnosis and access to health and social care services: a scoping review**

of UK and international evidence. Orphanet Journal of Rare Diseases, v. 20, art. 303, 12 jun. 2025.

BROWN, Theodore; CUEZO, Marcos; FEE, Elizabeth. **A transição de saúde pública internacional para global e a Organização Mundial da Saúde.** História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.13, n.3, p.624, 2006.

BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, Clarice Seixas. **Judicialização da saúde: a visão do poder executivo.** São Paulo: Saraiva, 2017.

BUCHANAN, James; TULLOCK, Gordon. **The calculus of consent: logical foundations of constitutional democracy.** Indianapolis: Liberty Fund, 1999.

BUSSE, R.; BLÜMEL, M.; KNIPEPS, F.; BÄRNIGHAUSEN, T. **Statutory health insurance in Germany: a health system shaped by 135 years of solidarity, self-governance, and competition.** Lancet, v. 390, n. 10097, p. 882-897, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28684025/>. Acesso em: 10 abr. 2023.

CALABRESI, Guido; BOBBIT, Philip. **Scelte tragiche.** Milano: Giuffrè Editore, 2006.

CALABRESI, Guido; BOBBIT, Philip. **Tragic choices: the conflicts society confronts in the allocation of tragically scarce resources.** New York: Norton, 1978. p. 17.

CALIENDO, Paulo. **Reserva do possível, direitos fundamentais e tributação.** In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

CALIXTO, Ângela Jank; CARVALHO, Luciani Coimbra de. **Pluralismo jurídico: uma nova perspectiva a respeito da relação entre os sistemas jurídicos internacional e interno.** Disponível em: https://cidhsite.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/05/ar_gt7_4.pdf. Acesso em: 26 ago. 2025.

CALLEGARI, Isabela. **Uso de Limiares de Custo-Efetividade nas Decisões em Saúde: recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.** Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento (IFFD), Policy Note n. 4, Brasil, jul. 2022.

CAMPOS, Ricardo. **Metamorfoses do direito global: sobre a interação entre o direito, tempo e a tecnologia.** São Paulo: Contracorrente, 2022.

CANADÁ. **Canada Health Act – R.S.C., 1985, c. C-6.** Disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-6/page-1.html>. Acesso em: 07 abr. 2023.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito constitucional e teoria da Constituição.** Coimbra: Almedina, 1999.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito constitucional**. Coimbra: Almedina, 1993. – É o mesmo livro?

CARDOSO, João Vitor. **O direito a medicamentos órfãos: do orphan drug act às avaliações de tecnologias em saúde no SUS**. In: DAVINO, Glaucia Eneida; MARTINS, Mirian Celeste; RAMOS, Rosangela Patriota (org.). XXV Mostra da pós-graduação UPM e USP: convergências e transbordamentos interdisciplinares. São Paulo: Liber Ars, 2019. p. 393-405.

CARNEIRO, Laura Elizandra Machado; NUNES, Silvio Gabriel Serrano. **A lógica do respeito e seu impacto na formulação de políticas públicas**. Peer Review, v. 5, n. 20, p. 381-394, 2023.

CARREAU, Dominique; FLORY, Thiébault; JULLIARD, Patrick. **Droit international économique**. Paris: Persée, 1990.

CASELLA, Paulo Borba. **Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito – o Brasil e as convenções interamericanas de direito internacional privado**. In: ARAUJO, Nadia de Araujo; CASELLA, Paulo Borba (orgs.). Integração jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado (CIDIPS) e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. p. 77-105.

CASSESE, Sabino. **Administrative Law without the State? The challenge of global regulation**. New York University Journal of International Law and Politics, v. 37, n. 4, p. 663–694, 2005.

CASTRO, Fabio Sousa Mendonça de; FUSER, Igor. **Bolívia em tempo de pandemia: crise humanitária e conflito político**. Intellèctus, v. 20, n. 2, p.50–77, 2021.

CELESTE, E.; da Silva Santarém, P. R. **Constitucionalismo Digital: Mapeando a resposta constitucional aos desafios da tecnologia digital**. Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça, 15(45), p. 63–91. Disponível em: <https://doi.org/10.30899/dfj.v15i45.1219>. Acesso em: 19.07.2024.

CHARLTON, V. **The ethics of aggregation in cost-effectiveness analysis or, “on books, bookshelves, and budget impact”**. Frontiers in Health Services, Lausanne, v. 2, 13 out. 2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frhs.2022.889423/full>. Acesso em: 25 ago. 2025.

CHARNOVITZ, Steve. **What is international economic law?** Journal of International Economic Law, v.14, n.1, 2014, p.3–22.

CHEN, Faye H. et al. **Telehealth for rare disease care, research, and education across the globe: a review of the literature by the IRDiRC telehealth task force**. European Journal of Medical Genetics, v. 72, art. 104977, dez. 2024.

CHIARELLO, Felipe; MENEZES, Daniel Francisco Nascimento; PINTO, Felipe da Costa Silva. **O financiamento da saúde na Região Metropolitana da Baixada Santista – disparidades entre a Constituição e a realidade**. Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP, v. 1, p. 9-26, 2014.

CLÈVE, Clèmerson Merlin; SIQUEIRA, Alexandre Reis. **Algumas notas sobre colisão de direitos fundamentais**. In: GRAU, Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérulo da (Coords.). Estudos de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 231-242.

COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL. **Nossa comunidade global: relatório da comissão sobre Governança Global**. Rio de Janeiro: FGV, BRASIL, 1996.

DAHL, Robert. **Sobre a democracia**. Tradução Beatriz Sidou. Brasília: Editora da UnB, 2001. p. 92.

DALLARI, Maria Paula Bucci. **O conceito de políticas públicas**. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Ed. Saraiva, 2006, p.10.

DALLARI, S. G.; OLIVEIRA, A. M. C. **Reflexões sobre o Sistema Único de Saúde e o Servizio Sanitario Nazionale: a reforma da reforma - a adoção do Ticket Sanitario**. Saúde Soc., v. 25, n. 4, p. 895-901, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sausoc/2016.v25n4/895-901/pt/>. Acesso em: 08 abr. 2023.

DALMOLIN, Bárbara Brezolin; BACKES, Dirce Stein; ZAMBERLAN, Cláudia; SCHAURICH, Diego; COLOMÉ, Juliana Silveira. **Significados do conceito de saúde na perspectiva de docentes da área da saúde**. Escola Anna Nery, v. 15, n. 2, jun. 2011.

DARON, Acemoglu; ROBINSON, James A. **Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty**. New York: Crown, 2012.

DE GREGORIO, Giovanni. **The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union**. Electronic copy. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3506692>. Acesso em: 19.07.2024.

DEATON, Angus. **A grande saída: saúde, riqueza e as origens da desigualdade**. Tradução Marcelo Levy. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

DEATON, Angus. **The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality**. Princeton: Princeton University Press, 2013, p.11.

DELOITTE Center for Health Solutions. **Scaling advanced therapies**. Deloitte, 2025. Disponível em: https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/cell-and-gene-therapies-growth-innovation.html?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 28 nov. 2025.

DHDU. **Artigos 21 e 25**. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights>. Acesso em: 20 ago. 2025.

DIAS, Roberto. **A dignidade da pessoa humana e o testamento vital no ordenamento constitucional brasileiro**. In: BERTOLDI, Márcia Rodrigues; OLIVEIRA, Kátia Cristine Santos de (coord.). *Direitos fundamentais em construção: estudos em homenagem ao ministro Carlos Ayres Britto*. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 99-120.

DINAMARCA. **The Health Act, N. 546 of 2005. Medical care and sickness benefit**. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=70825. Acesso em: 04 jun. 2026.

DINIZ, Maria Helena. **O estado atual do biodireito**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 44.

DIOGO, E. A. M. **Softlaw e a Sociedade da Informação**. São Paulo: Juruá, 2022.

DRUMMOND, M. F.; SCULPHER, M. J.; CLAXTON, K.; STODDART, G. L.; TORRANCE, G. W. **Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes**. 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.

DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p.73–125.

DWORKIN, Ronald. **O Império do Direito**. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

ELSTER, Jon. **Local justice**. New York: Russell Sage Foundation, 1992.

ESPANHA. **Constitución Española**, 1978, Art. 43. Disponível em: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-40008. Acesso em: 10 abr. 2023.

ESPANHA. **Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud**. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715>. Acesso em: 10 abr. 2023.

ESPANHA. Real **Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones**. Disponível em: <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2012/04/20/16/con>. Acesso em: 29 mai. 2023.

ESTADOS UNIDOS. **California et al. v. Texas et al. Certiorari to the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit No. 19–840**. Argued November 10, 2020 – Decided June

17, 2021. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-840_6jfm.pdf. Acesso em: 29 jul. 2023.

ESTADOS UNIDOS. **Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)**, 2010. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/3590>. Acesso em: 29 jul. 2023.

EURORDIS. **Rare diseases Europe: policy and advocacy**. Disponível em: <https://www.eurordis.org>. Acesso em: 22 ago. 2025.

FAORO, Raymundo. **Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro**. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. p. 1-15.

FONSECA, Frederico Rosa et al. **O impacto da inteligência artificial na interpretação de exames de imagem em diagnóstico médico**. Brazilian Journal of Health Review, v. 7, n. 3, p. e69808, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/69808>. Acesso em: 22.10.2024.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Rio de Janeiro: Graal, 2012.

FRAGKOU, Roxani. **De l'euthanasie aux soins palliatifs: la nécessité d'une réponse au-delà du strict droit positif**. Médecine & Droit, v. 2012, n. 114, p. 76-92, 2012.

G20. **Trilha de Sherpas – Saúde**. Disponível em: <https://www.g20.org/pt-br/trilhas/trilha-de-sherpas/saude>. Acesso em: 1 nov. 2024.

GALDINO, Flávio. **Introdução à teoria dos custos dos direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005,

GARCIA, Lara Rocha. **Inovação tecnológica e direito à saúde: aspectos jurídicos, econômicos, tecnológicos e de políticas públicas**. Curitiba: Juruá, 2017.

GEISINGER, Alex; STEIN, Michael Ashley. **Rational choice, reputation and human rights treaties**. Michigan Law Review, v. 106, n. 6, 2008.

GEORGE, B.; HARRIS, A.; MITCHELL, A. **Economic Evaluation of Public Health Interventions**. Sydney: Oxford University Press, 2001.

GOSTIN, Lawrence O. **Global Health Law**. Cambridge: Harvard University Press, 2014, p.59.

GOSTIN, Lawrence O.; TAYLOR, Allyn L. **Global Health Law: A definition and grand challenges**. Public Health Ethics, v.1, n.1, p.53–63, 2008.

GRIGGS, Robert C. et al. **Clinical research for rare disease: opportunities, challenges, and solutions**. Molecular Genetics and Metabolism, v. 96, n. 1, p. 20-26, jan. 2009.

HABERMAS, Jürgen. **Agir comunicativo e razão destranscendentalizada**. Trad. Lúcia Aragão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012.

HABERMAS, Jürgen. **O discurso filosófico da modernidade: doze lições**. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

HABERMAS, Jürgen. **Teoría de la acción comunicativa II: crítica de la razón funcionalista**. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, 1999.

HOLANDA. **Zorgverzekeringswet. Geraadpleegd op 05-06-2023**. Geldend van 01-01-2006 t/m 30-09-2006. Disponível em: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2006-01-01/1/>. Acesso em: 04 jun. 2023.

HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. **O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019, p.4–5, 11.

ÍNDIA. P.B.K.M.S. & others vs. **State of West Bengal**. 1996 SCC 37.

ÍNDIA. **State of Punjab vs. R.L.B.** AIR 1998 SC 1703.

INSTITUTE OF MEDICINE. **Rare diseases and orphan products: accelerating research and development**. Washington, DC: National Academies Press, 2010.

ITÁLIA. **Costituzione della Repubblica Italiana**, 1947, Art. 32. Disponível em: https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/ROSSA_Costituzione_testo%20vigente_agg_7_11_2022.pdf. Acesso em: 08 abr. 2023.

ITÁLIA. **Legge 23 dicembre 1978**, n. 833, Art. 1.

JESSUP, Philip C. **Transnational Law**. New Haven: Yale University Press, 1959.

JORDI, Ferrer Beltrán; RATTI, Giovanni Battista (eds.). **The logic of legal requirements: essays on defeasibility**. Oxford: Oxford University Press, 2012. Online edition Oxford Academic, 24 jan. 2013.

JUNG, H. W.; KWON, Y. D.; NOH, J. W. **How public and private health insurance coverage mitigates catastrophic health expenditures in Republic of Korea**. BMC Health Serv Res, v. 22, 1042, 2022. Disponível em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08405-4#citeas>. Acesso em: 08 abr. 2023.

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. **Prospect theory: an analysis of decision under risk**. Econometrica, v. 47, n. 2, p. 263-291, 1979.

KANDEL, Eric R. et al. **Princípios de neurociência**. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- KANT, Immanuel. **Crítica da razão pura**. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
- KRAHMAN, Elke. *National, Regional and Global Governance: One Phenomenon or Many*. In: *Global Governance* 9, 2003, p.323-346
- KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph. **Power and interdependence**. 4. ed. New York: Pearson, 2012.
- KHANGURA, S.; KONNYU, K.; CUSHMAN, R.; **Evidence summaries: the evolution of a rapid review approach**. *Syst Rev.*, v. 1, 2012.
- KICKBUSCH, Ilona; GLEICHER, David. **Governance for health in the 21st century**. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2012.
- KICKBUSCH, Ilona; HEIN, Wolfgang; SILBERSCHMIDT, Gaudenz. **Addressing global health governance challenges through a new mechanism: the proposal for a Committee C of the World Health Assembly**. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, v. 38, n. 3, p. 550-563, 2010.
- KINGSBURY, Benedict. **The Concept of ‘Law’ in Global Administrative Law**. *The European Journal of International Law*, v. 20, n. 1, p. 23–57, feb. 2009.
- LEAL, Saul Tourinho. **Direito à felicidade**. São Paulo: Almedina, 2017.
- LEAL, Tourinho Saul. **Direito à inovação: a vida nas cidades inteligentes**. 2. ed. Ribeirão Preto/SP: Ed. Migalhas, 2020.
- LEE, Y.; KIM, S.; KIM, S. Y.; KIM, G. **Ethical Consideration of National Health Insurance Reform for Universal Health Coverage in the Republic of Korea**. *Asian Bioeth Rev.*, v. 11, n. 1, p. 41-56, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7747280/>. Acesso em: 07 abr. 2023.
- LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
- LÉVY, Pierre. **Cyberdemocratie**. Paris: Odile Jacob, 2002.
- LEWIS, Alan. **The Cambridge handbook of psychology and economic behaviour**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- LOURENÇO, A. **Retrato da Saúde em Portugal: Health at a Glance 2021**. *Acta Médica Portuguesa*, v. 35, n. 2, p. 84-86, 2022.
- LUHMANN, Niklas. **El derecho de la sociedad**. Herder: Universidad Iberoamericana, 2005.
- LUNA, Florencia; LÓPEZ, Eduardo Rivera (comps.). **Los desafíos éticos de la genética humana**. México: Fondo de Cultura Económica, 2005, p.339–363.

LUNA, V. V. **Doenças raras e políticas públicas de saúde no Brasil e em Portugal: um estudo comparado.** (Re)pensando Direito, Santo Ângelo/RS, v. 9, n. 17, p. 190-220, jan./jun. 2019. Disponível em: <http://local.cneccsan.edu.br/revista/index.php/direito/index>. Acesso em: 07 abr. 2023.

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. **Amartya Sen como intérprete e crítico da teoria da justiça de John Rawls.** Revista PGM - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza, Fortaleza, v. 17, p. 427-440, dez. 2009. ISSN 2595-0789.

MACKENBACH, Johan P.; MCKEE, Martin. **Successes and failures of health policy in Europe: four decades of divergent trends and converging challenges.** Berkshire: Open University Press, 2013.

MAIA, Rousiley. **Democracia e a internet como esfera pública virtual: aproximando as condições do discurso e da deliberação.** Brasília: Universidade de Brasília, 2001. p. 84.

Maiores informações disponíveis em: <https://www.theglobalfund.org/en/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

MARDEN, Carlos; WYKROTA, Leonardo Martins. **Neurodireito: o início, o fim e o meio.** Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 8, n. 2, p. 48-63, 2018.

MARTINS E SILVA, João Alcindo. **Asclepius e o “culto da serpente”.** Boletim da SPHM, v. 19, n. 4, out./nov./dez. 2004.

MAZZUCATO, Mariana. **O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado.** São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.

MCEVOY, Emma; FERRI, Delia. **The role of the Joint Procurement Agreement during the COVID-19 pandemic: assessing its usefulness and discussing its potential to support a European Health Union.** European Journal of Risk Regulation, v. 11, n. 4, p. 851-863, 2020.

MÉXICO. Disponível em: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477535&fecha=24/03/2017. Acesso em: 25 ago. 2025.

MILLS, Charles Wright. **A elite do poder.** Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

MITTELSTADT, Brent. **Principles alone cannot guarantee ethical AI.** Nat Mach Intell 1, p. 501–507, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4>. Acesso em: 11.01.2023.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Direito da participação política.** Rio de Janeiro: Renovar, 1992.

MOSCA, Gaetano. **A classe política.** Brasília: Editora da UnB, 1982.

MUELLER, Milton; MATHIASON, John; KLEIN, Hans. **The Internet Governance Forum: a multistakeholder approach to global governance**. Berlin: Springer, 2007.

NABUT, Lucas Coelho. **A incorporação das novas tecnologias médicas na saúde suplementar: uma análise jurídica em busca da sustentabilidade e eficiência**. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020, 211 f.

NASCIMENTO, Anderson Ribeiro; NASSIF, Murilo Meneghetti. **Judicialização da saúde: o cidadão pode questionar a Conitec?** Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/judicializacao-da-saude-o-cidadao-pode-questionar-a-conitec>. Acesso em 05.nov.2025

NASCIMENTO, Leon; RABAHI, Marcelo; SOUZA, Mônica; KOZLOWSKY, Iury; FARJUN, Bruna; FIDALGO, Antonio. **Custos sociais da DPOC: o impacto sobre os anos de vida saudável e a perda de produtividade no Brasil entre os anos de 2017 e 2022**. *Jornal Brasileiro de Economia da Saúde*, v. 16, n. 2, p. 87–97, 2024.

NASSIF, Murilo M. **Bioética e a troca de medicamentos biológicos no SUS: Como a intercambialidade dos biológicos se relaciona com a bioética**. In: RIBEIRO, Raphael Lima (org.) et al. *Direito, Estado e Sociedade – Intersecções*, v. 4, São Paulo: Dialética, 2022.

NASSIF, Murilo Meneghetti. **Compra pública de medicamento biológico e os desafios decorrentes da intercambialidade automática no âmbito do SUS**. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional) – Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, São Paulo, 2020.

NASSIF, Murilo Meneghetti. **Instituições de controle e corrupção na nova lei de licitações e contratos administrativos**. In: FERREIRA, Pedro Paulo da Cunha (Org.). *Debates contemporâneos em Direito*. Vol. 4. São Paulo: Editora Dialética, 2023.

NASSIF, Murilo Meneghetti. **Saúde no STF: a tese do tema 6 da repercussão geral**. JOTA, 4 dez. 2020. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/saude-no-stf-a-tese-do-tema-6-da-repercussao-geral-04122020>. Acesso em: 2 jun. 2024.

NASSIF, Murilo Meneghetti. **Entre tribunais e hospitais: o descompasso do acesso à saúde**. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/entre-tribunais-e-hospitais-o-descompasso-do-acesso-a-saude>. Acesso em: 23 set. 2025.

NATIONAL CENTER FOR SCIENCE AND ENGINEERING STATISTICS. **Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons**. Alexandria, VA: U.S.

National Science Foundation, May 21, 2024. Disponível em: <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20245/>Acesso em: 22 ago. 2025.

NAUD, Ludmila Macêdo. **Doenças ultrarraras e o fornecimento do medicamento pós-estudo**. Revista Brasileira de Bioética, v. 15, e12, p. 1-16, 2019.

NEUMANN, John von; MORGENSTERN, Oskar. **Theory of games and economic behavior**. Princeton: Princeton University Press, 1944.

NOHARA, Irene Patrícia. **Direito Administrativo**. 12. ed. rev. e ampl. Barueri, SP: Atlas, 2023.

NOHARA, Irene Patrícia. **Reforma Administrativa E Burocracia: Impacto Da Eficiência Na Configuração Do Direito Administrativo Brasileiro**. Atlas, 2012

NOHARA, Irene Patrícia. **Reforma administrativa para além do discurso do “cidadão-cliente”: do paradigma econômico da eficiência ao ingrediente político da participação**. In: SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva; SIQUEIRA NETO, José Francisco (orgs.). 60 desafios do direito: política, democracia e direito. v. 3. São Paulo: Atlas, 2013. p. 35-36.

NOVAES, H. M. D. **Da produção à avaliação de tecnologias dos sistemas de saúde: desafios do século XXI**. Revista de Saúde Pública, 40 (N Esp): 133-140, 2006.

NOZICK, Robert. **Anarquia, Estado e Utopia**. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

NUNES, João Arriscado; MATIAS, Marisa; FILIPE, Ângela Marques. **As organizações de pacientes como atores emergentes no espaço da saúde: o caso de Portugal**. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, v. 1, n. 1, 2007. Disponível em: <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/894>. Acesso em: 05.07.2024.

NUNES, R. **Economia da Saúde**. Lisboa: Edições Sílabo, 2013.

NUNES, Silvio Gabriel Serrano; COMPARINI, Julio de Souza. **O direito constitucional à saúde: a ponderação entre o mínimo existencial e a reserva do possível**. In: NIELSEN JÚNIOR, Diógenes (org.). Princípios Constitucionais: Diretrizes e Aplicabilidade no Direito. v. 1. Londrina: Toth, 2022.

NUNES, Silvo Gabriel Serrano; SERRANO, Antonio Carlos Alves Pinto; GALIL, João Victor Tavares. **Como a COVID-19 afetou a interpretação das normas jurídicas durante o período pandêmico: a situação excepcional e o impacto nas decisões dos gestores públicos**. Brazilian Journal of Development, v.8, n.5, p.41991–42013, 2022.

OECD. **Ready for the Next Crisis? Investing in Health System Resilience.** OECD Health Policy Studies. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/1e53cf80.

OECD; WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health at a glance: Latin America and the Caribbean 2020.** Paris: OECD Publishing, 2020.

OECD. Organization for Economic Co-Operation and Development. **Exploring the consequences of greater price transparency on the dynamics of pharmaceutical markets.**

Paris: OECD, 2022. Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/09/exploring-the-consequences-of-greater-price-transparency-on-the-dynamics-of-pharmaceutical-markets_6a8ef807/c9250e17-en.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em 10 dez. 2025.

OECD. Organization for Economic Co-Operation and Development. **Exploring the feasibility of sharing information on medicine prices across countries.** Paris: OECD, 2024.

Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/09/exploring-the-feasibility-of-sharing-information-on-medicine-prices-across-countries_927c5a9a/5e4a7a47-en.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em 10 dez. 2025.

OLIVEIRA, Bruna Soraya da Silva Barbosa et al. **Análise e Evolução da Telemedicina no Brasil nos Anos 2019-2023 e sua atual importância.** Revista Contemporânea, v. 4, n. 10, p.

e6123, 2024. Disponível em:

<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6123>. Acesso em: 22.10.2024.

OLIVEIRA, Cláudio Roberto Cordovil; Guimarães, Maria Cristina Soares; MACHADO, Rejane. **Doenças raras como categoria de classificação emergente: o caso brasileiro.** Revista DataGramaZero - Revista de Informação, v.13, n.1, p. 1-10, 2012.

OMS/WHO. **Constituição da Organização Mundial da Saúde.** 1946. Disponível em: <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1>. Acesso em: 20 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Comentário Geral nº 14: O direito ao mais alto nível possível de saúde.** 2000.

Disponível em: file:///C:/Users/I0201134/Downloads/E_C.12_2000_4-EN.pdf. Acesso em: 21 ago. 2025.

PALMA, Juliana Bonacorsi de. **Atividade normativa da administração pública: estudo do processo administrativo normativo**. 2014. 279 f. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

PEREIRA, Gabriel Massote. **Doenças raras: a inaplicabilidade da reserva do possível em seu custeio. Supremacia do mínimo existencial como balizador de direitos fundamentais**. 2023. Dissertação (Mestrado em Direito Médico) – Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2023.

PEREZ, J. González. **El principio general de la buena fe en el derecho administrativo**. Madrid: Real Académica de Ciencias y Políticas, 1983.

PESSINI, Leo. **Dignidade humana nos limites da vida: reflexões éticas a partir do caso Terri Schiavo**. *Bioética*, v. 13, n. 2, p.65–76, 2005. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/108/113. Acesso em: 18 jan. 2023.

PINSKY, Jaime et al. **História da cidadania**. São Paulo: Contexto, 2013.

PINTO, Felipe; GARCIA, Lara. **Desafios internacionais da aplicação da inteligência artificial no Direito**. *Revista Justiça do Direito*, v. 35, n. 2, p. 6-29, 1 set. 2021.

PORTUGAL. **Constituição da República Portuguesa, 2 abr. 1976, Art. 64**. Disponível em: <https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art64>. Acesso em: 10 abr. 2023.

PORTUGAL. **Despacho nº 2129-B, de 2015**. Lisboa. Disponível em: https://fedra.pt/wp-content/uploads/2017/09/Despacho2129B_2015-EstrategiaIntegrada-para-as-doencas-raras.pdf. Acesso em: 07 abr. 2023.

POTTER, Van Rensselaer. **Bioética: ponte para o futuro**. Trad. Diego Carlos Zanella. São Paulo: Loyola, 2016. (Tradução de Bioethics: bridge to the future, 1971).

RAMACCIOTTI, Barbara Lucchesi; CALGARO, Gerson Amauri. **Construção do conceito de minorias e o debate teórico no campo do Direito**. *Sequência: estudos jurídicos e políticos*, v. 42, n. 89, 2021.

RAMOS, Carmen; ALVAR GONZÁLEZ, Mercedes; MORENO, Blanca. **Factores determinantes de la reducción de la desigualdad en la distribución de la renta en países de América Latina**. *Revista CEPAL*, n.126, dez. 2018.

RÁO, Vicente. **O direito e a vida dos direitos**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. v. 1.

- RAWLS, John. **Uma teoria da justiça**. 4. ed. rev. Trad. Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2016.
- REALE, Miguel. **Lições preliminares de direito**. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- REALE, Miguel. **Teoria do direito e do estado**. São Paulo, 1984, p.246–263.
- REZEK, José Francisco. **O Direito Internacional no Século XXI: Textos Fundamentais**. São Paulo: Saraiva, 2002.
- ROURKE, O. B.; ORTWIJN, W.; SCHULLER, T. **The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration**. *Int J Technol Assess Health Care*, v. 36, n. 3, p. 187–190, 2020.
- RUGER, Jennifer Prah. **Normative Foundations of Global Health Law**. *Georgetown Law Journal*, v.96, n.2, p.423–443, 2008.
- SAAVEDRA, Giovani Agostini. **Jurisdição e democracia: uma análise a partir das teorias de Jürgen Habermas, Robert Alexy, Ronald Dworkin e Niklas Luhmann**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
- SAAVEDRA, Giovani Agostini; BORGES, Gabriel Oliveira de Aguiar. **Constitucionalismo Digital Brasileiro**. *Revista da AJURIS*, v.49, n.152, p.157–180, 2022. Disponível em: <http://revistadaajuris.ajuris.org.br/index.php/REVAJURIS/article/view/1228>. Acesso em: 19.07.2024.
- SANDEL, Michael. **Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética**. 1. ed. Trad. Ana Carolina Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
- SANDEL, Michael. **Justiça: o que é fazer a coisa certa**. 24. ed. Trad. Heloísa Matias; Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
- SANTOS, André Felipe; AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. **Dever de incorporação de medicamentos para doenças raras: o caso Spinraza**. In: LAMY, Marcelo (Org.). *Temas avançados de Direito da Saúde*. 1. ed. São Paulo: Matrioska, 2020. v. 1, p. 295-304
- SANTOS, Boaventura de Sousa. **A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. **Toward a new legal common sense**. 2. ed. London: Butterworths, 2002.
- SANTOS, Boaventura de Souza; GARCIA, Mauricio Villegas (eds.). **El caleidoscopio de las justicias em Colombia**. Bogotá: Univ. Nacional/Univ. de los Andes. Siglo de Hombre Editores, 2001, p.139.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais**. 14. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.

SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchitine. **Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações**. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (org.). *Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 19.

SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchitiner. **Reserva do possível, mínimo existencial e direitos à saúde: algumas aproximações**. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti; BARCELLOS, Ana Paula de [et al.]. *Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

SARTORI, Giovanni. **A Teoria da Democracia Revisitada**. v.1, São Paulo: Ática, 1994, p.126–127.

SCHEFFER, Mário (coord.). **Demografia médica no Brasil 2020**. São Paulo: Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP; Conselho Federal de Medicina, 2020.

SCHIEPPATI, A.; HENTER, J-I.; DAINA, E.; APERIA, A. **Why rare diseases are an important medical and social issue**. *Lancet*, v. 371, n. 9629, p. 2039–2041, 2008.

SCLIAR, Moacyr. **História do conceito de saúde**. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 17, n. 1, abr. 2007. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-456560>. Acesso em: 20 ago. 2025.

SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. **O conceito de saúde**. *Revista de Saúde Pública*, v. 31, n. 5, out. 1997. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-234432>. Acesso em: 20 ago. 2025.

SEN, Amartya. **A ideia de justiça**. Trad. Denise Bottmann; Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SERAPIONI, Mauro; ROMANÍ, Oriol. **Potencialidades e desafios da participação em instâncias colegiadas dos sistemas de saúde: os casos de Itália, Inglaterra e Brasil**. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 11, p. 2411-2421, nov. 2006.

SHAPIRO, Martin. **The institutionalization of European administrative space**. In: STONE SWEET, Alec; SANDHOLTZ, Wayne; FLIGSTEIN, Neil (eds.). *The institutionalization of Europe*. Oxford: Oxford University Press, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/019924796X.003.0005>. Acesso em: 17 jan. 2023.

SIECKMANN, Jan-R. **La teoría del derecho de Robert Alexy: análisis y crítica**. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010.

SILVA JÚNIOR, João Batista da Silva. **Produtos de terapia gênica: panorama atual de riscos e regulação dos medicamentos à base de genes e células**. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade de Brasília, Brasília, 2023, 222 f.

SILVEIRA, Rafael Cerqueira de Barros et al. **Cirurgia laparoscópica: evolução, aplicações clínicas e impacto na saúde pública**. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, v. 17, n. 4, p. e6151, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/6151>. Acesso em: 22.10.2024.

SILVEIRA, Rebeca Costa Gadelha da; FREITAS, Raquel Coelho. **Definindo minorias: desafios, tentativas e escolhas para se estabelecer critérios mínimos rumo a conceituação de grupos minoritários**. Revista de Teoria e Filosofia do Estado, v. 3, n. 2, p. 95-116, jul./dez. 2017.

SIMON, Herbert. **A behavioral model of rational choice**. The Quarterly Journal of Economics, v. 69, n. 1, p. 99-118, 1957.

SMITH, Graham. **Democratic innovations: designing institutions for citizen participation**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

SOKEL, Michelle. Os desafios do acesso aos medicamentos para o tratamento das doenças raras no Brasil. Journal of Management & Primary Health Care, v. 12, p. 1-15, 2020. DOI: 10.14295/jmphc.v12.1071. Disponível em: <https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/1071>. Acesso em: 22 ago. 2025.

STEINMETZ, Wilson Antônio. **Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.

STRECK, Lenio Luiz. **Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas**. São Paulo: Saraiva, 2011.

SUÍÇA. **Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, Art. 32**. Disponível em: https://lex.weblaw.ch/lex.php?norm_id=832.10&source=SR&lex_id=14106. Acesso em: 29 mai. 2023.

TAYLOR, Charles (Org.). **Multiculturalismo**. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.

TEPEDINO, G.; FACHIN, L. E. **O Direito e o Tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas**. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

- THALER, Richard. **From Homo Economicus to Homo Sapiens**. *Journal of Economic Perspectives*, v. 14, p. 133-141, 2000.
- THALER, Richard; SUNSTEIN, Cass R. **Nudge: improving decisions about health, wealth and happiness**. New Haven; London: Yale University Press, 2008.
- TIMM, Luciano Benetti (coord.). **Direito e Economia no Brasil: estudos sobre a análise econômica do direito**. 5ª ed. Indaiatuba/SP: Ed. Foco, 2023.
- TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Ângela T. Gobbi. **Direito do comércio internacional**. Rio de Janeiro: FGV, 2009.
- TOEES, Brigit. **International health law: an emerging field of public international law**. *Indian Journal of International Law*, v.55, n.3, p.299–328, 2015.
- TORRES, Ricardo Lobo. **O mínimo existencial e os direitos fundamentais**. *Revista de Direito Administrativo*, n. 177, p. 24-49, 1989.
- TORRES, Ricardo Lobo. **O mínimo existencial e os direitos fundamentais**. *Revista Brasileira de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 177, p. 1-20, 1989.
- TOWSE, A.; PRITCHARD, C.; DEVLIN, N. **Cost-effectiveness thresholds: Economic and ethical issues**. Londres: King's Fund and Office of Health Economics, 2002.
- TUSHNET, Mark Victor. **Following the Rules Laid down: A Critique of Interpretivism and Neutral Principles**. *Harvard Law Review*, v.96, n.4, 1983, p.781–827.
- TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. **Judgment under uncertainty: heuristics and biases**. *Science*, v. 185, n. 4157, p. 1124-1131, 1974.
- TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. **Rational choice and the framing of decisions**. *The Journal of Business*, v. 59, n. 4, p. S251–S278, 1986.
- U.S. ECONOMIC DEVELOPMENT ADMINISTRATION. **Overarching Narrative - Advanced Pharmaceutical Manufacturing Tech Hub**. Washington, D.C.: U.S. Economic Development Administration, 2024. Disponível em: https://www.eda.gov/sites/default/files/2024-07/APM_Tech_Hub_Overarching_Narrative.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 22 ago. 2025.
- UNFCCC. **The Paris Agreement**. Bonn: UNFCCC, 2015.
- UNITED NATIONS. **Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health (Art. 12)**. 2000. Disponível em: file:///C:/Users/I0201134/Downloads/E_C.12_2000_4-EN.pdf. Acesso em: 21 ago. 2025.

UNITED NATIONS. **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development**. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Acesso em: 22 ago. 2025.

UNITED STATES OF AMERICA. **Orphan Drug Act of 1983**. 1984.

UNITED STATES. Congress. **Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)**. 2010. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/3590>. Acesso em: 29 jul. 2023.

UNITED STATES. Supreme Court. **California et al. v. Texas et al. Certiorari to the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, No. 19–840. Argued Nov. 10, 2020 – Decided Jun. 17, 2021**. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-840_6jfm.pdf. Acesso em: 29 jul. 2023.

WALKER, C. E. et al. **The collective impact of rare diseases in Western Australia: an estimate using a population-based cohort**. *Genetics in Medicine*, v. 19, p. 546–552, 2017.

WANG, C.; LI, D. **Esforços legislativos para o cuidado de doenças raras na China – análise dos fundamentos jurídicos e chamada para um quadro regulatório**. *Rev. Dir. Sanit., São Paulo*, v. 14, n. 1, p. 11-33, mar./jun. 2013.

WEINSTEIN, M.; ZECKHAUSER, R. **Critical ratios and efficient allocation**. *Journal of Public Economics*, v. 2, n. 2, p. 147–157, abr. 1973.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito**. Alfa Omega, 2001.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Classification of diseases**. Disponível em: <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases>. Acesso em: 18 ago. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Educomunicação em doenças raras**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/educunicacao-em-doencas-raras>. Acesso em: 09 jan. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Executive Board 156th Session – B156(15)**. Disponível em: [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_\(15\)-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_(15)-en.pdf). Acesso em: 18 ago. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **framework convention on tobacco control**. Geneva: WHO, 2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global Network for Rare Diseases**. Disponível em: <https://www.rarediseasesinternational.org/pt-br/collaborative-global->

network/#:~:text=A%20Rede%20Global%20para%20as%20Doen%C3%A7as%20Raras%20%28GNRD%29. Acesso em: 18 ago. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Rare diseases – Frequently Asked Questions**. Disponível em: <https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/rare-diseases>. Acesso em: 09 jan. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **World cancer report**. Disponível em: https://www.iarc.who.int/cards_page/world-cancer-report/. Acesso em: 20 ago. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Macroeconomics and health: investing in health for economic development. Report of the Commission on Macroeconomics and Health**. Geneva: WHO, 2001. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/924154550X>. Acesso em: 16 jan. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde. 2015**. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/186468/who_fwc_alc_15.01_por.pdf?sequence=6. Acesso em: 25 ago. 2024.